القضاء والشهادة

في الفقه الإسلامي المقارن

مقرر الفرقة الرابعة بقسميها لكليات الشريعة والقانون وما يعادلها

تأليف

الأستاذ الدكتور

عطا عبد العاطي السنباطي

أستاذ الفقه المقارن

وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

الأستاذ الدكتور

مراد محمود حيدر

أستاذ أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن

بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

تنسيق

د/ عبد الرحمن أشرف عبد العزيز

د/ **محمود السيد عطية**

العام الجامعي ٢٠٢٦-٢٠٢٧م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

افتتاحية الكتاب

قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ [1]

وقال رسول الله ﷺ: «مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِئٍ مُسلِمٍ بيَمينِه فقد أوجَبَ اللهُ له النَّارَ، وحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ، فقال له رَجُلٌ: وإن كان شيئًا يَسيرًا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وإنْ قَضيبًا مِن أراكٍ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»[2]

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إِذَا أتاكَ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ وَقَدْ فقئَتْ عَيْنُهُ فَلاَ تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأتِيَكَ خَصْمُهُ فَلَعَلَّهُ قَدْ فُقِئَتْ عَيْنَاهُ جَمِيعَا)[3].

(١) سورة النساء، الآية: ١٣٥

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه،٢٢/١/ح:١٣٧، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

(٣) نسب هذه المقولة إلى الإمام على رضي الله عنه، الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع،١٣/٣٤١، قال الميداني: هذا مثل أورده المنذريّ وقال: هذا من أمثالهم المعروفة، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوفى: ٥١٨هـ) انظر: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوفى: ٥١٨هـ) مجمع الأمثال، ٦٢/١، المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة - بيروت، لبنان.

ومن أقوال الفقهاء: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام .. العدل نظام كل شئ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.[1]

(١) الحسبة فى الإسلام لتقي الدين أحمد بن تيمية (المتوفى:٦٦١- ٧٢٨ هـ)، صـ٥٥٢،٥٥١ – الكتاب الثالث من التراث الاقتصادي الإسلامي . دار الحداثة . بيروت. ط أولى سنة ١٩٩٠م.

إهداء

- **إلى الذي خلقنا وهدانا، ووفقنا** لما نحن فيه نرفعُ عصارة هذا الفكر، لعلها من صالح العمل الذي ينفعنا يوم نلقاه.
- **إلى النور الذي جاء من الله رسولًا شاهدًا علينا**، نُهدى هذا العمل خدمة لشريعته يوم نلقاه على الحوض لعلنا نشرب من حوضه.
- **إلى رعاة العدل، وحماة العدالة في كل مكان**، نُهدى هذا العمل، مصباحًا يضيء طريق العلم ويهدي إلى صراط مستقيم.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي بعث رسله ليقيموا العدل والقسط بين الناس، وليكونوا حجة عليهم يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئًا، والصلاة والسلام على رسول العدل والرحمة سيدنا محمد ﷺ الذى بعث على فترة من الرسل، بعد أن ضلت الأفهام، وحرفت الحقائق، وفشا الظلم، وسيطرت الأوهام، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا كالنجوم بين العالمين.

أما بعد:

فإن القضاء بالعدل فريضة محكمة وسنة متبعة، وهو طريق الحق والعدل، وإنصاف المظلوم من الظالم، والضعيف من القوي، وهو ميزان بين الناس بل بين كل الخلق، وهو سبب إرسال الرسل، وتشريع الشرائع، وعليه مدار يوم القيامة والبعث، وهو قضية القضايا في الأرض في كل زمان ومكان، وبه تتقدم الأمم وتنهض، وبتخلفه تتخلف الأمم، لهذا وغيره تم إلقاء الضوء علي بعض مباحث هذا الموضوع، وهذه خلاصته، ولباب ما يُعتقد، فى هذا الباب الخطير، من أبواب الفقه الإسلامي، حيث إن حقل القضاء في الإسلام ملئ بالألغام، لم ينج منه إلا القليلون من العاملين فيه، ولذا سنرى أن كبار الفقهاء رفضوا الدخول فيه لِعِظم قدره، وخطورة أمره، وحاجة القاضي الدائمة إلى مقاومة نفسه في سره وجهره، وإنكار عواطفه مع صديقه وعدوه،

وضبط مزاجه في كل وقته ولحظه، والحفاظ على حيدته وهيبته واستقلاليته حتى لا يؤثر أحد في حكمه، هذه الدراسة يجب أن يلبس لها الدارس رداء الباحث المنصف، وينظر بالنظر الموضوعي غير المتحيز، ويتخلي عن كل شئ سواه، ليصل إلى الحق وصول الباحث المجتهد الحر ، لا المقلد التابع المأسور بسابق فكره ، والمأخوذ بسابق اعتقاده.

وترجع أهمية القضاء والشهادة إلى أنهما الأداة الضرورية التي تلزم لاستقرار المجتمع، إذ لا يصلح أن يعيش الناس في فوضى بلا قضاء ولا حكم، فالقضاء والشهادة من الوسائل العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى إنه؛ ليصح القول بأن كل مجتمع؛ يقتضي حتماً وجود نظام قضائي كامل يلزم لاستقرار المعاملات فيه بين البشر[1].

١- انظر: طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية وسوق الأدلة والموازنة بينها ثم مقارنة بالقانون ومعلقاً عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومواد قانون الإثبات الحالي ومواد مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، الشيخ أحمد إبراهيم، واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، ص٢٨، نشر: المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط٤، ٢٠٠٣م، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي،٥٨ د.عوض عبد الله أبو بكر، /١٤٧، "فقه الامام جعفر" الشيخ محمد جواد مغنية،١٧/٦، مكتبة الهلال، بيروت، بدون تاريخ.

كما تتضح أهمية القضاء والشهادة في استقرار المجتمع، حيث لا يمكن الفصل في أي دعوى ما لم يتوفر فيها أدلة مقبولة ومشروعة تصلح للفصل في الدعوى.

بل نجد بعض النظم لا تقبل الدعوي ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جدية الدعوى بإرفاق كافة المستندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها لإثبات دعواه، مثل ذكر الشهود وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى.

ونحن في هذا السِّفْر من الفقه الإسلامي، ندرسُ بالتفصيل المناسب أهم الأحكام المتعلقة بالقضاء، من حيث تعريفه ومشروعيته، وأركانه، وشروط تعيين القاضي، وأنواع القضاء، كقضاء المظالم وقضاء الحسبة، والقضاء العادي، ثم نُعرجُ على دراسة الشهادة من حيث تعريفها ومشروعيتها والحكمة من هذا المشروعية وحكمها بالنسبة للشاهد والمشهود له والمشهود به والمشهود عليه، وكذا حكم أخذ الأجر عليها، والنصاب المطلوب فيها، وحكم شهادة الزور ـ والعياذ بالله ـ منها ، ثم نختم بأهم الأحكام المتعلقة بها، كل ذلك بأسلوب سهل مُيسر يتناسبُ مع مدارك الطالب الجامعي، كي يخرج إلى المجتمع باحثًا تتوافر فيه أهلية الفهم للأدلة والنصوص، وكيفية مناقشتها، واستنباط الأحكام منها.

ونرجو من الله–تعالى– التوفيق والسداد، وأن يضع لهذه الدراسة قبولًا عند أهل العلم والمتخصصين.

ونسأل كل قارئ إذا عن له شئ فيها أن يقوم بإهداء هذا النقد لنا، وليعلم بأن الصدر يتسع ولا يضيق فى مثل هذه الأمور، وأن الأمر حينئذ لا يغلق علينا ولله الحمد والمنة، وسنشكره ونكافئه بالدعاء له بإذن الله –تعالى– والله من وراء القصد.

وإنا لنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم نلقاه.

المؤلفان.

أ.د/ عطا عبد العاطي السنباطي.

أ.د/ مراد محمود حيدر.

خطة الدراسة

وقد اشتملت هذه الدراسة على بابين:

الباب الأول: القضاء وأنواعه وأحكامه.

الباب الثاني: في الشهادة وأركانها وأنواعها وأحكامها.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

الباب الأول:

القضاء وأنواعه وأحكامه.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تعريف القضاء ودليل مشروعيته، وحكمة مشروعيته، وفضله، والترغيب فيه والترهيب منه، وأنواعه وحكمه.

الفصل الثاني: قضاء الحسبة وأركانه وأدلة مشروعيته.

الفصل الثالث: القضاء العام وأركانه وشروطه وأحكامه.

الفصل الرابع: قضاء المظالم.

الفصل الأول[1]:

تعريف القضاء ودليل مشروعيته، وحكمة مشروعيته، وفضله، والترغيب فيه والترهيب منه، وأنواعه وحكمه.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: أدلة مشروعية القضاء.

المبحث الثالث: حكمة مشروعية القضاء.

المبحث الرابع: القضاء بين الترغيب والترهيب.

المبحث الخامس: أنواع القضاء.

المبحث السادس: حكم القضاء من حيث الحكم التكليفي ونماذج من مواقف القضاة في التاريخ.

المبحث السابع: الفرق بين الحكم القضائي وغيره.

١- كتب هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ عطا السنباطي.

المبحث الأول

تعريف القضاء لغة واصطلاحا

*** أولًا: القضاء في اللغة.**

مصدر قضى، وقضى جاءت بمعان عدة منها ما يلي:

١. **الأمر**، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ.. ﴾ الآية [١] أي: أمر ربك.

٢. **بلوغ المراد**، فيقال قضى وطره: أي بلغ مراده وأتمه، وقضى حاجته: أي بلغها وأتمها وفرغ منها.

٣. **الدفع**، فيقال قضى دينه: أي دفعه.

٤. **الأداء**، فيقال قضى الصلاة: أي أداها.

٥. **الموت**، فيقال قضى الشخص نحبه أو أجله: أي مات.

٦. **القتل**، فيقال قضى عليه: أي قتله.

٧. **الإبعاد**، فيقال قضى علي الخطر: أي أبعده.

٨. **الحكم بين المتخاصمين**، فيقال قضى بين الخصمين: أي حكم بينهما.[٢]

---

١ - سورة الإسراء، من الآية ٢٣.

٢ - المعجم العربي الأساسي. تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صـ٩٩٤. توزيع لاروس، مختار القاموس. للطاهر أحمد الزاوى صـ٥٠٤، الدار العربية للكتاب سنة ١٩٨٣م.

فالقضاء في اللغة يأتي بمعانٍ متعددة، منها: الأمر، الحكم، والإتمام وبلوغ المراد، والدفع، والأداء، والإنفاذ، والإلزام، والموت، القتل، والإبعاد.

*** ثانيًا: عند المفسرين.**

ورد لفظ قضى ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من ستين موضعًا، وبمعان مختلفة، حصرها المفسرون في **عشرة وجوه**:

١. **قضى: يعنى وصى**، فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ..﴾الآية[١] يعنى: وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.

٢. **قضى: يعنى أخبر**، فذلك قوله في بني إسرائيل:﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ..﴾الآية [٢] أي: خبرنا بني إسرائيل في التوراة.

٣. **قضى: يعنى فرغ**، فذلك قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ..﴾الآية[٣] أي: فإذا فرغتم من أمر المناسك.

١- سورة الإسراء، من الآية ٢٣.
٢- سورة الإسراء، من الآية ٤.
٣- سورة البقرة، من الآية ٢٠٠.

٤. **قضى: يعنى فعل،** فذلك قوله: ﴿ فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ..﴾الآية[١] يعنى: افعل في أمرنا ما أنت فاعل، وقوله: ﴿ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا.. ﴾ الآية [٢] يعنى: إذا فعل أمرًا كان في علمه أن يفعله.

٥. **قضى: يعنى أنزل،** فذلك قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَيۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَوۡتَ.. ﴾ الآية [٣] يعنى: أنزلنا به الموت.

٦. **قضى: يعنى وجب،** فذلك قوله: ﴿ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّۖ..﴾الآية[٤] يعنى: وجب العذاب.

٧. **قضى: يعنى كتاب،** فذلك قوله في أمر عيسى –عليه السلام –: ﴿ وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيّٗا..﴾ الآية[٥] يعنى: كان عيسى أمرًا من الله مقضيًا: مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون.

٨. **قضى: يعنى أتم،** فذلك قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ..﴾الآية [١] يعنى: فلما أتم موسى شرطه.

---

١ - سورة طه، من الآية ٧٢.
٢ - سورة آل عمران،من الآية ٤٧.
٣ - سورة سبأ، من الآية ١٤.
٤ - سورة هود، من الآية ٤٤.
٥- سورة مريم، من الآية ١١.

٩. **قضى: يعنى فصل،** فذلك قوله: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ ..﴾ الآية [٢]

يعنى: فصل بينهم بالحق.

١٠. **قضى: يعنى خلق،** فذلك قوله: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ..﴾ الآية[٣]

يعنى: فخلقهن سبع سماوات[٤].

*** ثالثًا: عند الفقهاء.**

١. **في فقه الحنفية:** القضاء: هو الإلزام، ويقال له الحكم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحكمة التي تجعل في رأس الفرس[٥].

٢. **في فقه المالكية:** القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح المسلمين[٦]؛ لأن عموم

١- سورة القصص، من الآية ٢٩.
٢- سورة الزمر، من الآية ٦٩.
٣- سورة فصلت، من الآية ١٢.
٤- الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم، لمقاتل بن سليمان البلخى المتوفى سنة ١٥٠هـ، تحقيق د/ عبد الله شحاتة ص ٢٩٤ وما بعدها، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٤١٤هـ – ١٩٩٤م .
٥- شرح فتح القدير– للكمال بن الهمام جـ٦ص ٣٥٦. دار إحياء التراث العربي – دار الكتب العلمية –بيروت لبنان.
٦- شرح الخرشى على مختصر خليل جـ ٧ ص ١٣٨. المطبعة الأميرية ببولاق –مصر– ط ثانية سنة ١٣١٧ هـ

مصالح المسلمين يتولاها الإمام الأعظم –رئيس الدولة – من تقسيم للغنائم، والزكاة .. الخ، ويقال له الحكم أيضًا[1].

٣. **في فقه الشافعية**: القضاء هو: الإلزام – ممن له ولاية الإلزام – بحكم الشرع فى الوقائع الخاصة، أو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله –تعالى– [2]

٤. **في فقه الحنابلة**: القضاء هو: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات[3].

٥. **في فقه الشيعة الإمامية**: القضاء هو: منصب إلهى لمن له أهلية الفتوى فى الحكم بجزئيات القوانين الشرعية بين الناس وفصل الخصومة،وقطع المنازعة الواقعة بينهم به[4].

٦. **فى فقه الشيعة الجعفرية**: القضاء هو: الحكم بين المتخاصمين، لقطع الخصومات ورفع المنازعات، ومنع الظالم عن ظلمه[5].

١- حاشية الدسوقي جـ٤ ص١٢٩. دار إحياء الكتب العربية.

٢- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين وعمدة المفتين لأبى زكريا النووي جـ٤ ص٢٩٥، ٢٩٦. دار إحياء الكتب العربية، مغنى المحتاج جـ٤ ص ٣٧٢. مطبعة مصطفى البابى الحلبي [١٣٧٧ هـ –١٩٥٨م].

٣- كشاف القناع عن متن الإقناع. للبهوتى جـ ٣ ص ٣٦٥. ط سابعة سنة ١٣٩٢هـ –المطبعة السلفية.

٤- القضاء والنظام القضائي عند الإمام على .د/ محسن باقر الموسوى ص ٦٣-الغدير- بيروت – ط أولى [١٤١٩ هـ – ١٩٩٩م].

٥- فقه الإمام جعفر الصادق جـ ٦ص٦٠ لمحمد جواد مغنية – مؤسسة أنصاريان – إيران.

الراجح:

أن القضاء ولاية شرعية على الفصل في الخصومات والمنازعات بين الناس، وإلزام المتخاصمين بالحكم الشرعي.

ويرى البعض[1] **وهو ما نرجحه** أن ولاية إنشاء الأحكام ليست ثابتة للقاضي بل هي لصاحب الشرع خاصة.

ولذا يقول الفقهاء:

إن حكم القاضي مظهرٌ للحق وليس مثبتًا له أي ليس منشئًا له، فالإلزام الذي يصدر من القاضي إلزام في ظاهر الأمر فقط، أي ليس إلزامًا حسيًا، وأما التنفيذ الحسي فهو للسلطة التنفيذية، وهو تنفيذ للإلزام الذي ثبت بخطاب الشارع، ولهذا فالصحيح أن القضاء إخبار وليس إنشاء وعليه فالتعريف المختار هو ما ذكره ابن رشد من أن القضاء هو: إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.

١- أستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان. النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص١٦ وما بعدها. طبعة خامسة [١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م].

المبحث الثاني

أدلة مشروعية القضاء

القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب:

فقد وردت آيات كثيرة تدل على وجوب إقامة مرفق القضاء **منها ما يلي:**

١ – قوله –تعالى –: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى..﴾ [١]

٢ – وقوله –تعالى–:﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ..﴾ [٢]

وهذه من أوضح الآيات في أصل مشروعية القضاء؛ لأنها خاطبت من يتولى الحكم بين الناس وأمرته بالعدل

٣ – وقوله – تعالى –: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾[٣]

١- سورة ص، من الآية ٢٦.
٢- سورة النساء، من الآية ٥٨.
٣- سورة النساء، الآية ٦٥.

٤ - وقوله تعالى -:﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾[١]

٥- قال -تعالى-: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ..﴾ [٢] وهذه قاعدة مهمة جدًا في القضاء؛ فالخصومة لا تبرر الجور، والعداوة لا تسقط حق الخصم، فيجب العدل حتى مع الخصومة.

٦ - وقوله -تعالى-:﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ..﴾[٣]، أي الحكم بينهم بحكم الله الذي أنزله في كتابه.

٥ – وقوله – تعالي-: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ [٤] والقاسط الجائر الظالم

١- سورة النساء، الآية ١٠٥.
٢ - سورة المائدة، من الآية ٨.
٣ - سورة المائدة، من الآية ٤٩
٤ - سورة الجن، الآية ١٥

وأما السنة:

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك أيضا **منها ما يلي:**

١- ما روى أن الرسول ﷺ قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا، فسَلَّطَه على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، ورجل آتاه الله حِكْمَة، فهو يقضي بها ويُعَلِّمَه»[١]

٢ - ما روى أن الرسول ﷺ قال : «أتدرونَ من السابقونَ إلى ظلِّ اللهِ يومَ القيامةِ ؟ قالوا اللهُ ورسولهُ أعلمُ قال الذين إذا أُعطُوا الحقَّ قبلوهُ وإذا سئِلوهُ بذلوهُ وإذا حكموا للناسِ حكموا كحكمِهم لأنفسِهم»[٢]

٣ - ما روى أن الرسول ﷺ قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» .[٣]

٤ - ما روى أن الرسول ﷺ قال: «إذا جلس القاضي في مَجْلِسِه هبط عليه مَلَكانِ يُسَدِّدَانِه ويُوَفِّقَانِه ويُرْشِدَانِه، ما لم يَجُرْ ، فإذا جار عَرَجا وتَرَكَاه».[٤]

١ - صحيح مسلم جـ١٢ صـ٢١١ ط أولى [١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠م]
٢ - مسند الإمام أحمد (٢٤٤٤٣)
٣ - أخرجه مسلم (١٨٢٧).
٤ - مسند أحمد

٥ – ما روى عن عمرو بن العاص ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: « إذا حكَم الحاكمُ فاجتَهَد ثمَّ أصاب فله أجرانِ وإذا حكَم فاجتَهَد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ» وهذا الحديث يدل على أهمية الاجتهاد القضائي، وأن القاضي المجتهد إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحق ثم أخطأ بعد استفراغ الوسع فلا يكون كالمتعمد للباطل.

٦ – فعله ﷺ حيث إنه قضى بين المتنازعين فى قضايا لا تحصى كثيرة إلى أن قبضه الله – عز وجل– وولى القضاء جماعة من أصحابه، فبعث عليًا إلى اليمن قاضيًا وقال له إذا حضر إليك خصمان فلا تقض شيئًا حتى تسمع كلام الآخر، فقال على ﷺ فما أشكل على قضية بعدها، وبعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا وقال له بم تقضى قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد، قال:اجتهد برأيى، فقال رسول الله ﷺ الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى الله، وولى عتاب بن أسيد القضاء بمكة عام الفتح، وعلى هذا النهج صار الخلفاء الراشدون من بعده والولاة والأمراء ورؤساء الدول الإسلامية حتى يومنا هذا. [1]

١ - معالم القربة . مرجع سابق صـ ٢٦٥، ص ٢٦٦

وأما الإجماع:

فقد انعقد إجماع المسلمين فى العصور الإسلامية المتعاقبة على وجوب القضاء، وعلى ضرورة نصب القضاة ليحكموا بين الناس، بل إن العقل قاض به وبوجوبه ولو لم يكن قد ورد به شرع من كتاب أو سنة [1].

١- نظام القضاء فى الإسلام . د/ محمد مرسى غنيم. دار أبو الفضل [١٤١٠هـ-١٩٨٩م] ص١٤.

المبحث الثالث

حكمة مشروعية القضاء

الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش بمفرده بعيدا عن الناس، وهذا يقتضى وجود تعامل بينه وبين غيره من بنى جنسه، هذا التعامل قد ينشأ عنه نزاع أو خلاف، حيث إن طباع الناس جبلت على التنازع وحب الأموال والتنافس، وقد يكون أحد طرفي النزاع قويًا والآخر ضعيفًا، أو يكون أحدهما فاسد الذمة خرب الضمير، أو يكون الطرفان ملتزمين لكن الحق التبس عليهما، مما يقتضى وجود من يفصل في هذا النزاع حفظا للدماء والأموال والأعراض الخ فدعت الحاجة إلى حملهم على الخضوع للحق بإظهاره لهم باليد القاطعة للنزاع، وذلك عن طريق القضاء، حتى يعود المجتمع إلى حالته السوية، ويتحقق السلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، لأن الأصل في القضاء أن يتولاه الإمام أو رئيس الدولة بنفسه، ونظرًا لاتساع الدولة في العصر الحديث وتشابك العلاقات وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق رئيس الدولة ، أصبح غير قادر على فصل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى تولية

القضاء نيابة عنه[1] مما يدل على أن القضاء يحتل مكانة مركزية في النظام الإسلامي؛ لأنه الأداة التي تُصان بها الحقوق، وتُرفع بها الخصومات، ويُمنع بها الظلم، وتُرد بها المظالم إلى أهلها، ولم يجعل الإسلام العدل قيمة أخلاقية مجردة، بل جعله أساسًا من أسس إقامة المجتمع والدولة.

قال -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ..﴾ [2]

وقال -تعالى-: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..﴾ [3] فهذه الآية تجعل إقامة القسط من الغايات الكبرى لإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان.

١- شرح فتح القدير ٣٥٦/٦، مغنى المحتاج ٣٧٢/٤، معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد بن محمد القرشي المعروف بابن الأخوة من كتاب من التراث الاقتصادي الإسلامي ص ٢٦٤ – دار الحداثة – بيروت، القضاء والنظام القضائي عند الإمام على. د / محسن باقر الموسوى ص ٧٤
٢- سورة النساء، من الآية ٥٨.
٣- سورة الحديد، من الآية ٢٥.

المبحث الرابع

القضاء بين الترغيب والترهيب

النصوص الشرعية الواردة بخصوص القضاء تدور بين الترغيب فى هذا المنصب باعتباره من أفضل أعمال الطاعات ووفرة ثوابه الجزيل وبين الترهيب والتخويف من تولى هذا المنصب الخطير نظرًا لحساسيته وخوفًا من الهوى والتشهى، والجور والظلم، وبين الترغيب والترهيب كان موقف العلماء والفقهاء، فمنهم من تولى هذا المنصب ومنهم من ابتعد عنه، والنصوص الواردة فى ذلك كثيرة، **منها ما يأتى:**

*** أولًا: النصوص الواردة فى الترغيب فى تولى هذا المنصب.**

١- ما روى أن الرسول ﷺ قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا، فسَلَّطَه على هَلَكَتِهِ في الحَقِّ، ورجل آتاه الله حِكْمَة، فهو يقضي بها ويُعَلِّمَه»

٢ - ما روى أن الرسول ﷺ قال : «أتدرونَ من السابقونَ إلى ظلِّ اللهِ يومَ القيامةِ ؟ قالوا اللهُ ورسولهُ أعلمُ قال الذين إذا أُعطُوا الحقَّ قبلوهُ وإذا سئِلوهُ بذلوهُ وإذا حكموا للناسِ حكموا كحكمِهم لأنفسِهم».

٣- ما روى أن الرسول ﷺ قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا».

٤ - ما روى أن الرسول ﷺ قال: «إذا جلس القاضي في مَجْلِسِه هبط عليه مَلَكانِ يُسَدِّدَانِه ويُوَفِّقَانِه ويُرْشِدَانِه، ما لم يَجُرْ ، فإذا جار عَرَجا وتَرَكَاه».

٥- ما روى أنه ﷺ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله- وذكر- ﷺ منهم الإمام العادل».

٦- ما روى أن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: اقض وأنت حاضر، أو جالس، قال: نعم، قال: على ما أقضى، قال: على أنك إن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة. [١]

٧- وعن الحسن أنه قال: لأجر حاكم عدل يومًا واحدًا أفضل من أجر رجل يصلى في بيته سبعين سنة، أو قال ستين سنة، قال الحسن: لأنه يدخل من عدله في ذلك اليوم على كل بيت من المسلمين خير.[٢]

١ - أدب القاضي – مرجع سابق ص ٣٣

٢- كتاب أدب القاضي لأبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيبانى المعروف بالخصاف المتوفى [٢٦١ هـ – ٨٤٧م] ومعه شرح أبى بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص المتوفى [٣٧٠هـ – ٩٨٠ م] تحقيق فرحات زيادة ص ٣٣ وما بعدها. قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد تولى أصحاب أبى حنيفة القضاء، فوليه أبو يوسف وهو أول من لقب بقاضي القضاة في الإسلام في ولاية موسى الهادي، ثم أقره الرشيد عليه وقد ألف له كتاب الخراج بناء على طلبه، ولم ينس أن يضمنه مواعظ ونصائح مازالت مثالًا يحتذي لما ينبغي أن يكون عليه العلماء من التمسك بالحق وإسداء النصح لولاة أمور المسلمين، ثم وليه يوسف ابنه، ثم محمد بن الحسن، وقد ظل قضاة بغداد من أصحاب أبى حنيفة فترة طويلة، وهم اقتدوا فى ذلك بالرسول ﷺ حيث تولى ﷺ القضاء بنفسه وتولاه الأنبياء قبله، وعين ﷺ عليًا قاضيًا إلى اليمن وكذلك معاذًا وغيرهما[1]

*** ثانيًا: النصوص الواردة في الترهيب والتخويف من تولى هذا المنصب.**

١. ما روى أن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار وواحد فى الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار».

١ - د/ محمد مرسى غنيم – مرجع سابق ص٥٢، أستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان. النظام القضائي في الفقه الإسلامي ص ١٨. دار البيان. ط ثانية [١٤١٥ هـ – ١٩٩٤م]

٢. ما روى أن النبي ﷺ قال: «يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين في تمرة» [١]

٣. ما روى أن الرسول ﷺ قال: «إن أعتي الناس على الله، وأبغض الناس إلى الله، وأبعد الناس من الله: رجل ولاه الله من أمر أمة محمد ﷺ شيئا ثم لم يعدل بينهم».

٤. ما روى أن النبى ﷺ قال: «من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين».

وهذا الحديث يدل على معان عدة منها:

- أن من يتولى القضاء يصير كالمذبوح؛ لأنه يحتاج إلى أن يميت شهواته، ويكسر نفسه، ويقهرها ويمنعها عن التبسط ومخالطة الناس[٢].
- ومنها أن من يتولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه، فليحذره، وليتوقه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به، أو جهله له ، فهو فى النار، وقال الصنعانى: وقيل ذبح ذبحًا معنويًا؛ لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه فى الدنيا، لإرادته الوقوف على الحق وطلبه، واستقصاء ما تجب عليه رعايته فى النظر فى الحكم، والموقف مع الخصمين، والتسوية بينهما فى

١ ـ مسند أحمد ح٥ ص ٢١٠
٢ ـ نظام القضاء الإسلامى . د/ إسماعيل البدوى ص ٥٦ [١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠م]

العدل والقسط، وإن أخطأ فى ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلابد من التعب والنصب، وشبه ﷺ من يتولى القضاء بمن ذبح بغير سكين، لأنه كما يقول بعض العلماء: إن السكين تؤثر فى الظاهر والباطن جميعًا، والذبح بغير سكين يؤثر فى الباطن بإزهاق الروح، ولا يؤثر فى الظاهر ووبال القضاء لا يؤثر فى الظاهر، فإن ظاهره جاه وعظمة، لكن باطنه هلاك [1].

٥. ما ورد عن مكحول أنه قال: لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقى لاخترت ضرب عنقى.

٦. ما ورد عن المسيب أنه قال: ما يسرنى أنى وليت القضاء وأن سوارى مسجدكم هذا لى ذهبًا.

٧. ما ورد عن الفضيل بن عياض أنه قال: إذا ولى الرجل القضاء فليجعل للقضاء يومًا وللبكاء يومًا.

٨. وجاء في أخبار القضاة: حدثنا عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن كعب،قال:بعث عمر إلى كعب إني جاعلك قاضيًا قال:لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: لم يا كعب؟ قال: إن القضاة ثلاثة؛ فقاضيان في النار وقاض في الجنة؛ قاض علم وترك علمه فقضى

١ - نقلا عن أستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان. مرجع سابق ص ١٨ وما بعدها.

بجور، وقاض لم يعلم فقضى بجهالة فهو معه في النار، وقاض قضى بعلمه ومضى عليه فهو من أهل الجنة. فقال: يا كعب فإنك قد علمت؛ تقضى بعلم وتمضى عليه؛ قال: يا أمير المؤمنين أختار لنفسي أحب إلي من أن أخاطر بها [1].

٩. وعن محمد بن واسع، قال بلغني أن أول من يدعي يوم القيامة إلى الحساب القضاة[2].

١٠. وعن الحسن؛ قال: أخذ على القضاة ثلاث؛ ألا يشتروا به ثمنًا، ولا يتبعوا به هوىً، ولا يخشوا فيه أحدًا[3].

١١. وعن محمد قال: كنت عند عبد الله بن عتبة، وبين يديه كانون فيه نار؛ فجاء رجل فجلس معه على فراشه فساره بشيء ما ندري ما هو؛ فقال له ابن عتبة ضع لي إصبعك في هذه النار؛ فقال الرجل: سبحان الله تأمرني أن أضع لك إصبعي في النار! فقال له: أتبخل علي بإصبع من

١- أخبار القضاة للإِمَامِ المُحَدِّثِ القَاضِي أَبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ حَيَّانَ بنِ صَدَقَةَ الضَّبِّيّ البَغْدَادِيّ، المُلَقَّب بِـ"وَكِيع"المتوفى سنة ٣٠٦هـ ص ١٥ وما بعدها
٢ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٨
٣ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٨

أصابعك في نار الدنيا، وتسألني أن أضع جسدي كله في نار جهنم ! فظننا أنه دعاه إلى القضاء[1].

١٢. وعن حريش بن أبي الحريش؛ قال: طلب رجل للقضاء؛ فتجان، وتحامق، وركب قصبةً، واتبعه الصبيان.قال: وكان رجل حلف ألا يتزوج حتى يستشير أول من يلقاه، فلقيه فاستشاره؛ فقال: البكر لك ولا عليك، والثيب لك وعليك، وذات الجلاوز عليك ولا لك؛ خل سبيل الجواد؛ فقال له: ما قصتك ؟ قال: إن هؤلاء أرادوني على ذهاب ديني فاخترت ذهاب عقلي، امض لسبيلك [2].

١٣. وعن عباد بن كثير الأسدي؛ قال: أخبرني حماد أخي؛ قال: رأيت القاسم بن الوليد الهمداني وأرسل إليه يوسف بن عمر يوليه القضاء فرأيته يكحل عينيه بالزيت، ويجز لحيته؛ فلما دخل على يوسف قال: هذا مجنون ! أخرجوه[3].

١٤. عن أبي يوسف أن ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة نحوًا من مائة سوط مفرقةً على أن يلي قضاء الكوفة فأبى؛ فخلف ابن هبيرة ألا يتركه حتى

١ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٨
٢ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٩
٣ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٩

يلي، فكلمه رجال أهل الكوفة؛ فلم يزالوا به حتى قال أبو حنيفة: أنا ألى له عدد ما يدخل الكوفة من أحمال التين والعنب؛ ففعل وخلي عنه[1].

١٥. وعن أبي عاصم؛ قال: جئ بخالد بن أبي عمران إلى أبي جعفر ليوليه القضاء؛ فامتنع عليه؛ فتهدده وأشمعه؛ وقال: أنت عاص؛ فقال له خالد إن الله يقول: «**إِنَّا عَرَضْنا الأمانة على السَّموات والأرض والجِبالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَها وأَشفقْنَ مِنها** »، فلم يسمهن عصاةً حيث أبين حمل الأمانة، وقال: « **وَحَمَلَها الإنسانُ إنْهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً**» ؛ فقال: اخرج فلا ترى مني خيرًا؛ فلما أصحر إذا هو برجل حسن الوجه والثوب، طيب الريح؛ فقال له خالد: ساءك ما خاطبك به هذا ؟ قال: نعم؛ قال: أما علمت أن العبد إذا لم يكن لله فيه حاجة نبذه إليهم[2].

١٦. وعن حميد بن الربيع قال: جئ بعبد الله بن إدريس، وحفص ابن غياث، ووكيع بن الجراح إلى هارون الرشيد؛ دخلوا ليوليهم القضاء؛ فأما ابن إدريس فقال: السلام عليكم وطرح نفسه كأنه مفلوج؛ فقال

١ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ١٩ وما بعدها
٢ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ٢٠

هارون: خذوا بيد الشيخ: لا فضل في هذا، وأما وكيع فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أبصرت بها منذ سنة، ووضع إصبعه على عينه وعني إصبعه: فأعفاه هارون؛ وأما حفص فقال: لولا غلبة الدين والعيال ما وليت[1].

١٧. وقال عمر –رضي الله عنه–: ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض بهوى، ولا لقرابة، ولا لرغبة، ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه[2].

١٨. وعن عثمان بن عطاء، عن أبيه؛ قال: إذا هلك الحكم عرض عليه في قبره كل قضية قضى بها؛ فإن كان في شيء منها خلاف ضرب بمرزبة من حديد ضربة يسعل منها قبره[3].

لهذه الأدلة وغيرها امتنع كثير من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء من تولى هذا المنصب، فقد امتنع ابن عمر –رضى الله عنهما– لما سأله عثمان – رضى الله عنه – القضاء، وعرض على الحسين بن منصور النيسابورى قضاء نيسابور، فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله – تعالى – فمات فى اليوم الثالث، وورد

١ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ٢٠.
٢ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ٢١.
٣ - أخبار القضاة . مرجع سابق ص ٢٢.

كتاب السلطان بتولية نصر بن على الجهضمى عشية قضاء البصرة، فقال أشاور نفسى الليلة وأخبركم غدا، وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتًا **وامتنع الإمام أبو حنيفة من تولى القضاء**، فقد كتب إليه المنصور ليوليه قضاء الشرق والغرب فامتنع فحبس الإمام أبو حنيفة وضرب فى ذلك وقيل إنه مات فى السجن، وكان يقول: البحر عميق فكيف أعبر بالسباحة[1]؟

١- حيث أمر أبو جعفر المنصور بحمل أبى حنيفة، وسفيان الثورى، ومسعر، وشريك. على هذا المنصب وكانوا جلوسا بعد صلاة الصبح، فبعث أمير الكوفة إلى كل واحد رجلا، فأخذوهم، وبعث بهم إلى أبى جعفر، فقال أبو حنيفة: أنا أخمن فيكم تخمينا، أما أنا فأحتال وأتخلص، وأما مسعر فيتجانن وأما سفيان فيهرب، وأما شريك فيقع، فساروا، فلما كانوا بقرب بغداد أظهر سفيان أنه يريد قضاء الحاجة، فذهب ليقضيها، وجلس الموكل عليه ينتظره، فبصر سفيان، فقال للملاح: إن أمكنتنى من سفينتك وإلا أذبح – تأول قول الرسول ﷺ فقد ذبح بغير سكين ودفع للملاح دراهم، فاستبطأه الموكل به فلم يجده، فهرب، فلما أدخلوا على أبى جعفر تقدم إليه مسعر، فقال لأبى جعفر: هات يدك! كيف أنت وأولادك ودوابك؟ فقال: أخرجوه فإنه مجنون وعرض على أبى حنيفة تولية القضاء فأبى عليه ، فحلف ليفعلن ، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل، فحلف المنصور ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل ، فقال الربيع – الحاجب – لأبى حنيفة: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه منى على كفارة يمينى، فأمر بحبسه، ثم دعا به، فقال أترغب عما نحن فيه؟ فقال : أصلح الله أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! اتق الله ولا تشرك فى أمانتك من لا يخاف الله، والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب؟ فقال له كذبت ، أنت تصلح لذلك، فقال: يا أمير المؤمنين! قد حكمت على نفسك، إن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين أنى لا أصلح، وإن كنت كاذبا فكيف يحل لك أن تولى قاضيا كاذبا؟ ومع ذلك فإنى رجل مولى – أى من غير العرب – ولا تكاد العرب ترضى بأن يكون عليهم مولى قاضيا! فأمر به إلى الحبس، وعرض القضاء على شريك فاعتذر بعلل ، لما أزاحها أبو جعفر – أى ذللها وسهلها له – قبل شريك القضاء فقلده، ولما تقلد القضاء هجره سفيان الثورى وقال: أمكنك الهرب فلم تهرب. نقلا عن د/ اسماعيل البدوى ص ٥٨ وما بعدها.

وامتنع الإمام الشافعى أيضا عن هذا المنصب لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب أيضا، وحكى أن الوزير ابن الفرات طلب أبا على بن خيران لتولية القضاء فهرب منه، فختم على دوره نحوا من عشرين يوما كما قيل فيه:

وطينوا الباب على أبى على ❋ عشرين يوما ليلى فما ولى

وقال بعض القضاة:

وليت القضاء وليت القضاء ❋ لم يكن شيئا توليته

فأوقفنى فى القضاء القضاء ❋ وما كنت قدما تمنيته

وقال آخر :

فياليتنى لم أكن قاضيا ❋ ويا ليتها كانت القاضية [1]

الجمع بين الأدلة :

بعد أن أوردنا الأدلة الدالة على الترغيب فى تولى هذا المنصب الخطير، والأدلة الدالة على الترهيب والتحذير من تولى هذا المنصب فإنه يمكن الجمع بينها بأن يقال: إن الأدلة الدالة على الترغيب فى هذا المنصب تُحمل على من توافرت فيه شروط تولى هذا المنصب كما ذكرها الفقهاء، وأنس من نفسه القيام بأعباء هذا المنصب دون حيف أو جور وأنه من أهل الفقه والورع والتقوى

١ - مغنى المحتاج ح٤ ص ٣٧٣، ٣٧٤، أستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان. مرجع سابق ص ١٨، د/ محمد مرسى غنيم . مرجع سابق ص٥٣.

وأنه لا يقصد من التلبس بهذا المنصب سوى إقامة العدل وإيصال الحقوق لأصحابها، ولذا تولاه الأنبياء والخلفاء وغيرهم على النحو السابق ذكره، وتُحمل الأدلة الدالة على الترهيب والتحذير من هذا المنصب على من لم تتوافر فيه شروط تولى القضاء، أو على من خاف على نفسه من الوقوع فى الجور والظلم والهوى والبعد عن العدل وأنه قد يصاب بالكبر والتعالى والغرور وطلب الدنيا من هذا المنصب العظيم، فمن هذا حاله فإنه لا يجوز له شرعا أن يتولى هذا المنصب عملا بالأدلة الدالة على ذلك، ولهذا ابتعد عنه بعض الصحابة والفقهاء وفضلوا السلامة لأنفسهم، والابتعاد عن أمر هو بالاتفاق من أعظم الأمور وأخطرها حتى على الصالح للقضاء المتصف بشرائطه، وتأكيدا لهذا المعنى قال شريح: وليت القضاء وعندى أنى لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إلى فيه، فأول ما ارتفع إلى خصمان أشكل على من أمرهما ، من المدعى ومن المدعى عليه؟[1]

١ - د/ محمد مرسى غنيم . مرجع سابق ص ٥٤، ٥٥.

- **الفرق بين القضاء والفتوى والحسبة والمظالم:**

القضاء: هو الفصل الملزم في الخصومات.

الفتوى: بيان الحكم الشرعي للسائل، وهي في أصلها ليست حكمًا قضائيًا ملزمًا للخصوم.

أما الحسبة: فهي متابعة المنكرات الظاهرة والمصالح العامة في نطاق الولاية المقررة لها.

وأما المظالم: فهو النظر في الشكاوى التي قد تعجز عنها ولاية القضاء العادي، ولا سيما ما يتصل بتعدي أصحاب السلطة أو قوة الخصوم ونحو ذلك.

المبحث الخامس
أنواع القضاء

تمهيد:

أنواع القضاء في الفقه الإسلامي، أي الولايات القضائية والمؤسسات التي عرفها الفقه الإسلامي الكلاسيكي، فإن أشهر تقسيم عملي هو:

القضاء العادي – قضاء الخصومات –، **وقضاء المظالم** ، **والحسبة** ، وهذا التقسيم يظهر بوضوح في كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وبخاصة عند الماوردي وابن القيم، **فالماوردي** أفرد في الأحكام السلطانية بابًا مستقلًا لولاية القضاء، وبابًا مستقلًا لولاية المظالم، ثم بابًا مستقلًا للحسبة، وبيّن العلاقة بين هذه الولايات ، **كما يصرح ابن القيم** بأن الحكم بين الناس في الدعاوى هو المجال المخصوص بالقاضي، بينما ما لا يتوقف على دعوى يدخل في ولاية الحسبة، وأن ولاية المظالم كانت أيضًا ولاية مستقلة، هذه الأنواع ليست أحكامًا ثابتة، وإنما هي متغيرة يجوز الاجتهاد فيها وزيادة أنواع جديدة بما يحقق مصالح الناس.

أولًا: القضاء العادي أو قضاء الخصومات.

هو القضاء الذي يتولى الفصل في الخصومات والدعاوى بين المتنازعين، وإثبات الحقوق، وإلزام المحكوم عليه بما ثبت عليه ، ويقول الماوردي عند حديثه عن ولاية القاضي العامة إن من وظائفها النظر في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، واستيفاء الحقوق ممن ثبتت عليه، **فيدخل فيها** الفصل في المنازعات المالية، والمنازعات المتعلقة بالعقود والديون والبيوع والإجارات والنفقات ومسائل الأسرة والزواج والطلاق وما يتصل بها وإثبات الحقوق والمنازعات المتعلقة بالأملاك والحكم في الجنايات والجرائم وتنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق إلى أصحابها بحسب النظام القضائي القائم، فيمكن أن ينظر القضاء في الحقوق الخاصة، والحقوق العامة - حقوق الله بحسب التقسيم الفقهي - والجنايات، والقصاص والدية، والحدود، والتعزيرات، والمعاملات المالية، والأحوال.

*** خصائص القضاء العادي:**

١. وجود خصومة، فالأصل أن القضاء ينظر في دعوى يرفعها صاحب حق على من ينازعه.

٢. الالتزام بالإجراءات والبينة، فالقاضي لا يحكم بمجرد الظن أو الميل الشخصي، وإنما يعتمد على وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا.

٣. الحكم الملزم ، فالقضاء يختلف عن الفتوى في أن حكم القاضي ملزم في الواقعة القضائية بعد صدوره واستكمال شروطه.

٤. اختصاص القاضي، فلا يجوز للقاضي أن يتجاوز حدود الولاية التي فوضت إليه.

ثانيًا: قضاء المظالم أو ولاية المظالم.

وهي ولاية قضائية خاصة أُنشئت للنظر في المظالم التي تحتاج إلى قوة ونفوذ وقدرة على رد الحقوق، وخاصة عندما يكون أحد أطراف النزاع صاحب سلطة أو نفوذ، أو عندما يعجز القضاء المعتاد عن إنفاذ الحق، وقد عرف الماوردي نظر المظالم بأنه قيادة المتظالمين إلى الإنصاف وردع المتنازعين عن الجحود والامتناع، وقد نشأت ولاية المظالم؛ لأن بعض القضايا قد تكون

أكبر من الوسائل المعتادة للقضاء، فقد يكون الخصم واليًا أو موظفًا ذا سلطة، أو شخصًا قوي النفوذ، أوجهة تمتلك قدرة على منع تنفيذ الحكم، أو قد تكون القضية بحاجة إلى وسائل كشف وتحقيق أوسع مما يملكه القاضي في القضاء المعتاد ، ولهذا وصف الماوردي ناظر المظالم بأنه يحتاج إلى اجتماع صفات القضاة وأهل القوة والنفوذ، **فيدخل في اختصاصها** مظالم الولاة والموظفين، والنظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف، والشكاوى ضد أصحاب النفوذ، فإذا كان الشخص المتظلم منه ذا قوة تحول دون وصول المتظلم إلى حقه بالوسائل المعتادة، كان لنظر المظالم مجال أوسع، وتنفيذ ما عجز القضاء العادي عن تنفيذه، فمن الفروق المهمة أن ولاية المظالم يمكن أن تتولى تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، بحسب الولاية الممنوحة للناظر، ويدخل في اختصاصها أيضا كشف أسباب الظلم، فلا تقتصر وظيفة ناظر المظالم على الشكل الإجرائي الضيق، بل ذكر الماوردي أنه يستطيع استعمال وسائل أوسع في كشف الحقيقة، كالأمارات والقرائن وشواهد الأحوال، ضمن التصور الفقهي الذي قرره.

*** الفرق بين القضاء العادي وقضاء المظالم:**

وجه المقارنة	القضاء العادي	قضاء المظالم
المجال الأساسي	الخصومات والدعاوى	المظالم والشكاوى ذات الطبيعة الخاصة
قوة الولاية	مقيدة بإجراءات القضاء المعتادة	أوسع بحسب الولاية
الخصم القوي	يعامل كغيره من الخصوم	يمكن أن تتدخل ولاية المظالم عند تعذر إنصاف المظلوم
وسائل الكشف	وسائل الإثبات القضائية المعروفة	أوسع في بعض التطبيقات التاريخية
التنفيذ	ضمن سلطة القضاء	يمكن أن يتدخل لإيصال الحق عند عجز القضاء
العلاقة بالقاضي	ولاية قضائية أصلية	ولايةاستدراكية خاصةفي عدد من الصور

ثالثا: الحسبة.

ليست هي القضاء بالمعنى الفني الدقيق، لكنها إحدى الولايات الشرعية المرتبطة بالعدالة والنظام العام، ولذلك تذكر في باب أنواع الولايات القضائية وشبه القضائية عند الفقهاء، **فالحسبة هي** ولاية هدفها الأساسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الظاهرة التي يمكن تغييرها بوسائل الولاية، وحماية المصالح العامة، وقد وصف ابن القيم الحكم في الأمور التي لا تتوقف على دعوى بأنه المعروف بولاية الحسبة، والماوردي جعل الحسبة منزلة وسطًا بين القضاء والمظالم، ويدخل في مجالاتها أو اختصاصاتها تنظيم الأسواق، ومنع الغش، ومنع التدليس، ومنع التطفيف في المكاييل والموازين، ومراقبة بعض صور المعاملات الظاهرة المخالفة، وحماية الطرق والمرافق العامة، مثل منع الاعتداء على الطرق أو التسبب في أضرار عامة، بإزالة أسباب الضرر فيها، ومراقبة الصناعات والحرف وبعض شئون الصناع والأسواق، بمنع الغش في الصناعة إذا كان الأمر ظاهرًا، ومراقبة ما يتعلق بالمصالح العامة، ومنع المنكرات الظاهرة بحسب حدود الولاية الشرعية المقررة للمحتسب.

الفرق بين القضاء والحسبة.

هذه مسألة دقيقة، **فالقضاء** التقليدي يقوم غالبًا على دعوى، وخصومة، وبينة/ إثبات، وحكم، **أما الحسبة** فتتعامل أساسًا مع المنكر الظاهر أو المصلحة العامة التي لا تحتاج إلى إقامة دعوى بالمعنى القضائي المعتاد، ولهذا قال ابن القيم إن الحكم فيما لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة، كما وصف الماوردي الحسبة بأنها واسطة بين القضاء والمظالم.

العلاقة بين القضاء والحسبة والمظالم.

القضاء يفصل في الخصومات والدعاوى ويثبت الحقوق ويحكم فيها، **والحسبة** تتعامل مع المنكرات الظاهرة والمصالح العامة وما لا يتوقف على دعوى في الأصل، **أما المظالم** تتعامل مع المظالم التي تحتاج إلى قوة ونفوذ ووسائل أوسع، وخاصة ما يتعلق بتعدي أصحاب السلطة أو عجز القضاء المعتاد عن إنفاذ الحق، وهذا ليس تقسيمًا جامدًا بمعنى أن كل مسألة لا يمكن أن تخرج عنه أبدًا؛ بل هو تصوير للولايات كما عرضها فقهاء السياسة الشرعية، ولا سيما الماوردي وابن القيم.

وهناك تصنيف آخر كما سيأتي في المبحث التالي مختلف تمامًا، وهو القضاء من حيث الحكم التكليفي، أي ما حكم تولي القضاء شرعًا أي بالنسبة للشخص؟ وهذا لا يتعلق بأنواع المحاكم، وإنما بحكم القضاء بالنسبة للشخص، **وقد ذكر الفقهاء أحكامًا متعددة لتولي القضاء بحسب حال الشخص والظروف المحيطة به**، منها: الوجوب إذا تعين على شخص صالح للقضاء ولم يوجد من يقوم مقامه، بحسب تفاصيل الفقهاء، والاستحباب في حق من توفرت فيه الأهلية وكان قادرًا على تحقيق مصالح الناس، بحسب حاله، الإباحة، والكراهة، والتحريم إذا تولاه من لا يصلح له، أو كان يعلم من نفسه أنه سيظلم الناس أو يحكم بغير علم.

المبحث السادس

حكم القضاء من حيث الحكم التكليفي ونماذج من مواقف القضاة فى التاريخ

المطلب الأول

حكم القضاء من حيث الحكم التكليفي

الأصل أن القضاء فرض كفاية، لأن الفرض الذى يكتفى فيه بقيام البعض به يسمى فرض كفاية، إذا فعله هذا البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به هذا البعض أثمت الأمة كلها، وقد يتحول هذا الفرض الكفاية إلى فرض عين، إذا لم يوجد من يصلح له سوى شخص أو أشخاص معينين فى هذه الحالة يتغير الحكم إلى فرض عين هذا بالنسبة لولى الأمر وبالنسبة للأمة، أما بالنسبة لحكم طلب هذا المنصب، فقد ذكر ابن فرحون من المالكية

والماوردى من الشافعية[1] أن طلب القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون محرمًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مباحًا.

- **فيكون طلب القضاء واجبًا** على الشخص إذا توافرت فيه أهلية الاجتهاد أو شروط صلاحية تولى هذا المنصب ولا يوجد غيره تتوافر فيه هذه الشروط فيكون طلب القضاء بالنسبة لهذا الشخص واجبًا ويكون فرض عين عليه، لأن الناس مضطرون إلى علمه ونظره فى قضاياهم فكان ذلك شبيها بصاحب الطعام إذا منعه عن المضطر حيث يجبر على التخلى عنه لمن اضطر إليه، ويأثم إن لم يطلبه، **ويكون فرض عين أيضًا** إذا كان من يتولى القضاء لا تتوافر فيه شروط الصلاحية أو كان جائرا فيجب عليه فى هذه الحالة أن يطلب تعيينه فى هذا المنصب، ويكون مأجورًا شرعًا.

١- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. لعلى بن حبيب البصرى الماوردى [٣٧٠ –٤٥٠ هـ] ص٦٧ طبعة أولى [١٤٠٤ هـ – ١٩٨٣ م] دار الفكر، أستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان، المرجع السابق ص٣٠ وما بعدها.

- **ويكون طلب القضاء مستحبًا** على الشخص إذا كان عالمًا وتوافرت فيه شروط الصلاحية وأهلية الاجتهاد لكنه غير مشهور وغير معروف لدى ولى الأمر والناس ويريد أن يتولى منصب القضاء ليسهم فى نشر هذا العلم وإفادة الناس منه فيستحب له فى هذه الحالة طلب التعيين فى هذا المنصب.

- **ويكون طلب القضاء محرمًا** على الشخص إذا كان جاهلًا لا تتوافر فيه شروط صلاحية تولى هذا المنصب، ويكون محرمًا أيضًا إذا كان عالماً لكنه يطلب تولى هذا المنصب للانتقام من أعدائه، أو للحكم بالجور، أو لعدم الحكم بالحق إلا بعد الحصول على الرشوة أو للحكم بالحق بعد الحصول على الرشوة، أو لعزل من بيده القضاء الذى تتوافر فيه شروط الصلاحية لعداوة بينهما أو لجلب مصلحة لنفسه فقط، فى هذه الحالات وأشباهها يكون طلب القضاء محرمًا.

- **ويكون طلب القضاء مكروهًا** إذا لم تكن هناك حاجة داعية إليه كأن يكون القضاء منتظما بتولية من يصلح له، والشخص مشهور بين الناس، مشهور علمه بينهم، ومكفى فى رزقه، ليس به حاجة إلى التكسب، فالأولى فى حقه حينئذ أن يترك طلب القضاء ولا يسعى إليه، إذ الدخول فيه والحالة هذه مكروه لما روى أن النبي ﷺ قال: «من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين».

- **ويكون طلب القضاء مباحًا** إذا كان الشخص متوافرا فيه أهلية الاجتهاد وشروط صلاحية تولى منصب القضاء ويوجد غيره في هذا المنصب تتوافر فيه شروط الصلاحية أيضًا لكن هذا الشخص يطلب القضاء لا لعزل من يتولاه ولكن لطلب الرزق لفقره وحاجته فيجوز له أن يسعى في تحصيل القضاء لكي يسد حاجته، وكما لو كان يقصد به أن يدفع ضررا عن نفسه بتولي هذا المنصب[1].

١- تبصرة الحكام لابن فرحون ج١ ص ١٦ نقلا من النظام القضائى لأستاذنا الدكتور/ محمد رأفت عثمان، ص٣١ وما بعدها، د/ إسماعيل البدوى، المرجع السابق ص٦٤ وما بعدها، نظام القضاء فى الإسلام . د/ محمد مرسى غنيم ص ٤٦ وما بعدها طبعة [١٤١٠ هـ – ١٩٨٩ م]

المطلب الثاني

نماذج من مواقف القضاة في التاريخ

للقضاة مواقف يشهد لها التاريخ قديمًا وحديثًا، هذه المواقف تدل على الفطنة والذكاء والفراسة والهيبة والوقار والاستقلال وغير ذلك من الصفات التي كان يتصف بها القضاة، هذه الصفات يحتاج إليها قضاة هذا العصر بل هم أحوج ما يكونون إليها، نظرا للتطور السريع في مناحى الحياة المختلفة، وتعقد المشاكل وحداثتها، ولذا فإننى سأسرد بعض هذه المواقف للوقوف عليها، والتعلم منها والاقتداء بها، **من هذه المواقف ما يأتى:**

١. انظر إلى عدل شريح -رضى الله عنه- حيث تخاصم علي بن أبى طالب - كرم الله وجهه - مع صعلوك من صعاليك اليهود فى رمح، وأنت تعرف منزلة على من بيت النبوة، ادعى علي-رضى الله عنه- أن الرمح له، وادعى الثانى أنه رمحه، عند ذلك طلب القاضى من علي-رضى الله عنه- شهودًا، فأحضر ابنه الحسن -رضى الله عنه - فلم يقبل شريح شهادته لأبيه، وقال لعلى- كرم الله وجهه-: هذا ابنك فأحضر شاهدًا غيره، ولم يكن معه شاهدًا آخر، فحكم القاضي لليهودي وأن الرمح رمحه، فلما

رأى اليهودي هذا العدل الباهر سبح بحمد هذا الدين الإسلامي الحنيف وأسلم فى الحال، وأقر أنه كاذب فى دعواه الأولى، وأعطى الرمح لعلي-رضى الله عنه- ، فرده له وأعطاه فرسًا حتى يكون معه آلة الجهاد، فانظر إلى عدل الإسلام.

٢. وخاصمت امرأة من فقراء العرب العباس بن المأمون بن هارون الرشيد، وأنت تعلم منزلته فى بنى العباس، وفى إبان شوكة الدولة العباسية وشوكة الملك الذى كان يزيده جلالًا واحترامًا، جلس المأمون يومًا ينظر فى المظالم وكان هو الخليفة فى ذلك الوقت، فكان آخر من تقدم إليه وقد هم بالقيام امرأة عربية عليها ثياب رثة – أى قديمة وبالية - فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال: عليك السلام يا أمة الله، تكلمى فى حاجتك، فأنشدت:

يا خير منتصف يهدى له الرشد ❊ ويا إماما به قد أشـرق البلد

تشكوا إليك عميد القوم أرملــة ❊ عدا عليها فلم يترك لها سبد (أى قليل أو كثير)

وابتز منى ضياعى بعد منعتــها ❊ ظلما ففرق عنى الأهل والولد

فأطرق المأمون ثم قال:

بدون ما قلت زال الصبر والرشـــد ❋ عنى وقرح حتى القلب والكبـــد

هذا أذان صلاة العصر فانصرفـــى ❋ وأحضرى الخصم فى اليوم الذى أعد

والمجلس السبت أن يقض الجلوس لنا ❋ ننصفك منه وإلا المجلـــس الأحد

فلما كان يوم الأحد انعقد المجلس، فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقال لها: أين الخصم: قالت الواقف على شمالك، وأشارت إلى ابنه العباس، فأجلسه معها مجلس الخصوم، فأخذا يترافعان وكان كلامها يعلو كلام العباس، فقال أحد الحاضرين: إنك بين يدى أمير المؤمنين تكلمينه فى ابنه فاخفضى من صوتك، فقال المأمون: دعها فإن الحق أنطقها وأخرسه، ثم بعد شكايتها قضى لها وعاقب العباس وهو ولده وفلذة كبده.

٣. ويروى أن يهوديًا وقف لعبد الملك بن مروان وقال له: يا أمير المؤمنين إن نائبك ابن هرمز ظلمنى فأنصفنى منه، وكان عبد الملك فى شغل عنه فلم ينتبه لأمره، ثم تعرض له اليهودى مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين إنا نجد فى التوراة أن الإمام لا يكون شريكا فى ظلم أحد حتى يرفع إليه،

فإذا رفع إليه ولم يغيره شركه فى الظلم، فلما سمع عبد الملك قوله هذا فزع منه، فأنفذ فى الحال إلى ابن هرمز، ولما تحقق ظلمه عزله من الولاية.

٤. وانظر إلى احترام مجلس القضاء فى الإسلام وما يجب شرعا على المتخاصمين، حيث تنازع إبراهيم ابن الخليفة المهدى وابن بختيشوع الطبيب المعروف المشهور بين يدى أحمد بن داود فى مجلس الحكم فى عقار، فأربى عليه إبراهيم بن المهدى وأغلظ له، فأحفظ ذلك ابن أبى داود –أي ضايقه– فقال: يا إبراهيم إذا نازعت فى مجلس الحكم بحضرتنا امرءا فلا أعلمنى أنك رفعت عليه صوتا ولا أشرت بيد، وليكن قصدك أمما (قريبا)، وربحك ساكنة، وكلامك معتدلًا، مع وفاء مجالس الخليفة حقوقها من التعظيم والتوقير والاستكانة والتوجه إلى الواجب، فإن ذلك أعظم بك وأشمل لمذهبك فى محتدك، ولا تعجلن فرب عجلة تهب ريثًا، والله يعصمك من خطل القول والعمل، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبلك إن ربك حكيم عليم، فقال إبراهيم: أصلحك الله –تعالى– أمرت بسداد وحفظت على رشاد، ولست عائدا لما يثلم مروءتى عندك، ويسقطنى من عينك، ويخرجنى من

مقدار الواجب والاعتذار، أنا معتذر إليك عن هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه، معترف بجرمه، ولا يزال الغضب يستفزنى بمواده فيردنى مثلك بحلمه، وتلك عادة الله عندك وعندنا منك.

٥. ويروى عن يحيى بن عبد الصمد قال: خوصم موسى الهادى أمير المؤمنين إلى الإمام أبى يوسف -رضى الله عنه- فى بستان فكان الحكم فى الظاهر لأمير المؤمنين، وكان الأمر على خلاف ذلك، فقال أمير المؤمنين لأبى يوسف: ما صنعت فى الأمر الذى يتنازع إليك فيه؟ قال: خصم أمير المؤمنين يسألنى أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا على حق، فقال له موسى الهادى: وترى ذلك، قال: قد كان ابن أبى ليلى يراه، قال: فاردد البستان عليه، وانتهت الخصومة.

٦. ويروى أن أمير المؤمنين المنصور قدم المدينة، وكان محمد ابن عمران الطلحى متولى القضاء بها، ونمير المدنى كاتبه، فحضر جماعة من الحمالين واستعدوه على أمير المؤمنين المنصور فى شئ ذكروه، فأمر القاضى كاتبه أن يكتب كتابًا إلى المنصور بالحضور معهم أو إنصافهم، فقال الكاتب للقاضى: تعفينى عن ذلك فإنه يعرف خطى، فقال: اكتب، فكتب

وختمت، فقال: والله ما يمضى به غيرك، فمضيت به إلى الربيع حاجبه، وجعلت أعتذر إليه، فقال: لا بأس عليك، ودخل بالكتاب على المنصور، ثم خرج الربيع فقال للناس وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إنى قد دعيت إلى مجلس الحكم فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت، ولا يبدأنى بالسلام: قال: ثم خرج وبين يديه الربيع وأنا خلفه، وهو فى إزار ورداء فسلم على الناس، فما قام إليه أحد ثم مضى، فبدأ بقبر النبى ﷺ فسلم عليه، ثم التفت فلما رآه ابن عمران القاضى أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به، ودعى بالخصوم الحمالين ثم دعا بالمنصور فادعى عليه القوم وقضى لهم عليه ثم انصرف، فلما دخل المنصور الدار قال للربيع: اذهب فإذا قام القاضى من مجلسه فادعه، فلما دعاه ودخل على المنصور سلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: جزاك الله عن دينك ونبيك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء، قد أمرت لك بعشرة آلاف صلة لك، فاقبضها فقبضها.

٧. وروى أن الملك الكامل تقدم ذات يوم شاهدا عند القاضى ابن عين الدولة وهو فى دست الملك، فقال ابن عين الدولة: السلطان يأمر ولا يشهد، فأعاد عليه القول، فلما زاد الأمر وفهم السلطان أنه لا يقبل شهادته، قال: أنا أشهد تقبلنى أم لا، فقال القاضى: لا ما أقبلك، وكيف أقبلك و(عجيبة) تطلع إليك بجنكها كل ليلة وتنزل ثانى يوم بكرة وهى تتمايل على أيدى الجوارى، وابن الشيخ من عندك أيحسن ما نزلت، وكانت (عجيبة) هذه مغنية أولع بها الملك ، فكانت تحضر إليه ليلا وتغنيه بالجنك على الدفاف فى مجلس يحضره ابن شيخ الشيوخ ، فقال له السلطان : (يا كيواج) وهى كلمة شتم باللغة الفارسية، فقال القاضى: ما فى الشرع (يا كيواج) اشهدوا على أنى عزلت نفسى، ونهض فقام ابن الشيخ إلى الملك الكامل وقال : المصلحة إعادته؛ لئلا يقال: لأى شئ عزل القاضى نفسه؟ وتطير الأخبار إلى بغداد، ويشيع أمر (عجيبة)، ونهض إلى القاضى وترضاه وعاد إلى القضاء كما كان.

٨. وروى أن أبا حنيفة -رضى الله عنه- كان جالسًا يومًا فى المسجد، فدخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين سيوفهم فقالوا: يا أبا حنيفة نسألك عن

مسألتين فإن أجبت نجوت وإلا قتلناك، قال أبو حنيفة: أغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها يشتغل قلبى، قالوا: وكيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزيل بإغمادها فى رقبتك، فقال: سلوا إذن، فقالوا: جنازتان بالباب، أحدهما رجل شرب الخمر فغص فمات سكرانا، والأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت فى ولادتها قبل التوبة، أهما كافران أم مؤمنان؟ وكان مذهب السائلين التكفير بذنب واحد، فإن قال: مؤمنان قتلوه، قال أبو حنيفة: من أى فرقة كانا من اليهود؟ قالوا: لا، من النصارى؟ قالوا: لا، من المجوس؟ قالوا: لا، قال: ممن كانا؟ قالوا: من المسلمين، قال: قد أجبتم، قالوا: هما فى الجنة أم فى النار؟ قال: أقول فيهما ما قال الخليل إبراهيم – عليه السلام – فيمن هو شر منهما: (فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم)، وأقول كما قال عيسى– عليه السلام –: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فتابوا واعتذروا إليه.

٩. ويروى أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس جمع الفقهاء والعلماء فى قصره، وكان وقع على جارية يحبها فى رمضان ثم ندم أشد

الندم، فسألهم عن التوبة والكفارة فقال (يحيى): تكفر بصوم شهرين متتابعين، فلما بادر يحيى بهذه الفتيا سكت جميع الفقهاء والعلماء حتى خرجوا، فقال بعضهم ليحيى: لم لم تفت بالمذهب الذى يقول بالتخيير؟ فقال يحيى: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم فى رمضان ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور؛ لئلا يعود لمثل ذلك .

١٠. ويروى أن الفضل بن الربيع وزير الخليفة الرشيد شهد عند أبى يوسف -رضى الله عنه - فرد شهادته، فعاتبه الخليفة الرشيد فى ذلك، وقال له: لم رددت شهادته؟ قال: لأنى سمعته يوما يقول للخليفة: أنا عبدك، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذبًا فكذلك لا تقبل شهادة الكاذب؛ لأنه لم يبال فى مجلسك بالكذب فلا يبالى فى مجلسى، فقدره وعظمه الخليفة الرشيد من أجل ذلك، وإنما رده القاضى أبو يوسف - رضى الله عنه- لما فى كلام هذا الوزير من إذلال النفس؛ لأجل حب الدنيا الفانية التى لا تزن عند الله جناح بعوضة.

١١. ويروى أن عاقبة بن يزيد القاضى كان يلى القضاء ببغداد فى عصر الخليفة المهدى، فجاء فى بعض الأيام فى وقت الظهر للمهدى وهو منفرد،

فاستأذن عليه فلما دخل استأذنه فيمن يسلم إليه القمطر الذى فيه قضايا مجلس الحكم، واستعفاه من القضاء، وطلب منه أن يقيله من ولايته، فظن الخليفة المهدى أن بعض الأمراء من البيت المالك قد عارضه فى حكمه، فقال له فى ذلك: إن كان عارضك أحد لننكرن عليه: فقال القاضى: لم يكن شئ من ذلك، قال: فما سبب استعفائك من القضاء؟ قال يا أمير المؤمنين: كان قد تقدم إلى خصمان منذ شهر فى قضية مشكلة، وكل يدعى بينة وشهودًا ويدلى بحجج تحتاج إلى تأمل وتثبت، فرددت الخصوم؛ رجاء أن يصطلحوا وأن يظهروا الفصل بينهما، فسمع أحد الخصوم أنى أحب الرطب فعمد فى وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب، فجمع رطبا لا يتهيأ فى وقتنا هذا جمع مثله لأمير المؤمنين، وما رأيت أحسن منه، ورشا خادمى بدراهم على أن يدخل الطبق على ولا يبالى عاقبة ذلك، فلما أدخله على أنكرت ذلك، وطردت خادمى، وأمرت برد الطبق فرد عليه، فلما كان اليوم تقدم الخصمان إلى، فما تساويا فى عينى ولا فى قلبى، فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل الهدية، فكيف يكون حالى لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع على حيلة فى دينى فأهلك وقد فسد الناس،

فأقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله، وأعفنى عفا الله عنك، وشدد فى هذا الطلب فلم يسع الخليفة المهدى إلا إقالته من القضاء؛ إجابة لطلبه وإلحاحه فى ذلك.

١٢. ويروى أن سفيان الثورى -رضى الله عنه- دخل على الخليفة المهدى وسلم تسليم العامة، ولم يسلم عليه بالخلافة كما هو الشأن فى مثل ذلك، (والربيع) قائم على رأسه متكئًا على سيفه يرقب أمره، فأقبل عليه المهدى بوجه طلق وقال له: يا سفيان تفر ههنا وههنا، وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك، فقد قدرنا عليك الآن، أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ قال سفيان: إن تحكم فى بحكم فيه ملك قادر يفرق بين الحق والباطل، فقال الربيع: يا أمير المؤمنين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ أتأذن لى أن أضرب عنقه؟ فقال له المهدى: اسكت ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على ألا يعترض عليه فى حكم، فكتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج ورمى به فى نهر دجلة وهرب، فطلب فى كل بلد فلم يوجد، ولما امتنع من قضاء الكوفة تولاه شريك النخعى -رضى الله عنه- فقال الشاعر فى ذلك:

تحرز سفيان وفر بدينه * وأمسى شريك مرصدا للدراهم

١٣. ويروى أن منذر بن سعيد البلوطى كان قاضيا بقرطبة فى أيام زهوة الإسلام فى تلك البلاد التى أخذ عليها الدهر وأصبحت أثرا بعد عين، وفى عصره احتاج الخليفة الناصر إلى شراء دار فى قرطبة، فوقع استحسانه على دار كانت لأولاد أيتام قصر، وكانت قريبة لبعض أملاكه، وهذه الدار يتصل بها حمام له غلة واسعة، وكان الأولاد الأيتام القصر فى حجر القاضى، فأرسل الخليفة من قوم هذه الدار بقدر ما طابت نفسه، وأرسل ناسا أمرهم بمداخلة وصى الأيتام فى بيعها عليهم، فقال: إنه لا يجوز ذلك إلا بأمر القاضى، فأرسل الخليفة إلى القاضى منذر ليبيع هذه الدار، فقال القاضى لرسوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا بوجوه، منها الحاجة، ومنها الوهى الشديد، ومنها الغبطة، فأما الحاجة فلا حاجة بهذه الأيتام إلى البيع، وأما الوهى فليس فيها، وأما الغبطة فهذا مكانها، فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستديم به الغبطة نأمر وصيهم بالبيع، وإلا فلا، فنقل جوابه إلى الخليفة، فأظهر الزهد فى شراء الدار طمعا في أن يتوخى رغبته فيها، وخاف القاضى أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام ثورتها، فأمر وصى الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها، ففعل ذلك وباع

الأنقاض، فكانت لها قيمة أكسب مما قومت به للخليفة الناصر، فاتصل الخبر بالخليفة، فعز عليه خرابها وأمر بتوقيف الوصى على ما أحدثه فيها، فأحال الوصى على القاضى أنه أمر بذلك، فأرسل عند ذلك للقاضى منذر وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخى نجدة ، فقال له : نعم ، فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: أخذت فيها بقوله – تعالى-: «**أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا**» [1]، مقوموك لم يقوموها إلا بكذا، وبذلك تعلق وهمك، فقد قبض فى أنقاضها أكثر من ذلك وبقيت القاعة والحمام فضل، وقد نظر الله – تعالى- للأيتام ، فصبر الخليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك، وقال: نحن أولى من إنفاذ الحق، فجزاك الله عنا وعن أمانتك خيرًا.

١٤. ونقل بعضهم أنه لما تولى الشيخ عز الدين بن عبد السلام القضاء فى مصر، تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك، وذكر إنه لم يثبت عنده إنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم ، والشيخ مصمم على فكرته، لا يصحح لهم

١ - سورة الكهف، الآية ٧٩.

بيعًا ولا شراءً ولا نكاحًا، وتعطلت مصالحهم لذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة فاستشاط غضبًا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، فقال: نعقد لكم مجلسًا وننادى عليكم لبيت مال المسلمين، فرفعوا الأمر إلى السلطان، فبعث إليه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفى هذا، فركب بنفسه فى جماعة، وجاء إلى بيت الشيخ، والسيف مسلول فى يده، فطرق الباب فخرج ولد الشيخ، فرأى من نائب السلطنة ما رأى وشرح لوالده الحال، فما أكترث لذلك، وقال: يا ولدى أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله، ثم خرج، فحين أن وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منها، وارتعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعوا له وقال: يا سيدى ماذا تعمل؟ قال: أنادى عليكم وأبيعكم، قال: قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: فى مصالح المسلمين، قال: من يقبضه، قال: أنا، فتم ما أراد، ونادى على الأمراء واحدا واحدا، وغالى فى ثمنهم ولم يبيعهم إلا بالثمن الوافى، وقبضه وصرفه فى وجوه الخير التى تعود نفعها على الأمة الإسلامية.

١٥. ويروى أن القاضى بكار بن قتيبة كان عالمًا ورعًا ومحدثًا ثقة يبتعد عن الشبهات؛ خوفا من الوقوع فى المحرمات، وقد تولى القضاء فى مصر فى زمن الملك أحمد بن طولون، وكان ابن طولون يعظمه ويحترمه، ويظهر أن ابن طولون لما رأى نفسه ملكا مستقلا فى مصر، أراد أن يضيف إلى ذلك الخلافة الإسلامية ، فأرسل للقاضى بكار رسولا وطلب منه خلع الخليفة الموفق بن المتوكل، فامتنع القاضى بكار من ذلك، وقال: هذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فغضب احمد بن طولون على القاضى بكار، ويقال: إنه أحضره أمامه ومزق ثيابه، وبعد ذلك أمر بسجنه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حرض عليه بعض بطانته ، فادعى عليه بمظالم كذبًا وزورًا، وكان يحضره أمامه من السجن فى حالة لا تناسب الأدب، حتى إذا انتهى التحقيق فى المظالم المزعومة أعاده إلى السجن مرة ثانية، وقد منعه من أداء صلاة الجمعة، فيقول القاضى بكار: اللهم اشهد، فأرسل إليه ابن طولون من يقول له : كيف رأيت المغلوب المقهور لا أمر له ولا نهى ولا تصرف فى نفسه؟! وكل هذه المحن التى رآها القاضى بكار لم تمنعه من قراءة الحديث الشريف وهو فى السجن على تلاميذه

الذين يستمعونه من خارج السجن، ومكث القاضى بكار فى السجن على هذه الحالة ، ولا يعلم له جريمة حتى مرض ابن طولون مرض الموت، فأرسل إليه من يطلب سماحه ، فقال للرسول: قل له: أنا شيخ كبير، وأنت عليل مدلف، والملتقى قريب، والله يحكم بيننا ، وهو خير الحاكمين، ولم تمض أيام حتى مات ابن طولون ، وخرج القاضى بكار من السجن، وقد رأى ما رأى من البلايا والمحن ولم يغير عقيدته ويوافق ابن طولون ، فانظر كيف يكون القضاء فى الإسلام.

١٦. ويروى أنه فى عصر الخليفة المقتدر وقفت أم الخليفة ضيعة وكان القاضى فى ذلك الوقت ابن البهلول، وأرادت الواقفة كتاب الوقف لتمزقه وتخلص من الوقف، وكان كتاب الوقف فى ديوان القضاء فأرسلت أم الخليفة المقتدر إلى القاضى تطلب كتاب الوقف فذهب القاضى ومعه الكتاب وقال ماذا تريدون بالكتاب، قالوا نريد أن يكون عندنا ففطن ابن البهلول لما يقولون: وقال : قولوا للسيدة أعزها الله وأبقاها هذا والله مالا طريق إليه أبدًا، أنا خازن المسلمين على ديوان الحكم فلما مكنتمونى على خزنه كما يجب وإلا فاصرفونى وتسلموا الديوان دفعة فاعملوا به ما

شئتم وخذوا منه ما أردتم، فأما أن يفل منه شئ على يدى فوالله لا كان هذا أبدًا ولو عرضت على السيف، وقام ومعه الكتاب وهو لا يشك فى صرفه عن القضاء وبعد ذلك شكت القاضى ابن البهلول إلى الخليفة المقتدر فاجتمع به يوم الموكب وخاطبه المقتدر فى الأمر فكشف له الحقيقة وطلب منه الاستعفاء، فقال المقتدر مثلك يا أحمد يقلد القضاء وأقم على ما أنت عليه بارك الله فيك ولا تخف أن يثلم عرضك عندنا ، فلما رجع المقتدر من الموكب قابلته السيدة والدته فقال لها، الأحكام مالا طريق إلى اللعب بها، وابن البهلول مأمون علينا محب لدولتنا وهو شيخ مستجاب الدعوة ولو كان هذا شيئا يجوز مامنعك إياه، فسألت السيدة كاتبها ابن عبد الحميد عن ذلك وشرحت له حقيقة الأمر فقال لها: الآن علمت أن دولة السيدة وأمير المؤمنين تبقى وتثبت إذا كان فيها مثل هذا القاضى الشيخ الصالح الذى يقيم الحق على السيدة ولا يخاف لومة لائم، فأي شيء يساوى شراءكم لوقف وإن أخذتم كتابه وحرقتموه فأمره شائع زائع والله فوق كل شئ وبه عليم، وقد عظم قدر القاضى ابن البهلول فى

بيت الخليفة المقتدر وصار محترما وقال بعد ذلك من قدم أمر الله تعالى على أمر المخلوقين كفاه الله شرهم.

١٧. روى أن الخضرمى – عندما ولى قضاء مصر قال لزوجته – وهى له سكنى ولباس-: ألا إنني وليت القضاء .. فلا تعرضي لي في أمر من أموره .. ولا تذكريني بخصم .. ولا تسأليني عن حكم .. وإلا فأنت طلق .. ابق معي مكرمة .. أو اذهبي مذمومة، **فاستقلال القاضى بالقضاء هو الاستقلال الحقيقي.. حتى عن زوجه، هذا هو الاستقلال الحق.**

هذا هو حال القضاء فى الإسلام فى العصور الخالية ولولا الإطالة لذكرنا كثيرا وكثيرا من مثل ما تقدم فقارن بين القضاء فى العصور الخالية وبين القضاء فى هذا الزمان واحكم بما ترى وأنت العاقل اللبيب.

وليس معنى ذلك أن هذه المثل وتلك القدوة ليست موجودة إلا فى العصور الماضية، فالخير موجود فى الأمة إلى يوم القيامة، وشيوخ قضائنا فى مصر ضربوا المثل أروع المثل.[1]

١- قيم وتقاليد القضاء للسيد المستشار/ فاروق سيف النصر ص ١٩٢ وما بعدها . بحث منشور فى كتاب الفكر الإسلامى المعاصر. محاضرات الجمعية الخيرية الإسلامية فى موسميها الثقافية ٢٠٠٠/٩٩م

١٨. قال القاضي عبد العزيز باشا فهمي – أول رئيس لمحكمة النقض المصرية: إن مركز قاض لأسمى وأكرم عندي من مركز وزير، وذلك عندما عرضت عليه الوزارة سنة ١٩٢٨م واعتذر.

وقال أيضا: إن العدل من صفات الله الكبير المتعال، لو تمثل لكان خَلْقًا جميل الطلعة، طلق المحيا، حلو الحديث، مؤلفا للقلوب محققا رجاء الكافة على السواء، فى بسمته الطمأنينة والسلام، وفى راحته البركة والرخاء والنعيم المقيم، لقد عبر عبد العزيز فهمى – عن العدالة بأدق تعبير وبيان رصين .. وعلى رجال العدالة أن يتمثلوا هذه المعاني، و يتأملوها جيدا، عندما يجلسون فى محراب العدالة يوزعون العدل بين الناس.

١٩. ولنا أيضا فى خارج بلادنا عبرة .. فمن الأمثلة الذائعة فى ألمانيا، أن فردريك الأكبر إمبراطور ألمانيا أراد أن يرغم أحد جيرانه الفقراء على أن يبيع له قطعة أرض فرفض الجار الفقير البيع، فقال له فردريك: ألا تعلم أننى إمبراطور ألمانيا؟ فأجاب الرجل: أعرف، ولكن ألا تعرف أن فى ألمانيا قضاة؟

٢٠. قال المحامى الإيطالي بيرو كالمندرى: إذا جاء يوم أغلقت فيه المحاكم أبوابها لانعدام التقاضي، فإنني لا أرى على وجه اليقين هل يكون ذلك مبعثا لابتهاجي أم لاكتئابي؟ .. ذلك لأني سأبتهج إذا كان ذلك بزوغ فجر جديد، لا يحتاج فيه الرجل إلى الإضرار بجاره، عهد تقوم فيه المحبة مقام القانون، أما إذا كان ذلك يعنى أن الإنسان قد يئس وكفر لعدم قدرة الدولة على رد الحقوق لأصحابها، فإن ذلك اليوم سيكون أقسى أيام حياتي، إذ سأشعر فيه بهزيمة التقوى .. وغلبة الشر على الخير.

٢١. ويحكى أن عبد العزيز باشا فهمي – شيخ القضاة – والشئ بالشئ يذكر – أنه إبان أن كان رئيسا لمحكمة النقض – أن رأت الحكومة فى غير ما طلب منه – رفع مرتب رئيس محكمة النقض إلى مرتب وزير، فاعترض نائب المعارضة على رفع المرتب وأعتبره نفاقا من الحكومة لرئيس محكمة النقض ، واستمالة للقضاء ، فلما قرأ الشيخ – فى الصحف – وجهة نظر النائب المعارض – دخل إلى جلسته وقال عبارته المشهورة: إني أشعر أن كرسي القضاء الذي أجلس عليه يهتز من تحتي، وقدم استقالته، وثارت الثائرة، واعتذر المعارض ورفع المرتب، وعلمنا هذا الرجل كيف نحس

بكرامة القاضي، وكيف نحافظ على هذه الكرامة وكيف إذا عرض أمر من أمور القضاء ينبغي أن يعرض في إطار من الاحترام اللائق ..

٢٢. في إنجلترا يرشح القاضي من بين المحامين الذين أمضوا عشر سنوات فى عملهم ويكاد العامة أن يعرفوا المرشح من بين المحامين للقضاء متى عرفوا أفضلهم، والقاضي في إنجلترا يتقاضى مرتبه بقدر حاجته ..وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعين قضاة المحكمة الفيدرالية العليا مدى الحياة – وإن كانوا يستطيعون التقاعد في سن السبعين وبعد عشر سنوات من العمل بالمحكمة براتب كامل ، وقضاة هذه المحكمة التي تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين معروفون ومشهورون ، ويتابع الأمريكيون أخبارهم وأحكامهم وتكتب عنهم المجلدات فى حياتهم وبعد مماتهم، وهم متساوون فى البروتوكول مع نائب الرئيس ويسبقون أعضاء الكونجرس ورئيس المحكمة الفيدرالية العليا، وهو ثاني شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ويحلف أمامه رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وعندما يتناول المؤرخون فترة ما من فترات حياة الولايات المتحدة .. فإنهم لابد وأن يشيروا إلى ما أسهمت به المحكمة العليا فى هذا

الصدد، وقد أنشئت هذه المحكمة سنة ١٧٨٩م وكانت تتكون من ستة أعضاء بينهم الرئيس، وهى مكونة حاليا من تسعة أعضاء، ويعين الأعضاء بناء على اختيار رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس الشيوخ على الاختيار وقد جرى تمثيل الأقليات العنصرية أو الدينية على أن يكونوا من الشخصيات السياسية العامة البارزة أو من رجال القانون ذوى الكفاية الممتازة والفضل العميم ..لهذا يوجد بالمحكمة عادة قاض كاثوليكى وقاض يهودى، إلا أنه لم يحدث أن مثل الزنوج بين أعضاء المحكمة إلا منذ يونيو سنة ١٩٦٧م، حيث عين قاض زنجى هو تورجود مارشال فى عهد الرئيس جونسون، وهو أول ملون يعين بالمحكمة العليا، وفى عهد الرئيس ريجان عينت أول امرأة قاضية بالمحكمة العليا، ويقول العلامة بيردو فى مطولة عن علم السياسة: إن المحكمة العليا هى مرآة صادقة لوجهات نظر المجتمع الأمريكى، يرى فيها الأمريكيون أنفسهم سواء أكانوا راضين عنها أو منتقدين لها، كما يرى – بيردو– أن أكبر سند لهذه المحكمة هو اعتقاد الشعب الأمريكى أنها فوق السياسة فتسعة رجال بالرداء الأسود يوزعون الحكمة

والعدالة، هذه الصورة الشعبية قد رسخت فى الأذهان طوال سنين، وبرغم أن القانون من قديم، يعطى وزير العدل سلطة الإشراف على المحاكم، فيذكر للقاضى أحمد باشا إبان أن كان رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، أن استقبل وزير العدل فى المحكمة، وكان آنذاك المرحوم مرسى بك بدر، و حمد الوزير ما رأى من حسن نظام المحكمة وأدائها .. فعاد إلى وزارته ووجه كتابا إلى رئيس المحكمة يشكره فيها على ما رأى، فإذا رئيس المحكمة يرفق كتاب الوزير بكتاب من عنده يقول له فيه:

أرد إليك كتابك فيما أثنيت.. فمن يملك الثناء يملك القدح .. وأنت لا تملك هذا ولا ذاك.. هؤلاء هم شيوخ قضائنا ضربوا المثل –أروع المثل– فى توفير استقلال القضاء وتوكيد حصانته وإخلاصهم لرسالتهم.

٢٣. كما يذكر أيضا .. أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المرحوم المستشار طاهر راشد، كانت تنظر قضية .. وكان محامى المتهم المرحوم على الخشخانى .. وكان من المحامين الكبار .. والمستشارون الثلاثة يجلسون.. كل يلبس معطفه الأسود .. وعليه وسامه الأخضر .. المحامى يلبس الروب .. وكان وقتها يلبس الطربوش، وكان الجو صيفا، خلع

المحامى طربوشه .. ووضعه أمامه وهو يترافع، فنبهه رئيس الدائرة أن يلبس الطربوش .. فلبسه واستغرق المحامى فى مرافعته، فخلع الطربوش فنبهه رئيس الدائرة للمرة الثانية أن يلبس الطربوش .. فاحتد المحامى وقال: أنا لا أطيقه صيفا يا سعادة الرئيس، فرد رئيس الدائرة: وقال: فلتؤجل القضية إذن إلى الشتاء ..وأجلت القضية.

ولايفوتني هنا ما ذكره الشعبي؛ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية وهو أمير بالشام: أما بعد، فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيراً، فالزم خصالاً يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك؛ إذا حضر الخصمان فالبينة العدول، والأيمان القاطعة؛ أدن الضعيف حتى يجتري قلبه وينبسط لسانه، ويعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأساً، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء.[1]

وأختم حديثى هنا بذكر الكتاب الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى - قاضي الكوفة في عصر عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما-، هذا الكتاب الذى يعد بحق دستورًا للقضاء ونموذجًا لما يجب أن

١ - أخبار القضاة ص ٣٨

يتحلى به القاضى من صفات وآداب ولأصول المرافعات والإجراءات التى لم تصل إليها أرقى القوانين الحديثة فى عصر التقدم الحاضر ..

وكلنا يعلم فضل أبى موسى الأشعرى –رضى الله عنه– وصلاحه وتقواه، ونعلم مقدار رسوخه فى فهم كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام الشرعية وحرصه على الشريعة الغراء ولكن تشدد عمر بن الخطاب –رضى الله عنه– فى إقامة الحدود وتوطيد دعائم الأمن فى البلاد والمساواة بين الناس؛ حرصا علي تحقيق العدل الذي جاءت لأجله الشرائع السماوية وختامها الإسلام، كل ذلك كان باعثا على إرسال كتاب إلى أبى موسى الأشعري – رضى الله عنه– وقد وضعناه هنا بنصه ليتطلع عليه كل من لم يره ويعلم الجاهل مقدار تمسك الصحابة– رضوان الله عليهم – بالدين خصوصا فى الأمور التى يعود نفعها على جماعة المسلمين وها هو ذا بعد الديباجة:

أما بعد

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك – أى رفع لك الأمر وجئ به إليك– فإنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، أس بين الناس فى مجلسك ووجهك وعدلك، حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا يخاف

ضعيف من جورك، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل، الفهم، الفهم، عندما يتلجلج فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا سنة النبى ﷺ، اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل للمدعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا واجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا فى حد أو مجربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا فى ولاء أو قرابة، فإن الله – تعالى – قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات، ثم إياك والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر بالخصوم فى مواطن الحق التى يوجب بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله – تبارك وتعالى – ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره وأبدى فعله .. والسلام عليك [1] .

١- الشيخ / على الجرجاوى . المرجع السابق ح٢ ص ٢٠٧ وما بعدها

المبحث السابع
الفرق بين الحكم القضائي وغيره

أولًا: الحكم القضائى والفتوى.

يتفق الحكم القضائى مع الفتوى فى أمور ويختلف عنها فى أمور أخرى، حيث إن **الحكم القضائى** عرف كما سبق بأنه: إخبار عن حكم شرعى على سبيل الإلزام، **أما الفتوى** فقد عرفها الفقهاء بأنها: الإخبار عن الحكم الشرعى، وعلى ذلك فإن الأمور التى تتفق فيها الفتوى مع الحكم القضائى **هى كالتالى**:

١. أن كلا من الحكم القضائى والفتوى إخبار عن حكم شرعى فى الواقعة المعروضة على كل من القاضى والمفتى.
٢. كلا من القضاء والإفتاء أجره عظيم وخطره كبير، أما القضاء فلما سبق، وأما الإفتاء فلأن المفتى لابد وأن يكون عالما ، والعلماء ورثة الأنبياء، وكما يقول الإمام النووى –رحمه الله [١] إن المفتى قائم بفرض الكفاية،

١- آداب الفتوى والمفتى والمستفتى. لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى سنة [٦٣١ ، ٦٧٦هـ – ١٢٣٣، ١٢٧٧م] ، ص ١٣ وما بعدها .ط ثانية [١٤١١هـ – ١٩٩٠ م] .دار البشائر الإسلامية

لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا: المفتى موقع عن الله –تعالى– وروينا عن ابن المنكدر، قال:العالم بين الله –تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركًا، وروينا عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال:أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول، وفى رواية: ما منهم يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

- وعن ابن مسعود وابن عباس – رضى الله عنهم : من أفتى فى كل ما يسأل فهو مجنون ولو وردت على عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – لجمع لها أهل بدر، وعن عطاء بن السائب – التابعى–: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشئ فيتكلم وهو يرعد.

- وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدرى أصيبت مقاتله، وعن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسر الناس على

الفتيا أقلهم علما وعن الشافعى، وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال ، حتى أدرى أن الفضل فى السكوت أو فى الجواب.

- وعن الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول : لا أدرى ، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه – أى أكثر من قول فى المسألة .

- وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال فى اثنتين وثلاثين منها: لا أدرى، وعن مالك أيضا، أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة، فلا يجيب فى واحدة منها، وكان يقول: من أجاب فى مسألة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه، ثم يجيب وسئل عن مسألة، فقال: لا أدرى: فقيل: هى مسألة خفيفة سهلة، فغضب، وقال : ليس فى العلم شئ خفيف.

- وقال الشافعى : ما رأيت أحدا جمع الله – تعالى – فيه من آلة الفتيا ما جمع فى ابن عيينة، أسكت منه على الفتيا.

- وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله –تعالى– أن يضيع العلم، ما أفتيت ، يكون لهم المهنأ وعلى الوزر ...وأقوالهم فى هذا كثيرة معروفة.

- قال الصيمرى والخطيب: وقل من حرص على الفتيا، وسابق إليها، وثابر عليها، إلا قل توفيقه، واضطرب فى أمره، وإن كان كارهًا لذلك، غير مؤثر له، ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح فى جوابه أغلب، واستدلالًا بقوله ﷺ فى الحديث الصحيح: «لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أوكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها».

٣. يتفق القضاء مع الإفتاء فى أن كلا منهما مبنى على إعمال العقل وقدح الذهن فى النظر فى الصور الجزئية والأمور الفرعية، وإدراك ما تحتويه من أوصاف والتفرقة بين الأوصاف التى يجب اعتبارها والتى لا يجب اعتبارها، وربط الحكم الشرعى بما هو معتبر منها[1]

٤. يتفق القضاء مع الإفتاء فى ضرورة تحلى كل من القاضى والمفتى بآداب معينة، حيث يشتركان فى اشتراط عدم الفتيا أو القضاء فى حال تغير

١- نظام القضاء الإسلامى . د / إسماعيل إبراهيم البدوى ص ١١٥

خلقهما واضطراب مزاجهما وانشغال قلبهما انشغالا يمنعهما التأمل والنظر السليم، كغضب، وجوع، وعطش، وحزن، وفرح غالب، ونعاس أو ملل، أو حر مزعج أو مرض مؤلم، أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه القلب ويخرج عن حد الاعتدال.

كما أن على كل منهما أن يقضى أو يفتى – عند اجتماع القضايا والفتيا – حسب الأسبق فالأسبق، فإن تساووا، أو جهل السابق، قدم بالقرعة، والصحيح فى مذهب الشافعية جواز تقديم المرأة والمسافر الذى شد رحله، وفى تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته، ونحو ذلك، على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير، فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة[1]

٥. يتفق القضاء مع الإفتاء فى أن الأصل فى كل منهما أن يكون تبرعًا وبدون أجر، ولكن يجوز أخذ مرتب على كل منهما من خزانة الدولة كما هو الحال فى هذه العصور، إذا لم يكن عند كل منهما ما يكفيه، فإن تعين القضاء أو الفتيا على معين وله كفاية، فإنه يحرم عليه أخذ أجرة على الصحيح من مذهب الشافعية، وفى جميع الأحوال لا يجوز لكل من

١ - النووى . المرجع السابق ص ٣٨، ٥٧

القاضى والمفتى أن يأخذ أجرة من أعيان من يخاصم أو يستفتى نظير القضاء أو الفتوى، وإن كان يجوز أخذ قيمة الورق المدون فيه الحكم أو الفتيا وأجرة تدوينه، لأن الأصل أن الملزم فى القضاء والإفتاء الخالى من الأجر أن يكون قولا، أما الكتابة فالقاضى والمفتى ليسا ملزمين بها، قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى فى الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال، ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار فى السنة [1].

الأمور التى يختلف فيها القضاء عن الإفتاء:

١. الفتوى شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره من الناس، وأما القضاء فهو جزئى لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله .
٢. الفتوى غير ملزمة للمستفتى كقاعدة عامة إلا إذا لم يكن هناك علماء فى بلد المستفتى إلا هذا العالم الذى يتعين عليه الإفتاء فتكون الفتوى حينئذ ملزمة أما القضاء فإنه ملزم للخصوم فى جميع الأحوال.

١ - المرجع السابق ص ٤٠، علما بأن الدينار وقتئذ كان مصنوعا من الذهب، وكان يزن ٤.٢٥ جرام .

٣. القاضى أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من المفتى، لأن الأخير من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضى شأنه الأناة والتثبت بالنظر فى البيانات والحجج المقدمة له، ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب مالا يتهيأ لصاحب البديهة.

٤. الفتوى أعم من القضاء من جوانب عدة من **أهمها ما يلى:**

أ – أن الفتوى تدخل كافة جوانب الحياة دون تخصيص، فالمفتى يفتى فى العبادات والمعاملات ونظام الأسرة، والجنايات والحدود والعقائد وغيرها، أما الحكم القضائى فمسائله محدودة وليست عامة فليس له مثلا أن يدخل فى العبادات، وعلى ذلك فكل ما يجوز فيه القضاء تدخله الفتوى والعكس غير صحيح .

ب- أن الفتوى تتعرض لقضايا الدنيا والآخرة خلافا للقضاء فلا يتعرض إلا لمصالح الدنيا.

ج – الحكم القضائى يرفع الخلاف، أما الفتوى فلا ترفعه، وبيان ذلك أن القاضى إذا أصدر حكمه على أشخاص يعتقدون مذهبا آخر ويرجحون رأيا خلاف رأى القاضى من الناحية الفقهية، فإن حكم

القاضى فى ذلك النزاع ملزم لهم بخلاف الفتوى، حيث يجوز لمن صدرت فى مواجهتهم وكانت تخالف مذهبهم أن يعملوا بقول آخر، ويفتوا بخلاف ما صدر من المفتى.

د- الحكم القضائى أكثر تقييدا للقاضى، حيث لا يجوز له أن يقضى لنفسه أو لأحد من أقاربه لدرجة معينة من القرابة، خلافا للمفتى حيث يجوز له أن يفتى لنفسه ولغيره من أهله أو أقاربه، وأيضا لا يجوز للقاضى أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه خلافا للمفتى وذلك لوجود العلة فى القاضى وهى التهمة –حينئذ– وانتفائها فى المفتى.

هـ- السبيل الذى يسلكه القاضى فى إدراك الأوصاف والأمور الجزئية يختلف عن السبيل الذى يسلكه المفتى فى إدراكها، فالقاضى طريقه أصعب من طريق المفتى، إذ يعتمد القاضى على حجج المتخاصمين من إقرار، أو شهادة، أو غير ذلك حتى يظهر له ما يمكن اعتباره من الأوصاف، فيطبق حكم الشارع عليه، ومن ثم فإن القاضى ينبغى أن يتصف بالذكاء واليقظة التامة، والفراسة الوافرة، والقريحة الباهرة، والخبرة الواسعة، لكى يكتشف الأوصاف التى ينبغى اعتبارها، وينجح فى

إصابة الحق والتوصل إلى الصواب، فالخصوم يتعمدون غالبا المراوغة والتحايل وإخفاء الحقيقة وتمويه الحجج، أما المفتى فطريقه أيسر وأسهل، لأن المستفتى يأتيه بقلب أسلم ونية أصفى من الخصوم حين يأتون القاضى فينظر فى المسألة المعروضة عليه ويحللها ويستقرئ الأدلة، وينزل عليها النص أو الحكم المناسب لها فهو أقرب إلى السلامة من القاضى من هذه الزاوية.

و- القاضى يبحث عن الاعتبار القضائى للأعمال والأحكام ولا ينظر إلى الاعتبار الدينى، أما المفتى فيبحث عن الواقع وينظر إلى الاعتبار القضائى والاعتبار الدينى للأعمال والأحكام ، فإن اختلف اتجاههما أفتى بالاعتبار الدينى فحسب.

ز- القضاء يكون فى الواجبات والمحرمات والمباحات – كالحكم بإباحة الأرض المحياة التى يزول عنها الإحياء – ولا يكون فى المكروهات والمستحبات ، لأن القضاء إلزام، ولا إلزام فى المكروهات والمستحبات[1]

١- نظرية الحكم القضائى فى الشريعة والقانون. د/ عبد الناصر موسى أبو البصل. تقديم .د/ محمد نعيم ياسين ص٩٠ وما بعدها، دار النفائس. طبعة أولى [١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م]، القضاء فى الإسلام . د/ محمد عبد القادر أبو فارس ص١٧. دار الفرقان. طبعة رابعة [١٤١٥ هـ -١٩٩٥ م] د/ إسماعيل البدوى المرجع السابق ص١١٩وما بعدها.

ح- القاضى يشترط فيه الذكورة باتفاق جمهور الفقهاء – خلافا لبعضهم وهو الراجح كما سيأتى فى المبحث الثامن – أما المفتى فلا يشترط أن يكون ذكرا ، فالمرأة تصلح للإفتاء.

ثانيًا: الحكم القضائى والعمل التشريعى والقرار الإدارى.

على نحو ما سبق فإن الحكم القضائى يصدر فى منازعة بين خصمين لا يتعداهما، **أما العمل التشريعى فيخالفه من عدة نواحى منها:**

١. القانون -التشريع- سابق على المنازعة ولا يشترط لإصداره وجود منازعة، أما الحكم القضائى لاحق عليها ويشترط لإصداره وجود منازعة.
٢. القانون – التشريع- يتصف بالعمومية والتجريد خلافًا للحكم القضائى فهو قاصر على أطراف الخصومة.
٣. الهيئة التى تصدر القانون – التشريع- لا يشترط لصلاحيتها ما يشترط لصلاحية القاضى من شروط.
٤. الهيئة التى تصدر القانون – التشريع- ليست ملزمة بالمبادئ التى يرسيها القضاء أما القضاء فإنه ملزم بتطبيق ما يصدر عن هذه الهيئة من قوانين.

*** وكذلك القرار الإدارى يخالفه -أى الحكم القضائى- من عدة نواحى أيضا منها:**

١. الحكم القضائى لا يصدر إلا بناء على طلب من صاحب الحق الذى وقع الاعتداء عليه فلا يجوز للقضاء أن يتدخل من تلقاء نفسه أما القرار الإدارى فلا يتطلب ذلك ، حيث للإدارة أن تتدخل من تلقاء نفسها – وهذا من واجباتها – فتسير المرافق وتحافظ على المصالح وتحفظ النظام.

٢. لا يشترط أن يصدر القرار الإدارى بمناسبة منازعة خلافا للحكم القضائى.

٣. يشترط لإصدار الحكم القضائى توافر شكليات خاصة بالأحكام وإجراءات الدعوى وغير ذلك مما ليس بشرط فى صدور القرار الإدارى[١].

ثالثًا: القضاء والتحكيم.

يتفق القضاء مع التحكيم فى أن كلا منهما فيه فصل للخصومة وفض للمنازعة بين الناس، ويختلفان فى أمور كثيرة منها ما يلى:

١- د/ عبد الناصر موسى أبو البصل، المرجع السابق ص٩٢ وما بعدها

١. أن القاضى يعين من قبل ولى الأمر –رئيس الدولة– أما المحكم فيعين من قبل المتخاصمين الذين ارتضوا حكمه.

٢. أن الحكم القضائى نطاقه أوسع حيث يفصل فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنايات وغير ذلك مما هو منصوص عليه، أما التحكيم فلا يفصل فى العقوبات والحدود مثلا لأنها من حقوق الشرع ولا يفصل فيها إلا المختص وذلك عند فريق من العلماء.

٣. لا يجوز للمحكم أن يحكم على الغائب، ولا أن يكتب إلى القاضى، ولا أن يكتب القاضى إليه إلا إذا رضى الخصوم، ولا يتقيد بالاختصاص المكانى وإنما يجوز أن يحكم فى كل البلاد خلافا للقاضى.

٤. الحكم القضائى ملزم للخصوم سواء قبل أو بعد إصداره، خلافا للحكم الصادر من الحكم فلا يلزم إلا بعد صدوره.

٥. المدعى عليه ملزم بالحضور أمام القاضى ولا يجوز له أن ينسحب من الدعوى فى أى مرحلة من مراحلها وإلا حكم القاضى عليه غيابيا،أما فى التحكيم فرضاؤه الاستمرار فى إجراءات الدعوى مطلوب فى كل وقت طالما يصدر الحكم من المحكم.

٦. للحكم القضائى حجية أمام الكافة، أما حكم المحكم فليست له حجية إلا فى مواجهة الخصوم فقط.

٧. لا يشترط رضا الخصوم على القاضى الذى يحكم فى خصومتهم، أما التحكيم فيشترط فيه رضا الخصوم على المحكم فهم الذين يرتضونه ويولونه.

٨. شروط صلاحية المحكم أيسر وأخف من شروط صلاحية القاضى، فلا يشترط فى المحكم ما يشترط فى القاضى من شروط.

٩. للقاضى أن ينقض حكم المحكم فى المسائل الاجتهادية، خلافا للمحكم فلا يجوز له نقض حكم القاضى فى المسائل الاجتهادية إذا كان رأيه يخالف رأى القاضى.

١٠. حكم القاضى يرفع الخلاف الفقهى بالاتفاق، أما حكم المحكم فلا يرفع الخلاف عند الحنفية ويرفعه عند المالكية.

١١. لا يجوز للقاضى أن يفصل فى القضايا التى يكون هو نفسه أحد أطرافها ، أو فى القضايا التى يكون أحد أطرافها من لا تصح له شهادته، أو عدوه، خلافا للمحكم فى كل ما سبق.

١٢. الأصل فى الحكم القضائى العلنية، فى حين لا يشترط ذلك فى حكم المحكم.

١٣. القاضى يعزل من قبل السلطة التى قامت بتعيينه ولا دخل للخصوم فى عزله، حيث إنهم لم يقوموا بتعيينه ، خلافا للمحكم فإنه يعزل من قبل الخصوم الذين قاموا بتعيينه[١].

رابعًا: القضاء والفقه.

العلاقة بين القضاء والفقه هى علاقة عموم وخصوص، فالفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والقضاء هو تطبيق هذه الأحكام الكلية على الجزئيات بعد إحالة النظر فى الحوادث الجزئية، والعلم بكيفية الفصل فى الخصومات، فالقاضى يشترط فيه ما يشترط فى الفقيه وزيادة، حيث إن القاضى كما سبق هو من يخبر عن الحكم الشرعى على سبيل الإلزام، والمفتى يخبر عن الحكم الشرعى فقط من غير إلزام، حتى مع عدم الخصومة والمجتهد من يستدل على الحكم الشرعى، والفقيه هو العالم بالحكم عن دليله، والشخص الواحد الجامع لكل هذه الصفات يمكن أن يسمى

١ - د/ إسماعيل البدوى، المرجع السابق ص ١٤٤ وما بعدها، د/ عبد الناصر أبو البصل، المرجع السابق ص ٩٣ وما بعدها

قاضيا باعتبار حكمه على الأفراد بأحكام خاصة، ومفتيا باعتبار إخباره عن الحكم، ومجتهدا باعتبار استدلاله عليه، وفقهيا باعتبار علمه به، ومن ثم فإن القاضى ينبغى أن يكون واقفا على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة، ومتمكنا من فصل وحسم الدعاوى الواقعة تطبيقا لها[1].

خامسًا: القضاء والدين.

الفقه الإسلامي يحتوى الأحكام المنظمة لحياة الناس والراعية لمصالحهم فى الدنيا والآخرة، فالدين للدنيا والآخرة، أى أن الدين لا يقابل الدنيا، لأنه ينظمها، كما أنه جاء للآخرة أيضا، خلافا للدنيا فهي التي تقابل الآخرة، وعليه فإن قواعده وأحكامه تبنى على المصالح واعتبار الحلال والحرام، خلافا للقوانين الوضعية التي لا تتأثر بالحلال والحرام عند وضعها، ورغم أن الدين يعتنى بالحلال والحرام والحقيقة والواقع ، والباطن والظاهر كمنظومة متكاملة إلا أنه رغم ذلك لم يغفل الواقع والظاهر إعمالا للظاهر واستقرارا للأوضاع وإرساء لنظام مدنى راق من حق كل من ينتسب إليه أن يتباهى به، وفى هذه الحالات التى يخالف فيها الظاهر الباطن فإنه يأخذ بالظاهر للسبب السابق

١- فقه الإمام جعفر الصادق. لمحمد جواد مغنية ج٦ ص٦٠ وما بعدها. مؤسسة أنصاريان، إيران، د/ إسماعيل البدوى، المرجع السابق ص ١٢٩، ١٣٠

وذلك ما يلتزم به القاضى، وحكم القاضى المبنى على الظاهر وإن خالف الحقيقة فهو المعول عليه، ويقال فى هذه الحالة بأنه – أى الحكم – ينفذ ظاهرا لا باطنا أو قضاء لا ديانة، لأن القضاء يبنى على الظاهر، ولا إثم على القاضى فى هذه الحالة، وإنما الإثم على من يخفى الحقيقة أو يتعمد تزويرها، فلا يحل هذا الحكم حراما، ولا عكسه، فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة بالزواج بين رجل وامرأة – خلافا للحقيقة لم يحصل بحكم القاضى الحل باطنا، فلا يحل للمحكوم له معاشرة هذه المرأة معاشرة الأزواج بناء على هذا الحكم وعليها الامتناع والهرب ما أمكنها ، فإن أكرهت فلا إثم عليها. وذلك لقوله ﷺ-: «إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار».

هذه الصيغة الدينية أكسبت هذا النظام المدنى جلالًا ووقارًا، وأورثته احترامًا وسلطانًا على النفوس، فغدا الفقه الإسلامى شريعة مدنية ووازعًا دينيًا معًا لا يفتقر الإنسان فيه إلى قوة تراقبه دومًا، ولا يجد فى الإفلات من سلطانه فوزًا إن أمكنه الإفلات ، سواء أكان حاكمًا أم محكومًا، ولهذه الصبغة كان

الحكام المسلمون إذا دعاهم القضاة للمحاكمة فى دعوى رفعها ضدهم أحد أفراد الرعية يحضرون دون غضاضة أو حرج أو ضيق صدر أو استعلاء أو استخفاف إلى مجلس هؤلاء القضاة مثل عامة الناس، موقرين له، تاركين أبهة الحكم والسلطان، وإذا حكم القاضى على الخليفة أو رئيس الدولة يخضع لحكم الشرع كسائر الناس، عن رضا تام واقتناع كامل وعقيدة صادقة لم تصل إليها أى شريعة أو قانون فى عصرنا الحاضر.

فقد حكم محمد بن عمر بن الطلحى قاضى المدينة على أبى جعفر المنصور الخليفة العباسى حين استعداه عليه الحمالون والمكارون، فأمر القاضى كاتبه نميرا المدينى أن اكتب إلى أمير المؤمنين كتابا بالحضور معهم، فقال الكاتب: تعفينى من هذا فإنه يعرف خطى! فقال: اكتب، فكتب، ثم ختمه وقال لكاتبه: لا يمضى به أحد والله غيرك، فمضى به وأعطاه الربيع ، فأدخله على الخليفة ، ثم خرج الربيع فقال للناس – وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم-: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إني دعيت إلى مجلس الحكم، فلا أعلمن أحدا قام إلى إذا خرجت، أو بدأني بالسلام إلا فتكت به ثم خرج الخليفة وبين يديه المسيب والربيع وكاتب القاضي

خلفه فى إزار ورداء، فسلم الخليفة على الناس، فما قام إليه أحد، ثم مضى حتى بدأ بالقبر فسلم على رسول الله ﷺ ثم التفت إلى الربيع فقال: ويحك يا ربيع ، أخشى إن رآنى محمد بن عمر بن الطلحى أن يدخل قلبه هيبة فيتحول عن مجلسه، فوالله لئن فعل لا يولى لى على ولاية أبدا، فلما رأى القاضي الخليفة أطلق رداءه على عاتقه واحتبى –وكان متكئا – ثم دعا الخليفة والخصوم والحمالين، فعرضوا دعواهم، فحكم القاضي لخصوم أمير المؤمنين، فلما رجع الخليفة إلى الدار استدعى القاضي، فذهب إليه – بعد أن فرغ من أمور الناس جميعا– فلما دخل قال له المنصور: جزاك الله عن دينك، ونبيك، وعن حسبك، وعن خليفتك أحسن الجزاء[1]

١- د/ إسماعيل البدوى، المرجع السابق ص ١٣٢، ١٣٣

الفصل الثاني: قضاء الحسبة [1]

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاح.

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الحسبة.

المبحث الثالث: أركان الحسبة.

المبحث الرابع: التطور التاريخي للحسبة.

(١) كتب هذا الفصل:الأستاذ الدكتور/ عطا عبد العاطي السنباطي .

الفصل الثاني

قضاء الحسبة

تمهيد:

تُعد الحِسبة من النظم التي عرفها الفقه الإسلامي في إطار سعي الشريعة الإسلامية إلى تحقيق الصالح العام، وصيانة المجتمع من مظاهر الفساد والانحراف، وحماية الحقوق والمصالح التي اعتبرتها الشريعة جديرة بالحماية، وترتبط الحسبة ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ تمثل أحد التطبيقات العملية لهذا المبدأ، وقد عرفت المجتمعات الإسلامية الحسبة منذ العصور الأولى، ثم تطورت من ممارسة فردية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ولاية منظمة من ولايات الدولة، لها اختصاصات وقواعد، ويتولى القيام بها شخص أو جهاز يعينه ولي الأمر، **وقد اتخذت تاريخيًا صورتين أساسيتين:**

الحسبة الفردية التطوعية، والحسبة النظامية التي أصبحت ولاية من ولايات الدولة، وفي العصر الحديث لم تعد الحسبة في صورتها التاريخية ولاية مستقلة بالمعنى الذي عرفته كتب الفقه، وإنما أخذت صورًا قانونية ومؤسسية مختلفة بحسب النظام القانوني للدولة، وفي مصر، اكتسب موضوع دعوى الحسبة أهمية خاصة في مسائل الأحوال الشخصية، وأصدر المشرع القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، فأخضع مباشرتها لتنظيم إجرائي محدد، وجعل النيابة العامة هي الجهة المختصة برفعها، ومن هنا تبرز أهمية دراسة الحسبة من خلال **المباحث التالية:-**

المبحث الأول
تعريف الحسبة لغة واصطلاحاً

أولا : تعريف الحسبة لغة:

الحِسبة مصدر من الفعل احتسب، وهي مأخوذة من مادة حَسَبَ، وتدور معاني هذه المادة في اللغة حول الحساب والعدِّ والتقدير، كما تأتي بمعنى طلب الأجر والثواب من الله – تعالى- ويقال: احتسب فلان عمله عند الله، أي فعله طالبًا ثوابه وأجره عند الله، ومن هذا المعنى جاء إطلاق الحسبة على العمل الذي يقوم به الإنسان ابتغاء وجه الله – تعالى- ولا سيما إذا كان متعلقًا بتحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة عامة ، وعليه فإن المعنى اللغوي للحسبة **يتضمن عنصرين أساسيين**: القيام بعمل يُرجى منه الخير والصلاح، وابتغاء الأجر والثواب من الله -تعالى- وهذا المعنى اللغوي يتصل بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن المحتسب يقوم بعمل هدفه تحقيق المعروف ودفع المنكر، ويرجو بذلك الثواب من الله.

ثانيًا: معنى الحسبة اصطلاحا:

استعمل الفقهاء مصطلح الحسبة للدلالة على الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، بقصد المحافظة على المصالح العامة التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م أن الحسبة في اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يُحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه، أو نهي عن منكر ظهر فعله، وأنها من فروض الكفاية، **وعلى هذا يمكن تعريف الحسبة بأنها:**

قيام الشخص المختص أو الجهة المختصة بالأمر بالمعروف عند ظهور تركه، والنهي عن المنكر عند ظهور فعله، بقصد تحقيق مصلحة شرعية عامة أو دفع مفسدة عامة، وفق الضوابط التي قررتها الشريعة والقانون، وهذا التعريف يكشف أن الحسبة ليست مجرد نصيحة شخصية بين فردين، وإنما قد تتصل بمصلحة المجتمع، ولذلك اهتم الفقه الإسلامي بتحديد شروطها وضوابطها والجهة التي تباشرها، فالحسبة في أصلها تطبيق عملي لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المبحث الثاني
أدلة مشروعية الحسبة

الحسبة مشروعة بالكتاب والسنة:

فمن الكتاب قوله – تعالى– : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [1]

وقوله–تعالى–:«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» [2]

ففي الآية ارتباط واضح بين صلاح المجتمع وبين قيام أفراده ومؤسساته بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقوله– تعالى–:«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [3]

حيث تؤكد هذه الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مظاهر التعاون والتكافل داخل المجتمع، ومن ثم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل الأصل الشرعي العام، بينما تمثل الحسبة صورة أكثر تنظيمًا

١- سورة آل عمران . الآية ١٠٤
٢- سورة آل عمران . من الآية ١١٠
٣- سورة التوبة . من الآية ٧١

وتخصصًا لهذا الأصل، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، وأن مراتب القيام به تختلف بحسب القدرة والاختصاص، وأن استعمال القوة أو اليد ليس متاحًا لكل فرد، وإنما يكون للجهات المختصة.

ومن السنة قوله ﷺ: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»

هذا الحديث يبين تدرج وسائل مواجهة المنكر، كما يكشف عن ارتباط وسائل التغيير بالقدرة والاستطاعة ، وأن تغيير المنكر لا بد أن يكون بالحكمة، وألا يؤدي إلى منكر أكبر أو مفسدة أشد، ومن ثم فإن الحسبة ليست إباحة للفرد أن يستعمل القوة أو يتولى العقاب بنفسه، وإنما هي وظيفة لها ضوابطها، وتختلف وسائلها بحسب طبيعة الواقعة والقدرة والاختصاص.

حكم الحسبة :

الأصل في الحسبة أنها من فروض الكفاية؛ فإذا قام بها من يكفي لتحقيق المقصود الشرعي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع مع القدرة عليها ترتب الإثم بحسب الأحوال التي قررها الفقهاء؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وأنه إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الآخرين،

مع مراعاة القدرة والضوابط الشرعية، ومع ذلك قد تتحول الحسبة في بعض الحالات إلى واجب متعين على شخص بعينه إذا لم يوجد غيره ممن يستطيع القيام بها، وفق التفصيل الفقهي المعروف في هذا الباب.

الفرق بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل العام الذي تستند إليه الحسبة، **أما الحسبة** فهي الصورة المنظمة والمؤسسية لممارسة هذا الأصل في المجالات التي تتعلق بالمصلحة العامة، **وعليه يمكن القول** إن العلاقة بينهما علاقة أصل وتطبيق؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ شرعي عام، والحسبة أحد أهم التطبيقات العملية المنظمة لهذا المبدأ، ولا يعني ذلك أن كل أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر يمثل بالضرورة دعوى حسبة أمام القضاء؛ فدعوى الحسبة في النظام القانوني المصري لها مجال وإجراءات محددة.

المبحث الثالث

أركان الحسبة

للحسبة أركان أربعة على النحو التالى:-

أولًا: المحتسب:

وهو الشخص الذي يقوم بالحسبة، أو الجهة التي تتولى القيام بها، ويشترط فيمن يتولى الحسبة العلم بما يأمر به وما ينهى عنه ، والقدرة على القيام بالحسبة، والتمييز والإدراك، والعدالة والاستقامة بالقدر الذي يحقق الغرض من الحسبة، والرفق والحكمة؛ لأن الهدف هو الإصلاح وليس مجرد إيقاع العقوبة، ومعرفة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتظهر أهمية العلم بصورة خاصة؛ إذ إن الإنسان قد يظن أمرًا منكرًا وهو ليس كذلك، أو ينكر أمرًا مختلفًا فيه بين العلماء، ولذلك شددت المصادر الفقهية على ضرورة العلم قبل ممارسة الحسبة، فعلم الاحتساب يقوم على معرفة شروط المحتسب ومحل الحسبة وقواعدها؛ حتى لا تتحول إلى وسيلة للعدوان أو التشهير أو التعدي على حقوق الآخرين.

ثانيًا: المحتسب عليه:

وهو الشخص الذي يتعلق به فعل الحسبة، سواء كان مرتكبًا للمنكر أو تاركًا للمعروف، ولا يعني ذلك أن المحتسب يملك سلطة مطلقة على الناس، وإنما يمارس اختصاصه في حدود ما تسمح به الشريعة والجهة القانونية المختصة.

ثالثًا: المحتسب فيه:

وهو الأمر الذي تتعلق به الحسبة، ويكون عادة معروفًا ظهر تركه، أو منكرًا ظهر فعله، ويشترط أن يكون الحكم على الفعل بالمعروف أو المنكر قائمًا على أساس معتبر، لا على مجرد الأهواء الشخصية أو الاختلافات الخاصة، وينبغي أن يتم تغيير المنكر بطريقة لا تؤدي إلى زيادة المنكرات أو وقوع فتنة أشد، ويشترط أيضا احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية، وعدم اتخاذ الحسبة ذريعة للتشهير بالناس أو اقتحام خصوصياتهم أو الاعتداء على حقوقهم، وهذا ما لاحظه القانون المصري عند تنظيم دعوى الحسبة؛ إذ استهدف القانون منع استعمالها لأغراض الانتقام أو التشهير أو الترويع.

رابعًا: وسيلة الحسبة:

تختلف الوسيلة باختلاف طبيعة المنكر وقدرة المحتسب واختصاصه، وقد بين الحديث النبوي مراتب التغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب ، لكن هذه المراتب لا تعني أن لكل فرد الحق في استعمال جميع الوسائل، فالاستعمال المادي للقوة يرتبط بالاختصاص والولاية القانونية، أي أن التغيير باليد يكون للجهات المختصة ، فلا يجوز أن تتحول الحسبة الفردية إلى ممارسة للسلطة العامة أو إلى عقاب للأشخاص خارج إطار القانون، أي عدم التعدي على اختصاص السلطات، ومن هنا كان التطور التاريخي للحسبة مرتبطًا بإنشاء ولاية متخصصة يتولاها من يعينه ولي الأمر .

المبحث الرابع

التطور التاريخي للحسبة

لم تكن الحسبة في بدايتها جهازًا إداريًا مستقلاً بالصورة التي عُرفت بها في عصور لاحقة، وإنما كانت في أصلها ممارسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تطورت مع اتساع الدولة الإسلامية، وأصبحت ولاية الحسبة من الولايات التي يتولاها أشخاص مختصون، وأصبح للمحتسب اختصاصات تتعلق بالأسواق والمعاملات والغش التجاري والموازين والمكاييل وبعض مظاهر النظام العام، وقد اتسعت ولاية الحسبة في العصرين الأموي والعباسي، وأصبحت ولاية مستقلة إلى جانب القضاء وولاية المظالم، كما عرفت في مصر واستمرت بصور تاريخية مختلفة حتى بدايات القرن التاسع عشر، وهذا التطور التاريخي مهم لفهم الفرق بين الحسبة كمبدأ شرعي وبين ولاية الحسبة كنظام إداري تاريخي، أما عن موقف القانون المصري منها فقد ميز بين أمرين، الحسبة باعتبارها مبدأ شرعيًا عامًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوى الحسبة باعتبارها وسيلة قضائية في مسائل معينة، وبخاصة مسائل الأحوال الشخصية، والذي نظمه القانون المصري بصورة صريحة هو دعوى الحسبة في

مسائل الأحوال الشخصية، وذلك في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث جاء هذا القانون ليضع تنظيمًا إجرائيًا لدعوى الحسبة، وليس لإلغاء فكرة الحسبة من أصلها، كما أنه قصر رفع دعوى الحسبة على النيابة العامة، وأنها وحدها تختص برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وبالتالي فإن الشخص الذي يرى أن هناك حالة تستوجب تحريك دعوى حسبة لا يقوم برفعها بنفسه، وإنما يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة، يوضح فيه موضوع البلاغ وأسبابه، ويرفق به المستندات المؤيدة له، ثم تقوم النيابة العامة بسماع أقوال أطرافه وإجراء التحقيقات اللازمة، ثم يكون أمامها أحد أمرين، رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة، أوحفظ البلاغ، ويصدر القرار مسببًا من محامٍ عام، مع إعلان ذوي الشأن به وفق الإجراءات التي حددها القانون، كما نظم القانون سلطة النائب العام في مراجعة قرار النيابة العامة وفق المدة والإجراءات المحددة فيه، وإذا قررت النيابة العامة رفع دعوى الحسبة، فإنها تصبح هي المدعية في الدعوى، وتمارس الحقوق والواجبات المقررة للمدعي، وهذا التنظيم يعكس فلسفة قانونية مهمة، وهي أن دعوى الحسبة لا

تستهدف حماية مصلحة شخصية خاصة لرافعها، وإنما تتعلق بمصلحة عامة أو بمصلحة اعتبرها القانون جديرة بالحماية، فقبل تنظيم المشرع لهذه المسألة، كانت دعوى الحسبة قد أثارت إشكالات عملية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بشرط المصلحة والصفة في رفع الدعوى، وبعد التنظيم أصبحت غير متروكة للمبادرات الفردية؛ حيث جاء القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦م ليضع إطارًا إجرائيًا واضحًا لمباشرتها، بما يمنع إساءة استعمالها، ويحول دون استخدامها للانتقام أو التشهير أو الترويع، وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية المصالح التي تستهدفها الحسبة وبين حماية حقوق الأفراد وحسن سير العدالة، حماية للمصلحة العامة؛ لأن الحسبة في جوهرها تتعلق بمصلحة عامة، فقد رأى المشرع أن تتولى النيابة العامة، باعتبارها ممثلة للمجتمع، مباشرة الدعوى، ومنعا لإساءة استعمال حق التقاضي، فقد تتحول الدعوى إذا تُركت دون ضوابط إلى وسيلة للخصومة الشخصية أو الانتقام، ولهذا أكد المشرع في فلسفة القانون ضرورة منع استعمال الحسبة لأغراض الانتقام والتشهير والإرهاب والترويع، وحماية لحقوق الأفراد، فتنظيم الحسبة لا يستهدف فقط حماية المصلحة العامة، بل يحمي أيضًا

الأفراد من الدعاوى الكيدية أو التدخل غير المشروع في حياتهم وحقوقهم، وتحقيقا للتوازن بين الشريعة والقانون، حيث حاول المقنن أن يحافظ على أصل فكرة دعوى الحسبة في مجالها المعترف به، مع إخضاع ممارستها لإجراءات قانونية تمنع الفوضى في استعمالها، كما أنه من المهم التأكيد على أن القانون المصر حدد نطاق دعوى الحسبة في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦ في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالى كل صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كل صور الحسبة في المجتمع لا تصلح دعاوى قضائية، ففي المجال المدني والتجاري مثلًا، الأصل هو تطبيق قواعد المصلحة والصفة في الدعوى، وقد قررت المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة عامة تتعلق بضرورة توافر المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة، مع الاستثناءات التي يقررها القانون.

والخلاصة:

أنه يتضح مما سبق أن الحسبة نظام ذو جذور شرعية وفقهية عميقة، وأن أصلها يرتبط بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من المبادئ التي أكدت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والحسبة في معناها الفقهي لا تعني مجرد تدخل الفرد في شئون غيره، وإنما تقوم على ضوابط دقيقة، أهمها العلم بما هو معروف وما هو منكر، والقدرة على القيام بالحسبة،

والحكمة والرفق، ومراعاة المآلات، وعدم ترتب مفسدة أكبر على عملية الإنكار، كما أن الحسبة مرت تاريخيًا بمراحل متعددة؛ بدأت باعتبارها تطبيقًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تطورت إلى ولاية مؤسسية لها اختصاصات وقواعد محددة، أما في مصر الحديثة، فقد اتجه المقنن إلى تنظيم دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦، فجعل النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في رفع هذه الدعوى، بعد تلقي البلاغ وإجراء التحقيق اللازم، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة ومنع إساءة استعمال الحسبة وتحويلها إلى وسيلة للانتقام أو التشهير، وبذلك يمكن القول إن موقف القانون المصري يقوم على عدم ترك دعوى الحسبة للمبادرة القضائية الفردية في مسائل الأحوال الشخصية، وإنما وضع لها إطارًا مؤسسيًا وإجرائيًا تتولاه النيابة العامة، مع بقاء أصل الفكرة الشرعية قائمًا في نطاقها الذي يقرره الشرع والقانون، ومن ثم فإن الحسبة في صورتها المعاصرة ينبغي فهمها باعتبارها مفهومًا شرعيًا له ضوابطه، وتطبيقًا قانونيًا له مجاله وإجراءاته، ولا يجوز الخلط بين الحسبة كمبدأ شرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين دعوى الحسبة كطريق قضائي نظم المشرع المصري كيفية مباشرته.

الفصل الثالث[1]:

القضـــاء العـــام

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: أركان القضاء.

المبحث الثاني: شروط القضاء.

المبحث الثالث: جهة تعيين القاضي.

المبحث الرابع: ولاية القاضي واختصاصاته.

المبحث الخامس: آداب القاضي.

المبحث السادس: رَزْقُ القاضي.

المبحث السابع: قضاء القاضي بعلمه.

المبحث الثامن: القضاء بالشاهد واليمين.

المبحث التاسع: آداب القاضي.

(١) كتب هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ مراد محمود حيدر.

الفصل الثالث

القضـــاء العـــام

تمهيد وتقسيم: ينقسم القضاء في الفقه الإسلامي إلى عدة أنواع رئيسية، وذلك بناءً على نطاق صلاحيات القاضي "الولاية"، أو طبيعة القضايا التي ينظر فيها، أو طريقة الإثبات والحكم، فالحاكم ومن أقسام القضاء بحسب ذلك: **القضاء العام، والقضاء الخاص**.

ـ القضاء العام:

هو تخويل الحاكم للقاضي النظر في جميع الأحكام، بحيث لا يختص نظره في القضايا بنوع معين من أنواع القضاء، ولا يتقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهية، وهنا تكون ولاية القاضي عامة، فينظر في قضايا الأحوال الشخصية، كالنكاح والطلاق والنفقة، والإرث، ونحوها، وينظر في قضايا المعاملات المدنية، كالبيع والإيجار، والهبة، ونحوها، كما لا يتقيد قضاء القاضي في هذه الولاية العام بالمكان، وهو ما يُعرفُ بالاختصاص المكاني، أي النظر في قضايا دائرة مكانية معينة، كما لا يتقيد القاضي بالنظر في القضايا من حيث الزمان، بحيُ لا يُمنع القاضي العام من النظر في القضايا التي مرَّ عليها زمن معين، وبالجملة: فاختصاص القاضي العام هنا: هو النظر في جميع أنواع القضايا.

القضاء الخاص:

هو تخويل الحاكم للقاضي النظر في نوع معين من الأنواع السابقة، كأن يوليه النظر في قضاء الجنايات، أو قضايا المعاملات، أو أن يقيده بالنظر في قضاء دائرة معينة أو بلد معين، أو النظر في القضايا التي مضى عليها مدة كذا من الزمان فقط، أو أن يقضي في القضايا بمذهب معين من المذاهب الفقهية(١).

وقد اتفق الفقهاء على جواز تعميم ولاية النظر في القضاء، كما اتفقوا على جواز تخصيص القضاء بالمكان والزمان والنوع والأشخاص، وأن ما يستقيده مُتولِّي القضاء بالولاية، ليس له حد في الشرع، وإنما يُتلَقَّى من العرف، ومن رغبة وليِّ الأمر، التي تتجسد في ألفاظ التولية (٢) وبناء على ما تقدم، يشتمل هذا الفصل على عدة مباحث في القضاء، وهي كالتالي:

(١) انظر: في القضاء العام والخاص: الأحكام السلطانية، علي بن محمد حبيب الشهير بالماوردي، ص:١١٩ـ١٢١، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء، ص:٦٣، وما بعدها الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

(٢) انظر: روضة القضاة، ابن السمناني، ٧٢/١، معين الحكام، الطرابلسي، ص: ١١، بداية المجتهد، ابن رشد، ٤٣١/٤، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١٥/١، وما بعدها، الأحكام السلطانية، الماوردي، ص: ١١٩، وما بعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص: ٦٣، كشاف القناع، البهوتي، ٢٨٩/٦.

المبحث الأول

أركان القضاء

تتمثل أركان القضاء في خمسة أركان، هي: القاضي والمقضي به، وهو "منطوق حكم القاضي" والمقضي له، وهو أحد الخصمين في الدعوى، والمقضي فيه، وهو موضع الدعوى أمام القضاء، والمقضي عليه، وهو الطرف الآخر في الدعوى، والحكم، وبيان ذلك فيما يلي:

الركن الأول: القاضي

هو: "من يُنصِّبُه الإمام في تبيين الأحكام الشرعية، وإلزام الرعية بها "(١) ولا يصح قضاؤه، ولا يَنْفُذُ إلا بعد عقد الولاية، وهو ما يُعرف في عصنا الحالي ب" صدور قرار التعيين" (٢)

الركن الثاني: المقضي به

وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لأجل حسم النزاع، وقطع المخاصمة، وهو إما بإلزام المحكوم عليه فيقول: حكمتُ عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام مثل ما يقع من القضاة في القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٧٥.
(٢) انظر: المرجع والمكان السابقين.

بقوله للمدعي: ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن الإثبات، وحلف المدعى عليه، وهذا يسمى بقضاء التَّرْك، ويسمى صرف النظر عن الدعوى، ولا بد من أن تكون عبارة الحكم واضحة قاطعة في الدلالة. (١)

الركن الثالث: المقضي فيه

وهي الدعوى التي تكون محلا للحكم، وهي في اصطلح الفقهاء "قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أولمن يمثله أو حمايته "(٢) والمُدَّعَىَ في الدعوى لا يخلو من أن يكون أحد الحقوق التي قررها الشارع، وهذه الحقوق تعود في مجملها إما إلى حفظ النوع الإنساني وبقاء النسل وما يتبع ذلك، وإما إلى حفظ الفرد الإنساني وما يتبعه من حفظ عرضه وعقله ودينه وغير ذلك(٣)

الركن الرابع: المقضي عليه

وهو من يصدر الحكم ضده وهو الإنسان دائمًا إذ هو الذي يستوفى منه حقوق الشرع، أو حقوق العباد، وأما حقوق الشرع فتستوفى منه سواء وُجد مُدع عليه أو لا، بخلاف حقوق العباد.

(١) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ٣٥٢/٥، ٣٥٣، درر الحكام، منلا خسرو، ٥١٨/٤، وما بعدها، معين الحكام، الطرابلسي، ٥/١، وما بعدها، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٦٤/١، وما بعدها. مغني المحتاج، الشربيني، ١٠٥/٤، كشاف القناع، البهوتي، ٢٨٥/٦.
(٢) انظر: نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي والقانون المدني، د. مراد محمود حيدر، ص:١٦، د. محمد نعيم يسن، نظرية الدعوى، ص:٨٤.
(٣) انظر: رد المحتار، ابن عابدين،٣٤٣/٤.

الركن الخامس: المقضي له

وهو الذي يدعي الحق، ولا بد أن يدعي الحق المحكوم به، ويطلب الحكم له به، سواء بنفسه أم بواسطة نائب عنه، وكذا لا بد من أن يكون حاضرًا هو أو نائبه. وإذا كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع، وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين يكون صاحب حق وإنما تكون دعوى حسبة يتقدم بها المحتسب ممّن عين رسميًا أو أحد أعوانه أو أي شخص محتسب(١).

(١) انظر: المبسوط ١٦ / ٧٨، تبصرة الحكام ١ / ١٠٤، تحفة المحتاج ١٠ / ٢٩٧، المغني ٩ / ٨٦، أدب القضاء للغزي ق١٠ أ - مخطوط بدار الكتب (٩٠٧ فقه شافعي)

المبحث الثاني

شروط القضاء

يُشترط في القاضي عدة شروط، نص عليها الفقهاء، **ومنها ما يلي**:

١ـ الشرط الأول: الإسلام: وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء (١)، فلا يجوز تولية غير المسلم للقضاء بين المسلمين؛ لأن الكافر ليس له أهلية الولاية على المسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) (٢)، والقضاء ولاية عامة، والولاية من أعظم السبل فهذه الآية مع أنها خبر لفظا، فإنها نهي في المعنى، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، والقاضي له الهيمنة والولاية؛ لأن الولاية هي إنفاذ القول على الغير شاء أم أبى، وأحكام القاضي تنفذ سواء شاء المتخاصمون أم أبوا، فإذا ولينا الكافر القضاء على المسلمين كان له الهيمنة والولاية، وهذا يتنافى مع ما تفيده الآية(٣)

(١) انظر: بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ٣/٧، بداية المجتهد، القاضي ابن رشد الحفيد، ٢٤٣/٤، كفاية الأخيار، أبو بكر تقي الدين الحصني، ص:٥٤٩، كشاف القناع، منصور البهوتي، ٢٩٥/٦. المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨. السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ٨١٧/١.
(٢) من الآية: ١٤١، من سورة النساء.
(٣) انظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، د. محمد رأفت عثمان، ص:٧٧ الناشر: دار البيان، الطبعة: الثانية، ١٤١٥هـ١٩٩٤م

٢ـ الشرط الثاني: التكليف، وهو يشمل: البلوغ والعقل، وهذا محل إجماع عند الفقهاء(١).

أما البلوغ فعكسه الصبا، فلا يصح تولية الصبي القضاء، حتى لو كان مميزا واشتهر بالفطنة والذكاء، لقوله ﷺ "تعوَّذوا باللهِ من رأسِ السبعينَ وإمارةِ الصبيانِ "(٢) والتعوُّذُ لا يكون إلا من شر، فتكون ولاية الصبي للقضاء شراً، وهو ممنوع. ولأن الصبي قاصر الأهلية، يحتاج إلى ولاية غيره عليه، فلا يُستساغ في الشرع أن يكون والياً على غيره.

وأما المجنون فلا يصح توليه القضاء، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون غير مكلف، فلا يجوز توليه القضاء على المكلفين، والعقل المطلوب في تولي القضاء، هو العقل الذي يتمتع صاحبه بصحة التمييز وجودة الفطنة والذكاء.

(١) انظر: بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ٣/٧، بداية المجتهد، القاضي ابن رشد الحفيد، ٢٤٣/٤، كفاية الأخيار، أبو بكر تقي الدين الحصني، ص:٥٤٩، كشاف القناع، منصور البهوتي، ٢٩٥/٦. المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨. المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨. السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ٨١٧/١، ط: أولى دار ابن حزم.

(٢) انظر: أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٨٣٠٢)، قال الشوكاني:" رجاله رجال الصحيح، وله شاهد، قد أخرجه ما يشهد له أحمد من حديث قيس الغفاري مرفوعا." نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م

ودليل ذلك[1]، قوله ﷺ:" رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ وعَنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ"[2].

٣ـ الشرط الثالث: الحرية: أي: لا يكون عبداً، وهل هذا الشرط محللا خلاف بين الفقها؟ في ذلك تحرير محل النزاع على النحو الآتي:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على: اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل في القاضي، **واختلفوا في** شرط الحرية، على **قولين**:

القول الأول:

لا يجوز تولية العبد القضاء، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (٣)

(١) انظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، ص٨٨، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م

(٢) انظر: أخرجه أبو داود في سننه، برقم (٤٤٠٣) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٧ / ٣، ابن عابدين، رد المحتار، ٥ / ٣٥٥. بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ / ٤٥٠، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١ / ٢٣ - ٢٤، حاشية الدسوقي، ٤ / ١٣٠. أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص ٧٠، مغني المحتاج ٤ / ٣٧٥. شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٣ / ٤٦٤، المغني، ابن قدامة، ٩ / ٣٩، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤٤، كشاف القناع، البهوتي. ٦ / ٢٩٦.

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (١)

ووجه الاستدلال: إن الآية الكريمة قد فرقت بين العبد وبين الحر، وبَيَّنَتْ أن العبد المملوك لا يملك من أمر نفسه شيئاً، لأنه ملك لسيده، فكيف يتولى أمر العامة من الناس؟ (٢)

ونُوقشَ هذا: بأن الآية واردة في التفرقة بين المسلم والمشرك، فمَثَّلَتْ المسلم الذي يتصدق ويُنفق، ويقوم بسائر التكليف الشرعية بالرجل الحُر، ومثَّلتْ المُشرك بالعبد المملوك لسيده الذي لا مال له ولا استطاعة على الإنفاق، فهولا يستوي مع من أنفق، واما المساواة في أصل التكاليف الشرعية فهي باقية على أصلها العام(٣).

(١) الآية:٧٥ من سورة النحل.
(٢) انظر: حاشية عبد الرحمن بن قاسم النجدي، على الروض المربع للبهوتي، ٥١٧/٧.
(٣) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص٧٧، وما بعدها.

وأُجيب عنه: بأن النص وإن كان واردا في أصل التشبيه بين المسلم، وبين المشُرك، إلا إنه يبقى على عمومه في عدم التسوية بين الحُر وبين العبد، إذ الفرق بينهما في أصل جواز التملك باق على عموم حتى في الإسلام(١).

٢ـ لأن الرق -كما قال العلماء- أثر كفر؛ لأنه في الأصل عقوبة وقعت على أسير الحرب من الكفار، لما استكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى، جعله الله عبد عبيده(٢).

٣ إن العبد مشغول بخدمة سيده، فلا يتفرغ لمصالح الأمة(٣).

٤ـ ولأن منافع العبد مستحقة لسيده فلا يجوز أن يصرفها للنظر بين المسلمين. (٤)

القول الثاني:

يجوز تولية العبد القضاء، وإليه ذهب الظاهرية والزيدية. واختاره أبو طالب، وابن عقيل، من الحنابلة (٥)

(١) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٢) انظر: المراجع السابقة، نفس المواضع.
(٣) انظر: الروض المربع، منصور بن يونس البهوتي، وحاشية العنقري عليه ،٣٨٥/٣.
(٤) انظر: المنتقى، الباجي، شرح موطأ مالك،١٨٣/٥
(٥) انظر: المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨. السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ٨١٧/١. حاشية عبد الرحمن بن قاسم النجدي، على الروض المربع للبهوتي، ٥١٧/٧.

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: إن الله أمر المؤمنين جميعاً بأداء الأمانة، ومنها القضاء، والعبد مخاطب من جملة المؤمنين، فيجوز توليه القضاء (٢).

ونُوقش هذا: بأن الآية واردة في الأمر بأداء الأمانة، والقضاء ولاية، يُشترطُ فيها الأمانة، فتكون الولاية أعم منها. وحينئذ فالاستدلال بالآية الكريمة خارج عن محل النزاع(٣).

٢ـ بقوله ﷺ " اسمَعوا وأطيعوا، وإنِ استُعمِلَ حَبَشيٌّ كَأنَّ رَأسَه زَبيبةٌ."(٤).

ووجه الاستدلال:

إن الحديث الشريف قد دل بمنطوقه على وجوب طاعة العبد إن ولي أمر الإمامة، وإذن فتصح ولايته للقضاء من باب أولى(٥)

(١) من الآية: ٥٨ من سورة النساء.
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨. السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ٨١٧/١.
(٣) انظر: السامي، في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٧٧.
(٤) انظر: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:٦٩٣.
(٥) المحلى، ابن حزم، ٤٢٧/٨، البحر الزخار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ١١٩/٦.

ونُوقش هذا من وجوه:

١. أن دلالة النص الشريف افتراضية، بمعنى إنه لو فُرض وتولى الأمر عبد حبشي، فأطيعوه، والفرض ليس كالواقع، كما أن النص الشريف يدلُّ في عمومه على وجوب الطاعة، حتى ولو كان المُوَلَّى عليكم عبداً حبشياً، على أن النص الشريف دل على مُطلق الولاية وهو لفظ عام يحتمل ولاية الإمامة في سرايا الجيش، أو في الصلاة أو في القضاء، وإذن فيكون القضاءُ مستثنى من النص لخطورته(١).

٢. إن أصل المساواة بين الحر والعبد في أصل الدِّينِ، فالإسلام، لا يُفرق بين الحر والعبد في عموم الخطاب، من حَيْثُ المناصب، ولا يُستثني العبد من الأحكام المتعلقة بالولاية العامة إلا بنص صريح يمنعهن ولا نص في ذلك(٢).

٣. إن العبد يصح شهادته فيصح حكمه كالحر(٣).

(١) انظر: السامي، في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٧٧.
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم ، ٤٢٧/٨. السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ٨١٧/١.
(٣) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ١١٩/٦.

سبب الخلاف:

ويرجعُ سبب الخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية والزيدية، **إلى ما يلي**:

١. اختلافهم في فهم النصوص العامة، فمن فَهِمَ من النصوص العامة في الكتاب والسنة أنها تَهدفُ إلى المساواة في جميع التكاليف أجاز للعبد تولي القضاء إبقاء للنصوص على ظاهرها، ومن رأى أن العبد مُستَثْنىً من النصوص العامة، لأنه" وما ملكت يداه مملوك لسيده"، قالوا بعدم جواز توليه القضاء.

٢. كما يرجع سبب الخلاف، إلى اشتراط الولاية العامة في تولى القضاء، فيرى الجمهور أن القضاء منصب يتطلب "الولاية العامة" أي السلطة المستقلة"، والعبد لا يملك هذه الولاية الكاملة لأنه مملوك لسيده، ويرى الظاهرية والزيدية، أن ذلك ليس بشرط في تولي القضاء.

الترجيح:

قبل الترجيح ينبغي علينا محاولة التوفيق بين رأي الجمهور وبين رأي الظاهرية والزيدية، فنقول وبالله التوفيق: إن الأصل أن تنعقد ولاية القضاء للرجل الحر إذا توافرت فيه سائر شروط القاضي، وتساوى مع العبد فيها، فيكون الحر أولى، إعمالاً لرأي الجمهور، وأما إذا حدث تفاضلٌ في سائر الشروط المطلوبة في القاضي، بحيث يُفَضَّلُ العبد على الحر في ولاية القضاء، فيكون العبد أولى، إعمالاً لرأي الظاهرية والزيدية، وإنّما، يُصارُ إلى الترجيح بين القولين من حيثُ قوة الأدلة، وضعفها، وحينئذ فإن حُجة الجمهور أقوى، لما يَشهد له واقع النصوص الشرعية من إن العبد مملوك لسيده، وإنه لا يصح تملكه إلا بإذن سيِّده، وأما كون أصل الكفر قبل الإسلام مانع له من تولي القضاء ، فإن الإسلام يَجُبّ ُما قبله كما شهدت بذلك النصوص الشرعية . والله أعلم.

٤ـ الشرط الرابع: الذكورة: وهو محل خلاف بين الفقهاء على **أقوال ثلاثة**:(١)

القول الأول:

أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء، ولو ولاها الحاكم هذا المنصب يكون آثما، وتأثم هي أيضا لرضاها بأمر لا يجوز، ولو حكمت في أي قضية من القضايا، سواء أكانت من القضايا التي تصح شهادتها فيها كالأموال، والرضاع أم لا، لا ينفذ قضاؤها، حتى لو كان موافقا للحق، فالذكورة عند الجمهور شرط للجواز وللصحة. **وإلى هذا القول ذهب جمهور المالكية، ومعهم الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية، والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية وهو مذهب الإباضية (٢)**

(١) اعتمدنا في صياغة أقوال الفقهاء على ما ذكره أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه النظام القضائي في الإسلام ص:٩٨، وص ١٢٣، ومن نقل عنهم من مشايخه رحمهم الله جميعا، كالشيخ الدكتور عبد العال عطوة في كتابه محاضرات في القضاء، ص:٥٩، والشيخ الدكتور إبراهيم عبد الحميد، في كتابه: نظام القضاء في الإسلام، ص:٢٣، ٢٤. مع اختصار غير مُخِلٍّ، والسبب في ذلك: دقة ألفاظ الصياغة وتعبيرها عن جوهر ما كتبه الفقهاء وما حوته بطون كتب المذاهب من معان لم يفهمها بعض الباحثين المعاصرين. هذا مع مراعاة الحرص على شدة التوثيق والرجوع إلى المصادر المعتمدة في كتب المذاهب الثمانية في مظان المسألة.

(٢)انظر: مواهب الجليل الحطاب،٨٧/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون،٢٣/١، المنتقي شرح الموطأ، سليمان الباجي، ١٨٢/٥، الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:٧٢، نهاية المحتاج، الرملي،٢٢٦/٨، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد الحصني، ٢٥٧/٢، المقنع، عبد الله بن قدامة المقدسي ص٣٢٦، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الحلي، ج٤، ص٦٧. الاختيار لتعليل المختار، الموصلي،٨٤/٢، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن العاملي، ٦/١٨، البحر الزخار، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، ٦/ ١١٨، شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، ٢٣/١٣.

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (١)

ووجه الاستدلال: إن الآية الكريمة، قد حصرت القوامة في الرجل وأثبتها له، ولو أُجيز للمرأة أن تكون قاضية؛ لكان لها القوامة على الرجل وهو عكس ما تقيده الآية المباركة.

ونُوقش هذا: بأن الاستدلال بالآية الكريمة خارج عن محل النزاع، لأن القوامة المذكورة ليس المراد بها القوامة العامة التي تشمل القضاء وغيره، بل المراد هنا قوامة خاصة، وهي قوامة رب الأسرة عليها، وإذن فوجه الاستدلال من الآية فاسد(٢).

وأُجيب عنه: إن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك، أمّا قول: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة، وليست عامة فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن

(١) من الآية رقم٣٤ من سورة النساء.
(٢) انظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي ص:٢٧.

كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد، فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزًا عن إدارة شؤون الناس، والفصل في خصوماتهم، ومنازعاتهم، وحل مشاكلهم(١).

٢ـ **استدل الجمهور** أيضاً بقول الرسول ﷺ "لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمْرَهم امرأةً" (٢)

وجه الاستدلال: إن منطوق الحديث دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، فلا يحل للمرأة أن تلي من أمور المسلمين العامة شيئًا -والقضاء منها- وذلك أن تَجَنُّب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب كما هو منطوق الحديث، ونحن مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح. وكلمة (قوم) نكرة في سياق النفي فتعم(٣).

ونُوقش هذا: بأن الاستدلال بهذا الحديث ليس في محل النزاع أي: ليس في المسألة التي تختلف حولها؛ لأن الحديث وارد في رياسة الدولة، فيكون النهي المستفاد منه قاصرا على الولاية العظمى، فلا يشمل ولاية القضاء(٤).

(١) انظر: القضاء في الإسلام، محمد عبد القادر، ص: ٣٥. حقوق المرأة في ضوء السنة، نوال العيد، ص: ٤٨٨.
(٢) رواه البخاري، في صحيحه، كتاب المغازي، ١٥٨/٨، الحديث رقم: ٤٤٢٥.
(٣) انظر: سبل السلام، للصنعاني،١٢٣/٤، ونيل الأوطار للشوكاني. ٢٩٨/٨.
(٤) انظر: المحلى، ابن حزم، ٥٢٨/٨.

وأُجيب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا يخصص السبب كما هو المرجح في علم أصول الفقه(١).

٣ـ الإجماع: حيث قال الجمهور: إن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها، فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع من غير دليل شرعي (٢)

ونُوقشَ دليل الإجماع: بأن الإجماع لا يمكن تحققه، وعلى فرض أنه ممكن التحقيق، فلا يمكن لنا أن نعلم بحدوثه؛ لأن من المحتمل أن يكون هناك مخالف لم نعلمه. (٣).

وأُجيبَ عن هذا: بأن علماء الأصول قد أثبتوا أن الإجماع ممكن التحقق، وأنه يمكن الاطلاع عليه، فهذه القضية قد حسمها علم أصول الفقه. (٤)

٤ـ المعقول: استدل الجمهور بالمعقول **من وجهين**:

الوجه الأول: قالوا: إنَّ القاضيَ يحتاجُ إلى البروزِ لفَصلِ الخُصوماتِ، والمرأةُ لا تصلُحُ للبروزِ، وتعجِزُ لضَعْفِها عن القيامِ بأكثَرِ الأمورِ، وهي ناقِصةٌ، والإمامةُ والقضاءُ من كَمالِ الوِلاياتِ؛ فلا يَصلُحُ لها إلَّا الكامِلُ مِنَ

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٢٩٩/٨.
(٢) انظر: لأحكام السلطانية، الماوردي، ص: ٨٣.
(٣) انظر: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، حافظ محمد أنور، ص: ٢٣٦.
(٤) انظر: النظام القضائي، د. محمد رأفت عثمان، ص:١٣٦.

الرِّجالِ. كما أن المرأة وعاطفتها أقوى من الرجل فتنفعل بسرعة، وهذا يتنافى مع القضاء الذي يحتاج إلى التدبر والروية وتحكيم العقل مع الشرع (١)

ونُوقش هذا: الأنوثة في جانب القضاء لا تصلح أن تكون علة لمنع المرأة من تولي هذا المنصب، بل الأنوثة وصف طردي لا تأثير له، إذ قد ثبت بالإجماع -ولا أقل من اتفاق الخصوم- أن الأنوثة لا تأثير لها في الولاية الخاصة، كالوصاية على اليتيم، أو الولاية على الوقف فكذلك القضاء؛ لأن مناط الحكم هو القدرة على الولاية دون نظر إلى عموم أو خصوص (٢)

وأُجيب عنه: إن الأنوثة مظنة الإخلال، أو عدم قيام المرأة قياما كاملا بأعباء الولاية، والأنوثة موجودة في كل ولاية من الولايات العامة ومنها القضاء، فلا يجوز تولية المرأة أي ولاية من الولايات، ولولا أن الإجماع قد قام على استثناء بعض الولايات فجاز أن تتولى المرأة هذه الولايات التي قام الإجماع على جوازها اكتفاء بالقدرة فيها، لقلنا أيضا بأنه لا يجوز للمرأة تولي أي نوع من الولايات، وتخصيص العلة بدليل هو الراجح عند علماء الأصول(٣)

الوجه الثاني: لو كانت المرأة تصلح لقضاء لثبت توليتها هذا المنصب في عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم، أو عصر الخلفاء الراشدين، ولكن لم

(١) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢٩٠/٢، المغني، ابن قدامة، ٣٩/٩.
(٢) انظر: نظام القضاء في الإسلام، د. إبراهيم عبد الحميد، ص:٣٦.
(٣) انظر: المرجع السابق، ص:٧٣

ينقل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولاها القضاء، أو ولاية بلد من البلاد، ولا ولاها أحد من الخلفاء الراشدين ذلك، ولا من بعدهم، ولو جاز ذلك لما خلا منه الزمان غالباً(١)

القول الثاني:

أنه لا يجوز تولية المرأة القضاة، لكن لو وليت هذا المنصب -مع إثمها وإثم من ولاها- فحكمت، فإنه ينفذ حكمها في الأمور التي يصح لها أن تشهد فيها، وهي ما عدا مسائل الحدود والقصاص **وإلى هذا القول ذهب الحنفية، غير زُفَرٍ**،(٢) فالحنفية يرون كما يرى الجمهور أن قضاء المرأة في الحدود والقصاص لا ينفذ، ولو كان ما قضت به موافقا للحق، أما إذا حكمت في غير الحدود والقصاص فينفذ حكمها، فالذكورة عند الحنفية -غير زفر- شرط جواز لا شرط صحة(٣).

(١) انظر: محاضرات في علم القضاء، د. عبد العال عطوة، ص٦٣.مُشار إليه في النظام القضائي. د. رأفت عثمان، ص: ١٤٢.

(٢) انظر: الهداية شرح بداية المهتدي كلاهما للمرغيناني مع شرح فتح القدير الكمال ابن الهمام، ٣٩٧/٧، البدائع للكاساني، ٣/٧، الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود مودود، الموصلي، ٨٤/٢. حاشية رد المحتار، محمد أمين ابن عابدين. ٤٤٠/٥.

(٣) وما تجوز فيه شهادة المرأة عند المالكية هو وهو عند المالكية القصاص والحدود والطلاق والعتق، وقد ذكر أستاذنا الدكتور رأفت عثمان في كتابه النظام القضائي ص: ٩٨ إن بعض الباحثين في الفقه الإسلامي، ومنهم: د. منير العجلاني في كتابه عبقرية الإسلام، في أصول الحكم ص٣٥٣، والدكتور محمد فاروق النبهان في كتابه نظام الحكم في الإسلام، ص٦٢٥، والدكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتابه التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، ص٥٨، ينسبون إلى الحنفية أنهم يرون جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأمور التي يصح لها أن تشهد فيها، وهي ما عدا مسائل الحدود، والقصاص، والواقع أن حقيقة مذهب الحنفية غير ذلك؛ كما يرى

واستدلوا:

١ـ بأن القضاء من باب الولاية كالشهادة، والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فتكون أهلًا للقضاء في غير الحدود والقصاص(١).

ونُوقش هذا:

بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء؛ لأن الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة، فلا بد أن تكون الأهلية في الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلًا للقضاء، كما أن الشهادة إبانة للحق دون إلزام، والقضاء إبانة للحق مع الإلزام به، فالشهادة غير مُلزمة بعكس القضاء(٢).

أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان، في كتابه النظام القضائي في الإسلام ص: ٩٩ـ ١٢٣، وجمهور الباحثين في عصرنا الحاضر ، ويعلل ـ رحمه الله تعالى ـ لذلك بقوله :لأن الحنفية كما قلنا يقفون مع جمهور العلماء في القول بعدم جواز أن تتولى المرأة القضاء، لكنهم زادوا على ذلك أن قالوا: إذا وليت المرأة القضاء مع الكراهة١ التحريمية، وأثم من ولاها فحكمت في الأمور التي تصح فيها شهادتها -وهي ما عدا مسائل الحدود والدماء- فإنه ينفذ حكمها إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله -ﷺ-، وأما إذا حكمت في الحدود والقصاص فلا ينفذ قضاؤها، حتى لو كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله -ﷺ-، وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية، انظر: د. رأفت عثمان، النظام القضائي في الإسلام ، ص:٩٩، ١٠٠.

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٣/٧، فتح القدير، ابن الهمام، ٢٥٢/٧، ابن عابدين، رد المحتار، ٣١١/٤.

(٢) انظر: نظام القضاء في الإسلام، حسن المرصفاوي، ص: ٣٤.

القول الثالث:

إنه يجوز تولية المرأة القضاء، وينفذ قضاؤها في كل ما تصح فيه شهادتها، على خلاف بينهم في القضايا التي تصح فيها شهادة المرأة، وإذا وليت لا يأثم المولي، وتكون ولايتها صحيحة، وأحكامها نافذة سواء أكان القضاء في الحدود أم في غيرها(١) **وإلى هذا القول ذهب الحسن البصري أحد كبار فقهاء التابعين، وابن حزم الظاهري، وابن القاسم من المالكية (٢)**

واستدلوا:

١ـ بقوله ﷺ: **"** ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة

(١) انظر: فالإمام ابن حزم يري أن للمرأة أن تشهد في كل شيء، وأما الإمام ابن القاسم فيرى أن شهادتها لا تصلح إلا في القضايا الأموال، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كالولادة، واستهلال المولود، وعيوب النساء التي تحت الثياب، كالرتق، وهو انسداد فرج المرأة بلحم، والقرن. وهو انسداد فرج المرأة بعظم. انظر: نظام القضاء في الإسلام للدكتور إبراهيم عبد الحميد، ص٣٢، مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان، في النظام القضائي في الإسلام، ص:١٢٤.

(٢) انظر: المحلى بالآثار، علي بن احمد بن سعيد بن حزم، الظاهري، ٥٢٧/٨، مسألة رقم: ١٨٠٤. وحاشية الدسوقي، ابن عرفة، ١٨٨/٤، نظام القضاء في الإسلام للدكتور إبراهيم عبد الحميد، ص٢٣، د. رأفت عثمان، النظام القضائي، ص: ١١٧.

عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"(١).

ووجه الدلالة من الحديث:

أن رسول الله ﷺ أثبت للمرأة في بيت زوجها القيام على إدارته ورعاية وتدبير شؤونه عامة، والراعي من يتولى رعاية غيره، والقضاء رعاية للغير، فيدل هذا على أنها أهل لسائر الولايات، فيصح توليتها القضاء(٢).

ونُوقش هذا:

بأن ما أثبته النبي ﷺ للمرأة هو الولاية الخاصة، من رعاية بيت الزوج، والقيام بتدبير شؤونه، أما القضاء فإنه رعاية وولاية عامة(٣).

٢ـ واستدلوا من القياس:

فقالوا: إن المرأة يجوز لها الإفتاء، فيجوز لها القضاء بجامع الإخبار بالحكم في الكل(٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٦/ ٢٦١١)، الحديث رقم: ٦٧١٩

(٢) انظر: المحلى، ابن حزم، ٤٢٩/٩، السلطة القضائية في الإسلام، د. شوكت عليان، ص: ١١٨.

(٣) انظر: نظام القضاء في الإسلام، د. محمد عواد، ص: ٧٥، السلطة القضائية د. محمد البكر، ص: ٣٥٨.

(٤) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ١٥٦/١٦، المغني، ابن قدامة، ٣٩/٩.

ونُوقش هذا:

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإفتاء ليس ملزمًا للمستفتي، فهو إخبار عن حكم شرعي، بخلاف القضاء، فإنه ملزم للمتقاضي، فالقضاء إخبار عن حكم شرعي مع الإلزام، وبأن القضاء ولاية بخلاف الإفتاء فإنه ليس كذلك(١).

٣ـ استدلوا بالقاعدة الفقهية:

الأصل في الأشياء الإباحة (٢)، فقالوا: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع، فكل من يصلح للفصل في الخصومة، فإنه يجوز ولايته القضاء، والمرأة قادرة على الفصل في الخصومة، وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم(٣).

ونُوقش هذا:

بأن دليل المنع قائم، وقد أخرج المرأة عن أصل الإباحة، وهذا الدليل هو ما استدل به الجمهور من الكتاب والسنة، والإجماع على عدم جواز توليتها

(١) انظر: القضاء في الإسلام، المرصفاوي، ص: ٣٣، نظام الإسلام في القضاء، د. محمد عواد، ص:٧٤.

(٢) قاعدة فقهية جليلة، أصلها قوله تعالى " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" سورة البقرة، الآية:٢٩، ومعناها كإن كل ما هو موجود في الأرض حلال للإنسان، إلا ما قام الدليل على تحريمه. انظر: السلسلة الذهبية في القواعد الفقهية، د. مراد محمود حيدر، ص: ٧٥. وما بعدها.

(٣) انظر: الحلى لابن حزم، ٥٢٨/٨، القضاء في الإسلام، المرصفاوي، ص: ٣٣، نظام الإسلام في القضاء، د. محمد عواد، ص:٧٤.

القضاء، هذا بالإضافة إلى أن المرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات على وجه الكمال للنقصان الطبعي فيها، ولانسياقها وراء العاطفة، والعوامل الطبعية التي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حمل وإرضاع، فتؤثر فيها بلا شك(١).

٤ـ كما استدلوا بالقياس، فقالوا:

إنه قد ثبت في الشرع جواز أن تكون المرأة وصية ووكيلة، فكذا يجوز أن تكون قاضية، بجامع الولاية في كل منهما(٢).

وأُجيبَ عن هذا القياس بأنه فاسد؛ لأن الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من التصرفات الشرعية (٣)، فلا ولاية فيها إلا على الأموال، والتصرفات الشرعية، شأنها شأن الوصاية، فالوصاية والوكالة من قبيل الولاية الخاصة في التصرف عن الغير -أو في ماله- نيابة عنه، بقيامه وصيًّا على مال الصغير لأبوته، أو بتعيين القاضي، أو بتوكيل الموكل له في إجراء عقد ما، بخلاف القضاء فإنه ولاية عامة، منع منه المرأة الحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٤)

(١) انظر: نظام القصاء في الإسلام، المرصفاوي، ص:٣٢.
(٢) انظر: الحلى بالآثار، ٥٢٨/٨.
(٣) انظر: الروض المربع، البهوتي،٣٩/٢، الفروع، ابن مفلح، ٢٥٨/٤.
(٤) سبق تخريجه.

سبب الخلاف:

ومَرَدُّ سَبَبِ الخلاف بين الفقهاء في تولي المرأة القضاء: إلى تعارض الأدلة، وتنوع طرق الاستدلال، والقياس بين المذاهب، فَمَنْ رَدَّ قَضَاءَ الْمَرْأَةِ شَبَّهَهُ بِقَضَاءِ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى، وَقَاسَهَا أَيْضًا عَلَى الْعَبْدِ؛ لِنُقْصَانِ حُرْمَتِهَا، وَمَنْ أَجَازَ حُكْمَهَا فِي الْأَمْوَالِ فَتَشْبِيهًا بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي الْأَمْوَالِ، وَمَنْ رَأَى حُكْمَهَا نَافِذًا فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ النَّاسِ فَحُكْمُهُ جَائِزٌ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ مِنَ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى(١).

الترجيح:

بعد عرض الأدلة والمناقشات، نرى ـ والله أعلم ـ أن الراجح، هو رأي الجمهور القائلين باشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراض، وهذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها، وعليه العمل في عهد الرسالة، وعهد الصحابة، والتابعين، وهذه العصور هي الأقرب لعصر الوحي، وأصحابها بلا شك أدرى بأسرار التشريع، ومقصود الشرع. إلا إنه إذا وقع في بعض الأقطار الإسلامية تولي المرأة القضاء، فيجوز -والله أعلم- التقاضي لها فيما دون الحدود والقصاص، كما هو رأي الأحناف؛

(١) انظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ٢٤٣/٤،

لئلا تتعطل مصالح الناس، فإنهم إن لم يفعلوا ما سَارَتْ، أمورهم؛ وما تحصلوا على مصالحهم، لكن يمكن أن نقول إن الإلزام بعد حكم القاضي إنما جاء من الشرع، لا من القاضي وواسطة التنفيذ هنا هي الحاكم. والله أعلم.

٥ـ **الشرط الخامس: العدالة**: ليس المقصود بالعدالة هنا أن يكون الشخص عادلا في أحكامه، كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ الذي ليس له دراية بأساليب الفقهاء، بل لهذه الكلمة معنى آخر يريده العلماء، (١) فهم يقصدون من العدالة أنها: ملكة أي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة(٢)

والتقوى ضابطها: امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات من الكبائر ظاهراً، وباطناً من شرك أو فسق أو بدعة.

والمروءة ضابطها: آداب نفسية تحمل صاحبها على التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وترجع معرفتها إلى العرف. (٣)

(١) انظر: النظام القضائي، د. رأفت عثمان، ص:١٥٢.
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للعلامة الآمدي، ٦٩/٢.
(٣) انظر: بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني،٦٩٦/٩

وعرف بعض الفقهاء العدالة بأنها:

"الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه." (١) فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالمًا من الهوى؛ فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال وانحل عصام التقوى؛ فقال ما يهواه، وإبقاء هذا الوصف هو المقصود من العدل(٢).

والعدالة نقيضها الفسق، والعدل نقيضه الفاسق، وهل يشترط في القاضي العدالة؟ بمعنى أن القاضي إذا كان فاسقا فهل يبطل قضاؤه ويكون فسقه سبباً لعزلة؟ **لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:**

القول الأول:

إن العدالة شرط في تولي القضاء، فلا يجوز تولية فاسق ولا من كان مرفوض الشهادة لعدم الوثوق بقولهما، فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ، فلأن لا يكون قاضياً أولى، فلا تصح ولاية الفاسق القضاء، ولا ينفذ حكمه حتى لو صادف الحق، **وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية في رواية عندهم وهو مذهب الشيعة الإمامية، والزيدية(٣)**

(١) انظر: الأشباه والنظائر، لعبد الوهاب بن علي السبكي، ٤٥٠/١.
(٢) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٣) انظر: فتح القدير لابن الهمام، ج٧، ص٢٥٣، مواهب الجليل للحطاب، ج٦، ص٨٧، المغني، ابن قدامة، ٩٣/١٠، ونظام القضاء في الإسلام، ص١٦، وشرائع الإسلام للحلي، ج٤،

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة:

إن الآية الكريمة قد أمرت بالتثبت والتبين من قول الفاسق، فلا يُقبل قوله، ولا يصح في النظر الشرعي، أن يكون القاضي ممن لا يُقبل قوله. ولأنه من غير المقبول أن نُفتش في كل حكم للفاسق حتى نستبين وجه الحق فيه(٢).

٢ـ قياس القاضي الفاسق على الشاهد الفاسق، بجامع الفسق في كل منهما، فكما لا تقبل شهادة الشاهد، فكذا لا يجوز تعيين القاضي الفاسق(٣).

القول الثاني:

إن العدالة ليست شرطاً في تولي القضاء، وإنما هي شرط كمال، فلو عين الإمام قاضياً صح قضاؤه للحاجة، لكن ينبغي ألا يعين، كما في الشهادة، ويأثم من يعينه للقضاء ومن يقبل شهادته، **وإلى هذا ذهب الحنفية وأبو بكر الأصم**(٤).

ص٦٧، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي، ج١٨، ص٢. والبحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى، ج٦، ص١١٩.

(١) من الآية:٦ من سورة الحجرات.

(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٩٣/١٠.

(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.

(٤) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٣/٧، شرح العناية على الهداية لمحمد محمود البابرتي مطبوع مع فتح القدير،٥٤/٧.

واستدلوا:

بقول النبي ﷺ "لعلَّكم سَتدرِكونَ أقوامًا يصلُّونَ الصَّلاةَ لغيرِ وقتِها فإن أدرَكتُموهم فصلُّوا الصَّلاةَ لوقتِها وصلُّوا معَهم واجعلوها سُبحَةً" (١)

ووجه الاستدلال:

إن النبي ﷺ ، قد أخبر بوقوع أمراء فسقة، وأمر بالصلة خلفهم، وهذا معناه جواز كون الأمير فاسقاً، فكذلك يجوز أن يكون القاضي فاسقاً قياساً على الأمير (٢).

ونُوقش هذا:

بأن الحديث الشريف قد أخبر بوقوع كونهم أمراء، لا بمشروعيته، والنزاع في صحة توليته، لا في وجودها. (٣)

الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين، ومناقشتها، يظهر لنا ـ والله أعلم ـ رجحان قول الجمهور، باشتراط العدالة في القاضي، لقوة مأخذها، وخلوها عن المُعارض، ولأن اشتراط العدالة في صحة التصرفات التي تشترط فيها العدالة

(١) انظر: وأخرجه مسلم (٥٣٤)
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٩٣/١٠.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٩٣/١٠.

إنما هو لتحقيق المصلحة للناس، لحصول الضبط بها عن الخيانة، والكذب، والتقصير؛ لأن الفاسق لا يتحقق عنده الوازع الديني فلا يوثق به(١) لكن إذا لم يوجد من تتوافر فيه شروط العدالة لكي نوليه القضاء أقيم أصلح الموجودين وأقلهم فجورا، وهو ما يتبع أيضًا في مجال الشهادة؛ لئلا تضيع مصالح الناس؛ ولأن التكليف بالأحكام الشرعية مشروط بالإمكان(٢)

٦ـ الشرط السادس: سلامة الحواس: يقصد الفقهاء من شرط سلامة الحواس في القاضي: أن يكون سميعاً، ناطقاً، بصيراً، فالسمع صفة يستلزمها الجلوس للحكم بين الخصوم، إذ الصمم صفة تعوق القاضي عن الحكم، وكذا البصر، فإن العمى يؤثر حكم القاضي في القضايا التي تحتاج إلى مشاهدة الوقائع، وكذا النطق، إذ النطق تتحقق به مشافهة الخصوم وسؤالهم، وإذن فسلامة الحواس تساعد القاضي على إصدار حكمه بطريقة لا يشوبها شك في صحة الحكم. ولكن السؤال الذي يطرحُ نفسه: **هل اشتراط سلامة الحواس محل اتفاق بين الفقهاء أم فيه خلاف فقهي؟**

(١) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٢) انظر: فتح القدير،٢٥٢/٧، ومواهب الجليل، للحطاب، ٩٠/٦.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على ضرورة توافر الإسلام والتكليف في القاضي، **واختلفوا في اشتراط سلامة الحواس الظاهرة، كالسمع والبصر والكلام على قولين:**

القول الأول:

إن القاضي يُشترط لتوليه القضاء سلامة الحواس الظاهرة فيه، كالسمع والبصر والكلام، وهذا شرط لصحة توليه ونفاذ قضائه. **وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(١)**

القول الثاني:

إن السمع والبصر والكلام ليست شرطاً في صحة ولاية القاضي ابتداء، ولا في صحة دوامها، بل هي واجب غير شرط في الابتداء والدوام، ومعنى ذلك: إن صفات السمع والبصر والكلام، هي شرط لجواز تولى القضاء، وهي شرط أيضاً لاستمرار ولاية القاضي وبقائه في منصبه، لكن إذا فُرض أنه قد تم

(١) انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، ٢٤٣/٤، المنتقى، شرح موطأ مالك، للباجي، ج٥، ص١٨٣. الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص٣٨٧. المغني، ابن قدامة، ٩٣/١٠.

تعيين القاضي مع فقده لبعض هذه الصفات، فإن القضايا التي حكم فيها. **وإلى هذا القول، ذهب الشيخ الدردير، وابن عرفه الدسوقي من المالكية.** (١)

والفرق بين رأي الجمهور وبين هذا الرأي، هو في إمضاء الأحكام التي حكم فيها القاضي الذي فقد حاسة من حواس السمع أو البصر أو الكلام، فالجمهور يقولون ببطلان قضائه في القضايا التي فصل فيها، بينا الشيخ الدردير وابن عرفة يقولان بإنفاذ هذه الأحكام.

٧ـ **الشرط السابع: الاجتهاد:** من الشروط الواجب توافرها لتولي القضاء عند الفقهاء: أن يكون المتقدم للقضاء من أهل الاجتهاد.

والاجتهاد المقصود هنا: هو: تحقق الكفاية العلمية للقاضي، بحيث يكون أهلاً لمعرفة الأحكام الشرعية، ومواطن الاستدلال على الأحكام، حتى لا يقضي للناس على جهل. **ولكن هل هذا الشرط محل اتفاق أم محل اختلاف بين الفقهاء؟**

(١) انظر: الشرح الصغير للدردير،١٩١/٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،١٣٠/٤.

لقد اختلف الفقهاء حول ضرورة توافر شرط الاجتهاد في القاضي **على قولين:**

القول الأول:

إن الاجتهاد شرط في تولي القضاء، فلابد أن يكون للقاضي أهلية استنباط الأحكام من الأدلة، **وبناء على هذا:** فلو ولي المقلد (١) أو الجاهل (٢)لم يصح تقليده وأحكامه غير نافذة ولو صادفت الحق، إذ لا ولاية له فإن لم يوجد مجتهد، فهذا هو مكان قضاء الضرورة، فالاجتهاد شرط صحة وجواز، إذ لابد من تحقق قدرة القاضي على استنباط الأحكام. **وإليه ذهب: المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية (٣)، وهو مذهب الشيعة الإمامية، والشيعة الزيدية. (٤)**

(١) المقلد: هو من حفظ مذهب إمامه، لكنه غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته. انظر اللباب في شرح الكتاب، الميداني، ٤ / ٧٨.

(٢) والمقصود بالجاهل: من لا دراية له بأصول الاجتهاد والاستنباط، وليس الرجل العامي، الذي لا علم له مطلقاً، فهذا لا تصح توليته القضاء بالإجماع. انظر: ابن عابدين، رد المحتار، ٣٦١/٥.

(٣) ومنهم الإمام القدوري، اللباب في شرح الكتاب، الميداني، ٤ / ٧٨. قال في الهداية: والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط أولوية. فأما تقلي الجاهل أي غير المجتهد فصحيح عندنا؛ لأنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره.

(٤) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ٣٦٠/٥- ٣٦١، الاختيار، ابن مودود، ٨٣/٢، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ص: ٢٦، ٢٧، شرح الزرقاني على الموطأ ٢٧٢/٧، القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ص:١٩٥، الأحكام السلطانية، الماوردي ص: ٨٥، البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحي بن أبي الخير العمراني، ١٧/١٣، نهاية المحتاج، الرملي، ٢٣٨/٨، الأحكام

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (١)

وجه الاستدلال: إن الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول معناه الرد إلى سنته ولا يتأتى الرد إلى الكتاب والسنة إلا من المجتهد فلا بد أن يكون من يفصل في النزاع مجتهدا(٢)

٢ـ كما استدلوا بقوله تعالى (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٣)

وجه الاستدلال: إن القضاء بالحق والعدل، لا يتحقق على وجه الكمال إلا من المجتهد؛ لأنه هو الذي يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي الذي هو الحق؛ لأن الجاهل لا يعرف الحق ولو قيل: إنه يسأل غيره، فإن الأمر سوف يختلط عليه؛ لأنه لا يستطيع تحديد ما يسأل فيه أو موضوع السؤال كما أنه لا

السلطانية لأبي يعلى، ص ٦١ - ٦٢، المغني، ابن قدامة، ١٤/١٤، شرائع الإسلام الحلي، ٦٧/٤، البحر الزخار، ١١٩/٦.

(١) من الآية:٥٩ من سورة النساء.

(٢) انظر:حاشية الدسوقي،١٢٩/٤، تبصرة الحكام، لابن فرحون، بهامش فتح العلي المالك،٧٨/١.

(٣) من الآية: ٤٢، من سورة النساء.

يعرف من يسأل ومن لا يسأل والمقلد لا يعرف الحق كذلك؛ لأن الحق لا يعرف إلا بدليل(١).

٣ـ بقوله ﷺ " حديث معاذ بن جَبَلٍ -رضى الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَه إلى اليَمَنِ قال: "كيْفَ تَقْضي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ؟ " قال: أَقْضِي بِكِتَابِ الله قال: "فَإِنْ لم تَجِدْ في كِتَابِ الله؟ " قال: فَبِسُنَّةِ رسول الله ﷺ قال: "فَإِنْ لم تَجِدْ في سُنَّةِ رسول الله ولا في كتَابِ الله؟ " قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلُو، فَضَرَبَ رسول الله ﷺ صَدْرَهُ وقَالَ: "الحَمْدُ لله الذي وَفَّقَ رَسُولَ رسول الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله"(٢)

وجه الاستدلال: واضح في أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدًا، إذ إقرار الرسول لمعاذ على الاجتهاد بيان للصفة المعتبرة في القاضي دون غيرها إذ لو كان التقليد والحكم بقول الغير جائزًا لبينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -،

(١) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك،٥ الباجي، /١٨٣، سبل السلام، الصنعاني، ١١٧/١.
(٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء،٣٠٣/٣، برقم (٣٥٩٢)، قال التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من هذا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، قال شعيب الأرنؤوط: الحديث ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، ١/ ٢٠٢، انظر: مسند الإمام أحمد ٣٦/ ٣٣٣. تحقيق شعيب الأرنؤوط.

أو قال له: "فإن لم يمكنك ذلك"؛ لأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز. (١)

٤ـ القياس: حيث قاسوا القاضي على المفتي، بجامع القدرة على استنباط الأحكام في كل منهما، فكما لا يجوز للعامي الإفتاء، فلا يجوز له القضاء من باب أولى. (٢)

القول الثاني:

إن الاجتهاد ليس بشرط في تولي القضاء، فينعقد القضاء لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد مع وجود من بلغها بشرط أن يكون ذا علم ونباهة، وفهم بما يتولى أمره، وكذا يجوز تولية المقلد بشرط أن يتقيد بمذهب إمامه، ويستعين به في معرفة الأحكام. فالاجتهاد شرط أولوية واختيار، لا شرط صحة، **وبهذا الرأي قال أبو حنيفة، وبعض المالكية (٣)**

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (٤)

(١) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ص:١٤.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٥/١٤.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٣/٧، شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، ٢٣/٨، التجريد، أحمد بن محمد القدوري، ٦٥٢٩/١٢. مواهب الجليل، الحطاب، ٩٣/٦.
(٤) من الآية:٤٣، من سورة النحل.

وجه الاستدلال: إن الآية الكريمة قد حَثَّ على سؤال أهل العلم، عند عدم المعرفة، والنص عام، يدخل فيه القاضي وغيره. فإذا سأل القاضي المقلد عالماً فأفتاه، فحكم بقوله، فقد أدى ما عليه؛ لأن فصل القضاء فرضٌ تَوَجَّب عليه فعلُهُ، فإذا فصل في القضاء بفتوى غيره، فقد أدى الواجب عليه(١).

ونُوقش هذا: بأن المقلد جاهل بطريق العلم، وليس لديه علم يقضي به، وهو لا يعلم أقضي بالحق أم قضى بغيره، وهو جاهل أيضاً لا يستطيع معرفة ما يقضي به، إذ قد يُفتى خطأ، فيضل في الحكم، فتولية المقلد والجاهل القضاء، إنما هي ذريعة إلى الحكم بالباطل، وكل ما أفضى إلى الممنوع، فهو ممنوع (٢).

٢ـ كما استدلوا: بحديث الإمام علي -رضى الله عنه-: قال" بَعثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليَمنِ قاضيًا، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ! ترسِلُني وأَنا حديثُ السِّنِّ، ولا عِلمَ لي بالقضاءِ، فقالَ: إنَّ اللهَ سيَهْدي قلبَكَ، ويثبِّتُ لسانَكَ" (٣).

وجه الاستدلال: إن النبي ﷺ أرسل سيدنا علي رضي الله عنه قاضياً، ولم يشترط عليه الاجتهاد(٤).

(١) انظر: روضة القضاة، ابن السمناني، ٦٠/١، فتح القدير، ابن الهمام، ٢٣٨/٧.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ١٣٢/١، المغنى، ابن قدامة، ١٥/١٤.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه برقم: ٣٥٨٢ واللفظ له. قال محققه: حديث حسن.
(٤) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٣/٧.

ونوُقش هذا:

بأن النبي ﷺ دعا لعلي بأن يثبت الله قلبه، ويهدي لسانه، فإن كان بدعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رزقه الله أهلية الاجتهاد فلا إشكال، وإلا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد، فعلي -رضي الله عنه- كان يحكم وقد تحققت فيه الصفة العلمية التي تؤهله لذلك، وهذا لا يثبت في غير علي -رضي الله تعالى عنه (١).

٣ـ كما استدلوا بالمعقول، فقالوا: إن تقليد المقلد أو حتى الجاهل يحصل به الغرض من القضاء، وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات وإيصال الحق إلى مستحقه، إذ يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى قوله ورأيه وفتواه(٢).

ونُوقش هذا:

بأن الغرض من نصب القاضي، وتقليده ليس القضاء على أي وجه كان، وإنما القضاء على وجه الكمال، وهذا لا يتحقق إلا إذا توفرت في القاضي صفة الاجتهاد (٣)

(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٢٥٦/٧.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٣/٧.
(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٢٤٤/٧.

سبب الخلاف:

وَمَردُّ الخلاف بين الفقهاء في هذا المسألة إلى التنازع بين "تحقيق الكمال المطلوب في القاضي لدرء الأحكام الباطلة" وبين "ضرورة تسيير مصالح الناس وتعذر وجود المجتهد في كل مصر ووقت، فمن رأى تحقيق الكمال المطلوب والغرض المقصود من تولى القضاء، وهو إقامة العدل، والحكم بالقسط، رأى اشتراط الاجتهاد في القاضي، وهؤلاء هم الجمهور، ومن رأى إن توافر شرط الاجتهاد مُتَعَذّرُ لخلو الزمان عن المجتهد الحق، قال بجواز تقليد المقلد والجاهل بالأحكام للقضاء، للضرورة، ويمكنه أن يسأل غيره. كما يرجع سبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، إلى اعتبار الاجتهاد شرط صحة لنفاذ الأحكام، وشرط جواز لتقليد القضاء، فالجمهور يرون ذلك، والحنفية لا يرون الاجتهاد شرطا لتولي القضاء، بل هو شرط أولوية وكمال وليس بشرط صحة.

الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين، ومناقشتها، فإن الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ رجحان رأي القائلين باشتراط الاجتهاد عند توفره وإمكانية شغل مناصب القضاء من المجتهدين. لأن الاجتهاد أعونُ للقاضي على إصابة الحق، وتحقيق

موازين القسط، وتحقيق إقامة الشرع على الواقع، وهذا هو المقصد من تولي القضاء، أما إذا لم يوجد المجتهد حقيقةً أو حكما، فإن الفقهاء متفقون على صحة تقليد المقلد أو الإلزام بالحكم بمذهب معين، وذلك للضرورة عند الجمهور، ولجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل عند الفريق الثاني، لكن لا يلزم من ذلك جواز تولية القاضي الجاهل بناءً على أنه يمكنه الحكم بفتوى غيره؛ لأنه وإن عرف الحكم بفتوى غيره؛ إلا أنه لا يعرف إيقاعه وتطبيقه على موضوع القضية المعروضة عليه؛ لأن ذلك يحتاج إلى زيادة نظر لا تتوفر عنده. وعليه: فأقل درجات المقلد، هي التأهل في العلم والفهم ويستطيع استخراج الحكم من كتب المذهب.

وينبغي أن نعلم أن مُراد الحنفية بالجاهل في بعض كتبهم: هو ما يقابل المجتهد، فلا يقصدون بالجاهل العامي المحض كما قد يتوهم، وإنما يقصدون الذي يكون على علم ولكنه مقلد لإمام معين. على أن الاجتهاد في زماننا هذا أيسر مما كان في أي عصر مضى فقد جمعت العلوم وحررت ودونت ولكن المشكلة أين الهمم والنفوس العالية.والله أعلم.

المبحث الثالث
جهة تعيين القاضي

اتفق الفقهاء(١) على أن الذي يملك ولاية تقليد القضاء هو الإِمام؛ لأن هذه الولاية من المصالح العامة التي يختص بها الإِمام بعموم ولايته؛ إذ هو المستخلف على الأمة والقائم بأمرها والمتكلم بمصلحتها والمسئول عنها، ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك، ولا خلاف أن ذلك مُتعينٌ عليه عند الحاجة وله أن يُنيبَ غيره في ذلك، وله أن يتولاه بنفسه كما كان يفعله رسول الله ﷺ، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده كانوا يعينون القضاة، وفي عهد الدولة الأموية فوض معظم الخلفاء أمراء الولايات في أمر اختيار القضاة، ثم لما قامت الدولة العباسية استرد أبو جعفر المنصور حق تعيين الخلفاء للقضاة، فولى عبد الله بن لهيعة الحضرمي على مصر سنة ١٥٥هـ، فصار القاضي يعين من قبل الخليفة لا من قبل الوالي(٢)

(١) انظر: روضة القضاة ابن السمناني،٦١/١، وما بعدها، معين الحكام، الطرابلسي، ص:١٠، أدب القاضي للماوردي١/ ١٣٧،١٣٩ كتاب أدب القضاء ص: ٢٨، تبصرة الحكام ابن فرحون، ١/ ٢١، المغني، ابن قدامة،١٠/ ١٥٣، الكافي في فقه ابن حنبل، موفق الدين،ابن قدامة، ٤٣٥/٤، كشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٢٨٨.

(٢) انظر: القضاء في الإسلام بوجه عام، وفي العهد الإسلامي في مصر بوجه خاص، إلى سنة ٣٥٨هـ، لعطية مصطفى مشرفة، الطبعة الأولى.

ولا مانع شرعًا أن يعين ولي أمر المسلمين قاضيًا ويعطيه الصلاحية في مجال معين، ويعين قاضيًا لمجال آخر لتوزيع المهام وتعيين الاختصاصات وتسهيل القيام بهذه المهمة العظيمة، وهي خلافة الله تعالى في أرضه والحكم بشرعه في خلقه.

وإذا ثبت هذا الحق للإمام، فله أن يفوض غيره من الوزراء أو من غيرهم في اختيار القاضي وعزله، ووظيفة قاضي القضاة، هي تطبيق عملي في مسألة استنابة الإمام لأحد أعوانه في تولية القضاء، وأول من تقلدها في الدولة الإسلامية هو " أبو يوسف" صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان من اختصاص شاغلها تقليد من يصلح لمنصب القضاء، في أنحاء البلاد التي تخضع للخلافة، وله أيضًا حق عزله إذا أصبح مستحقا للعزل، ومن حقه أن يتفقد أحوال القضاة، فينظر في أقضيتهم، ويراجع أحكامهم، ويتتبع أخبارهم وسيرتهم بين الناس، بل كان له الحق في نقض أحكامهم(١).

(١) انظر: القضاء في الإسلام، للأستاذ محمد سلام مدكور، ص٤٦

المبحث الرابع

ولاية القاضي واختصاصاته

إنَّ ولاية القاضي: هي تفويض من ولي الأمر؛ لشخص مؤهل؛ للفصل في الخصومات وإصابة الحقوق، وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (١).

تأصيل ولاية القاضي: يَسْتَنَدُ التأصيل الشرعي لهذه الولاية، إلى الأدلة القطعية من القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما الكتاب العزيزفمنه آيات كثيرة:

* منها قوله تعالى (إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (٢)

* وقوله تعالى:(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(٣)

ووجه الاستدلال من النصين السابقين ظاهر، حيث أمر الله تعالى رسوله ﷺ وجماعة المسلمين عامة ــ بما فيهم القضاة ـ أن يحكموا بين الناس بالعدل الذي أنزله تعالى، وفي هذا ما يدل دلالة ظاهرة على مشروعية ولاية القضاء(٤).

(١) انظر: نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٦٥.
(٢) من الآية: ٥٨، من سورة النساء.
(٣) من الآية:٤٢، من سورة المائدة.
(٤) انظر: تفسير الطبري، محمد بن جرير، الآية: ٤٢ من سورة المائدة.

وأما السنة المطهرة:

- فمنها: قوله ﷺ "إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فلَه أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثُمَّ أخطَأَ فلَه أجرٌ" (١)

ووجه الاستدلال: إن النبي ﷺ أخبر عن حكم القاضي إذا اجتهد، وإذا أخطأ، وأنه مأجورٌ في الحلين، وهذا دليل على جواز تولي القضاء بلا ريب.

- كما أن النبي ﷺ باشر القضاء بنفسه، وولّى الصحابة، كبعثه علي بن أبي طالب (٢)ومعاذ بن جبل (٣) رضي الله عنهما إلى اليمن للقضاء. وهذا مما يقطع بمشروعية ولاية القضاء.

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة منذ عصر الصحابة على تعيين القضاة وأهمية وجودهم لاستقرار الدولة. قال الماوردي "وعَقدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ بالإجماع" (٤)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم: ٧٣٥٢.
(٢) حديث بعث الإمام علي رضي الله عنه إلى اليمن، أخرجه أبو داود في سننه، برقم: ٣٥٨٢ واللفظ له، قال المحقق: حديث صحيح.
(٣) حديث بعث معاذ إلى اليمن، أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: ١٤٦٩، ولفظه " قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ: إنَّكَ سَتَأتي قَومًا أهلَ كِتابٍ، فإذا جِئتَهم فادعُهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك، فإيَّاكَ وكَرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المَظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حِجابٌ."
(٤) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:١٥.

وأما المعقول:

فلأن مصالح العباد في دينهم ودنياهم لا تستقيم ولا تصلح إلا بالقضاء، وفي تعطيل ذلك، ضياع مصالحهم، وهو ما تأباه قواعد الشرع الحنيف، قال الطيبي" إن الراعي ليس مطلوبًا لذاته، وإنما أُقيم لحفظِ ما استرعاه المالك، فينبغي ألا يتصرف إلَّا بما أَذِنَ الشارع فيه"(١)

اختصاصات القاضي:

إن تولية القضاء عند الفقهاء، قد تكون ولاية عامة، فيولى الإمام القاضي النظر في جميع أنواع القضايا، وقد تكون ولاية خاصة، فيجوز للإمام أن يخصص ولاية القاضي بالنظر في قضايا بلد معين، وهذا ما يُسمى بالاختصاص المكاني، وقد يُخول الإمام القاضي النظر في قضايا الجنايات، أو المعاملات، أو نحو هذا، وهذا ما يُسمى بالاختصاص النوعي، وقد يخول الإمام القاضي النظر في أيام معينة، وهذا ما يُسمى بالاختصاص الزماني. ونحو هذا من أوجه تخصيص القضاء (٢).

(١) انظر: السياسة الشرعية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ص:٢١.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي ١١٩- ١٢٧.

قال الماوردي:

" وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَامَّ النَّظَرِ خَاصَّ الْعَمَلِ، فَيُقَلَّدُ النَّظَرَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ أَوْ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهُ، فَيَنْفُذُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ فِي الْجَانِبِ الَّذِي قَلَّدَهُ، وَالْمَحَلَّةِ الَّتِي عُيِّنَتْ لَهُ،" (١)

والأصل في ذلك:

إن صلاحيات القاضي لا تتعين من جهة الشرع، وإنما بموجب ألفاظ التولية والأحوال والعرف (٢).

فإذا كانت ولاية القاضي عامة: فإنها تشمل عشرة أمور كما نص على ذلك العلامة الماوردي، حيث قال:

" وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى **عَشَرَةِ أَحْكَامٍ:**

أَحَدُهَا: فَصْلٌ فِي الْمُنَازَعَاتِ، وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ، إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ، أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ.

وَالثَّانِي: اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا، وَإِيصَالُهَا إلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إقْرَارٌ، أَوْ بَيِّنَةٌ.

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:١٢٣.
(٢) انظر: الاختيارات الفقهية، أحمد بن بد الحليم بن تيمية، ص: ٣٣٢.

وَالثَّالِثُ: ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا.

وَالرَّابِعُ: النَّظَرُ فِي الْأَوْقَاتِ بِحِفْظِ أُصُولِهَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا، وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا وَصَرْفِهَا فِي سَبِيلِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ فِيهَا رَاعَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْخَاصِّ فِيهَا إِنْ عَمَّتْ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى الْعُمُومِ وَإِنْ خُصَّتْ.

وَالْخَامِسُ: تَنْفِيذُ الْوَصَايَا عَلَى شُرُوطِ الْمُوصِي فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَلَمْ يَحْظُرْهُ، وَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا بِالْإِقْبَاضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْصُوفِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا أَنْ يَتَعَيَّنَ مُسْتَحِقُّوهَا بِالِاجْتِهَادِ وَيَمْلِكُوا بِالْإِقْبَاضِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَصِيٌّ رَاعَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ.

وَالسَّادِسُ: تَزْوِيجُ الْأَيَامَى بِالْأَكْفَاءِ إِذَا عَدِمْنَ الْأَوْلِيَاءَ وَدُعِينَ إِلَى النِّكَاحِ، وَلَا يَجْعَلُهُ أَبُو حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِنْ حُقُوقِ وِلَايَتِهِ؛ لِتَجْوِيزِهِ تُفْرَدُ الْأَيِّمُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ.

وَالسَّابِعُ: إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهَّ تَعَالَى تَفَرَّدَ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ طَالِبٍ إذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ.

وَالثَّامِنُ: النَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ مِنَ الْكَفِّ عَنِ التَّعَدِّي فِي الطُّرُقَاتِ وَالْأَفْنِيَةِ، وَإِخْرَاجِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْأَجْنِحَةِ وَالْأَبْنِيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ خَصْمٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِيهَا إلَّا بِحُضُورِ خَصْمٍ مُسْتَعْدٍ، وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ اللهَّ تَعَالَى الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْتَعْدِي وَغَيْرُ الْمُسْتَعْدِي، فَكَانَ تَفَرُّدُ الْوِلَايَةِ بِهَا أَخَصَّ.

وَالتَّاسِعُ: تَصَفُّحُ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَاخْتِيَارُ النَّائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إقْرَارِهِمْ، وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ، مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَصَرْفِهِمْ، وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِمْ مَعَ ظُهُورِ الْجُرْحِ وَالْخِيَانَةِ.

وَالْعَاشِرُ: التَّسْوِيَةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمَشْرُوفِ وَالشَّرِيفِ، وَلَا يَتَّبِعْ هَوَاهُ فِي تَقْصِيرِ الْمُحِقِّ أَوْ مُمَايَلَةِ مُبْطِلٍ"(١)

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:١١٩- ١٢١، بتصرف.

كل هذا مع التنبيه على أن الاختصاص الأصيل للقاضي يكون في فصل الخصومات وقطع المنازعات، وهذا ما يراه جمهور الفقهاء، ويتضح من استعراض تعريفاتهم للقضاء في كتب المذاهب الفقهية(١).

وقد وضع العلامة القرافي ضابطا للعمل في المسائل التي يدخلها الحكم القضائي، فيقول عن اختصاص ولاية القضاء" وهذه الولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره"(٢)

وفي هذا المعنى يقول ابن رشد "وأما فيما يحكم، فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق، كان حق الله أو حقاً للآدميين" (٣)

(١) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ٣٥١/٥، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن فرحون، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد أحمد عليش،١٢/١، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٢٥٧/٦، الروض المربع، البهوتي، ٤٩/١.

(٢) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، أحمد بن إدريس القرافي، ص:١٦٦، وفي هذا المعنى: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ص:١٢.

(٣) انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، ٢٤٤/٤،

المبحث الخامس

آداب القاضي

إن آداب القاضي في الفقه الإسلامي هي: مجموعة الأخلاق والصفات والأحكام التي يجب أو يسن للقاضي الالتزام بها لضمان تحقيق العدالة ومنع الظلم (١)، **وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام**:

آداب متعلقة بشخص القاضي وصفاته، وآداب متعلقة بنزاهته وحفظ كرامته، وآداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أولًا: الآداب المتعلقة بشخص القاضي وصفاته:

١ـ أن يكون تقيًّا ورعاً، يخشى الحرام، ويتوقَّاه، فيعالج نفسه عَلَى آدَابِ الشَّرْعِ وَحِفْظِ المروءَةِ وَعُلُوِّ الهِمَّةِ، وَيَتَوَقَّى مَا يَشِينُهُ فِي دِينِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ، أَوْ يَحُطُّهُ فِي مَنْصِبِهِ وَهِمَّتِهِ(٢).

٢ـ أَلَا يَجْعَلُ حَظَّهُ مِنْ الوِلَايَةِ المُبَاهَاةَ بِالرِّيَاسَةِ وَإِنْفَاذَ الأَوَامِرِ وَالتَّلَذُّذَ بِالمَطَاعِمِ وَالمَلَابِسِ وَالمَسَاكِنِ فَيَكُونُ مِمَّنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا)(١).

(١) انظر: نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي، ص: ١٣٢.
(٢) انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٣١/١ وما بعدها.

٣ـ أَنْ يَكُونَ جَمِيلَ الهَيْئَةِ ظَاهِرَ الأُبَّهَةِ، وَقُورَ المِشْيَةِ وَالجِلسَةِ حَسَنَ النُّطْقِ وَالصَّمْتِ مُحترِزًا في كَلَامِهِ مِنْ الفُضُولِ وَمَا لَا حَاجَةَ بِهِ(٢).

٤ـ أن يكون قَوِيًّا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ، لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، لا يَطْمَعُ القَوِيُّ في بَاطِلِهِ، وَلَا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ(٣).

٥ـ أَن كُونَ حَلِيمًا، مُتَأَنِّيًا، ذَا فِطْنَةٍ وَتَيقُّظٍ، لا يُؤْتَى مِنْ غَفْلَةٍ، وَلَا يُخْدَعُ لِغِرَّةٍ(٤).

ثانيًا: الآداب المتعلقة بنزاهة القاضي وحفظ كرامته:

نص الفقهاء على مجموعة من الصفات التي تحفظ كرامة ونزاهة القاضي، ومنها:

١ـ التنزه عن طلب الحوائج: بحيث لا يطلب من الناس شيئاً، حتى ولو كان يسيراً، كالماعون، ووسيلة التنقل، وأدوات الطعام، مما يُستخدم في البيوت، ونحو هذا، ليكون موفور الكرامة محفوظًا من ألسنة الناس ملحوظًا بعين الإجلال والإكرام بعيدًا عن استغلال الآخرين(٥).

(١) من الآية: ٢٠، من سورة الأحقاف.
(٢) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ٤٥/١.
(٣) انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٣٢/١ و معين الحكام، الطرابلسي، ٤٦/١
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٧/١٤.
(٥) انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ص:٣٤.

٢ـ تحريم قبول الهدية: يُفَرَّقُ الفقهاء في حكم قبول القاضي للهدية بين حالين:

الحال الأولى: ألا تكون هناك عادة قد جرت بين القاضي وبين المُهدي له بذلك:

اتفق الفقهاء على أنه يحرُمُ على القاضي أن يَقبَلَ هَديَّةَ مَن لم تَجرِ له عادةٌ بالهَديَّةِ إليه قَبلَ الوِلايةِ، وكانَت له خُصومةٌ عِندَه(١).

واستدلوا:

١- بما رواه أبو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قال اسْتَعْمَلَ رسول الله ﷺ رَجُلًا من الأَسْدِ يُقَالُ له: ابن اللُّتْبِيَّةِ (قال عَمْرٌو وبن أبي عُمَرَ: على الصَّدَقَةِ) فلما قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ، وَهَذَا لي، أُهْدِيَ لي، قال: فَقَامَ رسول الله ﷺ على المِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عليه، وقال: "ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فيقول: هذا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لي، أَفلَا قَعَدَ في بَيْتِ أبيه أو في بَيْتِ أُمِّهِ حتى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إليه أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده، لَا يَنَالُ أحدٌ مِنكُمْ منها شيئًا إلا جاء بِهِ يوم القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على عُنُقِهِ،

(١) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ، ٣٠٥/٦، حاشية ابن عابدين، ٣٧٢/٥. مواهب الجليل للحطاب،١٢٠/٦، الشرح الكبير للدردير ، ١٤٠/٤ ،العزيز شرح الوجيز، للرافعي ٤٦٧/١٢، مغني المحتاج للشربيني ، ٢٨٧/٦. الإقناع للحجاوي ، ٣٨١/٤، منتهى الإرادات لابن النجار ، ٢٧٢/٥.

بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أو بقَرَةٌ لها خُوَارٌ، أو شَاةٌ تَيْعِرُ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه حتى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قال: "اللَّهم هل بَلَّغْتُ" ثلاثًا(١)

وجه الاستدلال: دَلَّ هذا الحَديثُ على تَحريمِ قَبولِ الهَديَّةِ التي يَكونُ سَبَبُها الوِلايةَ، وذلك مُستَفادٌ مِن تَعليلِه -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- المَنعَ بذلك. (٢)

٢ـ ولأن المهدي يقصد بها في الغالب استمالة القاضي إليه ليكون الحكم في جانبه فتشبه الرشوة حينئذ لقوله ﷺ "هدايا العمال غلول" (٣).

٣ـ قياسُ الهَديَّةِ على الرِّشوةِ في مَنعِ قَبولِها، بجامِعِ حُدوثِها عِندَ حُدوثِ الوِلايةِ؛ مِمَّا يَدُلُّ على أنَّها مِن أجلِها ليُتَوسَّلَ بها إلى مَيلِ الحاكِمِ مَعَ المُهدي أو الرَّاشي على خَصمِهما(٤)

٤ـ إن النُّفوسَ بطَبيعَتِها تَميلُ إلى مَن أهدى إليها؛ مِمَّا سيُؤَثِّرُ في عَدالةِ الأحكامِ، فلَم يَجُزْ للقاضي قَبولُ الهَديَّةِ. (٥)

(١) انظر: صحيح البخاري، برقم ،٦٧٥٣، صحيح مسلم، برقم ،١٨٣٢.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين، ٣٧٢/٥.
(٣) انظر: مسند أحمد بن حنبل ، ٥/ ٤٢٤، السنن الكبرى للبيهقي ،١٠/ ١٣٨. قال ابن الملقن: حديث هدايا العمال غلول رواه أحمد والبيهقيُّ من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن. خلاصة البدر المنير ،٢/ ٤٣٠.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦٨/١٠.
(٥) انظر: الشرح الكبير، الدردير، ١٤٠/٤.

٥ـ إن قَبولَ القاضي الهَديَّةَ مِمَّا يُدخِلُ به عليه التُّهمةَ ويُطمِعُ فيه النَّاسَ، فيَجِبُ التَّحَرُّزُ منها(١)

الحال الثانية: إن تكون العادة قد جرت بينهما بالهدية:

إذا كانت العادة قد جرتْ بتبادل الهدايا بين القاضي، وبين من يُهدي إليه قبل توليه القضاء، ولم تكن لمن أهدى إليه دعوى منظورة أمامه، **فقد اتفق الفقهاء** على جواز قبل القاضي للهدية لانتفاء التهمة حينئذ، وإن كان ردها أولى (٢)

واستدلوا:

١ـ إن تحريم الهدية لكَونِ الوِلايةِ سَبَبَها، وهذه الهَديَّةُ لم يَكُنْ سَبَبُها الوِلايةَ، فجازَ قَبولُها(٣)

٢ـ إنَّ التُّهمةَ مُنتَفيةٌ؛ لأنَّ الوِلايةَ لم تَكُنْ سَبَبَ الهَديَّةِ، فيَجوزُ قَبولُها في هذه الحالةِ(٤).

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٨٢/١٦.
(٢) انظر: الهداية، المرغيناني، ١٠٣/٣، البحر الرائق، ابن نجيم، ٣٠٥/٦، الكافي، ابن عبد البر، ٩٥٣/٢، تبصرة الحكام ، ابن فرحون، ١/ ٣٣، مغني المحتاج، الشربيني، ٦/ ٢٨٧، نهاية المحتاج، الرملي، ٢٥٥/٨، المغني ، ١٤/ ٥٨ ـ ٥٩، ، الإقناع، الحجاوي، ٣٨١/٤، منهى الإرادات، ابن النجار، ٢٧٢/٥.
(٣) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٢٢٧/٤.
(٤) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٦/ ٢٨٨

٣ـ تحريم قبول الرشوة: المقصود برشوة القاضي: ما يُبْذَلُه الراشي للقاضي؛ ليحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم هذه الرشوة(١).

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (٢).

وجه الاستدلال: إن الله عز وجل قد حرم أكل مال الغير بالباطل، لأنه ليس له فيه حق، ودفع الرشوة إلى القاضي، هو من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم بالنص المذكور(٣).

٢ـ بقوله ﷺ:" لعنةُ اللهِ على الرّاشِي والمُرْتَشِي" (٤).

وجه الاستدلال: إن النص الشريف، قد أثبت لعنة الله عز وجل على الراشي والمرتشي، واللعن، هو: الطرد من رحمة الله تعالى، وهو لا يكون إلا في حرام، فتكون الرشوة حراماً للقاضي وغيره من العمال والحكام(١).

(١) قال ابن قدامة: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف انظر: المغنى، ٥٩/١٤. انظرك في مواضع اتفاق الفقهاء على تحريم الرشوة: البحر الرائق، ابن نجيم،٣٠٧/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١/ ٣٨، البيان، العمراني، ٣١/١٣. المغني، ابن قدامة، ٢٧٧/٤.
(٢) انظر: سورة البقرة، الآية:١٨٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٣٩٢/٤.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ انظر: سنن الترمذيُّ ، ٣/ ٦٢٢، كتاب الأحكام، بَاب ما جاء في الرَّاشِي وَالمُرْتَشي في الحُكْمِ، برقم: ١٣٣٦، ١٣٣٧.

٣ـ من المعقول: لأن القاضي، إذا أخذ الرشوة في الحكم ليحكم بغير الحق فالحكم بغير الحق محرم، وكذلك الأخذ عليه. وإن أخذ الرشوة ليوقف الحكم.. فإمضاء الحكم واجب عليه، فحرم الأخذ على إيقافه. وإن أخذ الرشوة ليحكم بالحق.. لم يجز؛ لأنه يأخذ الرزق من الإمام، فلم يجز له أن يأخذ عوضا آخر(٢).

٤ـ الإجماع: أجمع الفقهاء على تحريم الرشوة، ومنها الرشوة للقاضي. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الفقهاء(٣).

٤ـ أن يتجنب بطانة السوء: يُستحبُّ للقاضي أن يتجنب بطانة السوء، لأن أكثر القضاة إنما يؤتى عليهم من ذلك. بل عليه أن يتخذ بطانة من أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة ليستعين بهم في اجتهاده ويخففوا عنه الأعباء التي يمكنهم القيام بها(٤).

٥ـ عدم إجابة الدعوة الخاصة: قرر الفقهاء إنه لا يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة؛ لأن إجابتها لا تخلو من التهمة، إلا إذا كان صاحب الدعوة قريبًا له، أو جرت العادة بدعوته قبل القضاء، بشرط: ألا يكَون لأحدهما

(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ٥٩/١٤.
(٢) انظر: البيان في مذهب افمام الشافعي، العمراني، ٣٠/١٣ــ٣١.
(٣) انظر: فتاوى قاضي خان ٢ / ٣٦٣، حاشية الرهوني ٧ / ٣١٠، نهاية المحتاج، الرملي، ٨ / ٢٤٢، كشاف القناع، البهوتي، ٦ / ٣١٦.
(٤) انظر: تبصرة الحكام،٣٥/١ـ٣٦.

خصومة عنده؛ لانعدام التهمة فإن عرف القاضي أن لأحدهما خصومة عنده امتنع عن حضورها ومرجع تحديد الدعوة الخاصة إلى العرف.

أما الدعوة العامة: فإن كانت مشروعة كوليمة العرس فإنه يجيبها، فإن إجابتها امتثال للسنة ولا تهمة في إجابتها، وإن كانت غير مشروعة فلا يجيبها(١).

٦ـ عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:

لا يجوز للقاضي أن يفتي في حادثة قد تعرض له، وهي الحوادث، والوقائع التي تدخل في اختصاصه، فلا يجوز له أن يفتي في موضوع يتعلق بالنكاح؛ إذا كان مختصًا بالنظر في الأنكحة فقط، ولا في موضوع يتعلق بالأموال إذا كان مختصًا بالنظر في المعاملات فقط؛ لأنه قد تعرض عليه هذه الحادثة في خصومة قضائية فيكون قد أبدى رأيه فيها وهذا يخل بنزاهة القاضي؛ ولأنه قد يتغير رأيه أثناء نظر القضية لسبب من الأسباب فلو قضى برأيه

(١) انظر: روضة الطالبين للنووي ، ٣٣٣/٧، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٩٧/٣، المبدع، ابن مفلح، ١٦٧/٧، منهى الإرادات، ابن النجار، ١٦٩/٤.

الأخير أدخل الشك في نفس الخصوم ولو قضى برأيه الأول يكون قد حكم بخلاف ما يعتقد صحته(١).

٧ـ عدم اشتغال القاضي بالتجارة:

التجارة لغة: تَجَر يَتجُر تَجْراً وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتَّجَر، ورجل تاجر، والجمع، تِجارُ، وتُجّازُ، وتَجُر(٢).

واصطلاحاً: هي تقليب المال، والتصرف فيه بالبيع والشراء بقصد الحصول على الربح(٣).

والمقصود من عدم اشتغال القاضي التجارة:

منع القاضي من الاشتغال بجميع أنواع المعاملات، من بيع وشراء، وإجارة، ومضاربة، واستثمار، ونحو هذا. قال النووي رحمه الله تعالى" ولا يختص هذا الحكم بالبيع والشراء، بل يعم الإجارة وسائر المعاملات" (٤)

(١) انظر: مواهب الجليل ، الحطاب، ٦/ ١١٩، فتاوى ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح، ، ١/ ٤٥، أدب المفتي والمستفتي ، ابن الصلاح، ١/ ١٠٨، مذكرة في علم القضاء د. عبد العال عطوة ص: ٨٠.
(٢) انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ٨٢/١.
(٣) انظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١١٣/١، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، ٨٢/١.
(٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ١٢٧/٨.

وقد قرر الفقهاء: إن بيع القاضي قد يكون لنفسه، أو لغيره، وكل منهما إما أن يكون في مجلس الحكم، أو خارج المجلس، وعلى هذا؛ فيجب التفرقة في حكم اشتغال القاضي بالتجارة، بين **أربع حالات**:

الحال الأولى: بيع القاضي وشراؤه لنفسه في مجلس الحكم:

قرر الفقهاء أنه يُكْرَهُ(١) للقاضي الاشتغال بالتجارة، في مجلس الحكم في الجملة(٢).

وقد استدل جمهور الفقهاء على كراهة بيع القاضي وشراؤه في مجلس القضاء بما يلي:

١ـ رواية أبي السود المالكي عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ، قال: " ما عدلَ والٍ اتَّجَرَ في رعيتِهِ" (٣)

وجه الاستدلال: إن النبي ﷺ، نفى العدل عن الوالي الذي يتاجر مع رعيته، فيكون الاشتغال بالتجارة مع الرعية ممنوعاً وخاصة في مجلس القضاء.

(١) الكراهة إذا أُطلقتْ عند الحنفية، فالمراد بها: الكراهة التحريمية، وأما عند جمهور الفقهاء: فالمراد بها الكراهة التنزيهية، التي مَرَدُّها خلاف الأولى والمستحب.
(٢) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣٦٣/٦، المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن مازة، ٤٤٨/٨، البحر الرائق، ابن نجيم، ٣٠٥/٦، الذخيرة، القرافي، ٨٥٢/١٠، الشرح الكبير، الدردير، ١٣٩/٤، التاج والإكليل، محمد بن يوسف المواق، ٢٢/١١، الحاوي الكبير، الماوردي، ٥١/١٦، المهذب، الشيرازي، ٢٩٣/٢، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٣٩١/٤، المغني، ابن قدامة، ٤٣٧/١١، الفروع، ابن مفلح،٣٩٩/٦، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٥٠٠/٣.
(٣) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، حديث رقم:٧٩٢٢

٢ـ ما رُوي عن شريح القاضي أنه قال "شَرَطَ عليَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي القَضَاءَ: أَلَّا أَبِيعَ، وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَرْتَشِيَ، وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ "(١)

ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر؛ حيث وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الشرط لمنع تعارض المصالح وحماية نزاهة القضاء.

٣ـ **بما رُوي** رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ لَمَّا بُويع، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ﷺ لَا يَسَعُك أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ، قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَك مَا يَكْفِيك، فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ"(٢)

٤ـ **واستدلوا من المعقول**، فقالوا: لأن القاضي إذا باع واشترى، لم يُؤمنُ له أن يُسامح ويُحابي، فتميل نفسه عند المحاكمة إليه، إلى مُمَايلة من سامحه وحاباهُ.

وأيضاً: لأن في مباشرة القاضي للتجارة تحدثُ له ذِلَّةٌ، تَقِلُّ بها هيبتُه، فكان تَصَوُّنُه عنها أولى(٣).

(١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ، ١٩٥/٤، "لم أجده " وذكره ابن قدامة المقدسي في الكافي ،٤٤/٣.

(٢) انظر: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ١٨٤/٣، قال ابن حجر في التلخيص الحبير ، ٤/ ١٩٤: "رواها ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات ويشهد لها عدة روايات رواها ابن سعد والطبراني"

(٣) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٥١/١٦.

الحال الثانية: بيع القاضي وشراؤه لغيره في مجلس الحكم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على **قولين**:

القول الأول:

إنه يجوز بيع القاضي وشراؤه لغيره في مجلس الحكم. **وإليه ذهب أكثر الحنفية**(١).

واستدلوا لذلك: بأن من أعمال القاضي البيع والشراء، فقد تدعوه طبيعة عمله إلى أن يبيع مال أحد الخصوم لسداد دينه، أو لضمانه، ونحو هذا، فهذا من عمل القضاة في كل زمن(٢).

القول الثاني:

إنه لا يجوز بيع القاضي وشراؤه لغيره في مجلس الحكم، **وإليه ذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض الحنفية**(٣).

واستدلوا على كراهة ذلك بنفس أدلة الكراهة الواردة في المسألة السابقة.

---

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣٦٣/٦، المحيط البرهاني، ابن مازة، ٤٤٠/٨، البحر الرائق، ابن نجيم، ٣٠٥/٦، مجمع الأنهر، عبد الرحمن بن محمد" داماد أفندي" ٢٤٣/٣.

(٢) انظر: المراجع السابقة، نفس المواضع.

(٣) انظر: الذخيرة، القرافي، ٨٢/١٠، الشرح الكبير، الدردير، ١٣٩/٤، الحاوي الكبير، الماوردي، ٥١/١٦، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٣٩١/٤،، المغني، ابن قدامة، ٤٣٧/١١، الفروع، ابن مفلح، ٣٩٩/٦.

الترجيح:

ويمكن الجمع بين قول الحنفية، وبين قول الجمهور، بان يُقال: بجواز بيع القاضي وشراؤه لغيره في مجلس الحكم، متى كانت حاجة عمله تدعوه إلى ذلك، كأن يبيع مال أحد الخصوم لسداد دينه، أو للوفاء بأحد ديون من ضمنهم أحد الخصوم في الدعوى، وأما ما عدا ذلك، فإن قول الجمهور هو الراجح بكراهة البيع في هذه المسألة صَوناً لكرامة القاضي عن الابتذال. والله أعلم.

الحال الثالثة: بيع القاضي وشراؤه في غير مجلس القضاء لنفسه أو لغيره:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على **قولين**:

القول الأول:

إنه يجوز للقاضي البيع والشراء لنفسه ولغيره متى كان ذلك في غير مجلس القضاء. **وإليه ذهب أكثر الحنفية والمالكية**(١).

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣٦٣/٦، المحيط البرهاني، ابن مازة، ٤٤٠/٨، الذخيرة، القرافي، ٨٢/١٠، الشرح الكبير، الدردير، ١٣٩/٤.

وقد استدلوا :

١ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم من بعده قد باشروا البيع والشراء.

٢ـ إن حاجة القاضي إلى البيع والشراء بعد تقلد القضاء، كحاجته إليه قبل تقلد القضاء، وقبل القضاء مَلَكَ القاضي البيع والشراء لحاجته، فبعد القضاء يملكُ كذلك لحاجته أيضاً إليهما(١).

القول الثاني:

إنه يُكرهُ للقاضي البيع والشراء لنفسه ولغيره متى كان ذلك في غير مجلس القضاء. **وإليه ذهب بعض الحنفية، وهو قول عند المالكية(٢).**

وقد استدلوا بما ورد ذكره من أدلة على الكراهة في الحال الأولى، فلا حاجة لتكراره.

الحال الرابعة: حكم اتخاذ القاضي وكيلاً له في البيع والشراء:

استحب جمهور الفقهاء للقاضي أن يتخذ وكيلاً لنفسه في البيع والشراء، بحيثُ لا يعرف الناس، هذا الوكيل؛ لئلا يُحابوه؛ ولئلا يدفعهم ذلك إلى توسط الوكيل عند القاضي لهم(١).

(١) انظر: المحيط البرهاني، ابن مازة، ٤٤٠/٨،
(٢) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٣٠٥/٦. الذخيرة، القرافي، ٨٢/١٠.

ثالثًا: الآداب الواجبة المتعلقة بجلوس القاضي للحكم:

١ـ وجوب التسوية بين الخصوم: قرر الفقهاء إن القاضي مأمور بالتسوية بين الخصوم ومحل هذه التسوية في: أن ينصف الخصمين في المدخل عليه حتى لا يتهم بالجور، وكذا التسوية بينهم في الاستماع منهم، وأن ينصت لكل واحد منهم حتى تنفذ حجته وكذا يسوي بين الخصمين في حسن الإقبال عليهما، فلا يخص أحدهما بإقبال دون الأخر، وكذا يجب على القاضي: ألا يميل إلى أحدهما بالسلام فيخصُّه به، ولا بالترحيب، وكذا لا يسأل أحدهما عن حاله، ولا عن خبره، ولا عن شيء من أمورهما في مجلسهما ذلك، وكذا لا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر، ولا ينهر أحدهما دون الآخر، إلا أن يكون أحدهما مستحقًا بذنب أو سوء أدب، وكذا لا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر. ولا يُضَيِّفُ أحدهما دون الآخر، وألا يزور أحدهما دون الآخر، حتى وإن كان مريضًا، أن يسوِّي بينهما في النظر إلا أن يتعدى أحدهما، فلا بأس أن يسوء نظره إليه تأديبًا له، أن يسوِّي بينهما في الخلوة، فلا يخلو بأحدهما في منزله، وأن يسوِّي بينهما في الإشارة، أن يستوي عنده الشريف والوضيع، والحاكم

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣٦٣/٦، الذخيرة، القرافي، ٨٢/١٠، الحاوي الكبير، الماوردي، ٥١/١٦، الفروع، ابن مفلح، ٣٩٩/٦.

والمحكوم، ألا يزيد لأحدهما في جلوسه على الآخر شيئًا، كوسادة ونحوها، وكذا المساواة بينهما في المجلس(١).

وقد استدل الفقهاء على عموم التسوية بين الخصوم في مجلس القضاء بما يلي:

١ـ من الكتاب العزيز بقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)(٢)

وجه الاستدلال: إن النص الكريم قد أمر جماعة المسلمين، ونهم القاضي بالقسد أي العدل بين الناس جميعاً، ومنهم الخصوم، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولم يَصرفه عن الوجوب هنا صارف، فيبقى على أصله، كما أن قوله تعالى" ولا تلووا أو تعرضوا" قيل في معنى الإعراض المذكور في الآية الكريمة: «هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون لي القاضي وإعراضه

(١) انظر: بدائع الصنائع، ٩/٧، البحر الرائق/،٣٠٧/٦، المبسوط، السرخسي، ٧٦/١٦، فتح القدير، ابن الهمام، ٤٦٩/٥، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٤٦/١، الأم، الإمام الشافعي، ٢٣١/٦،الحاوي الكبير، الماوردي، ٣٥١/٢٠، المغني، ابن قدامة، ٨٢/٩.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٣٥

لأحدهما على الآخر وهذا منهي عنه شرعًا؛ لأن فيه إعانة على أحد الخصمين، ومكسرة الآخر، والقاضي مأمور بالتسوية بينهما(١).

٢ـ واستدلوا من السنة المطهرة بقوله ﷺ "من ابتُلي بالقضاء بين المسلمين، فليعدل بينهم في لفظه، وإشارته، ومقعده "(٢).

وقوله ﷺ "من ابتُلي بالقضاء بين المسلمين، فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر " (٣)

وجه الاستدلال: إن في هذين الحديثين دليل صريح على وجوب التسوية بين الخصوم في كل ما يمكن العدل فيه(٤)

٣ـ واستدلوا من الأثر: بما ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قوله: «آسِ بين الناس في مجلسك، وفي وجهك، وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك»(٥)

ووجه الاستدلال من الأثر ظاهر، حيثُ أوصى سيدنا عمر أبا موسى رضي الله عنهما بالتسوية بين الخصوم في مجلس القضاء، وهو لا يفعله إلا إذا

(١) انظر: تفسير الطبري، ٣٠٧/٩، المغني، ابن قدامة، ٨٠/٩.
(٢)أخرجه الدارقطني في سننه، ٢٠٥/٤.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٣٥/١٠.
(٤) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر،ص:١١٤.
(٥) انظر: انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، ١٥٠/١٠.

كان له فيه شاهد عن النبي ﷺ والقرآن الكريم، وقد تقدم ذلك في الاستدلال من الكتاب والسنة.(١)

وبما ورد عن الشعبي أنه قال: «كان بين عمر -رضي الله عنه- وأبي بن كعب -رضي الله عنه- حائط يدعيان جميعًا، فتقاضيا إلى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فأتياه فضربا الباب، فسمع زيد صوت عمر -رضي الله عنه- فاستقبل، فقال: «ألا أرسلت إليَّ يا أمير المؤمنين» فقال: «في بيته يؤتى الحكم» فوسَّع له زيد عن صدر فراشه، فقال: «هاهنا يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: «جرت في أول القضاء، ولكن أجلسُ مع خصمي» فجلسا فادعى أبي، وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: «اعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره» فحلف عمر، ثم أقسم «لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء»(٢)

وجه الاستدلال: إن سيدنا عمر رضي الله عنه، قد رفض عدم المساواة بينه وبين خصمه، حتى في دفع "الوسادة" إليه، وهذا دليل على أن عدم التسوية، وتفضيل أحد الخصمين على الآخر في أبسط الأشياء ممنوع في مجلس القضاء. (٣)

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١١٢.
(٢) انظر: أخبار القضاة، وكيع ابن الجراح، ١٠٩/١.
(٣) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١١٢.

٤ـ واستدلوا من المعقول: فقالوا" في تخصيص أحد الخصمين بمجلس، أو إقبال، أو إكرام مفسدتان: إحداهما: طمعه في أن تكون الحكومة له، فيقوى قلبه وجنانه. والثانية: إن الآخر ييأس من عدله، ويضعف قلبه، وتنكسر حجته(١)

٢ـ اعتدال حال القاضي أثناء نظر الدعوى:

المقصود باعتدال حال القاضي في نظره للدعوى: عدم كونه في حال تحول بينه وبين سماع الدعوى على الوجه المطلوب شرعاً، بحيث لا يجلس للقضاء وبه جوع شديد، أو عطش يشغله عن حسن الاستماع بين الخصوم، وكذا حالة الغضب والكسل، ونحو هذا مما يعوق القاضي عن سماع الدعوى، والفصل فيها على الوجه الشرعي المطلوب(٢).

وقد تكلم الفقهاء عن حالة الغضب باعتبارها من أهم الأحوال التي تُخرج القاضي عن حال الاعتدال المطلوب في الجلوس للقضاء، وقد عَدَّ الفقهاء ما يدخل تحت حال الغضب من الجوع والعطش والكسل، ونحو هذا في حكم حال الغضب وبيان ذلك فيما يلي:

(١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،٨٩/١.
(٢) انظر: : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العلامة ابن حجر، ٥٣/١٥. إعلام الموقعين، العلامة ابن القيم، ١٦٦/١.

ـ حكم قضاء القاضي في حال الغضب:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه ينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن يكون في حال الاعتدال، وقد مثلوا بأحوال الغضب والجوع، والكسل والنعاس وغير ذلك مما يدخل في معنى الغضب، وَيْمَتَثِلُ نفس علة الغضب، وهي عدم صفاء الذهن، وقصور النظر والاستيعاب، القادح في صحة الحكم، ولذا فقد استحب له الفقهاء عدم الجلوس للقضاء وهو على تلك الحال(١).

وفي هذا الصدد يقول العلامة ابن حجر رحمه الله "قول الشيخ: وهو قياس مَظِنَّة على مَظِنَّة صحيح، وهو استنباط معنى دلَّ عليه النص، فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب فهم منهم أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك، وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يُسمى علة، بمعنى أنه مشتمل عليه، فألحق به ما في معناه كالجائع" (٢).

---

(١) انظر: المبسوط ، السرخسي، ٧٨/١٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٣٥/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ، الشيخ الخرشي، ١٥١/٧، نهاية المحتاج للرملي، ٩٤/٨، المحلى بالآثار، ابن حزم ، ٣٦٥/٩.

(٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العلامة ابن حجر، ٥٣/١٥. وفي هذا المعنى: إعلام الموقعين، العلامة ابن القيم، ١٦٦/١، حيث يقول "وما أحسن ما قال: ومن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمأ الشديد، وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قلَّ فقهه وفهمه، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم، ومراده يظهر من

ولكن إذا جلس القاضي للقضاء وهو على تلك الحال وقضى بين الخصوم، فهل يقعُ حكمه صحيحا ونافذا؟ **لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:**

القول الأول:

إن القاضي إذا جلس للحكم وهو في حال الغضب الشديد، أو نحو هذا من شدة الجوع والخوف والنعاس، فقضى بين الخصوم، فإن قضاءه يكون صحيحاً نافذاً، وعلي هذا: ذهب **الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية، على خلاف بينهم في الكراهة**، فقال الحنفية بصحة الحكم ونفاذه بلا كراهة، وقال المالكية والشافعية بصحة الحكم ونفاذه مع الكراهة(١).

واستدلوا:

١ـ بما رواه الشيخان عن الزبير بن العوام " أَنَّه خاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ قد شَهِدَ بَدرًا إلى رَسولِ اللهِ ﷺ في شِراجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كانا يَسقيانِ به كِلاهما، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ للزُّبَيرِ: اسقِ يا زُبَيرُ، ثُمَّ أرسِلْ إلى جارِكَ، فغَضِبَ الأنصاريُّ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟! فتَلَوَّنَ وجْهُ رَسولِ اللهِ

عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة أخرى، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان "

(١) انظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي، ٣٧٣/٣، مواهب الجليل، الحطاب، ٤٠٢/٣، الأم ، الإمام الشافعي، ص:١٩٩، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٦٢٠/٢.

ﷺ، ثُمَّ قال: اسقِ، ثُمَّ احبِسْ حتَّى يَبلُغَ الجَدرَ، فاستَوعى رَسولُ اللهِ ﷺ حينَئِذٍ حَقَّه للزُّبَيرِ، وكان رَسولُ اللهِ ﷺ قَبلَ ذلك أشارَ على الزُّبَيرِ برَأيٍ سَعةٍ له ولِلأنصاريِّ، فلَمَّا أحفَظَ الأنصاريُّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَوعى للزُّبَيرِ حَقَّه في صَريحِ الحُكمِ. قال عُروةُ: قال الزُّبَيرُ: واللهِ ما أحسِبُ هذه الآيةَ نَزَلَت إلَّا في ذلك: (فلا ورَبِّكَ لا يُؤمِنونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَينَهم) (١)(٢)

وجه الاستدلال: إن النبي ﷺ قد قضى في تلك الواقعة وهو غضبان، فدلَّ هذا على صحة قضاء القاضي ونفاذه في تلك الحال وما في معناها. (٣)

ونُوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح إلحاق غيره ﷺ به في مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه، بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ(٤).

٢ـ كما استدلوا بما رواه الشيخان عن أبي بكرة، أن النبي ﷺ " لا يَقضيَنَّ حَكَمٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ" (٥)

(١) من الآية:٦٥، من سورة النساء.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، الحديث رقم: ٢٧٠٨
(٣) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١٨٧.
(٤) انظر: نيل الأوطار، : محمد بن علي الشوكاني، ٣١٤/٨.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، الحديث رقم: ٧١٥٨

وجه الاستدلال: إن في هذا الحديث نهي النبي ﷺ عن القضاء في حال الغضب، والنهي يحمل على الكراهة، ويشهد لذلك ما قاله الصنعاني في «سبل السلام»: «وإنما حملوه على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك، وهي أنه لما رتب النهي على الغضب، والغضب بنفسه، لا مناسبة فيه لمنع الحكم، وإنما ذلك لما هو مظنة لحصوله، وهو تشويش الفكر، ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب، ولكنه غير مضطرد مع كل غضب، ومع كل إنسان، فإن أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه، وإن لم يفضِ إلى هذا الحد، فأقل أحواله الكراهة»(١)

القول الثاني:

إن القاضي إذا جلس للحكم وهو في حال الغضب الشديد، أو نحو هذا من شدة الجوع والخوف والنعاس، فقضى بين الخصوم، فإنه يَحْرُمُ عليه القضاء، ولا يكونُ نافذاً إلاَّ إذا وافق الحق. **وإلى هذا: ذهب الحنابلة والمالكية في رواية عنهم**.

(١) انظر: سبل السلام، الصنعاني، ١٦٣/٤، ١٦٤.

واستدلوا:

١ـ بما رواه الشيخان عن أبي بكرة، أن النبي ﷺ " لا يَقضيَنَّ حَكَمٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ"(١)

وجه الاستدلال: إن نهي النبي ﷺ عن القضاء حال الغضب، يقتضي الفساد، فيكون الحكم في حال الغضب باطلا، وغير نافذ(٢)

ونُوقشَ هذا الاستدلال: بأن النهي الذي يفيد فساد المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه، أو لجزئه، أو لوصفه الملازم له، لا المفارق كما هنا، وإذن فالنهي في هذا الحديث لا يقتضي بطلان حكم القاضي وعدم نفاذه، بل يقتضي الكراهة على أعلى تقدير(٣).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى التعارض الظاهري بين قوله ﷺ في حديث أبي بكره" لا يَقضيَنَّ حَكَمٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ " ، وبين فعله في حادثة الزبير ، كما يرجع أيضاً إلى مفاد النهي في قوله ﷺ " لا يَقضيَنَّ حَكَمٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضبانُ "، فالجمهور استدلوا بقضائه ﷺ في

(١) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، الحديث رقم: ٧١٥٨
(٢) قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، ١٦٣/٤، ١٦٤" لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم، وأن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد "
(٣) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٣١٤/٨.

حادثة الزبير وهو غضبان، وحملوا النهي في حديث أبي بكرة، على الكراهة، والحنابلة ومن وافقهم، جعلوا حادثة الزبير من خصوصياته ﷺ ولا يُقاس عليه غيره من البشر، كما حملوا النهي في حديث أبي بكرة على الفساد.

الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين، ومناقشتها، فإنه يمكن الجمع بين كلٍّ من القولين السابقين، وإذا أمكن الجمع فلا مصير إلى الترجيح، ولذا فإننا نجمع بين القولين، فنقول: بصحة قضاء القاضي ونفاذ حكمه، إذا لم يُخرجه الغضب عن التعدي، أي إلى ظلم أحد الخصمين، أو كان غضب القاضي لأجل الحق، وليس لأجل نفسه، أما إذا كان غضب القاضي قد أوقع به في التعدي أو الظلم، أو كان غضبه لغير الحق، وإنما لأجل نفسه، فإن قضاءه يكون باطلاً، ولا ينفذ في حق الخصوم، وإنما حاولنا الجمع بين الأدلة، وذلك لأن حديث الزبير، خاص بالنبي ﷺ، لأنه معصوم من الخطأ كما هو قول أكثر أهل العلم ، وإذن فلا يُقاس عليه غيره، وأما حديث أبي بكرة، فإنه من المعلوم عند الأصوليين: إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، إلا إذا كان النهي لذات المنهي عنه مثل: النهي عن الزنا والسرقة، أو لجزء منه، كالنهي عن بيع الميتة ، أو لأجل الوصف المقارن له، مثل بيع الربا، وأما الوصف المفارق للفعل، فلا

يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك، مثل النهي عن البيع، حال الأذان للجمعة، لإن النهي ليس لذات البيع، وإنما لوصف يمكن مفارقته، وهو وقت أذان الجمعة، ومثله حال الغضب التي قارن حكم القاضي، لأنه حال مفارقة للقضاء، غير ملازمة له، ولذا فإن الجمع بين القولين أولى من الترجيح، والله أعلم .

٣ـ ألا يقضي القاضي لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له:

اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم لنفسه هو من خصائص النبي ﷺ وذلك لأنه معصوم بعصمة الله له من الهوى، **كما اتفقوا** على إنه يجوز للقاضي أن يُعَزِّرَ من أساء الأدب عليه فيما يتعلق بأحكامه التي حكم بها، كأن يقول له: حكمت بالجور، وما ماثل هذا. (١)

واستدلوا لذلك: بحفظ هيبة القضاء، وعدم اجتراء الخصوم عليه. (٢)

لكنهم استحبوا للقاضي أن يعفو عمن أساء الأدب عليه، إن كان يُرجَى من العفو عنه ارتداعه عن فُحشِ قوله، وإساءة أدبه. (٣)

(١) انظر: الاستذكار، ابن عبد البر،٢٧٥/٨، المسالك، ابن العربي،٢٤٤/٧.طرح التثريب، العراقي، ٢١٠/٧. شرح مختصر الطحاوي، الجصاص،٥٩/٨، المنهاج، الحليمي، ٢٠٩/٣

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص،٥٩/٨، المنهاج، الحليمي، ٢٠٩/٣.

(٣) انظر: أدب القاضي، ابن القاص ،١٣٠/١، النوادر والزيادات، القيرواني، ٧٤/٨، روضة القضاة، ابن السمناني، ٧٤/١.قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ٣٦/٢.

وحجتهم في ذلك:

- ما روته أم المؤمنين السيدة عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: "ما خُيِّرَ رَسولُ الله ﷺ بَينَ أمرَينِ إلَّا أخَذَ أيسَرَهما ما لَم يَكُنْ إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعَدَ النَّاسِ مِنه، وما انتَقَمَ رَسولُ الله ﷺ لنَفسِه إلَّا أن تُنتَهَكَ حُرمةُ اللهِ، فيَنتَقِمَ للهِ بها" (١)

ووجه الاستدلال: في قولها رضي الله عنها" ما انتَقَمَ رَسولُ الله ﷺ لنَفسِه" حَيثُ يَدُلُّ على نَدبِ الأُمَراءِ وسائِرِ الحُكَّامِ والعُلَماءِ إلى أنَّه يَنبَغي لكُلِّ واحِدٍ مِنهم أن يَتَجافى عَنِ الانتِقامِ لنَفسِه؛ تَأسِّيًا بنَبيِّه ﷺ، ولا يَنسى الفَضلَ والأخذَ به في العَفوِ عَمَّن ظَلَمَه(٢)

أما إذا عرضت قضية للقاضي خصومة فيها أحد والدية، أو أحد أولاده، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على **قولين**:

القول الأول: إنه لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها بنفسه، وإن حكم لم ينفذ حكمه. **وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والمالكية وبعض فقهاء الحنابلة(٣)**

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، الحديث رقم: ٣٥٦٠. ومسلم في صحيحه، الحديث رقم: ٢٣٢٧.

(٢) انظر: كمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، القاضي عياض بن موسى السبتي، ٢٩٤/٧.

(٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني، ٩٠/٤، والشرح الصغير، الدردير، ١٩/٥. مغني المحتاج،٣٩٣/٤. أدب القضاء لابن أبي الدم،٤٠٤/١، الروض المربع مع حاشيته،٣٩١/٣.

واستدلوا: بأن القاضي لا تقبل شهادته له فلم ينفذ حكمه، كما لا ينفذ الحكم لنفسه.

القول الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم فيها بنفسه، ويَنْفُذُ حكمه. **وإليه ذهب: بعض فقهاء الحنابلة، وهو قول أبى يوسف صاحب أبي حنيفة، وابن المنذر، والمزني، وأبي ثور(١)**

واستدلوا: بأن القاضي قد حكم لغيره، فأشبه الحكم للأجانب(٢)

الترجيح:

ونحن نرى أن الراجح ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز قضاء القاضي خصومة فيها أحد والدية، أو أحد أولاده، وإذا قضى لا يَنْفُذُ حكمه، **وذلك لما يلي:**

١ـ عن عِمارةَ بنِ خُزَيمةَ أنَّ عَمَّه حَدَّثَه -وهو مِن أصحابِ النَّبيِّ ﷺ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ ابتاعَ فرَسًا مِن أعرابيٍّ، واستَتبَعَه ليَقبِضَ ثَمَنَ فرَسِه، فأسرَعَ النَّبيُّ ﷺ، وأبطَأ الأعرابيُّ، وطَفِقَ الرِّجالُ يَتَعَرَّضونَ للأعرابيِّ، فيَسومونَه بالفَرَسِ، وهم لا يَشعُرونَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ ابتاعَه، حَتَّى زادَ بَعضُهم في السَّومِ على ما ابتاعَه به مِنه، فنادى الأعرابيُّ النَّبيَّ ﷺ فقال: إن كُنتَ مُبتاعًا هذا الفَرَسَ وإلَّا بعتُه،

(١) انظر: مغني المحتاج الشربيني، ٣٩٧/٤، المغني، ابن قدامة، ٤٠٤/١١.
(٢) انظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ج٤، ص٣٩٧، والمغني، ابن قدامة، ج١١، ص٤٠٤.

فقامَ النَّبيُّ ﷺ حينَ سَمِعَ نِداءَه، فقال: "أَلَيسَ قدِ ابتَعتُه مِنكَ؟" قال: لا والله ما بعتُكَه، فقال النَّبيُّ ﷺ: "قدِ ابتَعتُه مِنكَ" فطَفِقَ النَّاسُ يَلوذونَ بالنَّبيِّ ﷺ وبِالأعرابيِّ وهما يَتَراجَعانِ، وطَفِقَ الأعرابيُّ يَقولُ: هَلُمَّ شاهدًا يَشهَدُ أنِّي قد بعتُكَه. قال خُزَيمةُ بنُ ثابِتٍ: أنا أشهَدُ أنَّكَ قد بعتَه، قال: فأقبَلَ النَّبيُّ ﷺ على خُزَيمةَ، فقال: "بمَ تَشهَدُ؟" قال: بتَصديقِكَ يا رَسولَ اللهِ، قال: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ شَهادةَ خُزَيمةَ شَهادةَ رَجُلَينِ"(١)

ووجه الاستدلال:

إنَّ النَّبيَّ ﷺ حينَ أنكَرَ الأعرابيُّ استيفاءَ ثَمَنِ الفَرَسِ مِنه، وقال: هَلُمَّ شاهدًا، شَهدَ له خُزَيمةُ رَضِيَ اللهُ عنه. فإذا كان هذا في حَقِّ مَن هو مَعصومٌ عَنِ الكَذِبِ ﷺ فمَن سِواه مِن قاضٍ وغَيرِه أولى(٢).

وبناء عليه:

إذا عرضت للقاضي خصومة على النحو السابق، وجب عليه أن يتنحى عن نظرها، وأن يرفعها إلى الحاكم أو من يفوضه الحاكم في القضاء فيها، والله أعلم.

(١) أخرجه أبو داود في سننه، الحديث رقم: ٣٦٠٧، والنسائي في سننه ، الحديث رقم: ٤٦٤٧، واللفظ له، والحكم في المستدرك، ٢١/٢، الحديث رقم: ٢١٨٧. قال الذهبي في تلخيص الحبير: "حديث صحيح" .
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي، ١٠٧/١٦.

المبحث السادس

رَزْقُ القاضي.

يقصد الفقهاء من "رَزْقِ" القاضي:

ما يُفرض للقاضي من مال في بيت المسلمين بقدر حاجته وكفايته، ليفرّغ نفسه لإقامة العدل وفصل الخصومات(١)

وأما الأجر: فهو عوض العمل أو المنفعة، ويكون باتفاق المتعاقدين(٢).

الفرق بين الرزق والأجر: الرَّزْقُ: يُعطى نظير التكليف بولاية عامة لحق المجتمع بينما الأجر عوض عن عمل تعاقدي محدد بيعاً أو إجارة(٣)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز منح القاضي رزقاً يحقق له، وأسرته المُلزَمَة منه حَدَّ الكفاية إذا كان من أهل الحاجة، أما إذا كان من الأغنياء فقد اختلفوا في حكم إعطائه هذا الرزق من بيت المال، **وفيما يلي بيان موضع الاتفاق وموضع الاختلاف بالتفصيل**:

(١) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ١٠٨/٤

(٢) انظر: المرجع والمكان السابقين.

(٣) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ٢٩٣/١٦، حيث قال ما نصه" قال الماوردي، " ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة، لأن الأجرة مستحقة بعقد لازم والجعالة مستحقة بعقد جائز. والقضاء في العقود الجائزة دون اللازمة، فلذلك كان الرزق فيه جعالة ولم يكن أجرة."

الحال الأولى:

موضع الاتفاق: أخذ الرزق من بيت المال إذا كان القاضي فقيراً.

اتفق الفقهاء على أن القاضي يجوز له أخذ الرزق على القَضاءِ مِن بَيتِ المالِ إذا كانَ القاضي فقيرًا.

واستدلوا لذلك:

١ـ بقوله تعالى (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا) (١)

وجه الاستدلال: دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّ العامِلينَ على الزَّكاةِ مِن جُملةِ المُستَحِقِّينَ لَها، فكَما أنَّ مَن يَقومُ على مَصالِحِ الزَّكاةِ لَه حَقٌّ فيها، يَكونُ للقُضاةِ الذينَ يَقومونَ على مَصالِحِ المُسلِمينَ حَقٌّ في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ، بَل أولى(٢).

٢ـ عَن بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: "مَنِ استَعمَلناهُ على عَمَلٍ فرَزَقناهُ رِزقًا، فما أخَذَ بَعدَ ذلك فهو غُلولٌ"(٣).

وجه الاستدلال: دَلَّ الحَديثُ على جَوازِ أخذِ الرِّزقِ إذا فرَضَه لَه الإمامُ(٤).

(١) انظر: من الآية:٦٠، من سورة التوبة.
(٢) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ١٥٠/١٣.
(٣)أخرجه أبو داود في سننه، برقم : ٢٩٤٣، والحاكم في المستدركة برقم: ١٤٩١. صحَّحه الحاكمُ على شرط الشَّيخين، وابن دقيق العيد في الاقتراح، برقم: ٩٤، وابنُ المُلَقِّنِ على شَرطِ الشَّيخَينِ في البدر المنير، ٦٥٤/٩.
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي، ٤٥٧/١٢.

٣ـ عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّعديِّ أنَّه قدِمَ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ، فقال لَه عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنهُ: "ألَمَ أُخبَرْ أنَّكَ تَلي أعمالًا مِن أعمالِ النَّاسِ، فتُعطى عُمالَتَكَ فلا تَقبَلُ؟ فقُلتُ: أجَلْ، إنَّ لي أفراسًا وأعبُدًا وأنا بخَيرٍ، وأنا أُريدُ أن يَكونَ عَمَلي صَدَقةً على المُسلِمينَ. فقال عُمَرُ: لا تَفعَلْ؛ فإنِّي قد أرَدتُ مِثلَ الذي أرَدتَ، وإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُعطيني العَطاءَ فأقولُ: أعطِه مَن هو أحوجُ إليه مِنِّي، وإنَّه أعطاني مَرَّةً مالًا فقُلتُ: أعطِه مَن هو أحوجُ إليه مِنِّي. فقال: يا عُمَرُ، ما آتاكَ اللهُ به مِن هذا المالِ مِن غَيرِ مَسألةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ فخُذْه فتَمَوَّلْه أو تَصَدَّقْ به، وما لا فلا تُتبِعْه نَفسَك"(١).

وجه الاستدلال: دَلَّ الحَديثُ على إباحةِ أخذِ الأرزاقِ مِن وُجوهِها للقُضاةِ(٢).

٤ـ واستدلوا من المعقول، فقالوا": لأنَّ بَيتَ المالِ أُعِدَّ لَمصالِحِ المُسلِمينَ، والقاضي مَحبوسٌ لَمصالِحِهم، والحَبسُ مِن أسبابِ النَّفَقةِ، فكانَ رِزقُه فيه كَرِزقِ المُقاتِلةِ والزَّوجةِ، يُعطى مِنهُ ما يَكفيه وأهلَه(٣).

(١)أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم: ٧١٦٣، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، حديث رقم: ١٠٤٥.
(٢) انظر: الأوسط، ابن المنذر،٦٠٠/٦.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي،٣٣/٦، البحر الرائق لابن نجيم ، ٨/ ٢٣٧.

الحال الثانية:

موضع الخلاف: أخذ الرزق من بيت المال إذا كان القاضي غنياً.

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال إذا كان القاضي غنياً على قولين:

القول الأول:

يَجوزُ أخذ الرِّزقِ مِن بَيتِ المالِ إذا كانَ القاضي غَنيًّا، **وإليه ذهب بعض الحنفية والإمام مالك وبعض أصحابه، وبه قال أبوبكر الشاشي شيخ الشافعية في عصره، به قال شريح وابن سيرين وهو مذهب الحنابلة والظاهرية (١).**

واستدلوا على ذلك:

١- عَن بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: "مَنِ استَعمَلناهُ على عَمَلٍ فرَزَقناهُ رِزقًا، فما أخَذَ بَعدَ ذلك فهو غُلولٌ"(٢).

وَجهُ الدَّلالةِ:

دَلَّ الحَديثُ على جَوازِ أخذِ الرِّزقِ إذا فرَضَه لَه الإمامُ(٣).

(١) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٢٣٧/٨،الدر المختار، وحاشية ابن عابدين رد المحتار، ٣٨٩/٦، الإقناع، الحجاوي، ٣٦٦/٤، كشاف القناع، البهوتي، ٢٩٠/٦. المحلى لابن حزم ٩/ ٤٣٥.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، برقم : ٢٩٤٣، والحاكم في المستدركة برقم: ١٤٩١. صحَّحه الحاكمُ على شرط الشَّيخين، وابن دقيق العيد في الاقتراح، برقم: ٩٤، وابنُ المُلَقِّنِ على شَرطِ الشَّيخَينِ في البدر المنير، ٦٥٤/٩.

(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي، ٤٥٧/١٢.

٢ـ عن جابر أن رسول الله ﷺ استعمل عتّاب بن أسيد على مكّة وفرض له عُمالته أربعين أوقية من فضة(١).

وجه الاستدلال: إن فعل النّبيّ ﷺ مع عتاب بن أسيد قد دل على جواز أخذ الرزق على العمل في مصلحة المسلمين دون فرق بين غنى وفقير، حيث لم يستفصل عن حالة أسيد من حيث الفقر والغنى. فدلّ ذلك على الجواز مطلقًا فكذلك القاضي؛ لأنَّ كلا منهما عامل للمسلمين(٢).

٢ – **عَن عَبدِ** اللهِ بنِ السَّعديِّ أنَّه قدِمَ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ، فقال لَه عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنهُ: "ألَمْ أُخبَرْ أنَّكَ تَلي أعمالًا مِن أعمالِ النَّاسِ، فتُعطى عُمالَتَكَ فلا تَقبَلُ؟ فقُلتُ: أجَلْ، إنَّ لي أفراسًا وأعبُدًا وأنا بخَيرٍ، وأنا أُريدُ أن يَكونَ عَمَلي صَدَقةً على المُسلِمينَ. فقال عُمَرُ: لا تَفعَلْ؛ فإنِّي قد أرَدتُ مِثلَ الذي أرَدتَ، وإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُعطيني العَطاءَ فأقولُ: أعطِه مَن هو أحوجُ إليه مِنِّي، وإنَّه أعطاني مَرَّةً مالًا فقُلتُ: أعطِه مَن هو أحوجُ إليه مِنِّي.

(١) انظر: أخرجه البيهقي، كتاب قسمة الفيء والغنيمة، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الأقاليم من مال الله ...، ٥٧٨/٦، حديث رقم: ١٣٠٢٢.
(٢) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد،٩/٢، وما بعدها، المغنى لابن قدامة،٩/١٤.

فقال: يا عُمَرُ، ما آتاكَ اللهُ به مِن هذا المالِ مِن غَيرِ مَسألةٍ ولا إشرافِ نَفسٍ فخُذْه فتَمَوَّلْه أو تَصَدَّقْ به، وما لا فلا تُتبِعْه نَفسَك"(١)

وَجهُ الدَّلالةِ:

دَلَّ الحَديثُ على إباحةِ أخذِ الأرزاقِ مِن وُجوهِها للقُضاةِ(٢).

٣ـ كما استدلوا من المعقول بوجوه:

الوجه الأول: إنَّ في إعطاءِ القاضي الرِّزقَ ولَو مَعَ غِناهُ صيانةً للقَضاءِ عَنِ الهَوانِ(٣).

الوجه الثاني: إنَّه لَو لَم يَجُزْ أخذُ الرِّزقِ مَعَ الغِنى لَأفضى ذلك إلى تَعطيلِ القَضاءِ؛ لأنَّه قَلَّ أن يوجَدَ أحَدٌ يَسهُلُ عليه الاشتِغالُ عَن أشغالِ نَفسِه وتَكَسُّبِه بغَيرِ عِوضٍ(٤)

الوجه الثالث: إن إعطاء القاضي رزقاً يرفع الضرر عنه بإلزامه ما لا يلزم، فحسب القاضي أن يبذل علمه واجتهاده في فصل النزاع بدون مقابل، فلا يجمع عليه بين هذا البذل وبين مؤونة وكلفة معيشته في زمن القضاء حتى

(١)أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم: ٧١٦٣، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، حديث رقم: ١٠٤٥.
(٢) انظر: الأوسط، ابن المنذر،٦/٦٠٠.
(٣) انظر: الهداية للمرغيناني، ٤/٣٨٢.
(٤) انظر: الممتع شرح المقنع لابن المنجي، ٤/٥١٢.

لو كان غنياً؛ خاصة أن القاضي كثيراً ما ينفق على مستلزمات عمله من ورق المحاضر والسجلات والأقلام والملبس والمواصلات(١).

الوجه الرابع: إن إكفاء القاضي وأسرته الملزمة منه بالرزق من بيت المال يحفظ نزاهة القضاء فلا يطمع القاضي في أموال المتخاصمين، وإذا فعل ذلك مع إكفائه في الرزق لم يكن له عذر عند مؤاخذته(٢).

الوجه الخامس: إن القاضي عامل في خدمة الناس، فكانت كفايته عليهم بالرزق لا من طريق الأجر، ولو لم يجز فرض الرزق له من بيت المال لتعطلت وضاعت الحقوق(٣).

القول الثاني:

لا يَجوزُ أخذ الرِّزقِ مِن بَيتِ المالِ إذا كانَ القاضي غَنيًّا، **وإليه ذهب بعض الحنفية والمازري وغيره من بعض المالكية، وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة حكاها أبو الخطاب، وإليه مال ابن القيم**(٤).

(١) انظر: لمغني لابن قدامة،٩/١٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ٤٦٢/٣.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣.
(٣) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٢/ ١١.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٣ - ١٤. تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، الذّخيرة للقرافي١٠/ ٧٨، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠. كتاب أدب القاضي (من التهذيب) للإمام البغوي ص: ١٥١، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧. مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٨٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢١٥. المغنى لابن قدامة ١٤/ ٩، الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩٠ - ٢٩١. بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢.

واستدلوا من المعقول:

١ـ إنَّ القضاء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة(١).

ونُوقش هذا: أن هذا الدّليل لا يصح إيراده هنا؛ لأنّه خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وهذا لا خلاف فيه، وإنّما الكلام هنا عن الرزق، وهو جائز على أعمال القرب؛ لأنّه ليس من باب المعاوضة، إنّما هو من باب الإعانة على الطّاعة(٢).

٢ـ إنَّ القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال لحاجته إليه، فإذا كان غنيًا، فلا حاجة له إلى أخذ الرزق، فلا يجوز(٣).

ونُوقش هذا: بأن القاضي لا يأخذ الرزق لحاجته فقط وإنّما يأخذ؛ لأنّه حبس نفسه لمصلحة المسلمين، ولم يردّ نصّ يخص الرزق بالعامل الفقير فقط دون الغني، بل وردت كثير من الأدلة تدل على جواز أخذ العامل للرزق مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا. (٤)

(١) انظر: الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٧٨، المبدع لابن مفلح ١٠/ ١٣.
(٢) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٩، روضة القضاة للسمناني ١/ ٨٧.
(٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٤.
(٤) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧، أدب القاضي لابن القاص ١/ ١٠٩، روضة القضاة للسمناني ١/ ٨٧.

٣ـ عدم إعطاء الرزق على القضاء أبلغ في المهابة له وأدعى للنفوس على اعتقاد التعظيم والجلالة لمقامه(١).

ونُوقش هذا: أن القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال، وبيت المال جهة عامة وأمواله مصروفة في مصالح المسلمين العامة، وهذا منها، فالأخذ منه لا يترتب عليه شيء ممّا ذكر في الدّليل، وإنّما قد يردّ ذلك إذا كان ما يأخذه القاضي من الخصوم وليس من بيت المال(٢).

٤ـ إنَّ القاضي كولي اليتيم، لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال على القضاء، إِلَّا إذا كان فقيرًا، فالوصي يعمل في مال اليتيم كما أن القاضي يعمل للمسلمين، فكل منهما منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم، فإن احتاج أخذ وإن استغنى ترك(٣).

ونُوقش هذا: بأن القاضي فرع متردد بين أصلّين، عامل الزَّكاة وناظر اليتيم، وإلحاقه بعامل الزَّكاة أولى لعموم الحاجة إلى القاضي وحصول المصلحة العامة به، وللأدلة الدالة على جواز الرزق مع الغني(٤).

(١) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.
(٢) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٧/ ١٣، بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٤) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٧.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلاف الفقهاء في تكييف طبيعة عمل القاضي: هل هو عبادة محضة أم مصلحة عامة تستوجب التفرغ؟ فمن منع أو كره أخذ المال: نظروا إلى القضاء باعتباره "قربة" وطاعة لله، والأصل في الطاعات: مثل الصلاة والصيام، عدم أخذ العوض المادي عليها لتظل خالصة لوجه الله. ومن أجاز أخذ الرزق "الجمهور "نظروا إلى القضاء على أنه "من المصالح العامة" الضرورية للمسلمين، ولأن القاضي يحبس نفسه ويفرغ وقته لفصل الخصومات وإقامة العدل، فلو لم يُعطَ رزقاً يكفيه لتعطلت مصالح الناس واضطر للكسب فيضيع الحق(١).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وذكر ما استدل به أصحاب كلّ قول، وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات وما أجيب به عنها يتبين لنا ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأوّل وهو جواز أخذ الرزق على القضاء من بيت المال وإن كان القاضي غنيا، **وذلك لما يأتي:**

(١) انظر: نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٧٧.

١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول، حيث جاءت أدلتهم في معظمها صريحة في الدلالة على المطلوب، ومن ذلك حديث ابن السعدي حيث جاء نصا صريحًا في جواز الأخذ مع الغنى، بل في استحباب ذلك.

٢ - إن هذه السنن الصحيحة الصريحة جاءت مؤيدة بفعل أصحاب النّبيّ ﷺ حيث اتخذوا القضاة وارزقوهم من بيت المال ووسعوا عليهم في ذلك كما تقدّم.

٣ - إن أخذ الرزق مع الغنى أعون في العمل وألزم للنصيحة من التارك.

٤ـ إن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز الرزق على القضاء مطلقًا دون تفريق بين غنى وفقير ومن ذلك ما نقله العلامة ابن حجر عن بعض العلماء فقال: "وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعًا، ومن تركه إنّما تركه تورعًا"(١) وقال العلامة القرافي: "القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعًا"(٢)

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.
(٢) انظر: الفروق للقرافي ٣/ ٣

٥ـ إن أدلة القول الآخر جاءت كلها أدلة عقلية، وقد أمكن مناقشتها جميعًا بما يضعف من دلالتها، وعلى فرض التسليم بعد مناقشتها فإنها لا تنهض لمعارضة الأدلة النصية من السُّنَّة والأثر الّتي استدل بها أصحاب القول الأوّل.

وعلى هذا: فإنّه ينبغي للإمام أن يعطي القاضي كفايته وكفاية من يعول من بيت المال، ويوسع عليه في ذلك، ويكفيه همّ دنياه ممّا يجعله مرتاح البال خالي الذهن، ومن نظر في الصفات المطلوبة في القاضي، وما يجب أن يكون عليه حال القضاء بين النَّاس أيقن بصحة هذا القول. والله تعالى أعلم.

حكم أخذ القاضي أجراً على القضاء:

هذه المسألة تختلف عن سابقتها، وقد بينا أن" الرزق" يختلف عن الأجر، فإذا كان "الرزق" هو: العطايا والمنح المنقطعة أو الجارية، وبتعبير أدق: هو: "ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة " فإن الأجر: هو عوض العمل أو المنفعة" وكما يكون الثمن باتفاق المتبايعين يكون الأجر باتفاق المتعاقدين غالباً.

وبهذا يتضح أن الفرق الأساسي بين الرزق وبين الأجر عند الفقهاء يرجع إلى تكييف العلاقة بين طرفي المعاملة المرتب عليها الأجر أو الرزق، فإن كانت تعاقدية، فإن ما يأخذه العامل يكون أجرًا وتجرى فيه المشارطة، وإن

كانت تكليفية بحكم الولاية، فإن ما يأخذه العامل يكون رزقًا ويكون إذعانًا من الولي لا يخضع إلا لحد الكفاية الإنساني(١).

وأخذ القاضي أجراً على القضاء لا يخرج عن حالين:

الحال الأولى: أن يأخذ القاضي أجراً على القضاء من خزينة الدولة.

الحال الثانية: أن يأخذ القاضي أجراً على القضاء من الخصوم.

وبيان ذلك فيما يلي:

الحال الأولى: حكم أخذ القاضي أجراً على القضاء من خزينة الدولة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء من خزينة الدولة على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء. **وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، وهو المذهب عند الشّافعيّة ، وبه قال الحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية(٢)**

(١) انظر: القضاء في الإسلام، المرصفاوي، ص:١٥٥.

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٥٠. الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، الموافقات للشاطبي ٢/ ١٣٦. روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٨٩. المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢. مستند الشيعة، النراقي، ٦٤/١٧، الجامع الكافي في فقه الزيدية، محمد بن علي العلوي، ٢١٦/٧.

واستدلوا بما يلي:

١ـ ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم(١).

٢ـ إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة(٢).

٣ـ إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه(٣).

٤ـ إنَّ القضاء عمل غير معلوم، يتعذر ضبطه، فلا يجوز الاستئجار عليه للجهالة(٤).

٥ـ إنَّ أخذ الأجرة على القضاء يؤدِّي إلى دخول التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض، فيكون كمن أخذ رشوة على الحكم، وعليه فيمتنع الاستئجار لذلك(٥).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٦/ ٥٠٥ ، حديث رقم: ١٨٤٥، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب هل يؤخذ على القضاء رزق ٨/ ٢٩٧ ، حديث رقم: ١٥٢٨١.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠
(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٤) انظر: الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٥) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠، الفروق للقرافي ٣/ ٣.

القول الثّاني:

يجوز الاستئجار على القضاء. **وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب ، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه ، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (١)**

واستدلوا بما يلي:

١ـ إن لاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره – رضي الله عنه – بالمؤاجرة فيجوز(٢).

ونُوقش هذا: بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء.

٢ـ إن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار(٣).

ونُوقش هذا: بأن تحريم الاستئجار على القضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة.

(١) انظر: روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧. المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٣) انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٦/ ١٥٧.

سبب الخلاف:

مَرَدُّ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى تعارض إلى تعارض مبدأين شرعيين، هما: هل القضاء "قربة وطاعة" لا تجوز المعاوضة عليها كالعبادات، أم هو "ولاية ومصلحة عامة" تتطلب تفرغاً وحاجةً للرزق لضمان العدل؟، فالجمهور يرون أن القضاء من القرب والطاعات، ولذا فلا يجوز أخذ الأجر عليه، وبعض الشافعية والظاهرية يرون أن القضاء ولاية عامة، تتطلب تفرغاً وحاجة للزق، ولذا، قالوا بجواز أخذ الأجر عليها. والله أعلم.

الترجيح:

بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين لي ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأوّل القاضي بالمنع من الاستئجار على القضاء، **وذلك لما يأتي**:

١ – قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

٢ – ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر حيث أمكن مناقشة ما استدلوا به بما يوهن من دلالته.

٣ – إنّه قد نقل الإجماع والاتفاق بين العلماء على المنع من الاستئجار على القضاء، وممن نقل الإجماع: القرافي، وابن حجر، وابن قدامة(١). **والله أعلم**.

(١) انظر: الفروق للقرافي ٣/ ٣، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١. المغني١٤/ ١٠.

الحال الثانية: حكم أخذ القاضي أجراً على القضاء من الخصوم:

اختَلَفَ الفُقَهاءُ في طَلَبِ الأُجرةِ على القَضاءِ مِنَ الخُصومِ، على **قَولَين**:

القَولُ الأوَّلُ:

لا يَجوزُ طَلَبُ الأُجرةِ على القَضاءِ مِنَ الخُصومِ. **وإليه ذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشيعة الإمامية والزيدية، وهو وَجهٌ للحَنابِلةِ صَوَّبه ابنُ مُفلِحٍ، والمرداويُّ**(١).

واستدلوا بما يلي:

١ـ **عَن بُرَيدةَ** بنِ الحُصَيبِ الأسلَميِّ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قال: "مَنِ استَعمَلناهُ على عَمَلٍ فرَزَقناهُ رِزقًا، فما أخَذَ بَعدَ ذلك فهو غُلولٌ"(٢)

وَجهُ الدَّلالةِ: إنَّ الحَديثَ دَلَّ على أنَّ ما يَأخُذُه القاضي مِن غَيرِ بَيتِ مالِ المُسلِمينَ يُعَدُّ غُلولًا وخيانةً(٣).

(١) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، ٥/ ٢٦٥، البحر الرائق لابن نجيم، ٨/ ١٦٨، مجمع الأنهر لداماد أفندي،٤٨٨/٢، الدر المختار للحصكفي: ص: ٦٣٠. شرح مختصر خليل للخرشي ، ١٤١/٧، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.: أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦. روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧ ـ ١٣٨، نهاية المحتاج للرملي ٨/ ٢٥١. عقد الجواهر الثمينةلابن شاس ، ٩٣١/٣، لوامع الدرر لمحمد بن سالم المجلسي (٣٢/١٢). مستند الشيعة، النراقي ، ٦٤/١٧، الجامع الكافي في فقه الزيدية، محمد بن علي العلوي، ٢١٦/٧. الفروع لابن مفلح (١١/ ١٢٨)، الإنصاف للمرداوي، ١١/ ١٦٦، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.

(٢)أخرجه أبو داود في سننه، برقم : ٢٩٤٣، والحاكم في المستدركة برقم: ١٤٩١. صحَّحه الحاكمُ على شرط الشَّيخين، وابن دقيق العيد في الاقتراح، برقم: ٩٤، وابنُ المُلَقِّنِ على شَرطِ الشَّيخَينِ في البدر المنير، ٦٥٤/٩.

(٣) انظر: أدب القاضي لابن القاص،١/ ١٠٨.

٢ـ وعن أنس عن النبي ﷺ قال: " مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ عَلَيْهِ الشُّفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَلَكًا يُسَدِّدُهُ " (١)

وجه الاستدلال: إن الحديث الشريف، قد أخبر أن من طلب على القضاء شُفعاء من الناس، فهو غَيْرُ مُعَانٍ، ولا يُسَدِّدُه الله في حكمه، وهذا في مقام التخويف والتنفير، والنهي، فيكون أخذ الأجر على المنهي عنه حراماً(٢).

٣ـ واستدلوا من القياس، فقالوا:

بقياسُ القَضاءِ على الصَّلاةِ في تَحريمِ أخذِ الأجرِ عليها، بجامِعِ كَونِهما قُربةً يَختَصُّ فاعِلُهُما أن يَكونَ مِن أهلِ القُربةِ(٣)

القَولُ الثَّاني:

يَجوزُ طَلَبُ المالِ على القَضاءِ مِنَ الخُصومِ إذا لَم يَكُن للقاضي رِزقٌ مِن بَيتِ المالِ، **وإليه ذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ**(٤)

(١) اخرجه الترمذي في سننه، : سنن الترمذي: ٣/ ٧، الحديث رقم: ١٣٢٤، قال الترمذي حديث حسن غريب"

(٢) انظر: مستند الشيعة، النراقي،٦٤/١٧، الجامع الكافي في فقه الزيدية، محمد العلوي، ٢١٦/٧.

(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٣٤/١٠.

(٤) انظر: أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٢٩٦. العزيز شرح الوجيز للرافعي، ١٢/ ٤٦٦، روضة الطالبين للنووي، ١١/ ١٤٢، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢. الفروع لابن مفلح (١١/ ١٢٨)، الإنصاف للمرداوي، ١١/ ١٦٦.

واستدلوا:

١ـ بالقياس من وجهين:

الوجه الأول: القياس على التحكيم، فكما يجوز أخذ الرزق من الخصمين على التحكيم فكذلك القضاء؛ لأنَّ كلا منهما عمل مباح(١).

الوجه الثاني: القياس على الوصي وأمين الحاكم، فكما أنّه يجوز للوصي وأمين الحاكم الأكل من مال اليتيم بقدر الحاجة فكذلك القاضي؛ لأنّه مع عدم الرزق من بيت المال لا يتعين عليه الحكم فجاز أخذ الرزق من الخصوم بقدر الحاجة(٢).

٢ـ وأما المعقول، فقالوا: إنّه إذا لم يأخذ من الخصمين مع حاجته، أدى ذلك إلى تعطيل القضاء والفصل بين النَّاس ولا سبيل إلى التعطيل لما يترتب على ذلك من المفاسد(٣).

سَبَبُ الخلاف:

مَرَدُّ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: إلى تَعارضِ حاجَةِ القاضي للتفرُّغِ للعملِ وخَوفِ الوقوعِ في الرَّشوةِ أو المحاباةِ، مع كون القضاء واجباً

(١) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ١٤٦، إعلام الموقعين ٤/ ٢٣١.
(٢) انظر: المرجعان السابقان، نفس المكان.
(٣) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب ٤/ ٢٩٦.

شرعياً، لا يجوز أخذ الأجر عليه(١)، فمن خاف وقوع القاضي في الرشوة والمحاباة، أباح له أخذ الأجرة من الخصوم، ومن قال: القضاء من الواجبات الكفائية، منع أخذ القاضي للأجرة من الخصوم. والله أعلم.

الترجيح:

يُمكن الجمع بين القولين السابقين، بأن يُقال: يُحمل القول بمنع أخذ القاضي الأجرة من الخصوم على القاضي غير المحتاج، ويُحمل قول من قال بجواز أخذ القاضي الأجرة من الخصوم، على حال القاضي المحتاج، خاصة وأن القائلين بالجواز قد عللوا قولهم بالحاجة إلى المال، والجمع بين القولين، يضبط مسألة أخذ الرزق من غير بيت المال، وكل ذلك حتّى لا يدب الشرّة في نفس القاضي إلى أموال النَّاس، فينفتح بذلك باب الرشوة في الحكم، وهذا فيه من الفساد ما فيه، والفقهاء لا يخالفون في ذلك بل هم أحرص النَّاس على نزاهة القاضي وإعفافه وضبط سلوكه، بما يضمن عدم الميل في الحكم. وبهذا تأتلف الأقوال في القول بجواز أخذ الرزق من الخصوم للحاجة والضرورة، خروجاً من الخلاف الفقهي في هذه المسألة، ومن ثم فلا مصير إلى ترجيح أحد القولين على الآخر. والله أعلم.

(١) انظر: أدب القاضي لابن القاص ،١/ ١٠٨. الإنصاف للمرداوي، ١١/ ١٦٦.

المبحث السابع:

قضاء القاضي بعلمه

معنى قضاء القاضي بعلمه:

إذا رأى القاضي جريمة، أو حادثة أو امرأة تزني، أو رجُلاً طلق امرأته، أو علم فسق شاهد، فهل يجوز له أن يقضي بعلمه أمّ لا؟

وإذن فالمقصود بقضاء القاضي بعلمه: أن يعتمد في حكمه على ما علمه يقيناً، أو ظَنَّهُ ظناً مؤكداً(١).

ولمزيد من الإيضاح، نقول: المقصود: هو علم القاضي بالسبب الموجب للحكم، فإذا علم القاضي بحقيقة الحادثة وأسبابها واقرارات أفرادها؛ بحيث اطلع على واقعة وسمع إقرارات وألفاظ أطراف القضية خارج مجلس القضاء، أو رأى الجريمة عند وقوعها، ثم رفعت الدعوى لدى القاضي للنظر فيها، والحكم بمضمونها، ثم جاء أحد الخصوم ببينة قاطعة في الموضوع، وهذه البينة مخالفة لما يعلمه القاضي مما اطلع عليه، فهل يحق للقاضي أن يحكم بناء على البينات المقدمة له وان كانت مخالفة لعلم القاضي؟ أم يجب على القاضي التنحي عن القضية وعدم الحكم بها؟(٢)

(١) انظر: الرملي، نهاية المحتاج،٢٥٩/٨.
(٢) انظر: تحفة المحتاج ، ابن حجر، ١٤٧/١٠، أسنى المطالب، الأنصاري، ٣٠٧/٤.

تحرير محل النزاع:

أولًا: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء على جواز قضاء القاضي بعلمه، في الأحوال الآتية:

الحال الأولى: الجرح والتعديل في الشهود:

اتفق الفقهاء على جواز الحكم بعلم القاضي في الجرح والتعديل، فإذا علم حال الشهود عدالة أو جرحًا فيجب عليه أن يعمل بموجب علمه، فيقبل العدل، ويسمع شهادته دون أن يأمر بتعديله أو تزكيته، ولو طلب الخصم ذلك، ويرد كل طعن فيه أو تجريح إلا إذا بيَّن المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح، وإذا علم فسق الشاهد وتجريحه، فلا يقبل شهادته، ولا يسأل عنه، ولا يسمع تعديله ولو طلب الخصم ذلك(١).

وقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، ومنهم: الماوَرديُّ، وابنُ عَبدِ البَرِّ، والمازَريُّ، والعِمرانيُّ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ القَطَّانِ، والعِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ ، والعَينيُّ (٢).

(١) انظر: بداية المجتهد، ابن رشد،٤٧٠/٢، الحاوي الكبير، ٣٩٤/٢٠، المغني،٣٣/١٤، موسوعة الإجماع، مجموعة من المؤلفين،٩٣/٧.

(٢) انظر: الحاوي، الماوردي، ٣٢١/١٦، الكافي، ابن عبد البر، ٩٠١/٢، الاستذكار، ابن عبد البر،٩٣/٧، منح الجليل، الشيخ عليش، ٣٦٠/٨، البيان، العمراني، ٤٣/١٣ـ٤٤، بداية المجتهد، ابن رشد،٢٥٣/٤، المغني، ابن قدامة، ١٥٠/١٠، الإقناع في مسائل الإجماع ، أبي الحسن ابن القطان، ١٦٤/٢، الغاية في اختصار النهاية، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، ٤٢٤/٧، المبدع، ابن مفلح، ١٦٨/٨، عمدة القاري، بدر الدين العيني،١٣/٦، المغنين ابن قدامة، ٥٠/١٠.

وحجة الفقهاء في ذلك: إن لحُكمَ بعِلمِ القاضي في جَرحِ الشُّهودِ وتَعديلِهم أمرٌ ضَروريٌّ للبَتِّ في الشَّهادةِ؛ لأنَّه لَو لم يَحكُمْ بعِلمِه فيهم لَلَزِمَ مِن ذلك التَّسَلسُلُ، فيَحتاجُ كُلُّ مُزَكٍّ إلى مُزَكِّينَ، ولا نِهايةَ لذلك(١).

الحال الثانية: شهادة الشهود:

اتفق الفقهاء على ألا يقضي القاضي بخلاف علمه ولو مع البينة المخالفة، فإذا علم بطلاق، أو بدين، أو بإتلاف، أو بقتل، ثم قامت البينة على ما يخالف علمه، فلا يجوز له أن يقضي بالبينة قطعًا(٢).

وقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك(٣)، فلو سمع القاضي رجلاً يُطلق زوجته، ثم جاء الشهود وشهدوا أنه لم يطلق زوجته، وجب على القاضي في تلك الحال أن يعتزل النظر في القضية، أو يفوض غيره فيها، ويكون شاهدًا، أو يرفض سماع الدعوى، ويترك شهادة الشهود، وكذا لو رأى إنساناً يكسر سيارة آخر، ثم شهدت البينة أمامه، بأن الرجل الذي رآه القاضي يكسر

(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٥٠/١٠.
(٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٨٠/٨، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الأنصاري، ٢٤٢/٥، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي للمنهاج، القليوبي وعميرة، ٢٠٠/٣، تحفة المحتاج، ابن حجر، ١٤٧/١٠، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان الجمل، ٣٤٩/٥، حاشية البجيرمي على المنهاج، ٣٥٣/٤. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، ٢٥٣/٦.
(٣) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، الأنصاري، ٣٠٦/٤، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ٢٩٦/٦، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٢٦٠/٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، ٢٥٣/٦، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، ١١٧/٣ـ ١١٨.

السيارة، لم يفعل ذلك، وجب عليه حينئذ أن يفعل مثل ما سبق، وكذا فإن القاضي إذا رأى رجلًا قتل رجلًا، فادعى الولي القتل على غير القاتل، فأقر المدعى عليه بالقتل، أو قامت به بينة عادلة، فلا يجوز له قتل غير القاتل لعلمه بكذب المقر والبينة، فلو حكم بذلك لكان حكمًا بغير حجة شرعية، بل هو أقبح من الحكم بغير حجة شرعية؛ لأنه إذا حكم بغير حجة شرعية جاز أن يكون ما حكم به حقًا موافقا للباطل (١).

والسبب في ذلك: إن القاضي متيقن ببطلان البينة، أي بطلان شهادة الشهود، وكذا بطلان الحكم بها، والحكم بالباطل حرام، فيجب عليه أن يعتزل النظر في القضية، أو يفوض غيره فيها، ويكون شاهدًا، أو يرفض سماع الدعوى أصلاً(٢).

وقد احتج الفقهاء لذلك:" بما رواه البخاري من أن سيدنا عمر رضي الله عنه، قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو رأيتَ رجلاً على حد سرقة، أو زنا وأنتَ أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صَدَقْتَ"(٣).

(١) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ٣٧/٢-٣٨.
(٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، ٢/ ٤٧٠. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، ٣٧/٢-٣٨.
(٣) انظر: أخرجه البخاري في صحيحه،٢٦٢٣/٦، الحديث رقم: ٦٧٤٩.

الحال الثالثة: حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس حكمه:

اتفق جمهور الفقهاء: المالِكيَّةِ في المشهورِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ على جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس حكمه، فإذا بدرتْ إساءة من أحد أطراف النزاع، نَهَرَهُ القاضي، وإذا تطاول أحدهم بالكلام على القاضي أو على الخصم مَنَعه، ويؤدِّبُ مَنْ تبين لَدَدَهُ (١)أو كذبه من المتخاصمين، وإذا حدث ضرب أو جرح في مجلس القضاء حكم القاضي على المعتدي، واستند في حكمه على ما سمع، ولا يحتاج إلى بينة(٢).

وقد احتج الجمهور لذلك بما يلي:

١ـ بقوله تعالى (كُونُوا قَوَّامِينَ بالقِسْطِ شُهَداءَ للهِ) (٣).

وجه الاستدلال: إنه ليس مِنَ القِسطِ أن يَترُكَ القاضي الإنسان الظَّالِمَ على ظُلمِه لا يُغَيِّرُه، فيَنبَغي على القاضي أن يُعطيَ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، وإلَّا فهو ظالِمٌ(٤).

(١) اللَّدَدُ في اللغة العربية: هو الخصومة الشديدة مع العناد والميل عن الحق، ويُقصد به التمادي في الجدال والتعنت حتى بعد ظهور الحقيقة انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ٣٩٩/٢.

(٢) انظر: التاج والإكليل، المواق، ١٣٨/٨، منح الجليل، الشيخ عليش، ٣٤٤/٨، تحفة المحتاج، ابن حجر، ١٤٩/١٠، نهاية المحتاج، الرملي، ٢٦٠/٨، المبدع، ابن مفلح، ١٨٤/٨، الإنصاف ، المرداوي،٢٥٠/١١، المبسوط، السرخسي،٩١/١٦، بدائع الصنائع، الكاساني، ٧/٦، رد المحتار، ابن عابدين، ٧١/١.

(٣) من الآية:٣٥، من سورة النساء.

(٤) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٥٢٦/٨، الاستذكار، ابن عبد البر، ٩٣/٧.

٢ـ عَنِ الأشعَثِ بنِ قَيسٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: فِيَّ أُنزِلَت -يَعني قَولَه تَعالى: إنَّ الذينَ يَشتَرونَ بعَهدِ اللهِ وأيمانِهِم ثَمَنًا قَليلًا أولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُم في الآخِرةِ إلى آخِرِ الآيةِ- كانَت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عَمٍّ لي، قال النَّبيُّ ﷺ: «بَيِّنَتُكَ أو يَمينُه»(١).

وجه الاستدلال: إنَّ مِنَ البَيِّنةِ التي لا بَيِّنَةَ أبيَنُ مِنها: صِحَّةَ عِلمِ الحاكِمِ بصِحَّةِ حَقِّهِ، فهو في جُملةِ هذا الخَبَرِ(٢).

٣ـ عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنهُ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: "مَن رَأى مِنكُم مُنكَرًا فليُغَيِّرْه بيَدِه، فإن لَم يَستَطِعْ فبِلِسانِه، فإن لَم يَستَطِعْ فبِقَلبِه، وذلك أضعَفُ الإيمانِ"(٣).

وجه الاستدلال: إنَّ الحاكِمَ إن لَم يُغَيِّرْ ما رَأى مِنَ المُنكَرِ حَتَّى تَأتيَ البَيِّنةُ على ذلك، فقد عَصى رَسولَ اللهِ ﷺ (٤).

٤ـ عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: "...وأن نَقومَ -أو نَقولَ- بالحَقِّ حَيثُما كُنَّا، لا نَخافُ في اللهِ لَومةَ لائِمٍ"(٥) .

---

(١) انظر: أخرجه البخاري، في صحيحه، برقم: ٤٥٥٠، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، برقم: ١٣٨.
(٢) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٥٢٦/٨
(٣) رواه مسلم في صحيحه، برقم:٤٩.
(٤) انظر: المحلى، ابن حزم، ٥٢٦/٨.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: ٧٢٠٠. واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه، برقم: ١٧٠٩.

وجه الاستدلال: إنَّ ما عَلِمَه القاضي: مِنَ الحَقِّ الذي يَجِبُ أن يَقومَ به، فيكون قضاء القاضي بعلمه واجب عليه هنا(١).

٥ـ واستدلوا من المعقول، فقالوا: "أَنَّه جازَ لَه القَضاءُ بالبَيِّنةِ، فيَجوزُ القَضاءُ بعِلمِه بطَريقِ الأَولى؛ وهذا لأنَّ المَقصودَ مِنَ البَيِّنةِ ليس عَينَها، بَل حُصولُ العِلمِ بحُكمِ الحادِثةِ، وعِلمُه الحاصِلُ بالمُعايَنةِ أقوى مِن عِلمِه الحاصِلِ بالشَّهادةِ؛ لأنَّ الحاصِلَ بالشَّهادةِ عِلمُ غالِبِ الرَّأيِ وأكثَرِ الظَّنِّ، والحاصِلَ بالحِسِّ والمُشاهَدةِ عِلمُ القَطعِ واليَقينِ، فكانَ هذا أقوى؛ فكانَ القَضاءُ به أولى"(٢).

الحال الرابعة: قضاء الحسبة:

اتفق على جواز الحكم بعلم القاضي في حق الله تعالى حسبة، كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج، ثم يدعي الزوجية، فيمنعه من الاتصال بزوجته، وكما إذا سمع القاضي وقف أرض، ثم ادعى رجل ملكيتها(٣).

(١) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، ٧/ ٩٣
(٢) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، ٧/ ٩٣، بدائع الصنائع، للكاساني، ٧/٧.
(٣) انظر: المبسوط، السرخسي، ٤٣٨/٥، شرح الخرشي، الخرشي، ١٦٩/٧، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم الجذامي، ١٠١٩/٣، التاج والإكليل، المواق، ٤٠/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٢٤٦/١،بداية المجتهد، ابن رشد، ٥٠٩/٢، كشاف القناع، البهوتي، ٣٢٩/٦، المحلى، ابن حزم، ٢٤٩/٩.

الحال الخامسة: تغليب حجة أحد الخصمين على الآخر:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للقاضي أن يقضي القاضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر، إذا لم يكن في ذلك خلاف، لكن هذا يرجع إلى علمه بالأحكام، ومنها طرق الترجيح عند التعارض وغيره(١)

ثانياً: محل الخلاف:

ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في جواز الحكم بعلم القاضي فيما علمه خارج القضاء، سواء أكان الموضوع حدًّا، أم قصاصًا، أم حقًّا ماليًّا، أم حقًّا غير مالي سواء علمه قبل توليه القضاء أم بعده، على **ثلاثة أقوال**:

القول الأول: إنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه مطلقاً، مهما كان نوع الحق وموضوع الدعوى، وكيفما كان حصول علمه، سواء أكان المحكوم به حقاً لله أم للعباد، فلا يحكم في حَدٍّ، ولا في غيره، فيما سمعه قبل الولاية ولا بعدها.

وإليه ذهب المالكية، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، والرواية المُفْتَى بها في مذهب الحنفية، وهو رأي بعض الصحابة

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ٤٣٨/٥، شرح الخرشي، الخرشي، ١٦٩/٧، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم الجذامي، ١٠١٩/٣، التاج والإكليل، المواق، ٤٠/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٢٤٦/١،بداية المجتهد، ابن رشد، ٥٠٩/٢، كشاف القناع، البهوتي، ٣٢٩/٦، المحلى، ابن حزم، ٢٤٩/٩.

ومنهم: أبي بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف. وهو رأي بعض التابعين، ومنهم: شريح، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق، وأهل الحجاز(١).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ـ بقول الرسول ﷺ " إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَّكُم تَختَصِمونَ إليَّ، ولَعَلَّ بَعضَكُم أن يَكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه مِن بَعضٍ، فأقضيَ على نَحوِ ما أسمَعُ، فمَن قَضَيتُ له مِن حَقِّ أخيه شيئًا فلا يَأخُذْه؛ فإنَّما أقطَعُ له قِطعةً مِنَ النَّارِ. " (٢)

وجه الاستدلال: دل الحديث بمنطوقه الواضح على: أَن القاضي إنما يقضي بما يسمع وليس بما يعلم(٣).

ونُوقش هذا: بأن الحديث ليس فيه دليل على منع القاضي بعلمه، بل دّل الحديث على أن القاضي يحكم بما يسمع وّلا ينفي ما عداه، في كونه طريقاً

(١) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، الخرشي، ١٦٩/٧، عقد الجواهر الثمينة، عبد الله الجذامي، ٣/ ١٠١٩، التاج والإكليل، المواق، ٦/ ٤٠، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١/ ٢٤٦، مغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٣٩٨ ، نهاية المحتاج، الرملي، ٨/ ٢٤٦، بداية المجتهد، ابن رشد، ٢/ ٥٠٩، كشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٣٢٩، المبسوط، السرخسي، ٤٣٨/٥. المحلى بالآثار، ابن حزم، ٤٢٩/٩.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم: ٧١٦٩.

(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٣٢/١٤.

للحكم، بل إن العلم، أقوى من السماع، فقد يخطئ المرء فيما يسمعه، ولكنه لا يخطئ فيما يعلمه(١).

٢ـ ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت" إنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ أبا جَهْمِ بنَ حذيفةَ مُصَدِّقًا فلاجَّهُ رجلٌ في صَدَقَتِه فَضربَهُ أبو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النبيَّ ﷺ فَقَالوا القَوَدَ يا رسولَ الله فقال النبِيُّ ﷺ لَكُمْ كذا وكذا فلمْ يَرْضَوْا فقال لَكُمْ كذا وكذا فلمْ يَرْضَوْا فقال لَكُمْ كذا وكذا فَرَضُوا فقال النبِيُّ ﷺ إنِّي خَاطِبٌ العَشِيَّةَ على الناسِ ومُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ . فَقَالوا: نَعَمْ، فَخطبَ رسولُ الله ﷺ فقال: إنَّ هؤلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عليهم كذا وكذا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟ قالوا: لا! فَهَمَّ المُهاجِرُونَ بِهِمْ، فأمرَهُمْ رسولُ الله ﷺ: أنْ يَكُفُّوا عنهُمْ، فَكَفُّوا، ثُمَّ دعاهُمْ فَزَادَهُمْ، فقال: أَرَضِيتُمْ؟ فَقَالوا: نَعَمْ! قال: إنِّي خَاطِبٌ على الناسِ ومُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ. قالوا: نَعَمْ! فَخطبَ النبيُّ ﷺ فقال: أَرَضِيتُمْ؟ قالوا: نَعَمْ"(٢).

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ١٩٨/٩.
(٢) أخرجه أبو داود في «السنن» كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ رقم ٤٥٢٣، واللفظ له.

وجه الاستدلال: من الحديث ظاهرٌ، حيث لم يأخذ النبي ﷺ ، منهم بما علم منهم، ولا قضى بذلك عليهم، وقد علم رضاهم، فدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه(١)

ونُوقش هذا: بأن غاية ما يُستفاد من الحديث هو مجرد وقوع الإخبار من الرسول ﷺ بما حصل به الرضا من المطالبين بالقصاص، وإن كان المانعون للقضاء بعلم القاضي قد احتجوا بعدم قضاء الرسول ﷺ على هؤلاء المطالبين بالقصاص بما رضوا به في المرة الأولى، فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم(٢).

٣ـ ما رواه جابر رضي الله عنه قال:" أتى رَجُلٌ رَسولَ الله ﷺ بالجِعرانةِ مُنصَرَفَه مِن حُنَينٍ، وفي ثَوبِ بلالٍ فِضَّةٌ، ورَسولُ الله ﷺ يَقبِضُ منها، يُعطي النَّاسَ، فقال: يا مُحَمَّدُ، اعدِلْ، قال: ويلَكَ ومَن يَعدِلُ إذا لَمَ أكُنْ أعدِلُ؟ لقد خِبتَ وخَسِرتَ إن لَمَ أكُنْ أعدِلُ، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: دَعْني يا رَسولَ الله، فأقتُلَ هذا المُنافِقَ، فقال: معاذَ الله أن يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أنِّي أقتُلُ أصحابي، إنَّ هذا وأصحابَه يَقرَؤونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُم، يَمرُقونَ منه كما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّميَّةِ" (٣)

(١) انظر: الاستذكار، ابن عبد البر، ٩٧/٦.
(٢) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٤٠٢/٨.
(٣) اخرجه مسلم في صحيحه، برقم: ١٠٦٣.

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ منع أصحابه من قتل صاحب هذه المقالة، بناء على علمه أن هذا الرجل من الصحابة، وبناء على ما علمه من مقالة الناس «إن الرسول ﷺ يقتل أصحابه»(١)

ونُوقش هذا: بأن هذا الحديث لا يدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه بل غاية ما فيه الإقلاع عن القتل لمن كان في الظاهر من الصحابة؛ لئلا يقول الناس تلك المقالة، والإخبار للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج، وترك أخذهم بذلك لتلك العلة(٢).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن حديث جابر، يقويه ما روي عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لأبي حين رآه: «والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرًا مما صنعت به»(٣) فهذا يدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه(٤).

٤ـ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قضية الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه"(٥).

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٤٠٢/٨.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٤٠٠/١١.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: ٤٤١٩ واللفظ له.
(٤) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر.،ص:٢٠١.
(٥)أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن، برقم ٢٥١٥، ٢٥١٦.

وجه الاستدلال: إن النبي ﷺ قد عوَّل في الإثبات على شادي المدعي أو يمين المدعى عليه، ولم يعوِّل على القضاء بعلم القاضي(١).

ونُوقش هذا: بأن نص النبي ﷺ على الشاهدين أو اليمين، لا ينفي ذكر ما عدا ذلك من وسائل الإثبات، حتى يصح الاستدلال به على عدم قضاء القاضي بعلمه، بل المراد أنه ليس للمدعي تجاه المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرا، إذا لم يكن للمدعي برهان(٢).

٥ـ كما استدلوا بالإجماع على أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً، وقد نقل الإجماع القرطبي وغيره(٣).

ونُوقشَ هذا: بأن هذا الإجماع منقوض بقول الحافظ في «الفتح»: «كذا قال، فجرى على عادته ـ يقصد ابن العربي ـ في التهويل، والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف(٤).

٦ـ **بما رواه البخاري** من أن سيدنا عمر رضي الله عنه، قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو رأيتَ رجلاً على حد سرقة، أو زنا وأنتَ أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صَدَقْتَ"(٥).

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ١٩٨/٩، المغنى ابن قدامة، ٤٠٠/١١ــ ٤٠٢.
(٢) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ١٩٨/٩.
(٣) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ٦٥/١٥.
(٤) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٥) انظر: أخرجه البخاري في صحيحه،٢٦٢٣/٦، الحديث رقم: ٦٧٤٩.

وجه الاستدلال: إن هذا الأثر قد دل على أن القاضي لا يقضي بعلمه مطلقًا(١).

٧ـ كما استدلوا من المعقول، فقالوا:" إن القاضي غير معصوم، فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه، فيُمنَعُ من ذلك، أو يمنع من القضاء بعلمه سدًّا للذرائع على قضاة السوء أن يحكم أحدهم بما شاء، ويحيله على علمه(٢).

القول الثاني: يجوز قضاء القاضي بعلمه مطلقاً، سواء علمه قبل توليه القضاء أم بعده، وسواء علمه في مكان ولايته أو خارجها.

وإليه ذهب إلى ذلك بعض أهل العراق مثل يوسف، ومن تبعه وابن الماجشون من المالكية والشافعية في الرواية الثانية، وهي الصحيح من المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الزيدية(٣).

واستدلوا لقولهم بما يلي:

١ـ عن أم المؤمنين، السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت" جاءت هندٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما

(١) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر.،ص:٢٠١.
(٢) انظر: فتح الباري، ابن حجر،٣٧/١٥
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ١٣٣/٨، نيل الأوطار، الشوكاني، ٤٠١/٨، المهذب، الشيرازي، ٣٩٩/٢. تحفة المحتاج، ابن حجر، ٣٦٨/٤، تكملة المجموع، المطيعي، ٦٧/٢٢. نيل الأوطار، الشوكاني، ٣٣٣/٨.البحر الزخار، أحمد بن يحي المرتضى، ٧٠/١٤.

يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ"(١).

وجه الاستدلال: إن رسول الله ﷺ قضى لها ولولدها من غير بينة ولا إقرار، لعلمه بصدقها، فكان ذلك دليلاً على صحة قضاء القاضي بعلمه(٢).

ونُوقشَ هذا: بأنه لا دلالة في هذا الحديث على المطلوب؛ لأنه خرج مخرج الفتيا، وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة كلام المستفتي، فيكون المعنى: إن صح كلام هند كان لها أن تأخذ من مال زوجها وولدها بالمعروف، والذي يدل على أن الحديث فتيا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في حق أبي سفيان من غير حضوره، ولو كان حكما عليه، لاستدعاه ولم يحكم عليه في غيابه (٣).

وأُجيب عنه: بأن هذا بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأخذ، واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه، فلابد من سبق علم(٤).

كما نُوقش أيضاً: بأن الأمر لا يستلزم الحكم؛ لأن المفتي يأمر المستفتي بما هو الحق لديه، وليس ذلك من الحكم في شيء(١).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: ٣٨٢٥، وأخرجه مسلم في صحيحه، الحديث رقم: ١٧١٤.
(٢) انظر: فتح الباري، ابن حجر،٣٧/١٥.
(٣) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٤٠١/٨، المغني، ابن قدامة، ٤٠٢/١١-٤٠٣.
(٤) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ٣٧/١٥.

٢ـ روى ابن عبد البر، في " كتابه " أن عروة ومجاهدا رويا، أن رجلا من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب، أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا. قال عمر: إني لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه، ونحن غلمان، فأتني بأبي سفيان. فأتاه به، فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهض بنا إلى موضع كذا وكذا. فنهضوا، ونظر عمر، فقال: يا أبا سفيان، خذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا. فقال: والله لا أفعل. فقال: والله لتفعلن. فقال: والله لا أفعل. فعلاه بالدرة، وقال: خذه لا أم لك، فضعه هاهنا، فإنك ما علمت قديم الظلم. فأخذ أبو سفيان الحجر، ووضعه حيث قال عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة، فقال: اللهم لك الحمد حيث لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه، وأذللته لي بالإسلام. قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان، وقال: اللهم لك الحمد، إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما أذل به لعمر(٢)."

وجه الاستدلال: إن الإمام عمر رضي الله عنه قد حكم بعلمه على أبي سفيان(٣).

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٤٠١/٨.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٠٢/١٠.
(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.

ونُوقش هذا: بأن ما روي عن عمر كان إنكارا منه لمنكر رآه، ولم يكن حكما، يدل على ذلك أنه لم توجد من الطرفين دعوى وإنكار بشروطهما(١).

٣ـ كما استدلوا من المعقول، فقالوا: " إن الحاكم يحكم بالشاهدين، لأنهما يغلبان على الظن، فَمَا تحققه وقطع به، كان أولى، ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم، فكذلك في ثبوت الحق، قياسا عليه(٢).

ونُوقش هذا: بأن القضاء بالشاهدين لا يؤدى إلى تهمة بخلاف قضاء القاضي بعلمه فإنه يوجد تهمة، إذ لا يؤمن على التقي أن تتطرق إليه التهمة، فمن المحتمل أن يكون هذا وسيلة إلى أن توجه القاضي أهواؤه، فيحكم على من يشاء من غير بينة، ولا غيرها من الحجج، كما أن الجرح والتعديل يحكم القاضي فيه بعلمه باتفاق العلماء؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لأدى هذا إلى التسلسل، والتسلسل باطل، وبيان التسلسل أن القاضي يحتاج إلى معرفة عدالة المزكيين وجرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين، ثم كل واحد من المزكيين الأخيرين، يحتاج أيضًا إلى مزكيين، وهكذا يحدث التسلسل وأما مسألتنا فبخلاف ذلك(٣).

(١) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٠٢/١٠. وبداية المجتهد، ابن رشد، ٥٨٧/٢.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٠٣/١٠.

القول الثالث: يجوز أن يقضي القاضي بعلمه فيما علم به بعد توليه القضاء، وفي مكان ولايته، وكان القاضي مستمرًا في الحكم منذ عمله حتى عرض الواقعة على القضاء دون أن يفرق بينهما عزل، فإذا علم القاضي بواقعة في زمان ومكان ولايته، فإنه يحكم بعلمه وإلا فلا.

وإليه: ذهب الإمام أبو حنيفة، والمتقدمون من الحنفية ووافقهم بعض المالكية في رواية(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ـ ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال" إنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرَأتَه عِندَ النَّبيِّ ﷺ بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ ﷺ: البَيِّنَةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك، فقال: يا رَسولَ الله، إذا رَأى أحَدُنا على امرَأتِه رَجُلًا يَنطَلِقُ يَلتَمِسُ البَيِّنَةَ! فجَعَلَ النَّبيُّ ﷺ يقولُ: البَيِّنَةَ، وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك، فقال هِلالٌ: والذي بَعَثَك بالحَقِّ إنِّي لَصادِقٌ، فلَيُنزِلَنَّ اللهُ ما يُبَرِّئُ ظَهري مِنَ الحَدِّ، فنَزَلَ جِبريلُ وأنزَلَ عليه: {والذينَ يَرمونَ أزواجَهم}، فقَرَأ حتَّى بَلَغَ: {إن كان مِنَ الصَّادِقينَ}(٢). فانصَرَفَ النَّبيُّ ﷺ ، فأرسَلَ إليها، فجاءَ هِلالٌ فشَهِدَ، والنَّبيُّ ﷺ يقولُ: إنَّ اللهَ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهل منكما تائِبٌ؟ ثُمَّ

(١) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ١٣٣/٨، عقد الجواهر الثمينة، ١٠١٨/٣.
(٢) سورة النور، الآيات(٦، ٧، ٨،٩)

قامَت فشَهِدَت، فلَمَّا كانَت عِندَ الخامِسةِ وقَّفوها، وقالوا: إنَّها موجِبةٌ، قال ابنُ عبَّاسٍ: فتلَكَّأت ونَكَصَت، حتَّى ظَنَنَّا أنَّها تَرجِعُ، ثُمَّ قالت: لا أفضَحُ قَومي سائِرَ اليَومِ، فمَضَت، فقال النَّبيُّ ﷺ أبصِروها؛ فإن جاءَت به أكحَلَ العَينَينِ، سابِغَ الأليَتَينِ، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ، فهو لشَريكِ بنِ سَحماءَ(١)، فجاءَت به كَذلك، فقال النَّبيُّ ﷺ لَولا ما مَضى مِن كِتابِ اللهِ لَكان لي ولَها شَأنٌ.(٢)

وجه الاستدلال: إن النبي ﷺ لم يقض في هذه الواقعة بعلمه، وإنما طلب من هلال بن أمية البينة على قوله، رغم علمه ﷺ بزنا المرأة(٣).

ونُوقش هذا: بأن النبي ﷺ لم يَقْضِ في هذه الواقعة بعلمه، لأن التلاعن بين هلال وزوجته قد حصل، وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بعدم الرجم، والنزاع إنما هو في الحكم بالعلم من دون أن يتقدم سبب شرعي ينافيه(٤).

(١) معنى قوله ﷺ: أكحل العينين: هو: الشخص الذي تعلو أجفانه سواداً طبيعياً خلقةً كأنها مكحولة، من غير أن يضع كحلاً. ومعنى قوله: سابغ الإليتين: أي: عظيم وضخم الأليتين. ومعنى قوله: خدلج الساقين: أي: الساق الممتلئة باللحم.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، الحديث رقم: ٤٧٤٧
(٣) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحي المرتضى، ٧٠/١٤.
(٤) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني،٣٣٣/٨.

٢ـ كما استدلوا بالقاعدة الفقهية" الحدود تُدرأ بالشبهات"(١)، فلا يقضي فيها القاضي بعلمه، لكون الحدود مما لا يجوز له القضاء فيه بعلمه(٢).

٣ـ كما استدلوا من المعقول: فقالوا: إن علم القاضي كشهادة الشاهدين، بل أولى؛ لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل وّليته، أو في غير محل وّليته فال يقضي به؛ لأنه في غير مِصْرِه، وفي غير ولايته، شاهد، لا حاكمٌ، وشهادة الفرد لا تُقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإَنه ّلا يعمل بها(٣).

ونُوقش هذا: بما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: أن رجلاً استعداه على أبي سفيان بن حرب، أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا. قال عمر: إني لأعلم الناس بذلك..(٤).

والشاهد من الحديث أن سيدنا عمر قضى على أبي سفيان، بما علمه عنه قبل القضاء حيث قال" إني لأعلم الناس بذلك".

---

(١) قاعدة فقهية جليلة، معناها: عدم تطبيق الحد ما دامت هناك شبه في ثبوت الجريمة، وأصلها: حديث النبي صلى عليه وسلم:" ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا"" رواه ابن ماجة في سننه، عن أبي هريرة بلفظه، ٥٧٩/٣،الحديث رقم: ٢٥٤٤، قال المحقق: وقال الترمذيُّ: ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.

(٢) انظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٣٩٨/٤.

(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، ٨٨/٢، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص:١٦٤.

(٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٠٢/١٠. جامع الأحاديث، ١١٩/٧.

سبب الخلاف:

يرجعُ سببُ الخلاف بين الفقهاء في مسألة قضاء القاضي بعلمه، إلى تعارض مبدأين شرعيين في الإثبات، هما: مبدأ إثبات الحق بطريق الواقع أي بطريق العلم، ومبدأ التهمة، المُوجبة لسوء الظن، وسد الذرائع، فمن أباح للقاضي أن يقضي بعلمه، اعتمد على المبدأ الأول، وهو إثبات الحق بطريق العلم والواقع، لأن علم القاضي أقوى من شهادة الشهود وسائر أنواع البينة، ومن منع القاضي من القضاء بعلمه، أعمل المبدأ الثاني، وهو خوف سوء الظن واتهام القاضي بالهوى، ولذا يجب المنع منه تطبيقاً لقاعدة سد الذرائع(١) في الفقه الإسلامي.

الترجيح:

من المعلوم عند الفقهاء، إنه لا يُصارُ إلى الترجيح، إلا إذا تعذَّرَ الجمع بين الأقوال الفقهية، التي تساوتْ في أدلتها، **ونحنُ هنا: يُمكننا الجمع بين الأقوال في هذه المسألة**، فنقول وبالله التوفيق:

(١) قاعدة فقهية، معناها: مَنعُ الوسائِلِ المُباحةِ في ظاهِرِها والمُفضيةِ غالبًا إلى مَفاسِدَ راجِحةٍ. أنظر: السلسلة الذهبية في القواعد الفقهية، د. مراد محمود حيدر، ص:٣١٠. الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، بلقاسم الزبيدي، ص: ٤٥٩.

إن القاضي الذي تحققتْ فيه صفة العدالة، على النحو الذي ذكرهُ الفقهاء، بحيُ تمنعهُ تلك الصفة من الهوى، والحَيْفِ؛ يجوز له أن يقضي بعلمه، حيث إن العلة من المنع من قضاء القاضي بعلمه، تتمثل: في مظنة اتهام القاضي بالوقوع في الهوى، والجنوح إلى رغبات نفسه، فلذلك منعه الفقهاء من القضاء بعلمه، خوفاً من الوقوع في المحظور الشرعي، وسدَّاً لباب الذريعة، المُفْضِية إلى الفساد، وأيضاً إذا كان المقصود من الحكم بالعدل، هو سلامة وسيلة الإثبات، وصحة أسباب الحكم، فإن علم القاضي بالواقعة يتحصل به اليقين لدى القاضي، وأما وسائل الإثبات الأخرى، كالشهادة واليمين، ونحوها، فيحصل بها الظن بغلبة الحكم لدى القاضي، ومعلوم أن اليقين أقوى في الإثبات من الظن.

وأما إذا كان القاضي، مشكوكٌ في عدالته، على نحو يمكنُ اتهامه فيه بالوقوع في الهوى، والميل إلى الجَور، وهو ما يُطلق عليه عند الفقهاء" القاضي الفاسق"، إن قول القائلين بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، يكون هو القوى، حينئذ، ويَجِبُ المصير إليه، منعاً للتهمة، وسداً للذريعة.

مَبْنى الجمع بين أقوال الفقهاء السابقة:

وهذا الجمع بين الأقوال الفقهية في المسألة مَبْنيٌّ على القول بأن وسائل الإثبات التي جعلها الشارع أسباباً للحكم كالبينة، واليمين، ونحوها، إنما هي أسبابٌ، يتوصل الحاكم بها إلى معرفة المُحق من المُبطل، والمُصيب من المُخطئ، وإنها غير مقصودة لذاتها؛ بل لأمر آخر وهو حصول ما يحصلُ للحاكم بها من علم أو ظن، وأنها أقل ما يحصل له ذلك في الواقع، فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل ما هو المعتبر، وحينئذٍ يجز للقاضي القضاء بعلمه.

أما إذا قلنا: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسبابا للحكم كالبينة، واليمين، ونحوها، أموراً تَعَّبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بها، وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين، فالواجب علينا الوقوف عندها والتقيد بها، وعدم العمل بغيرها في القضاء كائنا ما كان، وحيئذٍ؛ فلا يجوز للقاضي القضاء بعلمه.

على أن ما قُلناهُ، ليْسَ بِدْعاً من الفقه، فقد سَبَقَنَا إليه جَمْعٌ من الفقهاء، منهم: الإمام الشوكاني، وابن قدامة، وغيرهما(١). والله أعلم.

(١) انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ٣٣٢/٨.المغني، ابن قدامة، ١٠٣/١٠.

المبحث الثامن:

القضاء بالشاهد واليمين.

تَنقسِم الدعاوى إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلَّق بالحقوق الجنائية، وهي جرائم الحدود والقصاص، وقسم يتعلَّق بالحقوق المدنية؛ كالبيع والإجارة والرهن وغيرها من العقود، وقسم يتعلَّق بالحقوق الشخصية؛ كالزواج والنفقة.

كما أن إن وسائل الإثبات للحقوق السابقة في الإسلام محدَّدة ثابتة، منها ما هو متَّفق عليه؛ كالشهادة، واليمين والإقرار، ومنها ما هو مختلف فيه، كالشاهد واليمين، **فهل تَثبت الحقوق المدنية والمالية منها بشهادة الشاهد الواحد، ويَمين المدَّعي، أم لا تثبت؟**(١).

(١) انظر: نَيل الأوطار، الشوكاني ، ٩ / ١٩٠، بداية المجتهد، ابن رشد، ٤٦٧/٢، وما بعدها، تبصرة الحكام، ابن فرحون،١٢٣/١، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص: ١٣٨ وما بعدها.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن اليمين مع الشاهد تكون وسيلة من وسائل الإثبات، **كما اتفقوا** على أنه لا يُقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق الجزائية، وبشكل خاص جرائم الحدود، **كما اتفقوا على** أنه لا يُقضى باليمين مع الشاهد في الدماء والقصاص، وشذَّ في ذلك الظاهرية(١).

واختلفوا: في مجال القضاء باليمين والشاهد على **قولين**:

القول الأول:

إنه يجوز أن يقضي بيمين المدعي مع شاهده، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والظاهرية، والشيعة الإمامية والزيدية ،ويُنسب هذا الرأي إلى فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي(٢).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

- **روى عمرو بن دينار**، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد"(١).

(١) انظر: الشافعي: الأم، الإمام الشافعي، ٣/٧، وما بعدها، المغني ، ابن قدامة، ١٥١/٩.
(٢) انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي، ص: ٢٠٤، حلية العلماء، الشاشي القفال، ٢٨٠/٨، المغني، ابن قدامة،٩ / ١٥١، المحلى، ابن حزم،٩ / ٤٠٣، وما بعدها، نَيل الأوطار، الشوكاني، ١٩٣/٩، السيل الجرار، الشوكاني، ١٨٧/٤. الروض النضير، السياغي، ١٠٣/٤، البحر الزخار، لأحمد بن يحيى المرتضى، ٤٠٣/٥.وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٢٦٤/٢٧، مستند الشيعة، المحقق النراقي، ٢٢٢/١٧.

- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أنَّ النبي ﷺ قضى بشَهادة شاهد واحد، ويَمين صاحب الحق"(٢).

- ورُوي عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد"(٣).

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:

تفيد الأحاديث بوضوح أنَّ رسول الله ﷺ قضى بالشاهد واليمين، فدلَّ ذلك على جواز القضاء بهما؛ لأنه ليس أدل على الجواز من الوقوع.

ونُوقش هذا: بأن القضاء بشاهد ويمين مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى؛ لأنه تعالى أوجب الحق للمدعي بشهادة رجلين، نقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين، فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب، أو نُقول الزيادة عليه خلاف الكتاب.

---

(١) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وقال: إسناده جيد، وانظر: سنن ابن ماجه، ٧٩٣/٢، سبل السلام، للصنعاني١٣١/٤، فتح الباري، ابن حجر، ١٣٦/٥، شرح صحيح مسلم، النووي، ٢٤٤/٦.

(٢) انظر: سنن أبي داود، أبي داود، ١١٩/٢، سنن ابن ماجه، ابن ماجة ،٢ / ٧٩٢، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي، ٩١/٦، سنن الدارقطني ، الدارقطني، ٢١٢/٤، نَيل الأوطار، الشوكاني، ١٩٠/٩. وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي،٢٦٤/٢٧، الكافي، محمد بن يعقوب، الكليني، ٧: ٣٨٦ / ٨ والتهذيب، محمد بن الحسن الطوسي، ٦: ٢٧٢ / ٧٤٠ والاستبصار، محمد الطوسي، ٣: ٣٢ / ١٠٨

(٣) انظر: سنن الدارقطني، ٤ / ٢١٤، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، ابن العربي، ٨٩/٦.

كما أن القضاء بشاهد ويمين ثبت بخبر آحاد، فلا يقوى على معارضة قوله عليه الصلاة والسلام "البيِّنة على المدَّعي"؛ لأنه مشهور قريب من التواتر، وخبر الآحاد إذا ورد معارضًا للخبر المشهور يردُّ(١).

٢ـ واستدلوا بالآثار: فقالوا:

ـ روي أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعي(٢).

ـ ورُوي عن سعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: جواز القضاء بالشاهد واليمين(٣).

وجه الاستدلال بهذه الآثار:

تفيد هذه الآثار بوضوح أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقضون باليمين مع الشاهد الواحد، وهم لا يفعلون ذلك إلا عن توقيف وسَماع من الرسول ﷺ ؛ لأنه لا مدخل للرأي في ذلك، وهذا دليل واضح على جواز القضاء بالشاهد واليمين.

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص: ١٩٦.
(٢) انظر: السنن الكبرى، السنن الكبرى، ١٠ / ١٧٣، سنن الدارقطني، ٢١٥/٤.
(٣) انظر: السنن الكبرى، البيهقي، ١٧٣/١٠، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي، ٨٩/٦.

ونُوقش هذا: بأن القضاء بالشاهد ويَمين المدعي، ورَد في حادثة عامة مختلفة بين السلف، فلو كان ثابتًا لارتفع الخلاف، فلما لم يرتفع دلَّ على عدم ثبوته(١).

٣ـ واستدلوا بالمعقول، فقالوا:

إن اليمين تُشرع في حق من قوي جانبه في الدعوى؛ ولذلك شرعت في حق المُنكِر؛ لأن موقفه في الدعوى أقوى من موقف المدعي؛ لأنَّ الظاهر يؤيد المُنكِر، وكذلك الأمر في حق المدعي؛ لأن جانبه في الدعوى يقوى بشهادة الشاهد على جانب المدَّعى عليه، فتُشرع اليمين في حقه، تأكيدًا لرجحان موقفه في الدعوى، ونفيًا للتهمة، وهذا يكفي في إثبات الدعوى(٢).

القول الثاني:

إنه لا يجوز للقاضي أن يقضي باليمين مع الشاهد، وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية، وبه قال زيد بن علي، والشعبي، والحكم والثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد(٣)

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص: ١٩٦.
(٢) انظر: السنن الكبرى، البيهقي، ١٧٣/١٠، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي،٨٩/٦.
(٣) انظر: البدائع ، الكاساني، ٢٢٥/٦. فتح القدير، ابن الهمام، ٣٦٩/٧، رد المحتار، ابن عابدين، ٤٠١/٥، بداية المجتهد، ابن رشد، ٤٦٧/٢، تَبصرة الحكام، ابن فرحون، ٢٦٨/١، الاختيار، ابن مودود الموصلي، ١١/٢، طرق القضاء، الشيخ أحمد إبراهيم، أصول المُحاكمات

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ قال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (١).

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

تُشير الآية الكريمة إلى نِصاب الشهادة، ولم يرد في الآية الكريمة ذكر للشاهد واليمين، والآية مُحكمة، والقصر في مقام البيان، يفيد الحصر، وإذن فالقول بالقضاء بالشاهد واليمين زيادة على هذه الآية، والزيادة عليها نسخ لها، والقرآن الكريم لا يُنسخ بأخبار الآحاد.

ونُوقش هذا: بأننا نسلم بأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، ولكنه يقيده بطريق المفهوم، والمفهوم عند الحنفية من قبيل المسكوت عنه، فلا دلالة فيه على النفي.

ولو سلمنا أن المفهوم هنا معمول به كالمنطوق، فإن القاعدة أن المفهوم إذا عارضه منطوق فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وهنا في مسألتنا هذه قد عارض المفهوم منطوق حديث: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد.

الشرعية، د. محمد الزحيلي، ص:١٩٥، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، ص:١٨٩.

(١) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.

الحديث لم ينسخ الآية، بل خصص عمومها، وتخصيص القرآن بالسنة جائز، وكذلك الزيادة عليه، كما في قوله تبارك وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} بعد أن ذكر سبحانه وتعالى المحرمات من النساء في الزواج، مع أن الزواج بالعمة مع بنت أخيها محرم بالإجماع، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ.

كما أن الاستدلال بالآية الكريمة، غير صحيح؛ لأن الآية الكريمة تتحدَّث عن وسيلة من وسائل الإثبات متَّفق عليها؛ ولهذا تكون الآية خارج محل النزاع، ولا يجوز الاستدلال بها في هذه المسألة؛ لأنها لم تتعرَّض للقضاء بالشاهد واليمين لا من قريب ولا من بعيد (١)

٢ـ عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه"(٢).

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٣).

(١) انظر: منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب، للدكتور عبد السميع إمام، ص٢٢٧. نقلا عن د. رأفت عثمان، النظام القضائي ، ص:٤٠٧.
(٢) انظر: السنن الكبرى، البيهقي، ٢٥٢/١٠.
(٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ، ٢٤٣/٦، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي، ٨٦/٦، السنن الكبرى، البيهقي، ٢٥٢/١.

وعن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمْنا إلى رسول الله ﷺ فقال: "شاهداك أو يَمينه"" فقلت: إنه إذًا يحلف ولا يُبالي، ويضيع حقي، فقال: "من حلف على يمين يَقتطِع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقيَ الله وهو عليه غضبان" (١)

وجه الاستدلال: استدلوا بهذه الأحاديث من **وجهين**:

الوجه الأول: إنَّ النبي ﷺ أوجب اليمين على المدَّعى عليه، ولو جعلت حجة المدَّعي، لا تبقى واجبةً على المدَّعى عليه، وهو خلاف النص؛ لأن النص جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه ﷺ ذكر اليمين بلام التعريف، فيَقتضي استغراق كل الجنس، فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه، بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له، وهو يمين المدعي، وهذا خلاف النص(٢)

الوجه الثاني: الأحاديث لم تُشر إلى شهادة الشاهد مع يمين المدَّعي، فدلَّ ذلك على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين.

ونُوقش هذا: بأن معنى قول الرسول ﷺ: "البينة على المدعي" معنى عام، ويتناول كل أنواع البينة، وهي تصدق بشاهدين، وشاهد ويمين؛ لأن

(١) أخرجه البخاري في صحيحه،٣/٢٤٥.
(٢) انظر: البدائع، الكاساني، ٦/٢٢٥. المبسوط، السرخسي، ١٧/٢٨.

اليمن يسمى في عرف الشرع شهادة، يؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) ، أي: أربعة أيمان يقسمها الذي يتهم زوجته بجريمة الزنا، وليس معه شهود يشهدون على هذه الجريمة.

وأيضًا فإن معنى قوله ﷺ: "واليمين على من أنكر" يحمل على ما إذا لم يكن مع المدعي أصل الشهادة، ولا خلاف في هذا.

وأما تخيير الرسول ﷺ للمدعي بين الشاهدين، ويمين المدعى عليه، فمحمول كذلك على أن المدعي لم يكن معه أصل الشهادة، فكان التخيير بين أن يأتي بالشهادة التي تصدق بشاهد ويمين، وبين يمين المدعى عليه.

وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين حديث القضاء بشاهد ويمين وبين الأحاديث التي يوهم ظاهرها أنها تعارضه. (١)

واستدلوا من المعقول، فقالوا:

إن القضاء بالشاهد واليمين لا يَصدق عليه اسم البيِّنة؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الحق للمدَّعي بشهادة رجلين، ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين، فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب(٢).

(١) انظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامي ، ص: ٤١٠. أحمد عبد المنعم البهي في كتابه: من طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية وفي القانون. ص٢٣.
(٢) انظر: الاختيار، ابن مودود الموصلي،١١٢/٢.

ونُوقش هذا: بأن البينة: هي كل شيء يبين الحق ويظهره ويدل عليه، وتكون بالشاهدين، والرجل والمرأتين، وتكون بالشاهد مع اليمين(١).

سبب الخلاف:

يرجع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى **الأسباب التالية**:

١ـ إن الأدلة الواردة في هذه المسألة أدلة ظنية، يتطرَّق إليها الاحتمال، والدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال، يتسع للرأي والرأي الآخر، وفيه مجال واسع للاجتهاد بالرأي.

٢ـ تعارض الأدلة الواردة في هذه المسألة مع أدلة إثبات الحقوق المدنية الواردة في القرآن ، ومنها قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) (٢)

٣ـ الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص، وهي قاعدة أصوليَّة مُختلَف فيها بين الحنفية وجماهير العلماء؛ حيث يرى الحنفية أن الزيادة على النص نسخ؛ ولذا فإن القول بالقضاء بشاهد ويمين، زيادة على قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)(٣)والزيادة نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يَجوز، ويرى جماهير العلماء أن الزيادة على النص تقرير وضم وإضافة؛ ولهذا

(١) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص: ٢٠١.
(٢) من الآية:٢٨٢، من سورة البقرة.
(٣) من الآية:٢٨٢، من سورة البقرة.

تثبت الزيادة الواردة في خبر الآحاد؛ لأنها زيادة مستقلة بحكم مستقل، إذا ثبَت سنده وجب القول به(١)

الترجيح:

بعد أن عرضنا أدلة الفقهاء، ومناقشتها في هذه المسألة، حاولنا الجمع، بين أقوالهم، فلم نجدُ إلى ذلك سبيلاً، ولذا؛ فلا مناص من الترجيح، ولذا؛ أرى أن الرأي الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور والذي يقول بالقضاء بالشاهد واليمين في دعاوى الأموال فقط، **وذلك لما يلي:**

١ـ إن الأحاديث الواردة في القَضاء بالشاهد واليمين أدلة صحيحة في مجملها ومَشهورة، تقوم بها الحجة الشرعية.

٢ـ إن القول بالشاهد واليَمين، يؤدي إلى الجمع والتوفيق بين الأدلة الواردة في وسائل الإثبات؛ ليكمل بعضها بعضًا دون تعطيل أو تأويل.

(١) انظر: تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، ص:٥١، ٥٢، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ١٨٤/٣، ١٨٥، المستصفى من علم الأصول ، الغزالي، ١١٧/١، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني، ٣٦/٢، وما بعدها، بداية المجتهد، ابن رشد، ٤٦٨/٢، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ١٣٧/٥، ١٣٨، أصول السرخسي، ٨٢/٢، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن، ص: ٢٦٦.

٣ـ القول بالشاهد واليمين يؤدي إلى التوسع في وسائل الإثبات، حفظًا للحقوق، وتحقيقًا للعدالة في أوسع صُوَرِها.

٤ـ كما أن أدلة القول المخالف ضعيفة، ولا تقوى على معارضة أدلة أصحاب القول الأول، فلا تقوم بها حجة شرعية.

وأما دعاوى الحدود، وهي الجرائم التي يجب فيها الحد، كالقتل والسرقة، فهذه لا بد فيها من الشاهدين وأما جريمة الزنا فلابد فيها من أربعة شهداء، نظرا لخطورتها، وتعلقها بالأعراض، كما نص على ذلك الذكر الحكيم والسنة المطهرة. والله أعلم.

المبحث التاسع

انتهاء ولاية القاضي

تمهيد وتقسيم:

تنتهي ولاية القاضي، بالعزل، والعزل إما أن يكون من جهة الحاكم بلا سبب يُوجبُ العزل، وإما ان يكون بسبب الشكوى، وإما ان يكون باستقالة القاضي، وفيما يلي بيان ذلك:

المطلب الأول:

عزل القاضي من جهة الحاكم بغير سبب يوجب العزل

إن حكم القاضي بالعدل، وممارسته لسلطته، وفقاً لأحكام الشرع الحنيف، مرهونٌ بتحصينه من العزل، إذ القضاء سلطة تمنحُ صاحبها الخلافة عن الشارع في الأرض، ليحكم بين الناس بالعدل، قال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) (١)

(١) سورة: ص: الآية: ٢٦.

وقد نص العلماء على أن وظيفة الخلافة المذكورة في الآية الكريمة، إنما المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عين العدل، وأن الخلافة مرهونة في بقائها، ودوام استمرارها، بالحكم بالعدل، قال القرطبي " قوله تعالى:" فاحكم بين الناس بالحق" أي بالعدل، وهو أمر على الوجوب، وقد ارتبط هذا بما قبله "(١)

ومعناه: إن القاضي ما دام أهلاً للقضاء، مستوفياً لشروطه، ومُحَقِقاً للعدل في حكمه، فلا يجوز عزله بلاسبب، ذلك أن حصانة القضاة – من العزل – أمر ضروري جداً لاستقلال القضاة في أعمالهم ونزاهتهم في شئون القضاء على السواء ، بل ذلك واجب لتحقيق ثمرة القضاء وهو إقامة العدل(٢)

وبناء عليه:

فقد اتفق الفقهاء على أن عزل القاضي دون سبب أو مصلحة، هو خلاف الأولى، قال الرملي" وإن لم يكن في العزل مصلحة، فلا يجوز عزله به لأنه عبث وتصرف الإمام يُصان عنه" (٣)

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أبي بكر، شمس الدين القرطبي، ٤١٣/٥.
(٢) انظر: السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، د. نصر فريد واصل ، ص ٢٤٠
(٣) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٢٤٦/٨. وفي هذا المعنى: الشرح الصغير، الدردير، ٢٠١/٤، المغني، ابن قدامة، ١٠٣/٩، وشرائع الإسلام للحلي، ٧١/٤.

ولكن إذا حدث وعزل الإمام القاضي، فهل ينعزل؟

لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

إنه لا يجوز للإمام أو أحد نوابه عزل القاضين بلا سبب، وإذا عزله لا ينفذ هذا العزل، وإلى هذا القول: ذهب الشافعية، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة وهو قول عند الإمامية، وأحد الوجهين عند الزيدية (١)

واستدلوا لذلك:

١ـ إن تصرف الإمام ونوابه منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في هذا العزل.

٢ـ إذا عزله من غير مصلحة فإن ذلك يعد عبثا، وتصرفات الإمام يجب أن تصان عن العبث.

٣ـ إن الإمام إنما ولاه القضاء لمصلحة المسلمين، فلا يملك أن يعزله مع سداد حاله، كولي المرأة إذا عقد عليها عقد الزواج لم يكن من حقه أن يفسخ هذا العقد.

(١) انظر: نهاية المحتاج، ج٨، ص١٤٥، والشرح الصغير، ج٤، ص٢٠١، والمغني، ج٩، ص١٠٣، وشرائع الإسلام للحلي، ج٤، ص٧١، قواعد الأحكام، الحلي، الأقطاب الفقهية، ابن أبي جمهور، ١٠٣/١. البحر الزخار، أحمد بن يحي المرتضى، ٨٩/١٤.

٤ـ القاضي في الحقيقة وكيل عن الأمة، وإذا تعلق بالوكالة حق الغير – وهو هنا حق المسلمين– فلا يجوز عزل الوكيل(١)

القول الثاني:

إنه يجوز للإمام أو أحد نوابه عزل القاضي، ولو بلا سبب، وينفذ عزله، وإلى هذا القول: ذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وهو قول عند الإمامية، وأحد الوجهين عند الزيدية(٢).

واستدلوا لذلك:

١ـ **القياس على الولاة** على البلاد، فلما كان للإمام أن يعزل ولاته الذين ولاهم على البلاد، فكذلك يكون له أن يعزل قضاته، قياسا عليهم من باب أولى؛ لأن الإمارة أعلى من القضاء.

ونُوقش هذا: بأن هذا القياس لا يصح، لوجود الفارق وهو مانع من صحة القياس؛ لأن الإمارة ليست أعلى من القضاء، بل العكس هو الصحيح،

(١) انظر: المراجع السابقة، نفس المواضع، وانظر: القضاء في الإسلام، د. نصر فريد واصل، ص:٢٤١، د.محمد رأفت عثمان، النظام القضائي، ص:٢٠٩، ٢١٠. نظام القضاء في الإسلام، المستشار جمال المرصفاوي، ص ٥٣.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود،١١٦/٢،

ولذلك قال العلماء: "إن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا"، والقاضي ليس وكيلا لرئيس الدولة، وإنما هو يعمل بولاية المسلمين، وفي حقوقهم(١).

٢ـ روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه، أنه قال: لأعزلن أبا مريم، وأولين رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه "أي: خافه" فعزله عن قضاء البصرة، وولى مكانه كعب بن سوار(٢).

وولى علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه، أبا الأسود ثم عزله، فقال له: لم عزلتني، وما خُنْتُ ولا جَنَيتُ؟ فقال: إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين(٣).

وجه الاستدلال: عن هذا العزل قد حدث من صحابيين جليلين، ولم يخالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فكان العزل من الإمام للقاضي بلا سبب جائزًا.

ونُوقش هذا: بأن العزل كان لحاجة تدعو إلى ذلك، وليس العزل بغير حاجة وإلا كان عبثا(٤).

---

(١) انظر: النظام القضائي، د.رأفت عثمان، ص: ٢١١. نظام القضاء في الإسلام، المستشار جمال المرصفاوي، ص ٥٣.

(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٣٥/١٠

(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٣٥/١٠، عوالي اللئالي ، ابن أبي جمهور الإحسائي،٣٤٣/٢، مستدرك الوسائل، حسين النوري ٣٦٠/١٧.

(٤) انظر: النظام القضائي، د. رأفت عثمان، ص:٢١١.

سبب الخلاف:

مَرَدُّ الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، إلى تكييف وظيفة القاضي، هل القاضي ناظر للمسلمين ونائب عنهم لإحقاق الحق أم إنه مجرد أجير أو وكيل خاص للإمام؟

فمن رأى أن القاضي ناظر للمسلمين ونائب عنهم لإحقاق الحق، قال بعدم جواز عزله من قبل الإمام، لأنه لا يملك عزله.

ومن رأى أن مجرد أجير أو وكيل خاص للإمام، قال بجواز عزله من الإمام، لأنه يملك فسخ عقد الإجارة أو الوكالة.

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتها، أرى ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأول، القائل بعدم جواز عزل الإمام للقاضي، بلا سبب، وذلك لقوتها، وخلوها عن المُعارض لها. والله أعلم.

المطلب الثاني

عزل القاضي بالشكوى

اتفق الفقهاء على أن الشكوى المجردة من البرهان أو الدليل لا تكفي لعزل القاضي العادل أو المشهور بالنزاهة، منعاً للعبث بحصانة القضاء واستقلاله(١).

أما إذا كثرتْ الشكاوى في القاضي من جانب المترافعين إليه، وجب على الإمام أو من يُنيبُهُ ، التحقق من ذلك، فإن كانت الشكوى صحيحة، وكان لِمُصدرها سبباً وجيهاً مُوجباً للعزل عُزل، وإن كانت لمصالح وأهواء، أو كانت كيدية، لا حقيقه لها، أو كان القاضي لا يتوافق مع من قدم الشكوى عليه؛ لسببٍ غير وجيه، فإن القاضي لا يُعزل، ولو كثُرتْ عليه الشكاوي، على الصحيح من أقوال أهل العلم(٢).

(١) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ص: ٣٣ الذخيرة، أحمد بن ادريس القرافي،١٢٧/١٠، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٢٤٦/٨، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٤٦٥/٣، العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي، عبد الله بن صالح الكنهل ،٢٢٢/١. النظام القضائي الإسلامي، عبد الرحمن القاسم، ص: ١٤٠.

(٢) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ص: ٣٣ الذخيرة، أحمد بن ادريس القرافي،١٢٧/١٠، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٢٤٦/٨، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٤٦٥/٣، العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي، عبد الله بن صالح الكنهل ،٢٢٢/١. النظام القضائي الإسلامي، عبد الرحمن القاسم، ص: ١٤٠.

وخاصه إذا علم أن القاضي يحقق مصلحة المظلوم، فيبقى الظالم غير راضٍ، وقد قال ابن سيرين كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت؟ قال أصبحت وشِطر الناس على غضاب"(١)

وقد نص المالكية في المعتمد عندهم على إنه" يحرم عزل القاضي بمجرد الشكوى، إن كان مشهوراً بالعدالة ويجب عزله بالشكوى، إن لم يكن مشهوراً بها، وذلك لما يقع بعزل المشهور بالعدالة بمجرد الشكوى من فساد الناس على قضاتهم(٢).

(١) انظر: انظر سير اعلام النبلاء محمد ابن احمد الذهبي ١٠٥/٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني ٨٨/٨، مواهب الجليل، الحطاب،١١٤/٦، حاشيه الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، ١٣٧/٤.

المطلب الثالث

عزل القاضي نفسه "الاستقالة"

إذا عزل القاضي نفسه، فقال: عزلْتُ نفسي عن القضاء، وهو ما يُعرف في عصرنا الحاضر باستقالة القاضي من منصبه:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا جائز، لأنه صاحب الحق في ذلك، **وقد رأى بعض الفقهاء** إن بقاءه في الوظيفة مع قدرته على القيام بواجباتها على الوجه المشروع مصلحة مؤكدة للناس، يجب ألا يفوتها عليهم باستقالته بدون عذر مشروع، ولكن مع هذا لو استقال فعلاً لا لعجز فيه ولا لعذر مقبول فإن استقالته صحيحة ونافذة لأنه يباشر حقاً له وهو حق الاستقالة باعتباره وكيلاً وللوكيل حق الاستقالة كما قلنا. اللهم إلا إذا تعين عليه البقاء في وظيفة القضاء لعدم وجود الصالح لهذه الوظيفة، فلا يجوز له أن يستقيل في هذه الحالة(١).

وقد خالف بعض فقهاء الحنفية في ذلك، فقالوا: لا ينعزل القاضي بعزله لنفسه، لأنه نائب عن العامة، وحق العامة متعلق بقضائه(٢).

(١) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ص:٣٣،روضة القضاة، ابن السمناني، ٥٠/١، النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني ٨٨/٨، نهاية المحتاج، الرملي، ٢٤٦/٨.
(٢) انظر: لسان الحكام، إبراهيم بن أبي اليمن، المعروف بابن الشحنة، ص:٢٤٤.

ووافقهم بعض فقهاء المالكية، فقالوا: إذا كان قد تعلق لأحد حق بقضائه، وكان انعزاله، بسبب الضرر لمن التزم بينه وبين خصم، فإن القاضي يُمنع من عزل نفسه(١).

متى يُعتبَرُ عزل القاضي نافذا؟

وإذا كان للقاضي أن يستقيل من وظيفته، واستقال فعلاً بأن رفع استقالته إلى الخليفة الذي ولاه القضاء فمتي يعتبر مستقيلاً؟ قالوا: يعتبر مستقيلاً إذا سمع الخليفة استقالته أو بلغه كتاب الاستقالة، فقد جاء في الفتاوي الهندية: "القاضي إذا قال عزلتُ نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وسمع السلطان ينعزل".

أما بدون سماع السلطان فلا، وكذلك إذا كتب كتاباً إلى السلطان إني عزلت نفسي، وأتى كتاب السلطان صار القاضي معزولاً(٢).

رأينا الخاص في نفاذ العزل:

والذي نراه: إن القاضي لا ينعزل ويُعتبر مُستقيلاً، بمجرد وصول كتاب استقالته إلى الخليفة، أو الجهة التي تُقدم إليها الاستقالة، لأن طبيعة عمل القاضي وكونه يتعلق بمصالح الناس وقضاياهم، وأنه يعمل بولاية المسلمين

(١) انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٧٨/١.
(٢) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٢٤٦/٨.المغني،

ولمصلحتهم كما هو مبنى رأي الحنفية في ولاية القاضي، كل ذلك يجعل وكالته عنهم من نوع خاص لا تُشبه وكالة الأفراد فيما بينهم، وبالتالي يكون من الإضرار بالمصلحة العامة اعتبار القاضي مستقيلاً، واستقالته نافذة بمجرد رفع استقالته إلى الخليفة أو إسماعه إياها شفاهاً، لأنه ربما يتعلق لبعض الخصوم حق بقضائه، وكان انعزاله بسبب الضرر لمن التزم بينه وبين خصمه(١).

وإنما يجب اعتباره مستقيلاً من تاريخ إخباره بقبول استقالته تحريرياً، على أن يتم هذا الإخبار خلال مدة مناسبة من تاريخ رفعه الاستقالة مثل مدة شهر، وإذا لم يخبر القاضي خلال هذه المدة بقبول استقالته اعتبرت استقالته مقبولة في نهاية هذه المدة، وعلى أن يكون للخليفة أو من يخوله حق رفض الاستقالة، إذا وجد المبرر الشرعي مثل: عدم وجود البديل للقاضي المستقيل(٢).

ولكن ينبغي ألا يتعسف الخليفة في رفضه الاستقالة بحجة عدم تيسر من يعينه بدلاً عن القاضي المستقيل، ومن ضروب التعسف الإصرار على تعيين مثل القاضي المستقيل في جميع صفاته من العلم والدراية وحسن السمعة والورع ونحو ذلك، لأن المنظور إليه في تعيين القاضي توفر الشروط المطلوبة

(١) انظر: لسان الحكام، إبراهيم بن أبي اليمن، المعروف بابن الشحنة، ص:٢٤٤. تبصرة الحكام، ابن فرحون، ٧٨/١.
(٢) انظر: النظام القضائي مقارنا بالنظم الوضعية، عبد الرحمن القاسم، ص: ١٤٦.

فيه بالحد الأدنى المقبول من هذه الشروط وليس حدها الأعلى النادر الوجود(١).

وهناك رأي فقهي يجب التنبيه إليه لبعض أساتذتنا الفضلاء، يرى فيه إذا كان عزل القاضي نفسه بغير عذر سيؤدي إلى خلو هذا المنصب ممن توفر فيه شروط القاضي؛ لأنه لا يوجد شخص آخر تتوفر فيه هذه الشروط، فإنه في هذه الحال لا يصح عزله لنفسه، حتى يظهر من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، بل إنه يحرم عليه عزل نفسه -من غير عذر- إذا كان يعلم أنه لا يوجد غيره واحد تتوافر فيه الشروط، فإنه يجب عليه القبول ولا يجوز له أن يرفضه(٢).

(١) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ومعه لسان الحكام لابن الشحنة، ٢٤٣.
(٢) هذا الرأي لأستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه النظام القضائي في الإسلام، ص: ٢١٤.

الفصل الرابع[1]:

قضاء المظالم.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف قضاء المظالم.

المبحث الثاني: شروط واختصاصات قاضى المظالم.

المبحث الثالث: تعيين قاضى المظالم ومجلس حكمه.

(١) كتب هذا الفصل، الأستاذ الدكتور/ مراد محمود حيدر.

تمهيد وتقسيم:

ندرس في هذا المبحث: تعريف قضاء المظالم، وشروط واختصاصات قاضى المظالم، من حيث تعيين مهامه، وتعيين قاضي المظالم ومجلس حكمه، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول

تعريف قضاء المظالم.

القضاء: لغة: القضاء لغة: الحكم بين الناس. والقاضي: الحاكم (١).

وشرعًا: فصل الخصومات وقطع المنازعات (٢).

والمظالم في اللغة: جمع مظلمة، وهي مشتقة من الظلم، وتعني: الجور ومجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه (٣).

وفي الاصطلاح: يقصد بالظلم: التعدي من الحق إلى الباطل قصداً أو الانتقاص بحقوق الغير في الملك أو الأمن أو الحرية أو النشاط أي أن الظلم بإيجاز هو الاعتداء على الناس في أموالهم وممتلكاتهم بصفة عامة (٤).

(١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١٨٦/١٥مادة: "قضى"، مقاييس اللغة، ابن فارس،٩٩/٥، مادة: "قضى".
(٢) انظر:لسان الحكام،ابن الشحنة،٢١٨/١، الدر المختار،الحصكفي،٤/ ٣٠٩، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ١٢٩.
(٣) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١٨٦/١٥مادة: "قضى".
(٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١٨٦/١٥

قضاء المظالم في اصطلاح الفقهاء:

عرفه الماوردي بأنه: قَوْدُ الْمُتظَالَمَيْنِ إِلَى التَّنَاصُفِ بالرَّهْبَةِ، وَزَجْرُ المتنَازِعَيْنِ عَنْ التَّجَاحُدِ بِالهَيْبَةِ (١).

وفي الاصطلاح الإداري: عرفه ابن خلدون بأنه: "وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونُصفة القضاء، ويحتاج الوالي فيها إلى عُلو يَدٍ، وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي"(٢).

ويتضح مما سبق: إن قضاء الظالم هو: نوع خاص من القضاء منفصل عن القضاء العادي ويقوم إلى جانبه بفصل في التظلمات والخصومات التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما من ذوي القوة والجاه والنفوذ سواء استمد ذلك من عمله الوظيفي الذي يقوم به، أو بسببه أو بأي سبب آخر.

وتتنوع المظالم إلى نوعين:

الأول: ما يتعلق بظلم القائمين على أمور الأفراد أي شاغلي الوظائف العامة.

الثاني: ظلم الأفراد العاديين بعضهم البعض.

(١) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٨٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص: ٧٣.
(٢) انظر: المقدمة، ابن خلدون، ص٢٢٢

ومن هنا نلاحظ أن هناك تشابهًا بين القضاء الإداري، الموجود في عصرنا الحاضر وبين قضاء المظالم في الموضوع إلا أن قضاء المظالم أكثر شمولًا وأوسع اختصاصًا فهو يشمل الدعاوي والخصومات التي تقوم ما بين الأفراد وجهات الإدارة العامة إلى جانب الخصومات التي يكون أحد طرفيها جهة أو شخصًا ذا قوة ونفوذ وتسلط؛ بحيث إن القضاء العادي لا يستطيع أن يردعه عن ظلمه أو يوقفه عند حده (١).

مشروعية قضاء المظالم:

الأصل في قضاء المظالم ما روي عن النبي ﷺأنه جعل ما يفعله الحاكم من أمر، على غير وجه الحق في حكمه للرعية مظلمة. عن أنس قال: غلا السعر على عهد الرسول ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: «إِنَّ اللهَّ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَّ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ» (٢)، فجعل التسعير مظلمة لأنه لو فعله يكون فعل شيئاً لا حق له به، وكذلك جعل القضايا التي تحصل في الحقوق العامة التي تنظمها الدولة للناس، جعل النظر فيها من المظالم كسقي الزرع من ماء عام كل في دوره، فقد نظر رسول الله ﷺفي الشرب الذي تنازعه

(١) انظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي، ص:٣٤.
(٢) انظر: رواه الامام احمد في المسند برقم"١٤٠٥٧، قال المحقق: حديث صحيح.

الزبير بن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فحضره بنفسه فقال للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»(١)

فأية مظلمة تحصل على أي شخص، سواء أكانت من الحاكم، أم من تنظيمات الدولة وأوامرها، تعتبر مظلمة كما يفهم من هذين الحديثين، ويرفع أمرها للخليفة ليقضي في هذه المظلمة، أو لمن ينيبه الخليفة عنه في ذلك من قضاة المظالم (٢).

تكوين ديوان المظالم:

إن ديوان المظالم هي الهيئة التي تتولى فحص ودراسة المظالم ويرأس الديوان إما الخليفة الحاكم أو أحد الأفراد ممن تتوافر فيهم صفات معينة؛ ومن ثمَّ فإن المجلس يتكون من صاحب الديوان "رئيس الديوان" وهو والي المظالم وقد يكون الخليفة ذاته أو أحد الوزراء أو شخصاً معيناً بذاته.

أما مساعدو رئيس الديوان، فهم القضاة والفقهاء والكتاب والحماة والأعوان والشهود (٣).

(١) متفق عليه واللفظ لمسلم.
(٢) انظر: نظام الحكم في الإسلام، د. محمد يوسف موسي. ص:١٥٧ـ ١٥٨.
(٣) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:٧٧.

متى نشأ ديوان المظالم؟

كان الرسول ﷺ في صدر الإسلام أول من نظر المظالم بنفسه، فقضى في شِرْب بين الزبير بن العوام وأنصاري (١)، وأرسل علياً لدفع دية القتلى الذين قتلهم خالد من قبيلة بني جذيمة بعد أن خضع أهلها وقال: « اللهُمَّ إنِّي أبرَأُ إليكَ ممَّا صَنَعَ خالِدُ »(٢).

ولم يُنتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد؛ لأن الناس كان يقودهم التناصف إلى الحق، ويزجرهم الوعظ عن الظلم.

ولكن عمر رضي الله عنه كان شديد الوطأة على الولاة، ودائم التحذير لهم، فأمر بالاقتصاص من عمرو بن العاص؛ لأنه قال لأعرابي في المسجد: يا منافق، إلا أن يعفو الأعرابي، واقتص من ابن عمرو لإهانته مصريًا قبطيًا (٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، الحديث رقم: ٢٧٠٨

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، الحديث رقم: ٧١٨٩ ونص الحديث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " بَعَثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خالِدَ بنَ الوليدِ إلى بَني جَذيمةَ، فلَم يُحسِنوا أن يقولوا: أسلَمنا، فقالوا: صَبَأنا صَبَأنا، فجَعَلَ خالِدٌ يَقتُلُ ويَأسِرُ، ودَفَعَ إلى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أسيرَه، فأمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أن يَقتُلَ أسيرَه، فقُلتُ: واللهِ لا أقتُلُ أسيري، ولا يَقتُلُ رَجُلٌ مِن أصحابي أسيرَه، فذَكَرنا ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اللهُمَّ إنِّي أبرَأُ إليكَ ممَّا صَنَعَ خالِدُ بنُ الوليدِ مَرَّتَينِ."

(٣) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ٦٢٥٢/٨.

المبحث الثاني

شروط واختصاصات قاضى المظالم.

إن قضاء الظالم نشأ أصلًا، للنظر في أعمال الولاة والحكام ورجال الدولة مما قد يعجز عنه القضاء العادي، وقد ينظر واليها في المنازعات التي عجز القضاء عن فصلها، أو في الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها. ويجتمع فيها القضاء والتنفيذ معاً (١).

المطلب الأول

شروط قاضي المظالم

إن ولاية المظالم سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب، والنظر في المظالم موضوع في الأصل لما عجز عنه القضاة، وينظر قاضي المظالم في ظلامات الناس من الولاة والجباة والحكام، أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء، أو القضاة (٢).

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، صـ ٧٣، السلطات الثلاث في الإسلام، د. سليمان الطماوي، ص: ٣١٣.

(٢) انظر: قضاء المظالم وسيلة لقمع الظلم وإحقاق العدل، دراسة تحليلية مقارنة، د. محمد وليد العبادي، منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد الخامس، العدد (١)، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

ومن المعلوم أن القضاء من ضمن الوظائف المحفوظة لصاحب الإمامة الكبرى"الخليفة"(١)

فما يلزم القيام به كما قال الماوردي "قطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يعتدي ظالم ولا يضعف مظلوم..." وأن "يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة" (٢).

فالقضاء من وظائف الخليفة بحكم ولايته العامة، وبالاستناد إلى ذلك يباشر الخلفاء نظر المظالم بأنفسهم على النحو المعروف والمقرر لديهم ومن ثمّ فهو يباشر ذلك دون انتخاب أو تكليف وهذه الوظيفة تكون أيضاً لوزراء التفويض والأمراء باعتبار أن أيًا من هؤلاء يملك الأمور العامة فلا يحتاج إلى تقليد خاص(٣)

وقد عمل أصحاب الولاية العامة على وضع شروط خاصة وذلك بتعيين قضاة يتمتعون بصفات وخصائص تمكنهم من القيام بهذه الوظيفة إذا

(١) انظر: المقدمة، ابن خلدون، ص: ٢٧٥.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:١٨.
(٣) انظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي، ص:٣٤.

توافرت هذه الشروط ويصدر له بذلك كتاب تولية أو تقليد من الخليفة أو السلطان، وهو ما نسميه اليوم إن صح التعبير مرسومًا أو قرارًا (١).

والشروط الواجب توافرها في تعيين قاضي المظالم فهي كما بينها الماوردي:

أن الناظر في المظالم يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة طاهر العفة قليل الطمع كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وتثبت القضاة.

ولقد ذكر الإمام الماوردي شروط قاضي الظالم وفصلها على نحو يتناسب مع قدر هذه الوظيفة فقال:

" مِنْ شُرُوطِ النَّاظِرِ أَنْ يَكُونَ جَلِيلَ الْقَدْرِ، نَافِذَ الْأَمْرِ ، عَظِيمَ الْهَيْبَةِ ظَاهِرَ الْعِفَّةِ ، قَلِيلَ الطَّمَعِ، كَثِيرَ الْوَرَعِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي نَظَرِهِ إِلَى سَطْوَةِ الْحُمَاةِ وَتَثَبُّتِ الْقُضَاةِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ صِفَاتِ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بِجَلَالَةِ الْقَدْرِ نَافِذَ الْأَمْرِ فِي الْجِهَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْأُمُورَ الْعَامَّةَ كَالْوُزَرَاءِ وَالْأُمَرَاءِ لَمْ يَحْتَجْ النَّظَرُ فِيهَا إِلَى تَقْلِيدٍ وَكَانَ لَهُ بِعُمُومِ وِلَايَتِهِ النَّظَرُ فِيهَا، وَإِنْ

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:٢٢ـ ٧٢.

كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّظَرِ احْتَاجَ إِلَى تَقْلِيدٍ وَتَوْلِيَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ"(١).

والمتأمل في تلك الشروط، يلحظ أن الإمام الماوردي قد وضع هذه الشروط بحيث تتناسب مع الوظيفة التي يتقلدها قاضي المظالم، فإن اقتصرت مهمة المقلد للقضاء على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه، جاز أن يكون ناظر المظالم دون مرتبة الوزير والأمير في القدر والخطر، بشرط ألا تأخذه في الحق لومة لائم.

وأما إذا كان نظره في المظالم عامًا، فيحتاج إلى تقليد خاص من ولي الأمر لكل من توافرت فيه شروط ولاية العهد، أو وزارة التفويض، أو إمارة الأقاليم.

وهذه الشروط الخاصة التي يجب توافرها، يجب أن ينضم إليها الشروط التي العامة التي يجب توافرها في القاضي، والتي ذكرناها سابقًا.

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:١٣٣، الأحكام السلطانية، أبي يعلى، ص:٧٣.

المطلب الثاني

مهام واختصاصات قاضي المظالم

يختص قاضي المظالم باختصاصات متعددة بعضها استشاري يتعلق بمراقبة تطبيق أحكام الشرع، وبعضها إداري يتعلق بمراقبة أعمال الموظفين ولو بدون متظلم من الناس، كما يظهر من الاختصاصات الثلاثة الأولى، وبعضها قضائي يتعلق بفصل الخصومات بين الحكام والرعية، أو بين الرعية أنفسهم، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث: فئات (١):

الفئة الأولى:

وتتشكل من اختصاصات يتصدى قاضي المظالم بموجبها إلى ما يصدر عن الدولة وأشخاصها، فينظر المظالم بناءً على شكوى، أو تصديًا دونما انتظار شكوى كما أنه وجهة رقابية ومالية ورقابة على موافقة القواعد المعمول بها للشريعة أو خروجًا عنها من جهة أخرى، وتندرج تحت هذا الاختصاص مجموعتان:

(١) انظر: قضاء المظالم وسيلة لقمع الظلم وإحقاق العدل، دراسة تحليلية مقارنة،د. محمد وليد العبادي، منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد الخامس، العدد (١)، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

أـ ما يباشره دون شكوى بل يتصدى لنظره ويقع في دائرته وهي:

١- تعديات الولاة على الناس بالعسف والقهر.

٢- الجور في الضرائب والجباية.

٣- تصرفات كتاب الدواوين.

٤- مشارفة الوقوف العامة (الخيرية).

٥- المظالم الناشئة عن الغصوب السلطانية واستغلال النفوذ.

ب ـ ما ينظره بناءً على شكوى ويقع في دائرته وهي:

١- تظلمات الموظفين والمستخدمين.

٢- غصب المتنفذين للأملاك الخاصة.

٣- تظلمات أصحاب الوقوف الخاصة (الذرية) بمواجهة المشرفين عليها.

الفئة الثانية:

وتشمل الاختصاص بنظر بعض ما يدخل في اختصاص القضاء العام ويقع في دائرته:

١- النظر بين المتشاجرين.

٢- تنفيذ الأحكام القضائية.

الفئة الثالثة:

وهي اختصاصات تخرج عن ولاية القضاء أصلاً وتدخل في أعمال أصحاب ولايات أخرى ويقع ضمن دائرته:

١- ما يعجز عنه المحتسب.

٢- العمل على مراعاة العبادات. (١)

ويتضح من الاختصاصات السابقة أن ديوان المظالم يجب أن يتكون من خمسة أصناف لا يستغني عنهم ناظر المظالم ولا ينتظم نظره إلا بهم، وهم:

١ - الحماة والأعوان لجذب القوي، وتقويم الجريء.

٢ - القضاة والحكام لاستعلام ما ثبت عندهم من الحقوق، ومعرفة ما جرى في مجالسهم بين الخصوم.

٣ - الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه وأعضل.

٤ - الكتّاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق.

٥ - الشهود: ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم. فإذا استكمل مجلس المظالم بهؤلاء الأصناف شرع الناظر حينئذ في النظر فيها(١)

(١) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص: ٧٦ - ٧٨. الأحكام السلطانية للماوردي ص: ١٣٩ - ١٤١.

المبحث الثالث

تعيين قاضى المظالم ومجلس حكمه

تمهيد وتقسيم:

إن النظر في المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف في الرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر الفقه، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وثبات القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين (٢).

وبناءً عليه:

فإن قضاء المظالم هو أعلى منصب قضائي، في الترتيب القضائي، وهو أشدها خطرًا؛ ولذا نتعرض لدراسة كيفية تعيين قاضي المظالم، ونبين كيفية مجلس حكمه في المطلبين الآتيين:

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص:٧٦.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص: ١٣٣.

المطلب الأول

تعيين قاضي المظالم

من هو قاضي المظالم؟

قاضي المظالم هو: قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين(١).

تعيين قاضي المظالم:

يُعيّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قِبَل قاضي القضاة؛ وذلك لأن المظالم مِن القضاء، فهي إخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام، والقاضي بجميع أنواعه، إنما يُعيّنه الخليفة، لما ثَبت أن الرسول ﷺ هو الذي كان يُعيّن القضاة بأنواعهم كما بيّنا سابقًا.

(١) انظر: نظام الحكم في الإسلام، د. محمد يوسف موسى، ص ١٥٧.

وبذلك فإن الخليفة هو الذي يُعيّن قاضي المظالم، ويجوز لقاضي القضاة أن يعين قاضي المظالم إذا جَعَل له الخليفة ذلك في عقد التقليد.

ويجوز أن يقتصر عمل محكمة المظالم الرئيسة في مركز الدولة على النظر في المَظْلِمَة من الخليفة ووزرائه وقاضي قضاته، وأن تنظر فروع محكمة المظالم في الولايات في المظالم من الولاة والعمال وموظفي الدولة الآخرين.

وللخليفة أن يعطي محكمة المظالم المركزية صلاحية تعيين وعزل قضاة المظالم في محاكم المظالم في فروع الولايات التابعة لمحكمة المظالم المركزية. والخليفة هو الذي يعين أعضاء محكمة المظالم الرئيسة في مركز الدولة (١)

(١) انظر: القضاء في الإسلام، د. عبد العزيز عوام، ص: ٧٧.

المطلب الثاني

مجلس حكم قاضي المظالم

يتكون مجلس حكم قاضي المظالم من خمسة أصناف نص عليهم الإمام الماوردي بقوله: "فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يومًا معروفًا يقصده فيه المتظلمون ويراجعه فيه المتنازعون، ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير إلا أن يكون من عمال المظالم المنفردين لها فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام، وليكن سهل الحجاب نزه الأصحاب.

ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم:

أحدهم: الحماة والأعوان لجذب القوي وتقويم الجريء.

والصنف الثاني: القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم.

والصنف الثالث: الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل ويسألهم عما اشتبه وأعضل.

والصنف الرابع: الكتاب ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجب لهم أو عليهم من الحقوق.

والصنف الخامس:الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم، فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظرها (١).

وإذن نستخلص من كلام الامام الماوردي:

أن مجلس حكم قاضي المظالم يتكون من صاحب الديوان "رئيس الديوان" وهو والي المظالم وقد يكون الخليفة ذاته أو أحد الوزراء أو شخصاً معيناً بذاته، أما مساعدو رئيس الديوان، فهم القضاة والفقهاء والكتاب والحماة والأعوان والشهود.

(١) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص: ١٠٠.

المطلب الثالث

عزل قاضي المظالم

بقي أن نتحدث عن عزل قاضي المظالم، وهل طريقة عزله تكون بنفس طريقة عزل القاضي العادي؟

نظرًا لخطورة هذا المنصب، فإن الخليفة هو الذي يعين ويعزل أعضاء محكمة المظالم الرئيسة في مركز الدولة، وأما عزل رئيس محكمة المظالم المركزية، أي قاضي المظالم الذي ينظر في عزل الخليفة، فإن الأصل فيه أن يكون للخليفة حق عزله، كما له حق توليته كسائر القضاة. ولكن هناك حالةً يغلب على الظن أنه لو تُركتْ صلاحية العزل بيد الخليفة أثناءها، فإن هذه الصلاحية تؤدي إلى الحرام، وعندها تنطبق عليها قاعدة "الوسيلة إلى الحرام حرام"، حيث إن غلبة الظن تكفي في هذه القاعدة.

أما هذه الحالة فهي إذا كانت هناك قضية مرفوعة على الخليفة، أو وزرائه، أو قاضي قضاته " أي إذا كان الخليفة قد جعل لقاضي القضاة صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم" وذلك لأن بقاء صلاحية العزل بيد

الخليفة في هذه الحالة سيؤثر في حكم القاضي، وبالتالي يحد من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو أعوانه مثلًا، وتكون صلاحية العزل هذه وسيلةً إلى الحرام، أي أن بقاءها بيد الخليفة في هذه الحالة حرام.

وأما باقي الحالات فإن الحكم باقٍ على أصله، أي أن صلاحية عزل قاضي المظالم هي للخليفة كتوليته سواء بسواء (١).

(١) انظر: نظرية الدعوى في الفقه الاسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١٢٠.

الباب الثاني[1]:

في الشهادة وأركانها وأنواعها وأحكامها.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الشهادة، وأدلة مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها، وحكم تحمل الشهادة وأدائها.

الفصل الثاني: أركان الشهادة.

الفصل الثالث: نصاب الشهادة، وأخذ الأجرة عليها، والرجوع عنها.

(1) كتب هذا الباب الأستاذ الدكتور/ مراد محمود حيدر.

الفصل الأول

تعريف الشهادة، وأدلة مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها، وحكم تحمل الشهادة وأدائها.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الشهادة.

المبحث الثاني: وأدلة مشروعية الشهادة

المبحث الثالث: حكمة مشروعية الشهادة.

المبحث الرابع: حكم تحمل الشهادة وأدائها.

المبحث الأول

تعريف الشهادة

تعريف الشهادة في اللغة.

من معاني الشهادة في اللغة:

١. **الخبر القاطع**، وقد يعدى الفعل (شهد) بالهمزة، فيقال: أشهدته الشيء إشهادًا، أو بالألف، فقال: شاهدته مشاهدة، مثل عاينته وزنًا ومعنى(١)

٢. **الشهادة بمعنى الحضور**: قال تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(٢)

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: وشهد بمعنى حضر(٣)

٣. **الشهادة بمعنى المعاينة**: قال تعالى (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)(٤)

قال الراغب الأصفهاني في شرح معناها: وقوله:(أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (٥)، يعني: مشاهدة البصر(١).

---

(١) انظر: انظر مادة (شهد) في الصحاح، والقاموس، والتاج، واللسان، والمصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة، العين ٣ / ٣٩٧ - ٣٩٨، وتهذيب اللغة: ٦ / ٧٢-٧٧، ومادة شهد في جمهرة اللغة ٢ /٢٧٠، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني. انظر التنقيح ٤: ٢٨٣، والرياض ٢: ٤٢٣.

(٢) سورة البقرة / ١٨٥.

(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ٢ / ٢٩٩ (ط ٣ دار القلم بالقاهرة ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م) وفيه أن الشهر ليس بمفعول وإنما هو ظرف زمان.

(٤) الزخرف/١٩

(٥) الزخرف/١٩

٤. **الشهادة بمعنى القسم أو اليمين**: قوله تعالى (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)(٢)

قال ابن منظور: " الشهادة معناها اليمين هاهنا(٣)".

٥. **الشهادة بمعنى الخبر القاطع**: قال تعالى: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ)(٤)

واستعمالها بهذا المعنى كثير.

٦. **الشهادة بمعنى الإقرار**: قوله تعالى: (شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ)(٥) أي مقرين (٦) فإن الشهادة على النفس هي الإقرار.

تعريف الشهادة في الاصطلاح الفقهي:

استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس.

واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله.

واستعملوه في القسم كما في اللعان.

---

(١) انظر: المفردات ص ٢٦٩. مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٨١
(٢) انظر: سورة النور / ٦.
(٣) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (شهد).
(٤) سورة يوسف / ٨١.
(٥) سورة التوبة / ١٧.

(٦) انظر: المفردات (مادة: شهد) : ٢٦٩.

كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة: في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس لقضاء، وهو موضوع البحث في هذا المصطلح.

واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى.

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.(١)

وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه(٢)

وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد(٣)

وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت(٤)

وعرفها الشهيد الثاني من الإمامية بأنها " «إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم» (٥).

(١) انظر: فتح القدير، ٢/٦.
(٢) انظر: الشرح الكبير، ١٦٤/٤
(٣) انظر: حاشية الجمل ٥ / ٣٧٧،
(٤) انظر: نيل المآرب بشرح دليل الطالب بتحقيق د. محمد الأشقر ٢ / ٤٧٠.
(٥) انظر: الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام في تنقيح شرائع الإسلام، ١٥٣/١٤، النجفي، جواهر الكلام ٤١: ٧، مستند الشيعة - المحقق النراقي ٩/١٨، مستند الشيعة ١٨: ٩. عن المسالك، قوانين الاصول: ٤٦٤. قال النراقي في مستند الشيعة ٩/١٨" أي من حيث

وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده والإشارة إليها بحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضئ لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس (١)

وتسمى " بينة " أيضا؛ لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه (٢)

وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى.

إنه حاكم مطلقا. ولا يخلو التعريف عن نقض طردا وعكسا، لصدقه على الإخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه للغير، وعدم صدقه على الشهادة بالجرح والتعديل، ورؤية الهلال، والطلاق، والموت، وغير ذلك، ولذا وجدنا الكلبكاني يعرف الشهادة بأنها " وهي إخبار مكلف لشيء حصل أمامه بالمشاهدة أو غيرها، وبلغ به علمه الجزم أمام الحاكم الشرعي لإثبات حق أو نفي حق في دعوى من الدعاوي القضائية،" الگلپايگاني، كتاب الشهادات، ص ١٧- ١٨.
وقد يختلف الأمر باعتبار الموارد في صدق الشهادة عليه وعدمه، كالإخبار عن مجيء الحاج، فإنه ليس شهادة، فلو نوزع فيه لحق مترتب عليه يقال: إنه شهادة.
هذا، مع أن الظاهر من قوله: "شرعا" إرادة الحقيقة الشرعية، وإثباتها هنا مشكل، لعدم دليل على الوضع التعييني. وأما التعييني، فحصوله يتوقف على كثرة استعمال في المعنى الشرعي خاصة، بحيث يحصل التبادر فيه، وتحققه فيما نحن فيه غير معلوم، سيما مع ملاحظة لفظ الشهود والشهادة وما يشتق منهما في غير هذا المعنى في كلمات الحجج كثيرا، ولو سلم فتحققها في معنى خاص مضبوط يصلح، نظر: مستند الشيعة - المحقق النراقي- ج ١٨- الصفحة ٩
(١) انظر: حديث ابن عباس: ذكر عند رسول الله ﷺ الرجل يشهد بشهادة " أخرجه الحاكم (٤/ ٩٨-٩٩- ط دائرة المعارف العثمانية)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي في أحد رواته: " تكلم فيه الحميدي ولم يرو عن وجه يعتمد عليه " وقال الذهبي: " واه ".
(٢) انظر: المغني ١٢ / ٤، الشرح الكبير (على هامش المغني) ١٢ / ٣.

التعريف الراجح:

وبالنظر إلىٰ تعريفات الفقهاء للشهادة نلحظ التالي:

مناسبة المعنىٰ اللغوي للشهادة لمعناها الشرعي، ذلك أن كلاهما إخبارٌ عن علمٍ، إلا أنها في المعنىٰ الشرعي أخصُّ؛ ذلك أن الشهادةَ في الشرع إخبارُ عدلٍ دون غيره، في مجلس القضاء، بلفظ الشهادة.

ولنجمع شتات ما تفرق في كلام الفقهاء **يمكننا أن نخلص بتعريف للشهادة**، فنقول، الشهادةَ: (إِخْبَارُ عَدْلٍ عَنْ عِلْمٍ بِحَقٍ عَلَىٰ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ بِلَفْظٍ خَاْص)(١)

شرح التعريف:

(إخبار) يشمل كل خبر.

(عدل) قيدٌ في التعريف، ليخرج خبر الفاسق ومردود الشهادة؛ لأنَّ شهادَتَهُ غُيرُ مُعْتَّدٍ بها شرعاً.

(عن علم): قيد في التعريف، يدل علىٰ أن الشاهِدَ لابد أن يكون عالماً بما يشهد به بوسائل العلم والمعرفة، من الرؤية، أو السماع، أو الاستفاضة (٢)

(١) انظر: ، شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ٥٧٥/٣. وللبهوتي أيضاً: الروض المربع شرح زاد المستقنع، «المطبوع مع الحاشية»، ٥٨٠/٧، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي ١٨٥/٢.

(٢) استفاض الحديث في الناس: انتشر فهو مستفيض. الفيومي، المصباح المنير، ص١٨٥.

(**بحق علىٰ غيره لغيره**): قيد يخرج إخبار الإنسان بحق له علىٰ غيره؛ لأن هذه دعوىٰ وليست شهادة وكذا إخبار الإنسان بحق غيره عليه؛ لأن هذا إقرار وليس شهادة(١).

(**في مجلس القضاء**): ليخرج الإخبار فيما عداه من المجالس؛ لأن الإخبار في غير مجلس القاضي يُعد روايةً (٢)أو خبراً عادياً لا إلزام فيه للقاضي ليحكم بمقتضاه.

(**بلفظ خاص**): وهو كون الشهادة بلفظ: أشهدُ أو شهدتُ ونحوها.(٣)

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ،٦/٢٤٤.
(٢) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي ١٨٥/٢.
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، ٥٧٥/٣

المبحث الثاني

أدلة مشروعية الشهادة.

ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما الكتاب:

١- فقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (١)

٢- وقوله سبحانه (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)(٢)

٣- وقوله جل وعلا: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٣)

٤- وقوله تبارك وتعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(٤)

(١) البقرة/٢٨٢.
(٢) البقرة/٢٨٢.
(٣)الطلاق/٢
(٤) البقرة/٢٨٣

وجه الاستدلال من النصوص الكريمة:

أن الله عز وجل قد حث على الشهادة، وندب إليها، وحذر من كتمانها، فإن لم يكن الأمر مفيداً من الوجوب لقرينة تصرفه عنه إلى غيره، فيكون مفيداً للاستحباب، وهل دليل المشروعية ليس إلا(١).

ب ـ وأما السنة:

فأحاديث كثيرة منها:

١ـ حديث وائل بن حجر – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: شاهِداكَ أو يَمينُه(٢)

٢ـ وحديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أَنَّ النَّبيَّ ﷺقال: (البَيِّنةُ على المدَّعِي واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيهِ) (٣)والبينة هي الشهادة.

٣ـ وقوله ﷺ لمدع: « شاهِداكَ أو يَمينُه »(٤)

٤ـ وأنه ﷺسئل عن الشهادة، فقال للسائل: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ »(١).

(١) انظر: التسجيل العقاري، كشرط لنقل الملكية فيما بين المتعاقدين والغير، د. مراد محمود حيدر، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، التي تصدرها كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ـ فرع دمنهور العدد٢٤ـ المجلد ٣

(٢)أخرجه مسلم في صحيحه، ١ / ١٢٢ .

(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ١٠ / ٢٥٢ وإسناده صحيح.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: ٢٤١٧.

٥ـ وعن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (٢).

وجه الاستدلال:

أن النصوص الشريفة قد أفادت أن الشهادة مشروعة، وأنه يجب على الشاهد أن يتأكد من نفسه قبل الإدلاء بالشهادة.

ج ـ وأما الإجماع:

قد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوى.

د ـ وأما المعقول: فلأن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها (٣).

(١) رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده وتعقبه الذهبي، فقال: «بل هو حديث واه» وأخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف عن ابن عباس انظر: سبل السلام: ١٣٠/ ٤، نصب الراية: ٨٢/ ٤.

(٢) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، كتاب: الأقضية، باب: بيان خير الشهود، رقم الحديث٤٤٩٤،(١٧١٩)، ص٧٦٢. الترمذي، جامع الترمذي، أبواب الشهادات، باب: ما جاء في الشهداء أيهم خير، رقم الحديث: ٢٢٩٥، ص٥٢٦.

(٣) انظر: المغني ١٢ / ٣، وانظر في حاشية الشرح الكبير في الموضع نفسه.

المبحث الثالث

حكمة مشروعية الشهادة

من حكمة الله تعالى، أن جعل حياة الإنسان حياة جماعية؛ لأنه لا يستطيع الوفاء بما يحتاجه بمفرده في هذه الحياة من ضروريات، فكان في الحياة الجماعية قيام كل فرد بجزء من متطلباتها، مما ينجم عنه الوفاء بحاجياتها عن طريق التعاون الجماعي(١) قال الله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) (٢).

ومع أن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض في هذه الحياة، فمنذ وجد الإنسان على ظهر البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنه يحصل بينهم مشاحنات، ويحصل من بعضهم على بعض تطاولات واعتداءات على الأنفس، والأعراض، والثمرات، نتيجة لتجمعاتهم، ولما تحويه الأنفس من غرائز الطمع، والجنس، وغيرهما مما يجعل بعضهم يعتدي على البعض الآخر، ويحاول الاستيلاء على الممتلكات من غير حق.

(١) انظر: مجلة البحوث الإسلامية - المجلد ٢٥ - الصفحة ١٣٢ .
(٢) انظر: من الآية:٣٢، من سورة الزخرف.

وقد حصلت التعديات والاعتداءات في عهد صفوة الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي عهد صحابته الأطهار الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"(١)

وقد تجلت حكمة الله تعالى بأن شرع من الحدود ما يناسب الفطرة البشرية؛ حفاظا على أبدانها، وعقولها، وأعراضها، وأموالها، وكان من كراماته أن شرع طرقا لإثبات هذه الحدود والحقوق عند تنازع الناس فيها، ومن هذه الطرق الشهادة التي يستدل بها القاضي على الحق ويحكم بموجبها، بعد أخذ الحيطة للتأكد من عدالة الشهود وغيرها، وعدم وجود حجة قطعية أو ظنية تحول دون تغليب حجية الشهادة في القضية.

(١) انظر: أخرجه البيهقي بسند صحيح، انظر: البيهقي،٢٥٢/١٠، نصب الراية، الزيلعي، ٩٥/٤، بلوغ المرام، ابن حجر، ص ٣٤٦، سنن الدارقطني، ٤٧١٥٧.

وهي وسيلة عظيمة وجليلة لدفع التظالم ولإثبات الحقوق وردها إلى أهلها إذا اعتدى عليها، وتمكين القضاء من توقيع العقوبة على من يستحقها، وبدونها فإنها تضيع. كما أنها ترجح قول المدعي على قول المدعى عليه.

ولو أن القاضي اقتصر على علمه بالحادثة المراد منه الحكم فيها بحيث يكون علما منطبقا على الواقع بأن يشاهد الحادثة بنفسه ويحيط بها إحاطة تامة، أو يصل إليه خبرها بطريق التواتر المفيد للعلم، فإن أكثر مصالح الناس سوف تتعطل؛ لأن علمه إذا حصل في حادثة واحدة أو اثنتين فإن الكثير من الحوادث يتعذر عليه الوقوف عليها والعلم بها، كما يتعذر عليه العلم بها عن طريق التواتر المفيد لليقين؛ لأنه ليس من اليسر والسهولة وصول أخبار الحوادث دائما بطريق التواتر؛ ولذلك اقتضت حاجات الناس فيما يتقاضون فيه قبول الحجة الظنية ليبني عليها الحكم؛ لأنهم إما أن يهملوا النظر في الحوادث والقضايا التي لم يقم على ثبوتها دليل قطعي عند القاضي، ويترتب على هذا ضياع حقوق الناس وفوضى واضطراب في حياتهم ونظامها، وإما أن يقبلوا الدليل الذي يغلب على الظن صدقه كالشهادة، ويحفظوا حقوق الناس بها.

فهي طريق لإنصاف المظلومين، وردع للظالمين، وحسم للنزاع بين العالمين، الذي ينشأ من حين لحين؛ لأن المجتمعات البشرية على اختلاف زمانها ومكانها لا تخلو من الأسباب المقضية إلى المنازعات والخصومات مهما بلغت هذه المجتمعات من رقي وعلم وحضارة.

ومن هذا تتجلى الحكمة من مشروعية الشهادة، ويتضح أنها من الأهمية بمكان حيث تدعو الحاجة الماسة إليها في مختلف الأمصار والأعصار ما وجد الإنسان على ظهر الأرض (١).

(١) انظر: مجلة البحوث الإسلامية ـ المجلد ٢٥ ـ الصفحة ١٣٤

المبحث الرابع

حكم تحمل الشهادة وأدائها

حكم الشهادة بالنسبة للشاهد:

الشهادة من حيث حكم تحمل(١) الشاهد لها وأدائها(٢) أمام القاضي فرض كفاية عند الفقهاء، إذا دعي الشهود إليه؛ إذ لو تركه الجميع، لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهود بأداء الشهادة، ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها(٣)لإثباتها، فلا يسعهم كتمانها(٤).

(١) التحملُ: هو وقتُ التقاطِ الواقعة، أو سماع الحديث، أو مشاهدة الحدث. ينظر: المرتضىٰ بن زيد بن علي المحطوري، عدالة الرواة والشهود وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة، ص١٠٢.
(٢) الأداء:هو وقتُ أداءِ الروايةِ أو الإدلاءِ بالشاهدةِ عند الحاكم. ينظر: المرجع السابق. الخراساني، منهاج الصالحين ج ٣، ص ٤٦٧. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص ١٨٣.
(٣) وقد ذكر ابن العربي أن مَنْ كانت عنده شهادة لأخيه لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها فإنه يتعين عليه أن يؤديها من دون طلب للحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» رقم الحديث ٢٤٤٣، فقد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده، إحياءً لحقه الذي أماته الإنكار. محمد بن عبدالله بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: عبدالرزاق مهدي، ط١٤٢١،١هـ/٢٠٠٠م، دار الكتاب العربي: بيروت، ط١، ص٣٠٤. الخراساني، منهاج الصالحين، ج ٣، ص ٤٦٧. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص ١٨٣.
(٤) انظر: المبسوط: ١٧٧/ ١٦، فتح القدير: ٣/ ٦، الدر المختار: ٣٨٦/ ٤، الشرح الكبير للدردير: ١٩٩/ ٤، مغني المحتاج:٤٥٠/ ٤، المغني: ١٤٦/ ٩، المهذب: ٣٢٣/ ٢. أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان الهروي القاري، فتح باب العناية بشرح النقاية، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، دار الأرقم: لبنان،١٢٨/٣، الهداية، القدوري، ١٢٠/٨-١٢١، مواهب الجليل، الحطَّاب،١٦٥/٦ ج٦.الشرح الصغير،الدردير،٢٣٨/٢، روضة الطالبين، النووي، ٢٤٤/٨. المهذب، الشيرازي،٤٣٥/٣، شرح منتهىٰ الإرادات، البهوتي، ٥٧٥/٣. منهاج الصالحين، الخراساني، ٤٦٧/٣.

لقوله تعالىٰ: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)(١) وقوله تعالىٰ: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٢)؛ فالنهي الوارد عن الإباء في الآية الأولىٰ، والنهي عن الكتمان في الثانية، وإن لم يكن فيه أمر بأداء الشهادة إلا أنه يفيد الأمر بالشهادة؛ لأن النَّهْيَ عن الشيء أمرٌ بضده، إذا كان له ضد واحد؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به، فكان أداء الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الكتمان، فصار كالآمر به، بل آكد، ولهذا أسند الإثم إلىٰ الآلة التي وقع بها الفعل وهي القلب؛ لأن إسناد الفعل إلىٰ محله أقوىٰ من إسناده إلىٰ كله، وقولهم: أبصرته بعيني آكد من قوله: أبصرته، وإسنادُهُ إلىٰ أشرفِ الجوارحِ دليلٌ علىٰ أنَّه أعظم الجرائم بعد الكفر بالله تعالىٰ (٣)

فالشهادة أمانة كسائر الأمانات، وأداء الأمانة من أوجب الواجبات علىٰ المسلم، يقول تعالىٰ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (٤)

فكما يجب أداء الوديعة علىٰ الأمين، يجب أداء الشهادة على الشاهد، ولذلك نجد ابن عباس رضي الله عنهما يعد كتمان الشهادة من أكبر الكبائر(١)

(١) البقرة/٢٨٢.
(٢) البقرة/٢٨٣.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي ج٤، ص٢٠٧.ولعل الأولى أن يقال من أعظم الجرائم بعد الكفر بالله تعالى، ويؤيد ذلك ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث جعل كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري،٧٥/٣.
(٤) انظر: النساء/٥٨

فالشهادةُ فرضٌ يأثمُ تاركها إن علم أن القاضي يقبل شهادته، ودُعي إليها، ولم يكن ثمة شاهد غيره؛ لأن امتناعه حينئذ يضيع حق أخيه المسلم. فإن وجد من يقوم مقامه في تحمل الشهادة أو أدائها ممن تحصل بهم الكفاية سقط الفرض عن الباقين؛ لأن المقصود بالشهادة حفظ الحقوق، وذلك يحصل بالبعض، فهي فرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنعوا جميعاً أثموا؛ لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق، وإجابة جميعهم إليها تضييع للأشغال. ولأنَّ الشهادةَ تحيا بها حقوقُ الناسِ، وتصانُ بها الدماءُ والأموالُ والعقودُ عن التجاحدِ، وتحفظُ بها الأموال علىٰ أربابها وملاكها(٢)

لذلك كان تَحَمُّلُ الشَهَادَةِ فرضاً في الجملة؛ لأنها من باب التعاون علىٰ البر والتقوىٰ، بل إنها من أفضل البر؛ لأنَّه يتعلق بها حفظُ أموالِ النَّاسِ وحقوقِهم، وحقوقِ الله تعالىٰ، وإقامَةِ حدودِهِ.

(١) انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة، ٤/١٢ وما بعدها. دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، الإيرواني، ٧٥/٣.
(٢) انظر: الاختيار، الموصلي، ٤١٤/٢، المغني ابن قدامة ٤/١٢.

لذلك يقول تعالىٰ: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) (١)، وقال سبحانه: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)(٢)، قَالَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ: هو: ما يدفع اللهُ بالشهودِ من التجاحُدِ والتظالُمِ (٣).

حكم الشهادة بالنسبة للمشهود به:

أ- في غير الحدود:

يجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى، كطلاق امرأة بائناً، ورضاع، ووقف، وهلال رمضان، وخلع، وإيلاء، وظهار. قال الفقهاء (٤)الذي تقبل فيه الشهادة حسبة (٥) بدون الدعوى أربعة عشر: وهي الوقف، وطلاق الزوجة، وتعليق طلاقها، وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، والنسب، وحد الزنا، وحد الشرب، والإيلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة، ودعوى المولى نسب العبد،وزاد ابن عابدين: الشهادة بالرضاع.

(١) البقرة/٢٨٢
(٢) البقرة/٢٥١
(٣) انظر: المعونة، القاضي عبد الوهاب٣/١٥٤٠.
(٤) انظر: الدر المختار ورد المحتار: ٤٤٠/ ٣. الشرح الكبير للدردير: ١٩٩/ ٤، مغني المحتاج: ٤٥٠/ ٤، المغني: ١٤٦/ ٩، المهذب: ٣٢٣/ ٢.
(٥) الحسبة: الأجر، أي لقصد الأجر، لا لإجابة مدعٍ.

ب ـ في الحدود:

يخير فيها الشاهد بين الستر والإعلام؛ لأنه يكون متردداً بين شهادتي حسبة: في إقامة الحد، والتوقي عن هتك حرمة مسلم، والستر أولى وأفضل؛ لقوله ﷺ للذي شهد عنده: «لو سترْتَهُ بثوبِكَ كان خيرًا لكَ»(١) وقوله ﷺ: «مَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخِرةِ »(٢)

وقد عرفنا في الحدود أن الرسول عليه ﷺ لقن ماعزاً الرجوع عن الإقرار بقوله: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» (٣)

ففي هذا دلالة ظاهرة على أفضلية الستر.

لكن الأولى أن يقول الشاهد في السرقة: أخذ المال إحياء لحق المسروق منه، ولا يقول: سرق صوناً ليد السارق عن القطع، فيكون بهذا قد جمع بين الستر والإعلام أو الإظهار(٤)

(١) الواقع أن الذي قال له النبي ﷺ هذا القول وهو «هزَّال» لم يشهد عنده بشيء، ولكنه هو الذي أشار على ما عز أن يأتي النبي ﷺ ويقر عنده، فلم يكن شاهداً؛ لأن ماعزاً حد بالإقرار، فقال النبي لهزال: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك» رواه أبو داود والنسائي والبزار وأحمد والطبراني عن نعيم ابن هزال، راجع نصب الراية: ٧٤/ ٤.
(٢) متفق عليه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: ٦٨٢٤
(٤) انظر: فتح القدير، الدر المختار، المرجعان السابقان، اللباب: ٥٤/ ٤.

الفصل الثاني

أركان الشهادة.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الصيغة.

المبحث الثاني: الشاهد.

المبحث الثالث: شروط المشهود له.

المبحث الرابع: شروط المشهود عليه.

المبحث الخامس شروط المشهود به.

الفصل الثاني
أركان الشهادة

تمهيد:

الركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى (١).

أما في اصطلاح الفقهاء: فقد اختلف العلماء في تعريفه على **قولين**:

القول الأول:

الركن هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. وإليه ذهب الحنفية(٢).

القول الثاني:

الركن هو: ما لا يتم الشيء إلا به، سواء كان جزءا منه أم لا. وإليه ذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية (٣).

(١) انظر: المصباح المنير ، الفيومي، ١/ ٢٥٥، مختار الصحاح، الرازي، ص ٢٥٥ .
(٢) انظر: كشف الأسرار ٤/ ١٢٨٥، أحكام الأوقاف للزرقا ص ٣٨.
(٣) انظر: البحر الرائق ٥/ ٢٠٥، الخرشي ٧/ ٨٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧١.

أما من حيث الأثر الذي يترتب على عدم وجود الركن، أو الشرط، فيقولون: إنه لا فرق بينهما في العبادات على معنى أن العبادة التي يفوت ركنها، أو يتخلف شرطها تكون باطلة، فالركن والشرط إذن لا بد من وجودهما لصحة العبادة، وفوات أي منهما يبطلها، ويجعلها غير صالحة لأداء ما هو المقصود بها شرعا. وهذا لا خلاف فيه بين جميع الفقهاء.

أما في المعاملات فإنهم يفرقون بين ما فقد ركنه منها، فيكون باطلا، وما تخلف شرطه حيث يكون فاسدا، بخلاف الجمهور الذين يرون بطلان كل ما تخلف ركنه أو فقد شرطه؛ لأن الركن: ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لدخوله في حقيقته، أو لاختصاصه به.

وقد ترتب على الخلاف في معنى الركن الخلاف في أركان الشهادة اختلافهم في تعداد أركانها، ونوضح ذلك فيما يلي:

المبحث الأول

الصيغة

المراد بالصيغة عند الفقهاء: اللفظ الذي يتلفظ به الشاهد على الشهادة(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الشهادة بصيغة " أشهد" صيغة صحيحة، أو ما يتصل به، لأنها المبنى الأساسي للشهادة الشرعية(٢).

واختلفوا: إذا كانت الشهادة بغير هذا اللفظ على قولين:

القول الأول:

إن الشهادة إذا كانت بغير لفظ "أشهد" فلا تصح. **وإليه** ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة(٣).

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٤٠٢٩/٩.
(٢) انظر: فتح القدير ٦ / ٢، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٠٧. بدائع الصنائع، الكاساني، ٤٠٢٩/٩، الهداية، المرغيناني، ١١٨/٣. مغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧. مسالك الأفهام ١٤: ١٥٣، مستند الشيعة، النراقي، ٩/١٨، جواهر الكلام، النجفي، ٤١/٧، قوانين الأصول، أبو القاسم القمي، ص: ٤٦٤
(٣) انظر: فتح القدير ٦ / ٢، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٠٧. بدائع الصنائع، الكاساني، ٤٠٢٩/٩، الهداية، المرغيناني، ١١٨/٣. مغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧. مسالك الأفهام ١٤: ١٥٣، مستند الشيعة، النراقي، ٩/١٨، جواهر الكلام، النجفي، ٤١/٧، قوانين الأصول، أبو القاسم القمي، ص: ٤٦٤

واستدلوا لذلك:

١ـ بأن النصوص اشترطت هذا اللفظ، إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة تأكيد، فإن قوله: (أشهد) من ألفاظ اليمين. وهي تتضمن معنى المشاهدة أي الاطلاع على الشيء. فلو قال: (شهدت) لا يجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع، والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال(١)

ونوقش هذا: بأن غاية ما هناك أن النصوص وردت بلفظ الشهادة، وذلك لا يوجب على الشاهد لفظ الشهادة، كما قال تعالى: "وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ"(٢)، وكما جاء في السنة في تكبير افتتاح الصلاة قوله –صلى الله عليه وسلم: " مفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ وتحريمُها التَّكبيرُ وتَحليلُها التَّسليمُ "(٣) ومع ذلك فإن أبا حنيفة لم يشترط في تكبيرة الإحرام لفظ التكبير(٤) فمن أين لزم في الشهادة؟

(١) انظر: الدر المختار: ٣٨٥/ ٤، البدائع: ٢٦٦/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٤/٥٧، المغني: ٢١٦/ ٩.

(٢) الآية رقم:٣. من سورة المدثر.

(٣) أخرجه: أبو داود في سننه، الحديث رقم:٦١، قال المحدث: صحيح.

(٤) ومن المعلوم إن تكبيرة الإحرام عند أبي حنيفة من فروض الصلاة، وليست ركنا من أركانها، انظر: فتح القدير لابن الهمام مع شرح العناية على الهداية، للبابرتي، ٢٧٤/١.

وأُجيب عن هذا:

بأنه يوجد فرق معنوي، هو أن لفظة الشهادة أقوى في إفادة تأكيد متعلقها من غيرها من الألفاظ كأعلم وأتيقن، لما فيها من اقتضاء معنى المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس؛ ولأنها من ألفاظ الحلف، فالامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أظهر بخلاف التكبير فإنه للتعظيم، وليس لفظ أكبر أبلغ من لفظ أجل، أو لفظ أعظم، فكانت الألفاظ سواء، فلم يثبت خصوصية توجب تعيين لفظ أكبر(١)

٢ـ إن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها(٢).

٣ـ إن لفظة الشهادة فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات، بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد بالله، ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها من الألفاظ(٣)

(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٣٧٦/٧.

(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٢١٦/٩.

(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.

القول الثاني:

إن الشهادة لا يشترط في صحتها لفظ "أشهد"، بل متى قال الشاهد: رأيت كذا، أو سمعت ونحو ذلك، كانت شهادة منه، وإذن لا يشترط في أداء الشهادة صيغة معينة، فتصح بكل ما يدل على حصول علم الشاهد بالأمر الذي يشهد به(١).

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك، وهو ظاهر كلام أحمد، وهو مذهب الشيعة الجعفرية (٢)

واستدلوا لذلك: بأنه لا يشترط لفظ "الشهادة "حتى تصح، فكل من أخبر بشيء فقد شهد به وإن لم يتلفظ بلفظ أشهد(٣).

(١) انظر: الدر المختار: ٣٨٥/ ٤، البدائع: ٢٦٦/ ٦، اللباب شرح الكتاب: ٥٧/ ٤، المغني: ٢١٦/ ٩.

(٢) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٤٠٢٩/٩، الهداية، المرغيناني، ١١٨/٣. مغني المحتاج ٤/ ٤٢٦، والجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٧٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٧٧. مسالك الأفهام ١٤: ١٥٣، مستند الشيعة، النراقي، ٩/١٨، جواهر الكلام، النجفي، ٤١/٧، ، قوانين الأصول، أبو القاسم القمي، : ٤٦٤ .

(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٤٠٢٩/٩، الهداية، المرغيناني. الشرح الصغير لأحمد الدردير، ٣٤٨/٢، إعلام الموقعين، لابن القيم،٧٥/١. مسالك الأفهام ١٤: ١٥٣، مستند الشيعة، النراقي، ٩/١٨، جواهر الكلام، النجفي، ٤١/٧، ، قوانين الأصول، أبو القاسم القمي، : ٤٦٤ .

الترجيح:

والراجح في نظري ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم اشتراط صيغة معينة للشهادة، وذلك لأنه: "ليس في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا ورد ذلك من أحد من الصحابة، ولا ورد في القياس والاستنباط ما يقتضي ذلك، بل الأدلة المتظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة على ذلك (١).

(١) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، ٧٥/١، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص: ٢٣٩، ج١والاختيار لتعليل المختار، لابن مودود، ١٩٦/٢، المغني لابن قدامة، ١٩٦/٢، فتح القدير، ابن الهمام، ٣٧٦/٧، نهاية المحتاج، الرملي، ٢٩٢/٨.

المبحث الثاني

الشاهد

المقصود بالشاهد عند الفقهاء: هو الشخص الذي يؤدي الإخبار عن واقعة أو حق للغير على الغير في مجلس القضاء مستخدماً لفظ الشهادة(١)

الشاهد يشترط فيه القدرة على تحمل الشهادة والقدرة على أدائها، وفيما يلي بيان ذلك في المطلبين **الآتيين**:

المطلب الأول:

شروط تحمل الشهادة

معنى تَحَمُّل الشهادة:

تحمل الشهادة: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع.

ويشترط لتحمل الشهادة شروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون الشاهد عاقلاً:

فلا يصح تحمل الشهادة من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن التحمل يتطلب الفهم والإدراك، وهو يحصل بالعقل(٢).

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١٢٤.
(٢) انظر: فتح القدير ٦ /٢، والبدائع ٦ /٢٨٢، البناية في شرح الهداية ٧ /١٢٠، الفتاوى الهندية ٣ / ٤٥٠، شرح منح الجليل على مختصر خليل ٤ /٢١٥. الإقناع ٤ / ٤٣٠، ومنتهى الإرادات ٢ / ٦٤٧، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ١٢ / ٣.

قال الشيعة الإمامية: " غير البالغ إما غير مميز أو مميز، والثاني إما لم يبلغ عشر سنين أو بلغ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما". والأصل الأولي في الكل: عدم قبول شهادته، وعدم نفوذه، وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات(١).

الشرط الثاني: أن يكون الشاهد بصيرًا:

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على صحة تحمل الشاهد للشهادة إذا كان بصيرًا.

واختلفوا حول تحمل الأعمى للشهادة على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى اشتراط البصر في الشاهد.

واستدلوا: بأن البصر لازم لتحمل الشهادة فلا يصح التحمل من الأعمى عندهم.

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية وزفر من الحنفية إلى صحة تحمل الأعمى للشهادة، فيما يجري فيه التسامع إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت فلان(٢).

(١) انظر: مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١٢.
(٢) انظر: الهداية ٣ / ١٢١ وشرحها فتح القدير ٦ / ٢٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٢١٧، تبصرة الحكام ٢ /٨٠، المهذب ٢ /٣٣٦، المغني١٢ / ٦١، ٦٢ والشرح الكبير١٢ / ٦٧، وسائل الشيعة

الشرط الثالث: أن يكون التحمل عن علم، أو عن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لا بغيره:

واستدلوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر عن رسول الله ﷺ الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله ﷺ بيده إلى الشمس (١).

وجه الاستدلال: إن الشهادة حتى تكون واضحة ويُحكمُ بها لابد لها من العلم، أو المعاينة، إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع، كالنكاح، والنسب، والموت، وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء(٢)

وعن على ابن أبي طالب رضي الله عنه: قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك(٣) أما ما سوى ذلك فتشترط فيه المعاينة.(٤) **والله أعلم.**

(آل البيت) - الحر العاملي، ٤٠٠/٢٧. التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣ والكافي٧: ٤٠٠/ ٢٣- التهذيب ٦: ٢٥٥/ ٦٦٤، الكافي ٧: ٤٠٠/ ٣٤- الاحتجاج:٤٩٠.

(١) انظر: كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - ص ١٦.

(٢) انظر: البدائع ٩ / ٤٠٢٤، الفتاوى الهندية ٣ /٤٥٠، والدر المختار٤ /٣٧٠، والمهذب ٢/ ٣٣٥.

(٣) انظر: وسائل الشيعة،٣٤١/٢٧، حديث رقم :[٣٣٨٨١] مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨- الصفحة ٣٢١.

(٤) انظر: مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٢١.

المطلب الثاني

شروط أداء الشهادة

وأما شروط الأداء: فمنها ما يرجع إلى الشاهد.

ومنها ما يرجع إلى الشهادة.

ومنها ما يرجع إلى المشهود به.

ومنها ما يرجع إلى النصاب (أي عدد الشهود).

أولا: الشروط التي ترجع إلى الشاهد:

١ـ البلوغ والعقل، فلابد أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً باتفاق الفقهاء، فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً، مثل المجنون والسكران والطفل؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله، ولا تقبل شهادة صبي غير بالغ؛ لأنه لا يتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب، وقد سبق الحديث عن هذا الشرط منذ قليل في شروط تحمل الشهادة، فليرجع إليه منعاً للتكرار.

٢ـ الحرية.

اختلفت كلمة الفقهاء في اشتراط الحرية في الشاهد على **قولين**:

القول الأول:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية على أن الشاهد يشترط فيه أن يكون حراً، فلا تقبل شهادة رقيق، لقوله تعالى: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)(١)

ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، وهو لا ولاية له(٢).

القول الثاني:

وذهب الحنابلة والشيعة الإمامية: إلى القول بقبول شهادة العبد، لعموم آيات الشهادة، ولأن العبودية ليس لها تأثير في الرد، وقيدها الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص(٣).

(١) النحل، الآية:٧٥.
(٢) انظر: البدائع: ص ٢٦٧ وما بعدها، بداية المجتهد: ص ٤٥٢، الشرح الكبير: ١٦٥/ ٤، مغني المحتاج: ص ٤٢٧، المغني: ص ١٩٤.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ١٢ / ٣. المغني: ص ١٩٤.

وقيدها الشيعة الإمامية، فقالوا:

أـ شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة(١).

ب ـ شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا(٢).

ج ـ شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل(٣).

٣ـ الإسلام: اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماً، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأنه متهم في حقه(٤).

وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية في السفر، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، أو آخران من غيركم)(٥)

(١) انظر: إجماعات فقهاء الإمامية ، المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات، إجماعات مسائل العبيد والإماء، الشريف المرتضى/ المجلد الأول، ٢٣٩ ج١

(٢)جاء في الينابيع الفقهية: "ومما انفردت به الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه القول: بشهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا. وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول وهو قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور، وروي عن الشعبي أنه قال: يقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر" انظر: الينابيع الفقهية، علي أصغر مروارید، ٤٠٣٩/١١.

(٣) انظر: المرجع السابق، ٢٣٩ ج١

(٤) انظر: فتح القدير: ٤١/ ٦، الكتاب مع اللباب: ٦٣/ ٤، نصب الراية: ٨٥/ ٤، بداية المجتهد: ص ٤٥٢، مغني المحتاج: ص ٤٢٧، المغني: ص ١٨٢. مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٤

(٥) المائدة/١٠٦.

وأجاز الحنفية والشيعة الإمامية خلافًا للجمهور شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم، وإن اختلفت مللهم كاليهود والنصارى(١)، لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»(٢)

٤ـ البصر: وقد تكلمنا عن الخلاف الفقهي في قبول شهادة الأعمى منذ قليل في تحمل الشهادة.

٥ـ النطق: فلا تقبل شهادة الأخرس عند الحنفية والشافعية والحنابلة، حيث اشترطوا أن يكون الشاهد ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن فهمت إشارته؛ لأن الإشارة لا تعتبر في الشهادات؛ لأنها تتطلب اليقين، وإنما المطلوب التلفظ بالشهادة(٣).

(١) انظر: فتح القدير: ٤١/ ٦، الكتاب مع اللباب: ٦٣/ ٤، نصب الراية: ٨٥/ ٤، بداية المجتهد: ص ٤٥٢، مغني المحتاج: ص ٤٢٧، المغني: ص ١٨٢. قال النراقي في مستند الشيعة ٣٤/١٨" وهل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ قال: " نعم، إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " وانظر: الكافي ٧: ٤ / ٢، الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤ وفيه: عن عبيد الله بن علي الحلبي، التهذيب ٩:١٨٠ / ٧٢٤، الوسائل ١٩: ٣١٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ح٣، بتفاوت.

(٢)أخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض» وفيه مجالد وفيه مقال (نصب الراية: ٨٥/ ٤).

(٣) انظر: البدائع: ص ٢٦٨، فتح القدير: ص ٢٧، مغني المحتاج: ص ٤٤٦، المهذب: ٣٣٥/ ٢، المغني: ص ١٨٩، الشرح الكبير للدردير: ١٦٧/ ٤، اللباب: ٦٠/ ٤.

وأجاز المالكية والشيعة الإمامية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه وظهاره، فكذلك في شهادته. (١)

٦ـ العدالة: اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود، لقوله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) (٢) وقوله سبحانه: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) فلا تقبل شهادة الفاسق كالزاني والشارب والسارق ونحوهم، وكذا مجهول الحال .

تعريف العدالة:

هي لغة التوسط، **وشرعًا**: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، والحقيقة أن اجتناب الكبائر كلها هو شرط لصحة الشهادة، وبعد توقيها يلاحظ الشأن الغالب، فمن كثرت معاصيه أثَّر ذلك في شهادته، ومن ندرت

(١) انظر: المغني: ١١٠/ ٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١٦٨/ ٤. ونص الإمامية على قبول شهادة الأخرس فقالوا" يصح من الأخرس تحمل الشهادة والأداء " انظر: الشيخ الطوسي في الخلاف،٢/ ٦٤٤ وإجماعات الإمامية في القضاء والشهادات، المجلد السادس، الشيخ الطوسي، ٦٤٤/٢.
(٢) البقرة/٨٢
(٣) الطلاق/٢

منه المعصية قبلت شهادته. وهذا هو حد العدالة المعتبرة، حتى لا يترتب على التشدد سد باب الشهادة وإماتة الحقوق. (١)

٧ـ عدم التهمة: أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد بها الشهادة.

والتهمة: أن يجلب الشاهد إلى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً، فلا تجوز شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده، ولا شهادة الخصم لخصمه.

والخصم: كل من خاصم في حق، فلا تقبل شهادة الوكيل لموكله، ولا الموصى له للميت أو الموصى عليه: وهو اليتيم في حجره ورعايته، ولا الشريك لشريكه في أمور الشركة؛ لأنها شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في الشركة(٢)، لقوله ﷺ: « لا تقبلْ شهادةُ خَصْمٍ ولاظنينٍ »(٣).

(١) انظر: المبسوط: ١١٣/ ١٦، فتح القدير: ١٢/ ٦ وما بعدها، البدائع: ٢٦٨/ ٦ وما بعدها، الدر المختار: ٣٨٨/ ٤، الكتاب مع اللباب: ٥٧/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥١/ ٢، مغني المحتاج: ٤٢٧/ ٤، المغني: ١٦٥/ ٩ وما بعدها. وقال الشيعة الإمامية " العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات والمراد كونها باعثة بالفعل بحيث لو سقطت عن الفعلية لم تكن عدالة." انظر: المشكيني، مصطلحات الفقه- العدالة ص ٣٧٠.

(٢) انظر: راجع المبسوط: ١٢٠/ ١٦ وما بعدها، البدائع: ٢٧٢/ ٦، فتح القدير: ٣١/ ٦ وما بعدها، الدر المختار: ٣٩٢/ ٤ وما بعدها، اللباب:٦٠/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥٢/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ١٦٨/ ٤ وما بعدها، المهذب: ٣٢٩/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٣٣/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٨٥/ ٩، ١٩١. الشيخ جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن ج ١٠، ص ٨.

(٣) انظر: أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر، وهو منقطع، ورواه أبو داود في المراسيل عن طلحة بن عبد الله بن عوف، ورواه أيضاً البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً، ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناده نظر (نيل الأوطار: ٢٩١/ ٨).

المبحث الثالث

شروط المشهود له.

المشهود له: هو صاحب الحق أو المدعي الذي تُؤدى الشهادة لصالحه لإثبات حقه أو دفع الظلم عنه(١).

وقد اشترط الفقهاء في المشهود له عدة شروط، وبيانها على الوجه الآتي:

الشرط الأول: عدم وجود قرابة بين الشاهد والمشهود له.

اشترط الفقهاء عدم وجود قرابة بين الشاهد والمشهود له، لأن القرابة مظنة التهمة في الميل والمحاباة، والعدول عن الحق في الشهادة، والقرابة المانعة من الشهادة أنواع منها:

- **النوع الأول: قرابة الأبوة والبنوة:**

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على قبول الشهادة من الشاهد للمشهود له متى لم يكن المشهود له قريباً للشاهد، أو لم يكن من أصول الشاهد أو فروعه.

واختلفوا في قبول شهادة الشاهد إذا كانت من الأصل لفرعه أو العكس، أو كانت من الرجل لزوجته أو العكس على **قولين**:

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٧٥.

القول الأول:

إن شهادة الشاهد لا تُقبل، متى كانت من الأصول للفروع أو من الفروع للأصول. **وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(١)**

واستدلوا:

١ـ بقوله ﷺ " لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته" (٢)

٢ـ بقوله ﷺ " لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا ظَنِينٍ في قرابةٍ ولا ولاءٍ " (٣)

وجه الاستدلال من النصين الشريفين: إن النبي ﷺ ، قد نهى عن قبول شهادة الشاهد، متى كانت من الوالد لولده والعكس ، وكذا الرجل لزوجته والعكس، وكذا لا تُقبل شهادة " الظنين" وهو من تُظنُّ به التهمة، والعلة في ذلك: إن العادة جرت على أن ينتفع الأصول بمال الفروع والفروع بمال

(١) انظر: المبسوط للسرخسي،١٦/ ١٢١، المدونة لمالك،٤/ ٢٠، الأم للشافعي ٧/ ٤٩، المغني لابن قدامة،١٠/١٧٢.

(٢) انظر: أخرجه عبد الرازق في مصنفه، باب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته، ٨/ ٣٤٤، رقم: ١٥٤٧٤، قال المحقق: ، الحديث ضعيف، وقال عنه الزيلعي: غريب، انظر: نصب الراية، الزيلعي، ٤/٨٢.

(٣) انظر: أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته،٤/ ٥٤٥، رقم: ٢٢٩٨، ضعفه ابن حجر. انظر: المطالب العالية، ابن حجر، ١٠/٢٣٦.

الأصول، ومن ثم فإن شهادة كلٍ منهم تتضمن معنى النفع، فيكون الشاهد بذلك متهماً في شهادته، والاتهام في الشهادة يؤدي إلى عدم قبوله(١)

ونُوقش هذا بأن شهادة الأصل لفرعه والعكس تكون مقبولة متى كانت لا تَجُرُّ نفعاً لأحدهما، لانتفاء مظنة التهمة(٢).

وأجيب عنه: بأن التهمة موجودة في حق الأقارب، لأن أصل بقاء الانتفاع بالشهادة، لأكونها تُثبتُ حقاً للمشهود له، أو تدفع عنه شرًا(٣).

القول الثاني:

إن شهادة الشاهد تقبل في حالة واحدة، وهي إذا كانت الشهادة من الأصول للفروع، أو العكس، وذلك فيما لا يجري به نفعا بينهما، ولم يكن فيه تهمة لهما كالنكاح، والطلاق، والقصاص، **وإليه ذهب الإمامان: الشافعي وأحمد في رواية عنه(٤)**.

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٢/٦.
(٢) انظر: المغنى، ابن قدامة، ١٧٢/١٠
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٢/٦.
(٤) انظر: المغنى، ابن قدامة، ١٧٢/١٠.، الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، ٧٢/١٢.

واستدل لقولهما:

١ـ بأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك، فلا تهمة في حقه(١).

ونوقش هذا: بان مظنة التهمة باقية في حقهما، لوجود أصل القرابة(٢).

٢ـ عموم أدلة الشهادة من غير تخصيص، حيثُ جاءت الأدلة عامة من غير أن تنص على استثناء القرابة(٣).

ونوقش هذا: بأن القرابة مخصوصة من عموم الآية بالأحاديث السابق ذكرها(٤).

الترجيح:

والراجح ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة الأصل لفرعه والعكس، وكذا شهادة الرجل لزوجته والعكس، لقوة أدله الجمهور وسلامتها من المناقشات التي أوردت عليها.

(١) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ١٦٦/١٧، بحر المذهب، الروياني، ٢٨٩/١٤، ابن قدامة، ١٧٢/١٠، الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، ٧٢/١٢.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٢/٦.
(٣) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ١٦٦/١٧، بحر المذهب، الروياني، ٢٨٩/١٤،
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي، ١٦/ ١٢١،

- النوع الثاني: شهادة الأخ لأخيه:

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة: إلى قبول شهادة الأخ لأخيه(١).

واستدلوا:

١ـ بقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) (٢)

وجه الاستدلال: إن الخطاب عام من غير فصل بين القريب والأجنبي(٣).

٢ـ واستدلوا من الإجماع:

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم:

قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا كان عدلا"(٤)

(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة، ٣٢٥/٨، المبسوط للسرخسي، ١٦/ ١٢٥، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٢٤٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٧/ ١٦٦، المغني لابن قدامة) ١٠/ ١٧٥، الإشراف على مسائل الخلاف، ابن المنذر،٤/ ٢٧١، الإقناع لابن المنذر، ٢/ ٥٢٧، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ٧/ ٢٩٢. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد نعيم ٢/ ٩٥٥.

(٢) الآية:٢٨٢، من سورة البقرة.

(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة، ٣٢٥/٨

(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر،٢٦٢/٧ الإجماع لابن المنذر، ص:٧٨.

وقال ابن القطان: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلًا" (١).

٣ـ المعقول فقالوا:

إن وجود التهمة بينهما منعدم، لأن الأملاك ومنافعها متباينة بينهما، ولا ينبسط بعضهم في مال بعض عادة، فتقبل شهادة الأخ لأخيه قياساً على الأجنبي، ولا يصح القياس على الوالد والولد؛ لأن بين الوالد والولد بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ، وشهادة سائر الأقارب بعضهم على بعض(٢).

النوع الثالث: شهادة سائر الأقارب بعضهم على بعض:

وأما شهادة سائر الأقارب غير الأصول والفروع لبعضهم البعض: فهي مقبولة عند جمهور الفقهاء(٣)، كشهادة الشخص لأخواله، وأعمامه، وشهادة الأخوال لأولاد أخواتهم، وشهادة الأعمام لأولاد أخوتهم، وهكذا بقية الأقارب.

(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، ١٣٧/٢.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي، ١٦/ ١٢٥
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة، ٣٢٥/٨، المبسوط للسرخسي، ١٦/ ١٢٥، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٢٤٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٧/ ١٦٦، المغني لابن قدامة، ١٠/ ١٧٥، الإشراف على مسائل الخلاف، ابن المنذر،٤/ ٢٧١، الإقناع لابن المنذر، ٢/ ٥٢٧، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ٧/ ٢٩٢. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد نعيم ٢/ ٩٥٥.

واستدلوا:

١ـ بأن سائر الأقارب ليس لبعضهم تسلط في مال البعض لا عرفًا ولا عادة، فأَلْحِقوا بالأجانب، فشهادة سائر الأقارب أولى بالجواز(١).

٢ـ بالقياس على قبول شهادة الأخ، فإذا أجيزت شهادة الأخ مع وجود قربه، كان ذلك دليلاً على قبول شهادة من هو أبعد من الأخ من سائر الأقارب، من باب أولى(٢).

قال البغوي: "واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ، وسائر الأقارب"(٣)

الشرط الثاني: عدم وجود شراكة بين الشاهد والمشهود له:

لقد نص الفقهاء على كثير من التهم التي ترد بها الشهادة، ومن ذلك: **عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه**، ولذلك: شرطوا عدم وجود شراكة بين الشاهد والمشهود له، بل ونقل الاتفاق وعدم الخلاف في

(١) انظر: المبسوط للسرخسي، ١٦/ ١٢٥،البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ٣١٣/١٣، المغني، ابن قدامة، ١٧٥/١٠. الإشراف على مسائل الخلاف، ابن المنذر،٤/ ٢٧١، الإقناع لابن المنذر، ٢/ ٥٢٧، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ٧/ ٢٩٢. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي لمحمد نعيم ٢/ ٩٥٥.
(٢) انظر:المبسوط،١٦/ ١٢٥،البيان في مذهب الشافعي،٣١٣/١٣،المغني١٧٥/١٠.
(٣) انظر: شرح السنة، البغوي، ١٢٩/١٠.

ذلك، لأن كلاً من هؤلاء في حكم المالك، والمالك لا شهادة له، لأنه مدعٍ ومالك، فهو كالذي يشهد على فعل نفسه في البعض وهذا باطل ،فإذا بطل البعض بطل الكل، لكونها غير متجزئة إذ هي شهادة واحدة، فلا تقبل شهادته للتهمة ،ولو شهد بما ليس من شركتهما قبلت لانتفاء التهمة" (١)

جاء في كتاب العناية عند ذكره من تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: " ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما؛ لأنه يصير شاهدا لنفسه"(٢).

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله مجموعة من أهل العلم ممن رد شهادة الشريك لشريكه ثم قال: " ولا نعلم فيه مخالفا"(٣).

وقد نقل ابن القاص رحمه الله الاتفاق على عدم جواز ذلك فقال: " واتفق الجميع على أن شهادة المرء لشريكه فيما له فيه شرك غير جائزة"(٤).

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٤٧/١٦. المدونة، الإمام مالك، ١٨/٤، الحاوي الكبير، الماوردي، ١٦٠/١٧، المغني، ابن قدامة، ١٦٩/١٠، الإقناع، ابن المنذر، ٥٢٨/٢
(٢) انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، ٤٠٧/٧.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٦٩/١٠.
(٤) انظر: أدب القاضي، ابن القاص، ٣٠٨/١.

المبحث الرابع

شروط المشهود عليه.

المشهود عليه:

هو: الشخص الذي تُؤدَّى الشهادة ضده أو في مواجهته لإثبات حق عليه أو نفي دعوى(١) وقد اشترط الفقهاء في المشهود عليه ما يلي:

١ـ أن يكون المشهود عليه معلوما:

يجب أن يكون المشهود عليه معلوماً ومحدداً بالاسم أو الإشارة النافية للجهالة، فلا تقبل الشهادة على شخص مجهول، مثل: "شهدت أن أحداً من أهل هذه القرية سرق"(٢).

٢ـ ألا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه:

اشترط الفقهاء انتفاء العداوة الدنيوية الظاهرة بين الشاهد والمشهود عليه، لأن العداوة تثير شبهة الانتقام وتمنع قبول الشهادة(٣).

(١) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص: ١٧٥.
(٢) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل ٦ / ١٩١، ١٩٢، جواهر الإكليل ٢ / ٢٤٢، التاودي والتسولي على التحفة ١ / ١٣٢.
(٣) انظر: الفروق للقرافي ٤ / ٥٥، مواهب الجليل مع التاج والإكليل ٦ / ١٩١، ١٩٢.

٣ـ الأهلية لثبوت الحق عليه:

اشترط الفقهاء: أن يكون المشهود عليه ممن يمكن أن يثبت الحق في مواجهته، فإذا كانت الشهادة بحد أو جناية، يُشترط أن يكون المشهود عليه مكلفاً "بالغاً عاقلاً" لإنفاذ العقوبة البدنية، أما في الحقوق المالية فتقبل على الصبي والمجنون ويتحملها وليّهما(١).

٤ـ يَشترطُ جمهور الفقهاء(٢) غالباً، حضور المشهود عليه، أو وكيله ومن ينوب عنه، عند أداء الشهادة أمام القاضي؛ لتمكينه من الرد أو الاستفصال، ولتحقيق العدالة وضمان صدق الشاهد(٣).

وقد أجاز الفقهاء الاستماع إلى الشهادة في غياب المشهود عليه إذا وجد عذر شرعي كالسفر أو المرض أو التعذر الطارئ مع حضور وكيله(٤).

(١) انظر: الدر المختار ٤ / ٣٧٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٩٩، والشرح الصغير ٤ / ٢٨٥.
(٢) انظر: جواهر الإكليل، المواق، ٢ / ٢٤٢
(٣) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٤٧/١٦. المدونة، الإمام مالك، ١٨/٤، الحاوي الكبير، الماوردي، ١٦٠/١٧، المغني، ابن قدامة، ١٦٩/١٠.
(٤) انظر: الدر المختار ٤ / ٣٧٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٩٩، والشرح الصغير ٤ / ٢٨٥.

المبحث الخامس

شروط المشهود به.

المشهود به:

هو الواقعة أو الحق أو الفعل الذي يقع عليه إدراك الشاهد ويؤدي الشهادة لأجله أمام القاضي لإثبات الحقوق وإقامة العدل(١).

والشهادة لا تحصل للإنسان إلا بما يعلمه حقيقة ويقيناً ، لا ظناً.

لقول الله تبارك وتعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (٢)

وقوله تبارك وتعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا) (٣)

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما، أن النبي ﷺ قال لرجل: سئل عن الشهادة، تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ (٤)

(١) انظر: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر،ص:١٧٧

(٢) من الآية:٨٦ من سورة الزخرف.

(٣) الأية:٣٦ من سورة الإسراء.

(٤) انظر: سبل السلام، للصنعاني، ١٣٠/٤،وكشاف القناع، البهوتي، ٤٠٢/٦.

ويشترط الفقهاء :

١ – الزنى وعمل قوم لوط، فلا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)(١)

٢ – إذا ادعى من عُرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من شهادة ثلاثة رجال عدول(٢).

٣ – ما أوجب قصاصاً أو حداً غير الزنى أو تعزيراً فلا بد فيه من شهادة رجلين عدلين(٣).

٤ – قضايا الأموال كالبيع، والقرض، والإجارة ونحوها، والحقوق كالنكاح، والطلاق، والرجعة ونحوها، وكل ما سوى الحدود والقصاص فيقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتان، ويُقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إذ تعذر إتمام الشهود(٤).

(١)الآية:٤ من سورة النور..
(٢) انظر: الآية:٤ من سورة النور.
(٣) انظر: المبدع في شرح المقنع، ٢٥٤/١٠.
(٤) انظر: بدائع الصنائع،٢٦٦/٦، فتح القدير، ابن الهمام، ٣٧٦/٧.حاشية الدسوقي٤ / ١٩٩، والشرح الصغير، الدردير،٢٨٥/٤. الفروق للقرافي٤ / ٥٥، المبدع في شرح المقنع،٢٥٤/١٠.

٥ – ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالرضاع، والولادة، والحيض ونحو ذلك مما لا يحضره الرجال فيُقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، ويجوز من امرأة عدل، والأحوط اثنتان، أو رجل عدل، والأكمل كما سبق.

٦ – ما يُقبل فيه قول واحد عدل، وهو رؤية هلال رمضان أو غيره.

٧ـ ما يُقبَل فيه شهادةُ غير المسلمين، كالوصية في السَّفَر إذا تعذَّر وجود غيرهم(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ – قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) (٢).

٢ – عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى بيَمينٍ وشاهِدٍ". (٣).

(١) انظر: القواعد والأصول الجامعة"؛ لابن سعدي ص: ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٢) من الآية : ٢٨٢، من سورة البقرة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: ١٧١٢

وقد قسم الفقهاء طريق العلم بالشهادة إلى قسمين:

القسم الأول: الشهادة عن طريق العلم الحاصل بالرؤية.

القسم الثاني: الشهادة عن طريق العلم الحاصل بالسماع.

أولا: الشهادة بالعلم الحاصل عن طريق الرؤية:

أما ما يقع بالرؤية فالأفعال، مثل الغصب، والإتلاف، والزنا، وشرب الخمر، وسائر الأفعال، وكذلك الصفات المرئية، كالعيوب في البيع ونحوها، فهذا لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية؛ لأن الشهادة عليه ممكنة قطعا، فلا يرجع إلى غير ذلك.

ويشترط الفقهاء في المشهود به ما يأتي:

١ـ اتفق الفقهاء على وجوب أن يكون المشهود به معلوماً، ومحدداً بدقة؛ لرفع جهالة النزاع، فلا تصح الشهادة في مجهول لا تتبين حقيقته، ومن ثم فإن الرؤية هاهنا ضرورية للشهادة، فلا يصح هنا أن يكون السماع طريقاً للشهادة، فلا تُقبل شهادة الشاهد إذا قال أشهد بأنى سمعتُ أن فلانا سرق كذا . أو قتل فلاناً ونحو هذا(١).

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٧/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون ١ / ٣٤٦، ٣٤٧،مغني المحتاج، الشربيني، ١٠٢/٤، المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٤.

ويترتب على ذلك:

إن الشهود لو شهدوا على شخص أنه قتل شخصاً آخر فقط لم يشهدوا بغير هذا، فإن شهادتهم لا تقبل، إلا إذا بينوا فيها مكان حدوث القتل، وزمنه، والآلة التي تم بها القتل، واسم القاتل، والمقتول. وكذا لو شهد شخص على أن فلاناً اقر لفلان بمبلغ من المال أنه في ذمته، فيجب أن يبين الشاهد في شهادته اسم المقر، والمقر له، والمقر به- مبلغ المال- وصنفه، ونوعه، ومقداره، ومكان حصول الإقرار، وزمنه، وهل كان برضى المقر أم جبراً عنه، وهكذا في سائر الوقائع، فلا بد أن يبين الشاهد المشهود به بياناً كافياً نافياً للجهالة مما يجعله معلوماً لدى القاضي وبما يؤكد لديه صحة شهادة الشاهد، فيأخذ بها في قضائه، فإن كانت بمجهول فلا تقبل(١)

٢ـ أن يكون متقوماً شرعاً: أي أن يكون له قيمة مالية أو شرعية مباحة، فلا تقبل الشهادة في أمر مُحَرَّم لذاته، أو غير معتبر شرعاً، كمال غير متقوم "كالخمر والخنزير للمسلم" وهذه الشهادة طريقها العلم ، وليس السماع(٢).

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٢/٦، المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٢٤.
(٢) انظر: بدائع الصنائع،٢٧٧/٦، تبصرة الحكام، ابن فرحون ١ / ٣٤٦،٣٤٧، مغني المحتاج، الشربيني، ١٠٢/٤، المغني مع الشرح الكبير١٢ / ٢٤.

٣ـ أن يكون ممكناً عقلاً وواقعاً: ألا يكذب الواقع أو العادة، بحيث يستحيل وقوع المشهود به حقيقة، فلو شهد بشيء مستحيل رُدّت الشهادة، فلو شهد على شخص أنه ارتكب جريمة قتل، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه كان مسافراً وقت وقوع الجريمة، فلا تُقبل شهادته، وهذا أيضاً طريقه الرؤيا أي المشاهدة فقط(١).

٤ـ أن يكون محققاً غير مشكوك فيه: فلابد أن يكون المشهود به متعلقاً بعين ثابتة أو فعل متيقن، مستنداً إلى العلم اليقيني لا إلى الظن والتخمين، فلو شك في المسروق فقال ربما هو أو غيره، أوشك في عدد المسروق فقال: لا أدري ثلاثة أم أربعة، فلا تقبل شهادته(٢).

ثانيا: الشهادة بطريق السماع:

كانت الدراسة فيما سبق للشهادة عن طريق المشاهدة، وأما الشهادة عن طريق السماع فبيانها كما يلي:

وأما الشهادة بطريق العلم، الحاصل عن السماع، فنوعان: (٣)

(١) انظر: القوانين الفقهية ، ابن جزي الكلبي، ، ص: ٢٠٥، روضة الطالبين، النووي، ١١ / ٢٥٩، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ١٢ / ١٩.
(٢) انظر: الدر المختار، الحصكفي، ٤ / ٣٧٥، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١ / ٣٤٧، مواهب الجليل، الحطاب. ٦ / ١٩١ – ١٩٢.
(٣) انظر: في تفصيل ذلك: النظام القضائي، د. محمد رأفت عثمان، ص: ٣١٩ وما بعدها.

النوع الأول:

السماع من المشهود عليه، مثل العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك من الأقوال، فلا بد من سماع كلام المتعاقدين.

ولكن هل لا بد من رؤية المتعاقدين أم يكفي سماع صوتيهما من غير رؤية:

لقد اختلف الفقهاء في ذلك على **قولين**:

القول الأول: إنه لا تجوز الشهادة إلا إذا شاهد الشاهد المشهود عليه. وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي(١).

واستدلوا: بأن الأصوات تتشابه، فلا يجوز أن يشهد عليها من غير رؤية، كالشهادة على الخط(٢).

القول الثاني: إنه لا يشترط رؤية المتعاقدين إذا عرفهما الشاهد وتيقن كلامهما، وهذا ما يراه ابن عباس، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، وشريح، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والحنابلة.

واستدلوا: بأن الشاهد عرف المشهود عليه يقينا فجازت شهادته عليه كما لو كان رآه، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور، وإنما تجوز الشهادة

(١) انظر: القوانين الفقهية ، ابن جزي الكلبي، ، ص: ٢٠٥، روضة الطالبين، النووي، ١١ / ٢٥٩، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ١٢ / ١٩.
(٢) انظر: الدر المختار، الحصكفي، ٤ / ٣٧٥، تبصرة الحكام، ابن فرحون، ١ / ٣٤٧، مواهب الجليل، الحطاب. ٦ / ١٩١ – ١٩٢.

لمن عرف المشهود عليه يقينا، وقد يحصل العلم بأن الشاهد عرف المشهود عليه يقينا فجازت شهادته عليه كما لو كان رآه، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور، وإنما تجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقيناً بالسماع يقينا، وقد ثبت أن الشرع اعتبره، فإنه من الجائز رواية الحديث من غير رؤية، ولهذا قبلت رواية الأعمى للحديث، ورواية الذين رووا الحديث عن أزواج الرسول ﷺ من غير محارمهن، فإنهم رووا عنهن الحديث من غير رؤية لهن؛ لأن مخاطبة الرجال الأجانب لزوجات الرسول ﷺ لا تجوز إلا من وراء حجاب، قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ)(١).

النوع الثاني من السماع: ما يعلمه بالاستفاضة:

اتفق العلماء على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب، والولادة(٢)، قال ابن المنذر: "أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا يمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه"(٣).

(١) من الآية:٥٣، من سورة الأحزاب.

(٢) انظر: المغني، ج٩، ص١٦١، ١٦٢. سبل السلام، الصنعاني، ١٣٠/٤.

(٣) انظر: نشر المحاسن اليمانيّة، ابن البديع ، الشيباني الشافعي،٢٠٤/١.

الفصل الثالث

نصاب الشهادة، وأخذ الأجرة عليها، والرجوع عنها:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: نصاب الشهادة.

المبحث الثاني: حكم أخذ الأجر على الشهادة

المبحث الثالث: الرجوع عن الشهادة.

المبحث الرابع: تعريف شهادة الزور وحكمها وعقوبة شاهد الزور.

المبحث الأول

نصاب الشهادة.

المقصود بنصاب الشهادة في اصطلاح الفقهاء:

هو العدد المشترط شرعاً من الشهود وصفتهم "من الذكورة والأنوثة"؛ لكي تُقبل شهادتهم وتَثبتُ بها الحقوق أمام القضاء(١).

ويختلف هذا النصاب في الفقه الإسلامي باختلاف نوع القضية أو الحق المشهود به، وفيما يلي بيان ذلك:

(١) انظر: نظرية الدعوى في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:٢٠٧.

المطلب الأول

نصاب الشهادة على الزنا.

اتفق الفقهاء: على أن نصاب الشهادة، أي عدد الشهود المطلوب في جريمة الزنا هو أربعة شهداء. أي: رِجالٍ عُدولٍ، بالغين عاقلين من المسلمين، يرون الواقعة رؤية صريحة لا تحتمل التأويل، ولا تَصِحُّ شَهادةُ النِّساءِ.وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية، والإباضية(١) وقد حُكي الإجماع (٢)على ذلك(١).

(١) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي ،٢٠٨/٤، درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ٣٧١/٢، التاج والإكليل، للمواق ، ٨/ ٣٩٤، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، العدوي، ٣٢٣/٢، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، ٢٤٦/١٠، نهاية المحتاج، الرملي ، ٨/ ٣١٠، المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ، ٣٩٥/٧، الإنصاف، للمرداوي ، ١٢/ ٧٨. البحر الزخار، ٤/٥ـ٧، شرح الأزهار، ٢٢٩/٤، وما بعدها،ابن مفتاح، اللمعة الدمشقية، العاملي، ص:١٦٤.جواهر الكلام ، النجفي، ٢٥٨/٤١، المختصر النافع،المحقق الحلي، ٢٩٢ وما بعدها، مختصر الخصال، إبراهيم الحضرمي، ص:٣٤٨، وما بعدها. الكندي، المصنف، ٣٦/٤٠.

(٢)قال ابنُ عَبدِ البَرّ: "فأجمَعَ العُلَماءُ أنَّ البَيِّنةَ في الزّنا أربَعةُ شُهَداءَ رِجالٌ عُدولٌ يَشهَدونَ بالصَّريحِ مِنَ الزّنا لا بالكِنايةِ، وبالرُّؤيةِ كَذلك، والمُعايَنةِ). انظر: الاستذكار، ابن عبد البر، ٤٨٥/٧، وقال البَيهَقيُّ: " لَم أعلَمْ أحَدًا مِن أهلِ العِلمِ خالَفَ في ألا يَجوزَ في الزّنا إلَّا الرِّجالُ". انظر: معرفة السنن والآثار، البيهقي، ٣٧٨/٧، وقال ابنُ العَرَبيّ: "قَولُه تعالى: فاستَشهِدوا عليهنَّ أربَعةً مِنكُم: قَولُه تعالى: مِنكُم المُرادُ به هاهُنا الذُّكورُ دونَ الإناثِ؛ لأنَّه سُبحانَه ذَكَرَ أوَّلًا مِن نِسائِكُم ثُمَّ قال: مِنكُم، فاقتَضى ذلك أن يَكونَ الشَّاهِدُ غَيرَ المَشهودِ عليه، ولا خِلافَ في ذلك بَينَ الأُمَّةِ". انظر: أحكام القرآن،ابن العربي،٣٦٠/٤، وقال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: "فإنَّ المُسلِمينَ اتَّفَقوا على أنَّه لا يَثبُتُ الزِّنا بأقَلَّ مِن أربَعةِ عُدولٍ ذُكورٍ" انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، ٣٨١/٢، وقال ابنُ قُدامةَ: "أن يَكونوا رِجالًا كُلُّهم ولا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ بحالٍ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا... ولا خِلافَ في أنَّ الأربَعةَ إذا كانَ بَعضُهم نِساءً أنَّه لا يُكتَفى بهم"انظر: المغني)، ابن قدامة،٦٤/٩، وقال القُرطُبيُّ عِندَ تَفسيرِ قَولِه تعالى:(واللَّاتي يَأتينَ الفاحِشةَ مِن نِسائِكُم فاستَشهِدوا عليهنَّ أربَعةً مِنكُم:) " ولا بُدَّ أن يَكونَ الشُّهودُ ذُكورًا؛ لقَولِه: مِنكُم ولا خِلافَ فيه بَينَ الأُمَّةِ". انظر: تفسير القرطبي، ٨٤/٥، وقال النَّوَويُّ: "أجمَعوا على أنَّ البَيِّنةَ أربَعةُ شُهَداءَ ذُكورٍ عُدولٍ ... ولا يُقبَلُ دونَ الأربَعةِ". انظر: شرح صحيح مسلم،١٩٢/١١، وقال ابنُ القَيِّمِ: " الحُكمُ

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - **قَولُ اللهِ تعالى:** (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)(٢)

وَجهُ الاستدلال:

إنَّه سُبحانَه ذَكَرَ أوَّلًا مِن نِسائِكُم فجَعَلَ المَشهودَ عليه مِنَ الإناثِ، ثُمَّ قال: مِنكُم أي: مِنَ الرِّجالِ؛ لأنَّ الآيةَ تَقتَضي أن يَكونَ الشَّاهِدُ غَيرَ المَشهودِ عليه(٣).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).(٤)

بأربَعةِ رِجالٍ أحرارٍ، وذلك في حَدِّ الزِّنا واللِّواطِ، أمَّا الزِّنا فبالنَّصِّ والإجماعِ" . الطرق الحكمية، ابن القيم، ص: ١٣٧، وقال المَرداويُّ: "فلا يُقبَلُ فيه إلَّا شَهادةُ أربَعةِ رِجالٍ أحرارٍ بلا نِزاعٍ" الإنصاف، المرداوي، ٧٨/١٢، وقال الشَّوكانيُّ في بَيانِ بَيِّنةِ الزِّنا: "أي: شَهادةُ أربَعةِ شُهودٍ ذُكورٍ بالإجماعِ". نيل الأوطار، الشوكاني، ١٢٦/٧، وخالف في ذلك: عَطاءٌ، وحَمَّادٌ، وابنُ حَزمٍ، قال ابنُ قُدامةَ: " الشَّرطُ الثَّاني: أن يَكونوا رِجالًا كُلُّهم، ولا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ بحالٍ، ولا نَعلمُ فيه خِلافًا إلَّا شَيئًا يُروى عن عَطاءٍ وحَمَّادٍ أنَّه يُقبَلُ فيه ثَلاثةُ رِجالٍ وامرَأتانِ، وهو شُذوذٌ لا يُعَوَّلُ عليه؛ لأنَّ لفظَ الأربَعةِ اسمٌ لعَدَدِ المَذكورينَ) المغني،٦٩/٩، المحلى لابن حزم،٤٧٦/٨، البناية شرح الهداية، للعيني، ١٠٥/٩.

(١) وشَذَّ ابن حزم عن الإجماع فقال: " ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثمان نسوة فقط ."

(٢) انظر: من الآية:١٥، من سورة النساء.

(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ، ١/ ٤٦٠، تفسير القرطبي، القرطبي، ٥/ ٨٤، المغني لابن قدامة ، ١٦٩/١٠.

(٤) من الآية:٤، من سورة النور.

٣ – قَولُ اللهِ تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (١).

وَجهُ الاستدلال من الآياتِ:

الآياتُ دَليلٌ لإثباتِ حَدِّ الزِّنا بالشَّهادةِ، ولَفظُ أربَعةٍ نَصٌّ في العَدَدِ والذُّكورةِ(٢).

٤ـ عَن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ سَعدَ بنَ عُبادةَ قال: "يا رَسولَ اللهِ، إن وجَدتُ مَعَ امرَأتي رَجُلًا أأُمهِلُه حَتَّى آتيَ بأربَعةِ شُهَداءَ؟ قال: نَعَم"(٣) .

وَجهُ الاستدلالِ:

قَولُه: "حَتَّى آتيَ بأربَعةِ شُهَداءَ" دَليلٌ على أنَّ مِن شُروطِ حَدِّ الزِّنا أن يَكونَ الشُّهودُ أربَعةَ رِجالٍ(٤).

٥ـ واستدلوا من المعقول، فقالوا:

لأنَّ في شَهادَتِهنَّ شُبهةً؛ لتَطَرُّقِ الضَّلالِ إليهنَّ، قال اللهُ تعالى:(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) (٥)، والحُدودُ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ(٦).

(١) من الآية: ١٣، من سورة النور.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم، ٨/ ٤٧٦. البحر الرائق لابن نجيم ، ٧/ ٦٠
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ١٤٩٨
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ، ٦٩/٩.
(٥) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ، ٦٩/٩.

المطلب الثاني

نصاب الشهادة علي القصاص والحدود سوى الزنا.

اختَلَفَ الفُقَهاءُ في نِصابِ الشَّهادةِ في العُقوباتِ غَيرِ الزِّنا، على قولين:

القَولُ الأوَّلُ:

لا يُقبَلُ إلَّا شَهادةُ رَجُلَينِ في العُقوباتِ غَيرِ الزِّنا، وإليه ذهب: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ(١).

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ قَولُه تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (٢).

وَجهُ الاستدلال:

رَتَّبَ اللهُ الشَّهاداتِ بحِكمَتِه في الحُقوقِ الماليَّةِ والبَدَنيَّةِ والحُدودِ، فجَعَلَها في كُلِّ نَوعٍ شَهيدَينِ، إلَّا في الزِّنا؛ فإنَّه قَرَنَ ثُبوتَها بأربَعةِ شُهَداءَ؛ تَأكيدًا في السَّتر(٣).

(١) انظر: المبسوط للسرخسي ، ١٦/ ١١٤، البحر الرائق، لابن نجيم ، ٧/ ٦٠، التاج والإكليل للمواق، ٢٠٩/٨، منح الجليل لعليش،٨/ ٤٤٩، ٤٥٠. منهاج الطالبين للنووي ، ص: ٣٤٧، مغني المحتاج للشربيني، ٤/ ٤٤٢، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ٨/ ٣٣١، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٣٣.

(٢) انظر: من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.

(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، ١/ ٣٣٢.

٢ـ لا تُقبَلُ إلَّا شَهادةُ الرِّجالِ؛ لأنَّ في شَهادةِ النِّساءِ شُبهةَ البَدَليَّةِ؛ لقيامِها مَقامَ شَهادةِ الرِّجالِ، فلا تُقبَلُ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ(١).

القَولُ الثَّاني:

تُقبَلُ شَهادةُ رَجُلٍ وامرَأتَينِ في العُقوباتِ. وإليه ذهب حَمَّادٍ، وعَطاءٍ، واختاره ابنُ حَزم(٢).

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "...أمَّا نُقصانُ العَقلِ فشَهادةُ امرَأتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رَجُلٍ، فهذا نُقصانُ العَقلِ"(٣).

وَجهُ الاستدلال:

إنَّه ﷺ قَطَعَ بأنَّ شَهادةَ امرَأتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رَجُلٍ، فوجَبَ ضَرورةً أنَّه لا يُقبَلُ حَيثُ يُقبَلُ رَجُلٌ لَو شَهِدَ إلَّا امرَأتانِ، وهَكَذا ما زادَ(٤).

٢ــ قياسُ الشَّهادةِ على العُقوباتِ على الشَّهادةِ في الأموالِ(٥).

(١) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ، ٧/ ٦٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ، ١٠/ ١٣٠، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ، ١٢/ ٨٤، المحلى ، ٨/ ٤٧٦.
(٣) انظر: أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث رقم: ٧٩
(٤) انظر: المحلى ، ٨/ ٤٨٧.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ١٠/ ١٣٠، الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ، ١٢/ ٨٤.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين الجمهور، وبين من خالفهم إلى **الأسباب الآتية**:

١ـ عموم النصوص الواردة في الشهادة، فمن أخذ بعموم النصوص، قال بجواز شهادة المرأة مع الرجال في العقوبات البدنية غير الزنا، فقد خصصه النص بأربعة شهداء، فيبقى على ما عداه على أصله من العموم، ولهذا قال عطاء وابن حزم ومن وافقهما، بجواز شهادة النساء مع الرجال، وأما الجمهور، فقد جعلوا العلة من الشهادة الحيطة والحذر، والخوف من نسيان المرأة، وتغير رأيها، وتبدل حالتها المزاجية لما يعتريها من نقص في عقلها ودينها، وتلك حكمة الهية ،مردها إلى الجبلة والطبعيَّةِ التي في المرأة بحسب أصل خلقتها، ولذا فإن الجمهور أبقى الشهادة على أصلها فيما عدا الزنا من اشتراط رجلين، عدلين، أخذاً بالاحتياط في مجتال الدماء والقصاص؛ لما لها من عظيم الخطر.

٢ـ كما يرجع سبب الخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم إلى إجراء القياس، فالجمهور رفضوا إجراء قياس العقوبات فيما عدا الزنا على الأموال، التي يجوز فيها قبول شهادة المرأة إلى جانب الرجال، لوجود الفارق بين المقيس وبين المقيس عليه، إذا العقوبات البدنية في القصاص والدماء أعظم خطراً،

وأشدُّ ضرراً من الحقوق المالية، ومع هذا الفارق، فلا يصلح القياس. وأما من خالفهم، فقد أجرى قياس الدماء والعقوبات البدنية على الحقوق المالية، فأجاز شهادة المرأة مع الرجل، لأن العلة هي إثبات الحق، وهي موجودة في العقوبات البدنية والمالية على السواء.

٣ـ كما يرجع سبب الخلاف بين الجمهور وبين مخالفيهم إلى انعدام النص المانع لشهادة النساء مع الرجال، فمن تمكسك بجواز شهادة النساء مع الرجال، قال إنه لا يوجد نص يمنعهم من ذلك، ولو كان ذلك غير جائز، لَوَرَدَ النص بذلك، إذ لا يجوز في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان الشارع الحكيم يرفض شهادة المرأة إلى جوار الرجل، لَبَيَّنَ لنا ذلك، وأما إذا لم يرد نص، فيبقى العموم قائماً لانعدام النص، وأما الجمهور فقالوا بأن النص، باقٍ على أصله من اشتراط الرجال، وأما النساء، فتمتنع الشهادة منهن، لكون الدماء والعقوبات البدنية أشبه بحد الزنا، في الخطر، فلذا قالوا بعدم جواز شهادة النساء في القصاص والحدود سوى الزنا.

الترجيح:

وبعد عرض الأدلة، لكل رأي نرى ـ والله أعلم ـ رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارض، ولأن العقوبات البدنية أشبه بالزنا، من حيث الخطر.

والله أعلم.

المطلب الثالث

نصاب الشهادة في حقوق الأبدان

المقصود بحقوق الأبدان عند الفقهاء:

هي كل حكم يتعلق بالبدن، مما ليس مالاً ولا يؤول إلى مال، كالنكاح والطلاق والرجعة والنسب والعدة والجراح والرضاع والولادة وعيوب النساء(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على قبول شهادة المرأتين مع الرجل عملاً بالآية الكريمة، واتفقوا على حالات تقبل فيها شهادة المرأتين والرجل(٢).

كما اتفقوا الفقهاء على جواز القضاء بشهادة المرأتين مع الرجل في الأموال، كالمُداينات، وما يؤول إلى مال، كالبيع والوقف والإجارة والهبة والصلح والمُساقاة والمضاربة والشركة وغيرها مما يقصد به المال، ودليلهم ورود شهادة المرأتين مع الرجل في آية الدين(٣).

(١) انظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ١٦٨/١.
(٢) انظر: المبسوط، ١٠٠/١٦. الفروق، القرافي ٢٢٧/٤، مغني المحتاج، الشربيني ٤٤٢/٤، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص١٣١، المغني، ٧/١٢، دار الفكر.
(٣) انظر: المراجع السابقة، نفس المواضع.

واختلفوا في أحكام الأبدان: هل تجزئ فيها امرأتان مع رجل أم لا بد من رجلين فقط؟ على **قولين**:

القول الأول:

تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في أحكام الأبدان. وإليه ذهب إلى هذا القول الحنفية، ورواية عن أحمد، والظاهرية، وهو قول للزيدية والإمامية، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وإسحاق، وأجاز ابن حزم شهادة النساء في سائر الحقوق(١).

أدلة القول الأول:

١ـ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)(٢).

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة من وجهين:

الوجه الأول : أن الله عز وجل، أقام المرأتين والرجل مقام الرجلين في ذلك مطلقا، لا عند عدم وجود الشاهدين فق ط، بل مع وجودهما أيضا، فلا

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٠٠/١٦. الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ١٥١/٢. المغني، ابن قدامة، ٧/١٢، إعلام الموقعين، ابن القيم، ٧٧/١. المحلى، ابن حزم، ٣٩٦/٩. شرح التجريد في فقه الزيدية، الهاروني الحسني، ٢٣٤/٦، بحار الأنوار، المجلسي، ٣٢١/١٠١. وسائل الشيعة، العاملي، ٢٥٨/٩/١. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي، ص٣٣٢.
(٢) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.

يصح حمل النص على عدم وجود الرجلين لجواز شهادة المرأتين مع الرجل؛ لأن شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الشاهدين إجماعا، فتعين أن الله تعالى شرع شهادة الرجلين والمرأة بالتسمية، فيكونان مرادين بالنص؛ لذا تقبل شهادتهما في أحكام الأبدان(١).

الوجه الثاني: إن قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (٢).عام من وجه، أي في جميع المعاملات المالية، وخاص من وجه آخر، أي في نوع معين من الحقوق، وهي الحقوق المالية، وما خُصَّ مَوضعاً، فَيَعُمُّ، فاقتضى أن يكون للرجل والمرأتين شهادة في سائر الأحكام، إلا ما قُيد بدليل(٣)

ونوقش هذا: بأن عموم الكتاب مردود بما ورد في معناه، والآية خاصة بالأموال، ولا يصح استعمال العموم فيها، فآخر الآية مرتبط بأولها(٤).

٢ـ قول النبي ﷺ في المرأة: " أَلَيْسَ شَهَادَتُهَا بِنِصْفِ شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ"(٥)

(١) انظر: الفروق، القرافي، ٢٢٧/٤.
(٢) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٧٩/٦، القرافي، الفروق، ٢٢٦/٤.
(٤) انظر: الفروق، القرافي، ٢٢٧/٤. الحاوي الكبير، الماوردي، ٩/١٧.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: ٨٠.

وجه الاستدلال:

إن النبي ﷺ قد جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، وهذا دليل جواز شهادتها، خاصة وأن لفظ الشهادة ورد على الإطلاق، ولم يقيد بموضع معين، فتدخل فيه شـهادة المرأتين مع الرجل في أحكام الأبدان، ما لم يرد دليل يخصص ذلك(١).

٣ـ عن وائل بن حجر، قال" جاءَ رَجُلٌ مِن حَضرَمَوتَ ورَجُلٌ مِن كِندةَ إلى النَّبيِّ ﷺ ، فقال الحَضرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا قد غَلَبَني على أرضٍ لي كانَت لأبي، فقال الكِنديُّ: هي أرضي في يَدي أزرَعُها ليس له فيها حَقٌّ، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ للحَضرَميِّ: ألَك بَيِّنةٌ؟ قال: لا، قال: فلَك يَمينُه، قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الرَّجُلَ فاجِرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عليه، وليسَ يَتورَّعُ مِن شيءٍ، فقال: ليس لك منه إلَّا ذلك، فانطَلَقَ ليَحلِفَ، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أدبَرَ: أما لَئِن حَلَفَ على مالِه ليَأكُلَه ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعرِضٌ" (٢).

وجه الاستدلال:

إن لفظ "شاهداك" جاء مطلقا، ولو أحضر المدعي رجلاً وامرأتين حكم له، فِعُلِمَ أن هذا يقوم مقام الشاهدين(٣).

(١) انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، ٧٩/١.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: ١٣٩
(٣) انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، ١/ ٧٠.

٤ـ ما روي عن أم المؤمنين عائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيِّ ﷺ قال**" لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ، وشاهِدَي عَدلٍ "**(١)

وجه الاستدلال:

طلب النبي ﷺ في الحديث الإشهاد على عقد النكاح، والنكاح من أحكام الأبدان، وذِكْرُ لفظ الشاهد في الحديث جاء مطلقًا، فيشمل المذكر والمؤنث، فاقتضى الأمر قَبول شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح، ويقاس عليه باقي أحكام الأبدان.

ونُوقش هذا: بأن الأحاديث كلها لا تدل على أن لفظ "الشاهد" يشمل المذكر والمؤنث، بل يقتصر اللفظ على المذكر فقط؛ لأنه جاء بهذه الصيغة، فلا تقبل - بناءً على هذه الأدلة- شهادة المرأتين والرجل في أحكام الأبدان.

٥ـ كما استدلوا بآثار كثيرة وردت عن الصحابة والتابعين تدل على ذلك، منها:

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه" أجاز عمر شهادة النساء في الطلاق" (٢).

(١)أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ١٢٥/٧. قال المحقق: الحديث صحيح لشواهده.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، المصنف،٣٢٢/٥، . وممن استدل بهذا الأثر: ابن القيم، الطرق الحكمية، ص.١٣١ والأثر صحيح لوروده من رجال ثقات، منهم: الزبير بن الخريت، وجرير بن

وجه الاستدلال:

إنه إذا أجيزت شهادة النساء في الطلاق وحدهن، فمن باب أولى أن تقبل مع الرجال.

ونُوقش هذا: بأن الاثار الواردة في إجازة شهادة النساء مع الرجال، لا يصح الاستدلال بها، لأنها معارضة بآثار أخرى تدل على عدم قَبول شهادة النساء مع الرجال في الأبدان،

فقد ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ"(١).

٦ـ كما استدلوا بالإجماع فقالوا:

ـ ما ورد عن عمر رضي الله عنه، في" قبول شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح"(٢). ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة، فكان إجماعا منهم على الجواز(٣).

ونُوقش هذا: بأن الاستدلال بالإجماع، لا يصح، لأنه معارض بآثار أخرى تدل على عدم قَبول شهادة النساء مع الرجال في الأبدان، فقد ورد عن

حازم، قال عنه ابن حبان: "من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع والدين". مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الاقطار، ابن حبان،٢٥٠/١، انظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني،٢٧١/٣.
(١) انظر: الذخيرة، القرافي،٢٥٤/١٠، الفروق، القرافي،٢٠٩/٤، الأم، الإمام الشافعي،٨٤/٧.
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم، ٧٧/٤.، وأخرجه أخرجه البيهقي، السنن الكبرى،١٢٦/٧.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني،٢٨٠/٦.

عمر وعلي، رضي الله عنهما، أنهما قالا: "لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود"(١).

وعن الزهري أنه قال: "لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق"(٢).

وقد ورد عند البيهقي أن رواية عمر في إجازة شهادة المرأتين مع الرجل منقطعة(٣)، مما يرد دعوى الإجماع.

٧ـ كما استدلوا بالقياس:

فقاسوا أحكام الأبدان على الأموال، بجامع عدم سقوطها بالشبهات، فتقبل فيها النساء، كالأموال(٤).

ونُوقش هذا: بفساد دليل القياس، لأنه قياس مع الفارق، حيث إن أحكام الأبـدان

أعظم رتبة من الأموال؛ لأن الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات، فلا يقـبلن فيـه مطلقـا، كالقصاص؛ ولأننا وجدنا النكاح آكد من الأموال؛

(١) انظر: الذخيرة، القرافي، ٢٥٤/١٠، الفروق، القرافي، ٢٠٩/٤، الأم، الإمام الشافعي، ٨٤/٧.
(٢) أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ١٢٦/٧.
(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٤) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٠٠/١٦، الفروق، القرافي، ٢٢٧/٤، المغني، ابن قدامة، ٧/١٢.

لاشتراط الولاية فيه، ولم يدخله الأجل والخيار والهبة، كما أنه يصح الإبراء في الأموال، ولا يكون ذلك في النكاح(١).

٧ـ كما استدلوا بالمعقول، من وجوه عدة، فقالوا:

اـ إن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين؛ لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب.

ب ـ وإن الأصل في شهادة المرأة القَبول لوجود ما يبنى عليه أهلية الشهادة وهي الولاية.

ج ـ وتقبل شهادة المرأة في ذلك فهي من أهل الشهادة؛ لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل، لهذا قُبلت رواية النساء لأحاديث الأحكام المُلزِمة للأمة(٢).

ونوقش هذا:

بأن قياس الأبدان على الأموال لا يصح، فالأبدان أعلى من الأموال فلا يقبل فيها ما يقبل في الأموال، ونظيره أن الحدود أعلاها الزنا وأدناها السرقة، ولم يقبل في أحدهما ما يقبل في الآخر.

(١) انظر: الفروق، القرافي، ٢٢٧/٤، الحاوي الكبير، الماوردي، ٩/١٧.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٢٨٠/٦، تبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٠٩/٤، فتح القدير، ابن الهمام ،٣٩١/٧، الاختيار، ابن مودود الموصلي، ١٥١/٢.

ولأن النكاح آكد من الأموال؛ لاشتراط الولاية فيه، ولم يدخله الأجل والخيار والهبة، كما أنه يصح الإبراء في الأموال، ولا يكون ذلك في النكاح(١).

القول الثاني:

لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في أحكام الأبدان، ولا يثبت ذلك إلا بشهادة رجلين فقط، وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وهو قول الحنابلة وإليه ذهب الإمامية في أحد قوليهم وهو قول النخعي، والزهري، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وربيعة في الطلاق(٢).

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

١ـ قوله تعالى في الطلاق (واشهدوا ذوي عدل منكم) (٣)

وجه الاستدلال:

لقد أمر الله تعالى بإشهاد ذوي عدل في الطلاق أو الرجعة وهما من الأحكام البدنية، فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك، إلا موضع لا يطلع عليه الرجال، وجاء النص بصيغة المذكر، ولم يذكر فيه شهادة النساء، فهذا يدل

(١) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٠٠/١٦، الفروق، القرافي، ٢٢٧/٤، المغني، ٧/١٢.
(٢) انظر: القرافي، الفروق، ٢٢٧/٤، الكافي، ابن عبد البر، ٩٠٦/٢، الأم، الإمام الشافعي٨٥/٧، المغني، ابن قدامة٧/١٢، وسائل الشيعة، العاملي،٢٨٥/٩، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي ص.٣٣٢
(٣) من الآية:٢، من سورة الطلاق.

على اختصاص الرجال بذلك، فلو كانت شهادة النساء جائزة هنا لنص عليها كما نص عليها في الأموال(١).

٢ـ قوله تعالى(شَهَٰدَةُ بَينِكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلمَوتُ حِينَ ٱلوَصِيَّةِ ٱثنَانِ ذَوَا عَدل مِّنكُم أَو ءَاخَرَانِ مِن غَيرِكُم)(٢)

وجه الاستدلال:

إن االله سبحانه وتعالى، أمر بالإشهاد على الوصية اثنان ذوا عدل، وهذا اللفظ يختص بالرجال دون النساء، ولو أراد االله تعالى أن تقبل شهادة النساء في الوصية لقال: إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كما في الأموال(٣)

ونُوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول: القول بأن لفظ "شاهد" يقتصر على المذكر فقط لا يسلَّم به؛ لأن في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، كقوله تعالى(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

(١) انظر: القرافي، الفروق، ٢٠٩/٤، الذخيرة، القرافي، ٨٤/١٠، الكافي، ابن عبد البر ٩٠٦/٢، الأم، الإمام الشافعي،٨٤/٧.
(٢) من الآية: ١٠٦، من سورة المائدة.
(٣) انظر: الأم، الإمام الشافعي،٨٤/٧، الحاوي الكبير،، الماوردي،١٧/٩، . إعلام الموقعين، ابن القيم، ٧٧/١.

مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (١).

وعلى هذا:

فآيات الطلاق والوصية التي استدللتم بها، تتناول الصنفين معاً(٢).

الوجه الثاني: إن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالـديون، وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت، فإذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها تُكْتَبُ غالبا في مجامع الرجال، فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة والنكاح أولى، يوضحه أنه قد شرع في الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند الحاجة، فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين، بطريق الأولى والأحرى(٣).

٣ـ كما استدلوا بقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٤)

(١) من الآية: ٢٨٢، من سورة البقرة.
(٢) انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، ٧٨/١.
(٣) انظر: المرجع والمكان السابقين.
(٤) رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، وأعلَّه بالإرسال. انظر: سنن البيهقي، حديث رقم:١٣٨٤٣.

وجه الاستدلال:

إن النكاح حكم بدني، واشتُرط للإشهاد عليه شاهدي عدل من الذكور، ولم تُذكر فيه النساء، فتُقاس عليه باقي الأحكام البدنية(١).

ونُوقش هذا: بأن الحديث المذكور مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ(٢)، ومعنى هذا: إنه يُحتمل أن يكون حديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" من كلام ابن عباس، لا من كلام النبي ﷺ ، والأصل عند الفقهاء إن الحجة فيما يقوله النبي ﷺ ، لا في كلام غيره من الصحابة.

٣ـ واستدلوا من الآثار:

بما رواه ابن أبي شيبة عن حفص، عن حجاج، عن الزهري، قال: مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود(٣).

وبما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن ابي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء(٤).

(١) انظر: الفروق، القرافي،٢١٠/٤، مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٤٤٢/٤.
(٢) انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، ٣٩/٣.
(٣) انظر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، حديث رقم: ٢٩٣٠٧، قال المحقق: مرسل لا تقوم بمثله الحجة.
(٤) انظر: نصب الراية، في تخريج أحاديث الهداية، الزيلعي، ٧٧/٥، قال المحقق: له شواهد.

وجه الاستدلال:

إن هذين الأثرين: يدلان بمنطوقهما على عدم جواز شهادة النساء في الحدود والدماء، ويقاس على ما ورد في الآية والحديث والأثر بقية ما يطلع عليه الرجال غالبًا، بجامع أنها ليست بمال، ولا يقصد منها المال، والقصد من الوكالة والوصية اللتين لم يقصد منهما المال: الولاية والخلافة(١).

ونُوقش هذا:

أ ـ بأن هذا الاستدلال لا نُسلم به؛ لأن شهادة المرأتين مع الرجل في باب الأموال تكون مع القدرة على شهادة الرجال، فدلَّ أنها مطلقة لا ضرورة، ولهذا تقبل روايتها في الإخبار، وكان ينبغي أن تقبل شهادتهن مطلقًا كالرجال، ولكن جاء النص بخلافه؛ كي لا يكثر خروجهن(٢).

ب ـ إن نقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم أخرى إليها، فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهة كالمال، مما يقوي أنها حجة أصلية لا ضرورية(٣).

ج ـ إنَّ جعل الشارع المرأتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك، بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غير، ونرى كثيرا من النساء

(١) انظر: الفروق، القرافي،٢١٠/٤، . مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٤٤٢/٤.
(٢) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني،٢٨٠/٦، تبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٠٩/٤
(٣) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٠٩/٤.

يـضبطن أكثر من ضبط الرجال؛ لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال؛ لكثرة الواردات علـى خـاطر الرجال(١).

٤ـ واستدلوا أيضًا **بالقياس** من وجهين:

الوجه الأول:

قاس الجمهور أحكام الأبدان على القصاص، بجامع عدم قَبول شهادة النساء فيهما على الانفراد، فكل ما لا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لم يقبلن فيه مع الرجال(٢).

ونُوقش هذا:

بأن الاستدلال بقياس أحكام الأبدان على القصاص: فإنه قياس مع الفارق؛ لأن النكـاح والطلاق والوصية تثبت مع الشبهة، بخلاف القصاص فإنه يسقط بالشبهة اتفاقا(٣).

الوجه الثاني:

قياس حقوق الآدميين في غير الأموال على حقوق الله تعالى، بجامع التفاوت في الدرجة الذي يستلزم التفاوت في الإثبات، فكما أن حقوق الله تعالى أعلاها حد الزنا، فلا يثبت إلا بأربعة رجال، وأدناها الخمر، فيثبت

(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٣٧١/٧.
(٢) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي،٩/١٧.
(٣) انظر: : وسائل الإثبات، الزحيلي، ١٧٣/١.

باثنين، وجب أن يقع الفرق في حقوق الآدميين بين أعلاها وأدناها، فأعلاها حقوق الأبدان، وأدناها حقوق الأموال(١).

ونُوقش هذا:

بأن قياس حقوق الآدميين على حقوق االله تعالى: فالعلة فيه لا تصلُح للقياس، وإلا وجب علينا أن نضع سلما تصاعديا أو تنازليا في الإثبات حسب الدرجات، وأن سبب التشدد في إثبات الزنا بأربعة شهود، أنه يجري من اثنين، فكانت الشهادة مقسمة عليهما، ولأن الزنا يجري فيـه الستر فاحتاط به الشارع خلافا لبقية الحدود، فظهر الفرق بين حدود االله تعالى، ولا موجـب للتفريق بين حقوق الآدميين(٢).

كما **استدلوا بالمعقول**، من وجهين:

الوجه الأول:

إن أحكام الأبدان ليست بمال ولا المقصود منها المال حتى تقبل فيها شهادة النساء (٣).

(١) انظر: الفروق، القرافي،٤/٢١٠، . مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ٤/٤٤٢.
(٢) انظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ١/١٧٣.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٢/٧.

ونُوقش هذا:

بأن شهادة المرأتين مع الرجل في بـاب الأمـوال تكون مع القدرة على شهادة الرجال، فدلَّ أنها مطلقة لا ضرورة، ولهذا تقبل روايتها في الإخبار، وكان ينبغي أن تقبل شهادتهن مطلقًا كالرجال، ولكن جاء الـنص بخلافـه؛ كـي لا يكثـر خروجهن(١).

الوجه الثاني:

إن أحكام الأبدان مما يطلع عليها الرجال، فلم يكن للنساء فيها مدخل كالحـدود والقصاص، وإنما قُبِلت شهادة النساء حيث قُبِلت؛ للضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ ولعموم البلوى في الأموال، وفي غير هذه المواضع تبقى الشهادة فيها للرجال دون النساء؛ لاختصاصهن بنقصان العقل، وقصور الولاية، واختلال الضبط(٢).

ونُوقش هذا:

بأن نقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم أخرى إليها، فلم يبق بعد ذلك إلا الـشبهة، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهة كالمال، مما يقوي أنها حجة أصلية لا ضرورية(٣).

(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني،٢٨٠/٦، تبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٠٩/٤
(٢) انظر: تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، ص:٢٦٦ المغني، ابن قدامة، ٧/١٢.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٢٠٩/٤.

سبب الخلاف:

ويرجع سبب الخلاف بين الفقهاء إلى **السببين الآتيين:**

١ـ اختلافهم في دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الوارد فيها لفظ الشاهد والشهادة، فهل لفظ الشاهد يشمل المذكر والمؤنث؟ أم يقتصر على المذكر فقط؟ فالحنفية ومن وافقهم قالوا إن لفظ الشاهد مطلق عن التقييد لجنس معين، فيشمل المذكر والمؤنث. ولذا، تجوز شهادة النساء مع الرجال. والجمهور قالوا: إن لفظ الشاهد مقيد، فلا يشمل إلا الرجال.

٢ـ كما يرجع سبب الخلاف إلى هذا السؤال: هل لفظ الشهادة مُطْلَقٌ؛ فيشمل جميع المواضع، أم مقيد في موضع معين كما يقتضيه سياق النص؟ فالحنفية ومن وافقهم قالوا: إن اللفظ عام، فيشمل شهادة النساء مع الرجال، والجمهور قالوا: إن لفظ الشهادة مقيدٌ بالرجال فقط، ولذا لا تجوز معهم شهادة النساء(١)

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١٩٨.

الترجيح:

وبعد عرض الأقوال الفقهية وأدلتها ومناقشاتها، يترجح عندي ـ والله أعلم ـ **رأي جمهور الفقهاء** القائل بعدم جواز شهادة المرأة في حقوق الأبدان، وذلك لقوة أدلتهم، ولأنه لا ضرورة لشهادتها في حقوق الأبدان، لوجود الرجال، ولأن النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة لم تنص على جواز شهادتها، ولما في طبعها من العاطفة الداعية إلى إمكان عدم الضبط، في شهادتها، خاصة وأن النصوص الشرعية ، قد نسبتْ احتمال نسيانها، بسبب ما يعتريها من أحوال جبلية، يتغير فيها مزاجها الجِبِلِّي، ولأن من حياء المرأة استتارها، وعدم بروزها للرجال(١)، ولأن الشهادة متى أمكن تحقيق نصابها من الرجال، فلا حاجة إلى تكليف المرأة عنتاً ومشقة، بإحضارها إلى مجالس القضاء، والاختلاط بمن لا تعرفهم، ومعلوم أن الإسلام كرم المرأة، وأحاطها بسياج من العفة، وفي حضورها مجالس القضاء، مظنة النظر إليها، ولأن المرأة قد تتعرض للحرج، في شهودها مجالس الرجال، وأخيراً نسوق حديث عمرو بن العاص، رضي الله عنه قال" نهى أنْ تُكَلَّمَ النساءُ إلا بإذنِ أزواجِهنَّ"(٢).

(١) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام، الزحيلي، ص: ٢١٦، وما بعدها، المرأة في الإسلام، صبحي الصالح، ص:٥٠.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم: ٢٧٧٩، ، وأحمد في مسنده برقم: ١٧٧٦١، قال المحقق: حديث صحيح.

فإذا كان نبي الإسلام ﷺ ، قد نهى أن يتحدث أحد مع المرأة إلا بإذن زوجها، فكيف بمن تخرج إلى مجلس القضاء، وتُخاطب الرجال؟

ونحن لا نقول هنا هذا القول بدافع التمييز بين الرجل وبين المرأة لهوى شخصي، بل لأن حقيقة التمييز في الشرع المطهر، قد اقتضته الفوارق الطبيعية التي لا مناص منها بين الرجل والمرأة، والوظيفة التي خصصتها الفطرة السليمة لكل منهما، ومدى استعداد كل منهما لتحمل تبعات معينـة، ومدى دربته في بعض الميادين، ومدى قدرته على إعطاء أفضل النتائج في بعض الشؤون، من غير أن يؤثر شيء من هذا على الأهلية الكاملة، والشخصية المستقلة لكل منهما.

والله أعلم.

المطلب الرابع

نصاب الشهادة في الأموال وما يؤول إلى الأموال.

يُقصد بـ نصاب الشهادة في الأموال وما يؤول إلى الأموال: مثل البيع، الإجارة، القروض، والرهن، هو عدد الشهود وصفاتهم التي يشترطها الفقه الإسلامي لإثبات الحقوق المالية.

اتفق الفقهاء على أنه يُقبَلُ في الأموالِ أو ما يُقصَدُ به المالُ شَهادةُ رَجُلَينِ أو رَجُلٍ وامرَأَتَينِ، (١) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.(٢)

---

(١) انظر: المبسوط للسرخسي١٦/ ١١٤، تبيين الحقائق للزيلعي،٤/ ٢٠٩. التاج والإكليل للمواق،٨/ ٢٠٩، الشرح الكبير للدردير،٤/ ١٨٧. تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مع حاشية الشرواني، ١٠/ ٢٤٧، نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي، ٣١١/٨. كشاف القناع للبهوتي،٦/ ٤٣٤ المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح ،٨/ ٣٣٣.

(٢) في دليل الإجماع: قال ابنُ حَزمٍ: "اتَّفَقوا على قَولِ رَجُلٍ وامرَأَتَينِ كما ذَكَرنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ إن لَم يوجَدْ رَجُلانِ، في الدُّيونِ مِنَ الأموالِ خاصَّةً". مراتب الإجماع، ص: ٥٣. وقال القاضي عَبدُ الوهَّابِ: "وإنَّما قُلْنا: إنَّ الشَّاهِدَينِ والشَّاهِدَ والمَرأَتَينِ يُقبَلانِ في المالِ أو ما يَكونُ المَقصودُ مِنه المالَ؛ لقَولِه عَزَّ وجَلَّ: واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البَقَرة: ٢٨٢] ولا خِلافَ في ذلك". المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ص: ١٥٤٦. وقال ابنُ رُشدٍ: "اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عَدلٍ ذَكَرٍ وامرَأتَينِ؛ لقَولِه تعالى: فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: ٢٨٢] ". بداية المجتهد، ٢٤٨/٤. وقال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ، وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كِتابِه، بقَولِه سُبحانَه: يا أيُّها الذينَ آمَنوا إذا تَدايَنتُم بدَينٍ [البقرة: ٢٨٢] إلى قَولِه: واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: ٢٨٢] ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ به). المغني، ١٣٣/١٠. وقال ابنُ القَيِّمِ: اتَّفَقَ المُسلِمونَ على أنَّه يُقبَلُ في الأموالِ رَجُلٌ وامرَأتانِ، وكَذلك تَوابِعُها مِنَ البَيعِ، والأجَلِ، والخيارِ مِنَ البَيعِ، والأجَلِ فيه، والخيارِ فيه، والرَّهنِ، والوصيَّةِ للمُعَيَّنِ، وهِبَتِه، والوقفِ عليه.... إعلام الموقعين، ٧٢/١. وقال البُهوتيُّ: "يُقبَلُ في المالِ وما يُقصَدُ به المالُ -=كالبَيعِ وأجَلِه وخيارِه- رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامرَأتانِ... لقَولِه تعالى: فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ [البقرة: ٢٨٢] ، وسياقُ الآيةِ يَدُلُّ على الاختِصاصِ بالأموالِ، والإجماعُ مُنعَقِدٌ على ذلك". كشاف القناع، البهوتي، ٦/ ٤٣٤.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ـ قَولُه تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (١).

وَجهُ الاستدلال:

إنَّ سياقَ الآيةِ يَدُلُّ على الاختِصاصِ بالأموالِ(٢).

٢ـ واستدلوا من المعقول فقالوا:

إنما قُبِلَت شَهادةُ النِّساءِ؛ لأنَّهنَّ مِن أهلِ الشَّهادةِ بالآيةِ، فتُقبَلُ شَهادَتُهنَّ لوُجودِ المُشاهَدةِ والحِفظِ والأداءِ، كالرَّجُلِ، وزيادةُ النِّسيانِ تُجبَرُ بزيادةِ العَدَدِ(٣)

(١) انظر: من الآية:٢٨٢، من سورة البقرة.
(٢) انظر: كشاف القناع للبهوتي ، ٦/ ٤٣٤.
(٣) انظر: الاختيار لابن مودود، ٢/١٤٠.

المطلب الخامس

نصاب الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال.

المقصود عند الفقهاء بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، هو: شهادة النساء منفردات فيما لايطلع عليه الرجال،كالولادة، والحيض، والعدة، والحمل، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على عدم جواز شهادة النساء منفردات في الحقوق المتعلقة بالأبدان(٢).

واختلفوا في شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال على **ثلاثة أقوال:**

القول الأول:

تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال، كالحيض والولادة والعدة والحمل، والبكارة، والثويبة، وسائر عيوب النساء.

(١) انظر: السامي في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د. مراد محمود حيدر، ص:١٩٩.
(٢) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٠٠/١٦. الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ١٥١/٢. المغني، ابن قدامة، ٧/١٢، إعلام الموقعين، ابن القيم، ٧٧/١. المحلى، ابن حزم، ٣٩٦/٩. شرح التجريد في فقه الزيدية، الهاروني الحسني، ٢٣٤/٦. ، بحار الأنوار، المجلسي، ٣٢١/١٠١. وسائل الشيعة، العاملي، ٢٥٨/٩/١. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي، ص٣٣٢.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(١)، وقد حكي الإجماع على ذلك(٢).

وقد استدلوا لذلك بما يلي:

١ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا»، فَنَهَاهُ عَنْهَا." (٣) .

وفي لفظ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ» (٤).

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار، الموصلي،٢/ ١٤٠. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٤/ ١٤، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد بداية ٣٨١/٢، تبصرة الحكام، ابن فرحون ،٢٥٠/١. إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، البغدادي، ص٢٠٣، التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، ١٨٢/٦، الأم، الإمام الشافعي، ٤٨/٧.

(٢) انظر: في حكاية الإجماع: الأم ، الإمام الشافعي،١٩٧/٨، حيث قال" الولادة، وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته من أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن" وانظر: أدب القاضي، ابن القاص، ١/ ٢٨٩ حيث قال" «اتفق الجميع على جواز شهادة النساء منفردات لا رجال معهن في الولادة» وانظر في حكاية الإجماع أيضا: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، القاضي عبد الوهاب، ٣/ ١٥٥٢، بداية المجتهد، ابن رشد،٦٣٨/٢ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي،١٣/ ٢٢٦.

(٣) انظر: أَخْرَجَهُ البخاري في صحيحه ، باب شهادة الإماء والعبيد. برقم: ٢٦٥٩

(٤) انظر: أَخْرَجَهُ البخاري في صحيحه ، باب شهادة الإماء والعبيد. برقم: ٢٦٦٠

وجه الاستدلال:

لَمَّا فرق النبي ﷺ بينهما دل على قبول شهادة المرضعة في الرضاع (١).

ونوقش هذا:

بأنه كان للتورع، والاحتياط؛ لأنه أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثانية أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمر؛ إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على المحرَّم(٢) .

وأجيب عنه:

بأنه خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي ﷺ أربع مرات، وأجابه بقوله: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» وفي بعض ألفاظه «دَعْهَا»، وفي رواية الدارقطني: «دَعْهَا عَنْكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا»(٣)، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد(٤).

(١) انظر: شرح السنة، البغوي، ٩/ ٨٧، المغني، ابن قدامة، ١٤/ ١٣٥، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، الشوكاني، ١٢/ ٦٤٠.
(٢) انظر: فتح القدير شرح الهداية، ابن الهمام، ٣/ ٤٦٢.
(٣) انظر: أَخْرَجَهُ الدارقطني في السنن ، برقم:٤٣٧٣، من حديث عقبةَ بن الحارثِ رضي الله عنه. قال المحدث: صحيح:
(٤) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، ١٠/ ١٠.

٢ـ واستدلوا من الآثار:

أ- فعَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَتَجُوزَ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» (١).

وفي لفظٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهُ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ»(٢) .

ب - عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاسْتِهْلَالِ»(٣) .

ج- عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله، أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه، «فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»(٤)

(١) انظر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ٢٠٧٠٨.
(٢) انظر: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، برقم: ١٥٤٢٧.
(٣) انظر: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، برقم:١٥٤٢٩.
(٤) انظر: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، برقم: ١٣٩٦٩.

د- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ، وَحَيْضِهِنَّ»(١) .

٣ـ واستدلوا من المعقول، من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لأنها شهادة على عورةٍ للنساءِ فيها مدخل فقُبل فيها شهادة النساء(٢) .

الوجه الثاني:لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد؛ تحصيلا للمصلحة(٣).

الوجه الثالث: لأن الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنه لا تحضر المرأة غيرها، فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة، ولبطل ما يتركب عليها من نسب، وحرمة، وميراث، وسائر الحقوق(٤) .

(١) انظر: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، المصنف برقم: ١٥٤٢٥.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة،١٤/ ١٣٥.
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ٢/ ١٤٠.
(٤) انظر: المسالِك في شرح موطأ مالك، ابن العربي، ٦/ ٢٦٠.

القول الثاني:

تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال، إلا في مسألتين، هما الرضاع والاستهلال(١) (٢).

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ عَلَى الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ»، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر النكير من أحد؛ فيكون إجماعا(٣) .

أجيب عنه من **وجهين**:

أحدهما: أنه يعارض حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ المتقدم.

الآخر: أنه لا يصلح للاحتجاج على عدم قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، إنما يستدل به على عدد النساء الواجب توفره في شهادة النساء منفردات في الرضاع، ومما يدل على هذا القول أنه رُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثَيْنِ مُرْسَلَيْنِ عَنْهُ «أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ»(٤) ، مما

(١) الاستهلال: لغةً رفع الصوت أو الظهور، واصطلاحاً : هو ما يصدر عن المولود عند ولادته ممّا يدلّ على حياته، انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ١٧٢/٨.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، ٣/ ٣٤٨، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٤/ ١٤، ، فتح القدير شرح الهداية، ابن الهمام ،٣/ ٤٦١.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٤/ ١٤.
(٤) انظر: معرفة السنن والآثار، البيهقي، ١١/ ٢٧٠.

يدل على أنه يقبل شاهدين، والشاهد يطلق في اللغة ويراد به الرجل، والمرأة(١).

٢- رُوي عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع(٢) .

أجيب بما أجيب به الأثر السابق.

أما المعقول:

١- فلأن هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالمال، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال، أما ثدي الأمة فلأنه يجوز للأجانب النظر إليه، وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد(٣) .

٢- لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة، وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال على المشهود به فإذا جاز الاطلاع عليه في الجملة؛

(١) انظر: شهادة النساء، أحلام محمد إغبارية، صـ ١١٠.
(٢) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ٤٨٣.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٤/ ١٤.

لم تتحقق الضرورة بخلاف الولادة فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول(١).

أجيب عن هذين التعليلين بأنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، والضرورة داعية إلى اعتباره(٢) .

القول الثالث: لا يجوز قبول النساء منفردات دون رجل في شيء أصلا، لا في ولادة ولا في رضاع ولا في عيوب النساء ولا في غير ذلك.

وإلى هذا القول ذهب زفر بن الهذيل من الحنفية (٣).

ويمكن الاستدلال لذلك بما يلي:

١ـ عموم النصوص في الشهادة، حيث أوجبت انضمام الرجال إلى النساء، فتبقى على أصلها.

٢ـ ولأن الضرورة التي تستوجب اطلاع النساء على ما لا يطلع عليه الرجال يمكن دفعها بانضمام الرجال إلى النساء، خاصة وأن الرجال يجوز لهم الطلاع على عورات النساء للضرورة، كالطبيب في حالات الكشف والولادة، ونحو هذا.

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٤/ ١٤.
(٢) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي، ١٠/ ١٠.
(٣) ذكر ابن حزم رأي زفر في المحلى، ٣٩٦/٩. وقد اجتهدت في البحث عن رأي زفر في كتب الحنفية ولم أعثر عليه.

الترجيح:

ونحن نميل إلى القول بضرورة انضمام الرجال إلى النساء في الشهادة، وهو ما يراه بعض المالكية والشافعية، لأن هذه الأعمال مما يمكن أن يقوم بها الرجال في الغالب، كحالات التوليد، والنظر إلى عورات النساء مما أباحه الشارع للطبيب للضرورة، فتبقى العلة عدم حضور الرجال لمثل هذه الأمور. والله أعلم.

المبحث الثاني
حكم أخذ الأجر على الشهادة

تمهيد:

من المتفق عليه عن الفقهاء إن تحمل الشهادة، وآدائها، من فروض الكفايات، بحيثُ إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين؛ لأن المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم، وإن امتنع الكل أثموا جميعا؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (١)، ولأن الشهادة أمانة، فلزم الأداء عند الطلب.

وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية، وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به(٢).

غير أن الواقع الآن يتطلبُ مِنَّا النظر إلى ما يتكلفه الشاهد من مشقة السفر، وأجرة المواصلات، فهل يحق أخذ الشاهد أجراً على ما دفعه في المواصلات، والركوب إلى مجلس القضاء؟ وهل إذا استحق أجراً، وهو ما

(١) سورة البقرة، من الآية(٢٨٣).
(٢) انظر: الدر المختار، الحصكفي٤ / ٣٧٠، حاشية الدسوقي، ابن عرفة ٤ / ١٩٩، والشرح الصغير، الدردير، ٤ / ٢٨٥، المهذب، الشيرازي ٣٥/٢، المغني ابن قدامة، ١٦٢/١٠.

يُتعارف عليه الأن باسم " بدل الانتقال"، فهل يكون هذا الأجر من الخصوم أم من المحكمة؟، وهو ما يُمكنُ إدراجه تحت مُسمى " خزانة الدولة"؟

هذا ما سوف نناقشه من خلال عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، فنقول ـ وبالله التوفيق:

المقصود بتَعَيُّنِ الشهادة عند الفقهاء: أن يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية، وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الشاهد، متى تَعَينتْ عليه الشهادة، أي أصبحتْ فرض عين عليه، لعدم وجود من يؤديها غيره، أو توقف إحقاق الحق ومعرفة الحقيقة على شهادته وحدها، ودُعي إليها وقدر بلا ضرر معتبر.

واختلفوا في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.

وإليه ذهب: الحنفية ، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح(١).

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ بقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٢)

وجه الاستدلال:

إن الله تعالى، نهى عن كتمان الشّهادة، ورتب عليه الإثم العظيم، ومن امتنع من أداء الشّهادة إِلَّا بأجرة، فإنّه يعد كاتمًا لها، فيدخل تحت الوعيد في هذه الآية(٣)

٢ـ قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله) (٤).

(١) انظر: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار "تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة" ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ٢٠٧. الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ ـ ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.

(٢) انظر: من الآية:٢٨٣، من سورة البقرة.

(٣) انظر: الشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٨٦.

(٤) انظر: الآية: ٢، من سورة الطلاق.

وجه الاستدلال:

إن هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به، تقربًا إلى الله تعالى، فإذا كان الشهود مأمورين بأداء الشّهادة، كانت الشّهادة حينئذ فرض عين عليهم، فلا يجوز أخذ العوض عليها (١)

٣ـ كما استدلوا من المعقول **بثلاثة أوجه:**

الوجه الأوّل:

إنَّ الشّهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقًا سواءً أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أمّا إذا كانت فرض كفاية فلأنّه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك(٢)، ثمّ إنَّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة(٣)

وأمّا إذا كانت الشّهادة فرض عين عليه، فلا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليها، كسائر فروض الأعيان(٤)

(١) انظر: فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٢) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.
(٣) انظر: كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٤.
(٤) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.

الوجه الثّاني:

قالوا: إنَّ الشّهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها(١).

الوجه الثّالث:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا امتنع من الشّهادة إِلَّا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته. لأنّه معصية؛ لأنّه رشوة أخذها في نظير ما وجب عليه(٢)

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وإليه ذهب: المالكية، وهو الأصح عند الشّافعيّة(٣).

واستدلوا بما يلي:

١ـ أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة:

قالوا: إنَّ تحمل الشّهادة فرض كفاية، لا يلزمه، فجاز أخذ الأجرة عليه(٤).

(١) انظر: روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥.
(٢) انظر: الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩.
(٣) انظر: الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ ـ ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩. المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦
(٤) انظر: الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

٢ – أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة:

أدلة هذا القول على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة هي نفسها أدلة القول الأوّل، فلا داعي لتكرارها.

القول الثالث:

لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه.

وإليه ذهب الحنابلة في قول، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(١).

واستدلوا لذلك بما يلي:

١ـ الشّهادة إمّا أن تكون غير متعينة عليه، وإما أن تكون متعينة.

أ – إذا كانت غير متعينة:

قالوا: يجوز له في هذه الحالة أخذ الأجرة على شهادته؛ لأنَّ النفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين: النفقة على العيال وأداء الشّهادة(٢).

ب – إذا كانت متعينة:

(١) انظر: الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦. الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص: ٣٥٤. وانظر: الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.

(٢) انظر: الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.

قالوا: إنَّ أخذ الأجرة في هذه الحالة جائز كذلك؛ لأنَّ النفقة على العيال فرض عين وأداء الشّهادة فرض عين، ولا يمكن تأدية هذه الفروض إِلَّا بالأجرة، وينوي المحتاج عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على تأدية هذه الفروض، بخلاف الغني فليس هناك حاجة تدعوه إلى الكسب وأخذ الأجرة على شهادته، فلا حاجة تدعوه أن يؤدِّي شهادته لغير وجه الله تعالى(١).

ونوقش هذا:

إننا لا نسلم لكم أن الشّاهد يجوز له أخذ الأجرة على الشّهادة، ولو كان ذلك للحاجة؛ لأنَّ الحاجة يمكن دفعها بغير الأجرة، وهي النفقة فقد تقدّم نقل اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز النفقة على الشّهادة حتّى لو كان يكسب قوت يومه يومًا بيوم فإنّه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ نفقة نفسه وعياله في ذلك اليوم، وعليه فلا حاجة للقول بجواز الأجرة للحاجة لانتفاء الحاجة بالنفقة. والله أعلم.

(١) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

القول الرّابع:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وإليه قول عند الشّافعيّة، ووجه عند الحنابلة (١)

واستدلوا لذلك بما يلي:

أ – دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض(٢)

ب – دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:

١ـ استدلوا بالقياس، فقالوا:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٣)

ونوقش هذا:

لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين فلا خلاف، أمّا

(١) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧.
(٢) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٣) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.

إذا كانت فرض كفاية، فإن الشّاهد إذا قام بها كانت فرض عين في حقه يسقط به فرض الكفاية عن الأُمَّة، كصلاة الجنازة(١)

ثمّ إنَّ الشّهادة ممّا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة بخلاف الكتابة فإنها عمل مباح في أصله لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

ثمّ إنَّ الشّهادة هو مأمور بأدائها احتسابًا لوجه الله تعالى، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله)(٢)

وقال تعالى: (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٣).

وعليه فقد فارقت الشّهادة الكتابة فلا يصح القياس، والله تعالى أعلم.

٢ـ كما استدلوا من المعقول، فقالوا:

إنَّ النفقة على عياله فرض عين، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن اشتغل بالشهادة جاز له حينئذ أخذ الأجرة عليها (٤).

(١) انظر: المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦
(٢) سورة الطلاق، من الآية(٢) .
(٣) من الآية: ٢٨٣ من سورة البقرة.
(٤) انظر: الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.

ونوقش هذا:

أَوَّلًا: أن الشّهادة وإن كانت فرض كفاية في الأصل، إِلَّا أنّه إذا اشتغل بها تعينت في حقه كصلاة الجنازة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها(١).

ثانيًا: أن أخذ الأجرة على الشّهادة يورث تهمة في حق الشّاهد؛ لأنَّ الأجرة على أداء الشّهادة كالرشوة وهذا يقدح في عدالة الشّاهد(٢).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في اعتبارها واجبًا عينيًّا أو كفائيًّا لله تعالى، فمن قال بأنه فرض كفائي قال بجواز أخذ الأجرة عليها، لإمكان أن يقوم بها غيره، ومن قال بعدم جواز أخذ الأجرة عليها، اعتبر كونها من الفروض العينية التي لا يثبت الحق إلا بها، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فصل قال مرة باعتبارها واجباً عينياً، ومرة باعتبارها واجباً كفائياً، أو التفرغ لها، كما يرجع اختلافهم إلى معارضة أخذ الأجرة للمحاذير الشرعية، كالرشوة.

(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشّهادة مطلقًا **وذلك لما يأتي:**

أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وبخاصة الأدلة من القرآن الكريم، فهي تدل على وجوب أداء الشّهادة، وأن يكون ذلك قربة إلى الله تعالى، قال الإمام الشوكاني: "هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربًا إلى الله"(١).

إذن فالشهادة واجبة إمّا على الكفاية فإذا أتى بها الشّاهد تغنيت عليه، أو تكون واجبة على الأعيان من الأصل، وفي كلّ من الحالين فهي من القرب إلى الله تعالى، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.

ثانيًا: أن ما ذكره أصحاب الأقوال الأخرى من الأدلة أمكن مناقشتها وإخراجها عن دلالتها.

(١) انظر: فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢٤١.

ثالثًا: أن هذا القول لا يردّ عليه اعتراضات كما ورد على الأقوال الأخرى، فإن قول من قال بالجواز للحاجة، يمكن دفعه، بما حصل الاتفاق عليه من جواز النفقة للشاهد، فإن بها تندفع الحاجة.

وأمّا بقية الأقوال الأخرى فمدارها على الجواز إذا كانت الشّهادة فرض كفاية، وهذا يندفع بما إذا قام بها الشّاهد، فإنها تصبح حينئذ فرض عين، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذه أجرة عليها بالاتفاق. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث

الرجوع عن الشهادة.

الرجوع عن الشهادة:

هو أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به، ونحوه، فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا يكون رجوعاً، ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فسخ للشهادة، فيكون في المكان الذي تعتبر فيه الشهادة، وهو المحكمة، ولأن الرجوع توبة، والتوبة تكون بحسب الجناية: السر بالسر، والعلانية بالعلانية(١) أي إذا كان الذنب سرًا فالتوبة سرية، وإن كان علانية فالتوبة علانية.

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الشاهدين إن رجعا عن شهادتهما، فلا يخلو رجوعهما أن يكون قبل قضاء القاضي أو بعده، فإن رجعا عن شهادتهما قبل الحكم سقطت شهادتهما، لأن الحق إنما يثبت بالقضاء، والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يتلفا شيئا على المدعي، ولا على المدعى عليه. (٢)

(١)هذا بعض حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلّى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فقال: أوصني، فقال: عليك بتقوى الله تعالى ما استطعت. إلى أن قال: «وإذا عملت شراً، فأحدث توبة: السر بالسر، والعلانية بالعلانية» فتح القدير: ٨٧/ ٦.

(٢) جاء في منهاج الصالحين " مسألة ١٢٠ إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فان كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال، والاقرب نفوذ الحكم ."

وإن رجعا بعد الحكم وقبل التنفيذ: فإن كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء والتنفيذ؛ لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة ظاهرة، فلم يجز الاستيفاء لقيام الشبهة.(١) وإن كان مالًا أو عقدا استوفى المال لأن القضاء قد تم، وليس هذا مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع؛ فلا ينتقض الحكم. وعلى الشهود ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان، ولا يرجعون على المحكوم له. (٢)

أما إن رجع الشهود بعد تنفيذ الحكم: فإنه لا ينقض الحكم، ولا يجب على المشهود له رد ما أخذه، لأنه يحتمل أن يكونا صادقين، ويحتمل أن يكونا كاذبين، وقد اقترن الحكم والاستيفاء بأحد الاحتمالين؛ فلا ينقض برجوع محتمل،(٣) وعلى الشاهدين أن يضمنا ما أتلفاه بشهادتهما(٤).

فإن كان ما شهدا به يوجب القتل، أو الحد، أو القصاص: نظر، فإن قالا تعمدنا ليقتل بشهادتنا: فقد اختلف الفقهاء في ذلك على **قولين**:

(١) انظر: الدر المختار ٤ /٣٩٦، ومنح الجليل٤ / ٢٨٨، والمغني ١٣٧/١٢، والمهذب ٢ /٣٤١
(٢) انظر: المهذب ٢ /٣٤١، ومغني المحتاج ٤ /٤٥٦، الهداية ٣ /١٣٢، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٣٥، الشرح الكبير١١٣/١٢، الخرشي ٢٢٠/٤، شرح منح الجليل ٤ /٢٨٤، ٢٨٩ ـ ٢٩٠
(٣) انظر: المهذب ٢ /٣٤١، المغني ١٣٨/١٢ .
(٤) انظر: الهداية ٣ /١٣٢، وجاء في وسائل الشيعة " باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائمًا بعينه فيرد على صاحبه" انظر الحر العاملي وسائل الشيعة ، ٣٢٧/٢٧.

القول الأول:

يجب عليهما القود عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد وابن شبرمة(١)

واستدلوا لذلك:

بما روى الشعبي أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه برجل آخر فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وهذا السارق، فأبطل شهادتهما على الآخر، وضمنهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما(٢)

ولأنهما ألجآه إلى قتله بغير حق، فلزمهما القود كما لو أكرهاه على قتله(٣)

القول الثاني:

إنه لا قود عليهما، وإليه ذهب الحنفية، وجمهور المالكية والشيعة الإمامية.

واستدلوا لذلك:

بأنهما لم يباشرا الإتلاف، فأشبها حافر البئر، وناصب السكين، إذا تلف بهما شيء، وعليهما الدية(١)

(١) انظر: حاشية الدسوقي ٤ /٢٠٧، المهذب ٢ /٣٤١، المغني ١٣٦/١٢، ١٣٨، الشرح الكبير ١١٧/١٢.

(٢) رواه الإمام الشافعي (الأم: ٧ / ٤٩) والطحاوي (اختلاف الفقهاء: ٢١٦) ومحمد بن الحسن في كتاب الرجوع عن الشهادة (المبسوط ١٧٨/١٦) والبيهقي (السنن الكبرى١٠ /٢٥١)

(٣) انظر: المهذب ٢ /٣٤١.

وذلك لما روي ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام علي رضي الله عنه: في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه) (٢)

وإن قال الشهود: أخطأنا، أو جهلنا كانت عليهم الدية في أموالهم مخففة مؤجلة، ولا تتحمل العاقلة عنهما شيئا؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف.(٣).

وذلك لما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور(إن كان قائمًا (٤)، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.) (٥)

وعن الإمام الباقر (عليه السلام) أو الإمام الصادق (عليه السلام) – في الرجوع عن الشهادة وقد قضي على الرجل –:" ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا"(٦) **والله أعلم.**

(١) انظر: شرح أدب القاضي للحصاف تأليف ابن مازة ٤ / ٥٠٨ الفقرة: ١٥٥٩، وبدائع الصنائع ٤٠٦٦/٩، الفتاوى الهندية ٣ /٥٥٥، شرح منح الجليل٤ /٢٨٩ ـ٢٩٠ المهذب ٣٤١/٢، منهاج الصالحين، مسألة ١٢٠. وجاء في

(٢) انظر: محمد بن الحسن الحرّ العاملي [العلامة الشيخ حرّ العاملي]، وسائل الشيعة- ج ٢٧، ص:٣٢٧.

(٣) انظر: المهذب ٢ /٣٤١، الحر العملي، وسائل الشيعة، ٣٢٨/٢٧

(٤) أي: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه، انظر التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٨.

(٥) انظر: وسائل الشيعة - ج ٢٧،ص:٣٢٨، التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٥ ، الفقيه ٣ : ٢٧ /٧٤.

(٦) انظر: ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - الصفحة ١٥٠٧، الكافي: ٧ /٣٨٣ / ١.

المبحث الرابع

تعريف شهادة الزور وحكمها وعقوبة شاهد الزور

تعريف شهادة الزور:

شهادة الزور: مركب إضافي يتكون من كلمتين هما: الشهادة، والزور.

أما الشهادة في اللغة، فمن معانيها: البيان، والإظهار، والحضور، ومستندها المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة.

وأما الزور فهو الكذب والباطل، وقيل: هو شهادة الباطل، يقال: رجل زور وقوم زور: أي مموه بكذب(١)

وشهادة الزور عند الفقهاء: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام أو تحريم حلال(٢)

حكم شهادة الزور:

اتفق الفقهاء على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأنها محرمة شرعا، قد نهى الله تعالى عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان فقال الله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (٣)، وقد روي عن خريم بن فاتك

(١) انظر: المفردات في غريب القرآن، ولسان العرب، ومختار الصحاح، والمصباح المنير مادة " شهد "، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥٣/٢٦.

(٢) انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (٣ /٢٦٠) ط دار المعرفة، بيروت، والعناية بهامش فتح القدير (٣ / ٢٢٦) ، ط بولاق، ومواهب الجليل ٦ / ١٢٢ ط دار الفكر بيروت، وفتح الباري (١٠ /٤١٢) ط الرياض الحديثة، والقرطبي ١٢ /٥٥ ط الكتب سنة ١٩٦٤.

(٣) سورة الحج ٣٠-٣١.

الأسدي:(أن النبي ﷺ صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: (واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به)(١)

وروى أبو بكرة – رضي الله عنه – عن النبي ﷺ أنه قال (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين –وكان متكئا– فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت.) (٢)

وروي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي ﷺ أنه قال: (لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار). (٣)

العمل بشهادة الزور:

لا يجوز العمل بشهادة الزور ولا تقبل شهادة شاهد الزور فيما بعد لحديث أبي بكرة قال: قال النبي ﷺ:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين – وجلس وكان متكئا – فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)(٤)

(١) انظر: أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٤ - ط الحلبي) وأعله ابن حجر في التلخيص (٤ /٩٠ - ط شركة الطباعة الفنية) بقوله: " إسناده مجهول ".
(٢) انظر: أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٠٥ - ط السلفية) ، ومسلم (١ / ٩١ - ط الحلبي) .
(٣) انظر: أخرجه ابن ماجه (٢ / ٩٧٤ - ط الحلبي) وقال البوصيري: " إسناده ضعيف " كذا في مصباح الزجاجة (٢ / ٣٨ - ط دار الجنان) .
(٤) انظر: أخرجه البخاري (الفتح ٥ /٢٦١ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٩١) - ط الحلبي)

ولما روي عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: "ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار." (١)

ولأن فيها رفع العدل، وتحقيق الجور.

فإذا أقر شخص أنه شهد بزور أو قامت البينة على ذلك، فقد اختلف فيه الفقهاء على **قولين**:

القول الأول: قال أبو حنيفة(٢)يشهر به في السوق، إن كان من أهل السوق أو في قومه أو محلته بعد صلاة العصر في مكان يجتمع فيه الناس، ويقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه. ولا يحبس ولا يعزر بالضرب لتحقق القصد وهو الانزجار. وكان شريح يشهره ولا يضربه(٣)

القول الثاني: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة و به قال أبو يوسف ومحمد(٤) **وهو مذهب الشيعة الإمامية**(٥) أن للإمام أن يعزر شاهد الزور

(١) انظر:وسائل الشيعة ، ٣٣٣/٢٧. الكافي ٧ : ٣٨٣ | ٢، وأمالي الصدوق /٣٨٩/٢، وعقاب الأعمال ٢٨٦/١.

(٢) انظر: الهداية ٣ / ١٣٢، فتح القدير ٦ /٨٣، وأصل ذلك ما ورد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك انظر أخبار القضاة لوكيع ٢ / ١٩، ٣ /٨٩، المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٨ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦ الأحاديث ١٥٣٨٨ ـ ١٥٣٩٠، جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢ / ٢٧٤، المبسوط ١٦/ ١٤٥، سنن البيهقي الكبرى ١٠ / ١٤١ ـ ١٤٢، الدراية ٢ / ١٧٢

(٣) انظر ذلك في أخبار القضاة ٣ / ٢١٩ ـ ٢٢٠، المبسوط ١٦ / ١٤٥ .

(٤) انظر: الهداية ٣ / ١٣٢، فتح القدير ٦ / ٨٣. المهذب ٢ /٣٣٠ المدونة الكبرى ٥ / ٢٠٣، تبصرة الحكام ٢/ ٣١٤. منتهى الإرادات: ٦٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٢ / ١٠٧، المغني ١٢ / ١٥٣، الشرح الكبير ١٢ / ١٣١.

(٥) انظر: جاء في وسائل الشيعة، ج ٢٧ ، ص: ٣٣٣، " باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب.."

بالضرب أو الحبس أو الزجر، وإن رأى أن يشهر أمره فعل ويطاف به في المجالس (١)

وذلك: لما روي عن عمر – رضي الله عنه – أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه أي: سوده (٢)

ولما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه، قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.

وعن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا رضي الله عنه كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله(٣)

ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد، وليس فيها حد مقدر فيعزر.(٤)

(١) انظر: منتهى الإرادات: ٦٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٢ / ١٠٧، المغني ١٢ / ١٥٣، الشرح الكبير ١٢ / ١٣١المغني ١٢ / ١٥٣، الشرح الكبير ١٢ /١٣١.
(٢)رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠ /١٤٢، بسنده عن مكحول عن عمر رضي الله عنه، المدونة الكبرى ٥ / ٢٠٣، تبصرة الحكام ٢ / ٣١٤.
(٣) انظر: وسائل الشيعة - ج ٢٧،ص:٣٣٤
(٤) انظر: المدونة الكبرى ٥ / ٢٠٣، تبصرة الحكام ٢ / ٣١٤.

الخاتمة

نسأل الله حسنها

الحمد لله أولًا وآخرًا، ونُصلي ونُسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .

وبعد:

فقد درسنا في هذا الكتاب أهم الأحكام المتعلقة ببابي القضاء والشهادة في الفقه الإسلامي، ذلك أن حصر جميع ما يتعلق بهذين البابين، أمر يصعب على الطالب دراسته، نظراً لطول المقام والمقال، فالوقت الدراسي لا يسمح باستقصاء جميع ما ورد من معلومات في هذين البابين كاملة غير منقوصة ، كما أن مراعاة المستوى العلمي للطالب في هذه المرحلة الدراسة، يقتضي تزويده بكم من المعلومات يتوافق مع مداركه العلمية في مثل هذه السن، وفي مثل هذا المستوى الدراسي، وقد أضربنا الذكر عن بعض المعلومات التي تقتضي الإسهاب، تاركين ذلك لمحله من كتب المطولات والمراجع الرئيسة في الفقه المقارن ،وقد سقنا ما ذكرناه في بابي القضاء والشهادة ، من حيث التعريف بالقضاء، وأنواعه كقضاء الحسبة وقضاء المظالم، والقضاء العادي، وقد ذكرنا شروط تولي القضاء مما هو موضع اتفاق، وما هو موضع خلاف بين الفقهاء،

ثم عرجنا على حكم قضاء القاضي بعلمه، وذكرنا الخلاف الفقهي في ذلك وناقشنا الأدلة مناقشة وافية كافية ، بحيث تغرسُ في نفس الطالب الملكة الفقهية في معرفة الدليل الفقهي، وتحليله، وكيفية المناقشة، والجمع بين الآراء متى أمكن، وإلا فلا مفر من الترجيح، وختمنا هذا الباب بعزل القاضي، كل هذا؛ كي تتسع مدارك الطالب الفقهية، ثم عرجنا على باب الشهادات، فعرفنا الشهادة، ومشروعيتها والحكمة من تشريعها، وأركان الشهادة، والشروط التي ذكرها الفقهاء لكل قسم ، ثم تعرضنا لشهادة الزور وحكمها، وختمنا بالرجوع عن الشهادة والأحكام الفقهية المتعلقة به، وكنا نود أن يتسع المقام لدراسة غير ذلك من الأحكام الفقهية المتعلقة ببابي القضاء والشهادة، ،لكنا اقتصرنا على مفردات الخطة الدراسية ، كما أن العذر الذي سقناه يشفع لما تركناه ، "وما لا يُدرك كله ، لا يُترك كله" ، وفيما ذكرناه الكفاية ، والله نسأل أن ينفع به العامة والخاصة ، وحسبنا شرف القصد ونبل الغاية ، والله حسبنا ونعم الوكيل ، وآخر دعوانا (أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

المؤلفان:

أ.د/ عطا عبد العاطي السنباطي

أ.د/ مراد محمود حيدر

فهرست أهم مراجع الكتاب

📖**ابن أبي العز**، صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى ٧٩٢ هـ)، **التنبيه على مشكلات الهداية**، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر) - أنور صالح أبو زيد أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

📖**ابن أبي المكارم** ،أبو زهرة ابن أبي المكارم **الغنية مع الجوامع الفقيه**، طهران، إيران .

📖**ابن إدريس**، محمد بن منصور بن أحمد الحلي، **السرائر**، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٧ .

📖**ابن الأثير**، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ) **النهاية في غريب الحديث والأثر**، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

📖**ابن البراج**، عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي، **المهذب**، تحقيق: إعداد : مؤسسة سيد الشهداء العلمية / إشراف : جعفر السبحاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، هـ. الطبعة: الاولى، ، سنة الطبع: ١٤٠٦

📖**ابن الرفعة**، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ٧١٠هـ)، **كفاية النبيه في شرح التنبيه**،،المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م ٢٠٠٩

📖**ابن العربي**، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ) **أحكام القرآن**، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا.

📖**ابن العربي**، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣ هـ)، **عارضة الأحوذي**، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.

📖**ابن المقرئ، روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء)**، إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله الشرجي ابن المقري شرف الدين أبو محمد، المحقق: خلف مفضي المطلق، الناشر: دار الضياء – الكويت.

📖**ابن المنذر**، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)، **الإشراف على مذاهب العلماء** ، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م

📖**ابن الهمام**، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ) **فتح القدير**، الناشر: دار الفكر، بيروت.

📖**ابن تيمية**، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ) **مجموع الفتاوى**، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

📖**ابن جزي**، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ)،**القوانين الفقهية**، نشر: وزارة الأوقاف والشئون الكويتية .

📖**ابن حبان**، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، **صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٣م.

📖**ابن حجر**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، **التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير**، ،تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة – مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م، وانظر في مصادر الجعفرية الحديثية : الحديث النبوية، ٨/ ١، الحديث رقم :٧٧.

📖**ابن حجر**، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، **تحفة المحتاج في شرح المنهاج**، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون

طبعة، عام النشر: ١٣٥٧ هـ - ١٩٨٣ م، (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي - بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ)

📖**ابن حجر**، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، **لسان الميزان**، المحقق: دائرة المعرف النظامية – الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧١م.

📖**ابن حزم** ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : ٤٥٦هـ) **مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات**، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

📖 **ابن حزم** ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦هـ)، **المحلى بالآثار**، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

📖**ابن حنبل**، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**،المحقق: شعيب

الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

📖**ابن رجب**، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

📖**ابن رشد**، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م.

📖**ابن زهرة**، السيّد حمزة بن علي الحلبي، **غنية النزوع**، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ١٤١٧ هـ.

📖**ابن سيدة**، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ]، **المحكم والمحيط الأعظم**، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م .

📖**ابن ضويان**، إبراهيم بن محمد بن سالم (المتوفى: ١٣٥٣هـ)، **منار السبيل في شرح الدليل**.

📖**ابن عابدين**، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) **رد المحتار على الدر المختار**، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

📖**ابن عبد البر**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) **التمهيد لما في الموطأ من المعاني** والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ هـ .

📖**ابن عبد البر**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) **الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في**

قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، تحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي، الناشر: أضواء السلف -السعودية.، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

📖**ابن عبد البر**، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، **الاستذكار**، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م.

📖**ابن فارس**، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، **معجم مقاييس اللغة**، المحقق: عبد السلام هارون، سنة النشر: ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.

📖**ابن فهد** ،جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي؛ **المهذب البارع في شرح المختصر النافع** ، الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ الطبعة: الاولى ١٤٠٧هـ .

📖**ابن قدامة**، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)، **المغني**، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.

📖**ابن قدامة**، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)، **الكافي في فقه الإمام أحمد**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

📖**ابن قدامة**، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) **روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل**، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

📖**ابن كثير**؛ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين ، **إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه** المحقق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب، الناشر: مؤسسة الرسالة.

📖**ابن مازة**، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ)**المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه**، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي،

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

📖**ابن مفلح**، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: ٨٨٤هـ) **المبدع في شرح المقنع**، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

📖**ابن مفلح**، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) **كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي**، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

📖**ابن منظور**، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)،**لسان العرب** الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة – ١٤١٤هـ.

📖**ابن مودود**، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)، **الاختيار لتعليل المختار**، عليها

تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م.

📖**ابن نجيم**، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) **البحر الرائق شرح كنز الدقائق** وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

📖**ابن نجيم**، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ)، **الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ**، . وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م .

📖**أبو البصل، د. على أبو البصل، تعريف الفقه المقارن**، منشور على شبكة الألوكة، www.alukah.net

📖**أبو الحسين البَصْري**، محمد بن علي الطيب المعتزلي (المتوفى: ٤٣٦هـ)، **المعتمد في أصول الفقه**، المحقق: خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

📖 **أبو الصلاح الحلبي** ،تقي بن نجم ، **الكافي في الفقه** ، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (ع) العامة، مكان النشر،اصفهان – إيران، سنة النشر،١٤٠٣ ق، مطبعة١.

📖**أبو جيب**، سعدي أبو جيب، **موسوعة الإجماع** في الفقه الاسلامي، نشر:دار الفكر، دمشق، برامكة، الطبعة الرابعة، ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.

📖**أبو داود**؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود، **سنن أبي داود**، المحقق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية، الناشر: دار الرسالة العالمية، سنة النشر: ١٤٣٠هـ – ٢٠٠٩م

📖**أبو سمرة**، د. رمضان ثابت محمد أبو سمره، **مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة دراسةنظرية تطبيقية**، منشور في مجلة الدراسات العربية، جامعة المنيا ، مصر.

📖**الآبي**، صالح عبد السميع الأبي الأزهري، **جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل**، الناشر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان.

📖**اختلاف الفقهاء** في الفتوى، بحث منشور على موقع سيد الشهداء عليه السلام للبحوث الإسلامية:-www.sayyid-shouhadaa center.com

📖**الأردبيلي**، أحمد بن محمد الشهير بالمقدس الاردبيلي المتوفى سنة ٩٩٣ه **زبدة البيان في احكام القرآن** حققه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره المكتبة المرتضوية المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية تهران – ناصر خسرو پاساژ مجيدي .

📖**الإسنوي**، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٧٧٢هـ)،**نهاية السول شرح منهاج الوصول**، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م .

الأصفهاني، المحقق محمد حسين الأصفهاني **تعليقه على المكاسب**، طبعة حجرية (١٣٦٤هـ).

آل بحر العلوم ، السيد محمد آل بحر العلوم ، **بلغة الفقيه** ط٣، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، (١٣٩٦هـ – ١٩٧٦م).

الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ) **الإحكام في أصول الأحكام**، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، وروضة الناظر لابن قدامة ص١٦ ط السفلية.

الآمدي، محمد الحسن الآمدي، **المسح في وضوء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)** دراسات مقارنة بين المذاهب الاسلامية، المطبعة: أمين الطبعة: الأولى / ١٤٢٠هـ العدد: ١٢٠٠ التنضيد الضوئي...دار المصطفى (صلى الله عليه وآله) لإحياء التراث .

الآملي، الميرزا هاشم، **المعالم المأثورة فى شرح كتاب العروة الوثقى**، نشر: مؤسسة آل البيت ، قم ، إيران.

📖**الأنصاري**، الشيخ الاعظم مرتضى الأنصاري، **كتاب الخمس**، نشر: مؤسسة آل البيت . قم، إيران.

📖**الأنصاري**، الشيخ مرتضى **المكاسب**، (ت: ١٢٨١هـ) ،تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر،ط١،منشورات جامعة النجف الدينية ،مطبعة الآداب، النجف،(١٣٩٦هـ).

📖**الأنصاري**، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)ـ **أسنى المطالب في شرح روض الطالب**، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بيروت، لبنان.

📖**الباجي**، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ) **المنتقى شرح الموطأ**، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢.

البُجَيْرَمِيّ، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ)، **تحفة الحبيب على شرح الخطيب"** حاشية البجيرمي على الخطيب" ١/ ١٧٥ الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .

📖**البحراني**، يوسف البحراني **الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة**، الشيخ ، **البحراني**، يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني، **الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة**، نشر: دار الأضواء، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م ، وطبعة: علي الآخوندي، دار الكتب الإسلاميّة، قم، إيران.

📖**البخاري**، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري**، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ .

📖**البركتي**، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي **التعريفات الفقهية** ، ، الناشر: دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م .

📖**البركتي**، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي الناشر: الصدف ببلشرز - كراتشي **قواعد الفقه** لطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م .

📖**البروجردي**، السيد حسين البروجردي، **جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة**، سنة الطبع: ١٤٠٩ - ١٣٦٧ ش، المطبعة: مطبعة المهر - قم، إيران، سنة الطبع: ١٤٠٩ - ١٣٦٧ .

📖**البزار**، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ) .

📖**البستي**، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، **معالم السنن** ،وهو شرح سنن أبي داود ، الناشر: المطبعة العلمية – حلب، الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢م.

📖**البغوي**، أبو الحسين محمد بن مسعود الفراء البغوي، **جواهر البحار** طبعة عيسى البابي الحلبي، مصر .

📖**البلاغي**، الشيخ محمد جواد البلاغي **العقود المفصّلة**، ،المطبعة المرتضويّة، النجف،(١٢٤٣هـ).

📖**البهوتى**، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي (المتوفى: ١٠٥١هـ) **كشاف القناع عن متن الإقناع**، الناشر: دار الكتب العلمية .

📖**البهوتي**، منصور بن يونس البهوتي **الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع**، المحقق: أ. د خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع – الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ الروض المربع .

📖**البهوتي**، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى **عمدة الطالب لنيل المآرب** «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»، قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ عدنان بن سالم النهام، حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر، الناشر: مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت، على نفقة: مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي، الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م .

📖**البهوتي**، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى **دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات**، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .

البوطي، د. محمد سعيد رمضان البوطي: محاضرات في الفقه المقارن، نشر:دار القلم ، سورية، الطبعة الأولى ، ١٩٨٤.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: ٦٨٥هـ)، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٤١٨هـ.

البيهقي، أبو بكر البيهقي (٣٨٤ هـ - ٤٥٨ هـ) **الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، تحقيق ودراسة**: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي **شعب الإيمان**، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند، الناشر:

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م .

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، **السنن الكبرى** (سنن البيهقي الكبرى) (ط. العلمية)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤٢٤ – ٢٠٠٣م .

تبريزى، جواد، يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، متوفاى ١٣٣٧ ه. ق.، **تنقيح مباني العروة**، كتاب الصلاة، ناشر: دار الصديقة الشهيدة(سلام الله عليها) مكان چاپ: قم- ايران .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف " حاشية البجيرمي على الخطيب"، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، **سنن الترمذي**، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، سنة النشر: ١٩٩٨م .

📖**التفتازاني**، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٧٩٣هـ) **شرح التلويح على التوضيح**، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

📖**التفتازاني**، أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، **دراسات في الفلسفة الاسلامية** ، القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٥٧ .

📖**التنوحي**، : أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (المتوفى: بعد ٥٣٦هـ)، **التنبيه على مبادئ التوجيه** ، المحقق: الدكتور محمد بلحسان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م .

📖**توني**، عبد الواسع بن محمّد علّامي توني كاساني، **وسيلة النجاة في شرح دعاء السمات** ، محقق : قاسم شيرجعفرى، توزيع دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، بيروت لبنان، الطبعة: الثانية ،تاريخ النشر ١٩٨١م .

📖**الجذامي**، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: ٦١٦هـ)، **عقد الجواهر الثمينة في مذهب**

عالم المدينة، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

📖**الجصاص**، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ)، **شرح مختصر الطحاوي**، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداشن الناشر: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

📖**جماعة من فقهاء** الشيعة الإمامية ، **الجوامع الفقهيّة** ، طهران، إيران.

📖**الجمل**، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل"منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي تم شرحه في شرح منهج الطلاب" الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (المتوفى: ١٢٠٤هـ).

📖 **الجواهري**، حسن الجواهري، درس الفقه ، على موقع https://www.eshia.ir

📖**الجواهري**، محمد الجواهري، **الواضح في شرح العروة الوثقى** ، نشر: العارف للمطبوعات، تاريخ الطبع: ١٤٣٦هـ، الطبعة: الاولى .

📖**الجوهري**، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)**الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية**، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م .

📖**الجويني**، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) ،**المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه**، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م .

📖**الجويني**، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ) **البرهان في أصول الفقه**، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م .

📖**الحاكم** ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ)، **المستدرك على الصحيحين**، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ -١٩٩٠م .

📖**الحائري**، السيد كاظم الحسيني، **الفتاوى المنتخبة** ـ مؤسسة البلاغ المبين، بلا معلومات أخرى.

📖**الحراني**، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: ٦٥٢هـ)، **المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل**، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ -١٩٨٤م .

📖**حسن**، أ. د. محمود محمد حسن، **بيع الأعيان المحرمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي**، بحث علمي نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، عدد ٣٠، عام ١٤١٧هـ، د.

📖**الحسيني** ،السيد عبد الفتاح بن علي المراغي الحسيني، **العناوين**، طبعة حجرية،(١٢٩٧هـ).

📖**الحصني**، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: ٨٢٩هـ)، **كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار**، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.

📖**الحطاب**، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)، **مواهب الجليل في شرح مختصر** 📖**خليل**، الناشر: دار الفكر- الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

📖**الحكيم** محسن محمد الطباطبائي الحكيم **مستمسك العروة الوثقى**، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، الطبعة: ٤، تاريخ النشر : ١٣٩١ هـ

📖**الحكيم**، السيد محمد سعيد الحكيم **منهاج الصالحين، فقه الشيعة** (فتاوى المراجع)، الطبعة: الأولى، دار الهلال، ، سنة الطبع: ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م .

الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة ٧٢٦ هـ **تذكرة الفقهاء، تحقيق** مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. قم التصوير الفني (الزينگغراف): ليتوكرافي حميد - قم الطبعة: الأولى - محرم ١٤١٤هـ ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه.

الحلّي، **مختلف الشيعة في أحكام الشريعة**، ، طبعة حجرية، دار الخلافة، طهران.

الحلي، أبو القاسم نجم الدين، جعفر بن الحسن المشهور بالمحقّق الحلي ،**شرائع الإسلام**، طبعة أولى، النجف، بتحقيق عبد الحسين محمد علي. (١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م)

الحلي، احمد بن فهد الحلي، **المهذب البارع في شرح المختصر النافع** ، تحقيق جعفر السبحاني.

الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر: **نهاية الإحكام** ،تحقيق: السيد مهدي الرجائي، **الطبعة: الثانية، سنة الطبع: ١٤١٠**

الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، . **منتهى المطلب في تحقيق المذهب**، التحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية.، الناشر: مجمع

البحوث الإسلامية، إيران مشهد ص. ب ٣٣٦/ ٩١٧٣٥.، الطبعة: الأولى ١٤١٣ ق.، الطبع: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة. حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر.

📖**الحلي**، المحقق أبو طالب، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، **إيضاح الفوائد في شرح القواعد**، ط١، المطبعة العلمية قم، إيران، (١٣٨٧هـ).

📖**الحلي**، جعفر بن الحسن الحلي، **المعتبر في شرح المختصر**، ناشر: مؤسسة سيد الشهداء(ع)، ١٤٠٧ه. تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل، إشراف : ناصر مكارم شيرازي.

📖**الحلي**، جعفر بن الحسن، **باب المسائل المصرية**، شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام للتراث والفكر الإسلامي.

📖**الحلي**، جعفر بن الحسن، **المسائل العزية** ، هذا الكتاب، نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف، شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام للتراث والفكر الإسلامي.

📖**الحلي**، جعفر بن الحسن، **الرسائل التسع** ، تحقيق: رضا الأستادي، الناشر مكتب اية الله المرعشي_قم، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٣ - ١٣٧١ ش.

📖**الحلي**، حسن بن يوسف بن المطهرّ الحلّي المعروف بالعلاّمة الحلي ، **تحرير الأحكام**، طبعة حجرية، (١٣١٦هـ).

📖**الحلي**، حسن بن يوسف بن المطهرّ الحلّي المعروف بالعلاّمة الحلي، **تذكرة الفقهاء**، نشره السيد محمد الموسوي كلانتر، مطبعة النجف،(١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م).

📖**الحلّي**، محمد بن إدريس الحلّي، **السرائر**، طبعة حجرية، ١٢٧٠هـ.

📖**حماد**، د. نزيه حماد، **المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء** بين النظرية والتطبيق، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دار البشير.

📖**الحميري**، نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: ٥٧٣هـ)، **شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم**، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر

المعاصر (بيروت – لبنان)، دار الفكر (دمشق – سورية)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م.

📖**الحنفي**، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ)، **مراقي الفلاح** شرح متن نور الإيضاح، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٥م .

📖**حيدر**، ا.د. مراد محمود حيدر، **مقالات الحيدري في الدين والاجتماع** ، ص:٢٠١، نشر: مكتبة الوراق ، الأردن ، ٢٠١٩م .

📖**حيدر، ا.د. مراد محمود** حيدر، **بحوث في الفقه المقارن**، نشر: مكتبة النهضة ، ط: أولى، ٢٠١٠.

📖**حيدر**، ا.د. مراد محمود حيدر، **شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، طبع دار الفقه ـ** جاكرتا ، إندونيسيبا، عام ٢٠١٣م .

📖**حيدر**، ا.د. مراد محمود حيدر، **محاضرات في مقاصد الشريعة**، مطبعة النهضة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠١٤م .

📖حيدر، ا.د. مراد محمود حيدر، **نهاية المعتمد شرح طريقة بداية المجتهد لابن رشد** ، نشر:دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، ط/ : أولى ، عام ٢٠١٤م .

📖**حيدر**، علي قلمداران القمي، بحث عميق في مسألة الخُمس: في الكتاب والسنة وفتوى علماء الشيعة، مكتبة العبيكان ، جدة ، السعودية.

📖**خازم**، الشيخ علي خازم، **مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة** ، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .

📖**الخازن**، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: ٧٤١هـ) **لباب التأويل في معاني التنزيل**، تصحيح: محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ .

📖**الخراساني**، حسين الوحيد الخراساني، **مقدمة في أصول الدين** ويليها منهاج الصالحين، شبكة دار الفكر.

📖**الخرشي**، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: ١١٠١هـ) **شرح** 📖**مختصر خليل** الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

📖**خلاف**، الشيخ الدكتور عبد الوهاب خلاف (المتوفى: ١٣٧٥هـ)،**علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع**،، الناشر: مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر»،

📖**الخلخالي** السيد محمد مهدي الخلخالي، **فقه الشيعة**، نشر: مؤسسة الآفاق، بلا معلومات أخرى.

📖**الخلخالي**، محمد مهدي الموسوي الخلخالي، **دروس في فقه الشيعة** القاها سماحة آية الله العظمى، أبو القاسم الموسوي الخوئي، نشر: معهد الخوئي، قم ، إيران.

📖**الخميني**، السيد مصطفى ، **تحرير العروة الوثقى**، تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش .

📖**الخميني**، روح الله الموسوي الخميني ،**تحرير الوسيلة** ،الناشر توزيع دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، بيروت لبنان، الطبعة: الثانية ،تاريخ النشر ١٩٨١م .

📖**الخن**، وآخرون، الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي** رحمه الله تعالى،الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق .

📖**الخن**، د. مصطفى سعيد، الخن: **أثر الاختلاف في القواعد الأصولية** في اختلاف الفقهاء الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: ١٤٠٢ – ١٩٨٢م .

📖**الخوانساري**، المحقق المدقق العلامة حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري **مشارق الشموس في شرح الدروس**، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم ، إيران .

📖**الخوئي**، أبو القاسم الخوئي، **كتاب الطهارة** ، تأليف، محمد مهدي الموسوي الخلخالي، الناشر: دار آفاق ، بلا معلومات أخرى.

الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي الخوئي ، **منهاج الصالحين**، الناشر : مؤسسة الخوئي الإسلامية. قم ، إيران.

الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، **موسوعة الإمام الخوئي** – الناشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم ، إيران.

الخوئي، السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي، **دروس في فقه الشيعة** تأليف: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي، الناشر: مؤسسة الآفاق، تاريخ الطبع: ١٤٢٢هـ ، ٢٠٠١ م، الطبعة: الثالثة .

الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ)، **سنن الدارقطني**، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م .

الدُّبْيَانِ، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

📖**الدردير**، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، **الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع** بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، عام النشر: ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢م .

📖**الدردير**، أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العَدوي المالكي الأزهري الخَلْوَتِي ، الشهير بأحمد الدردير، **الشرح الكبير، ومعه حاشية الدسوقي**، ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة الدردير، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي، وشركاه، الدراسة ،القاهرة، مصر.

📖**الدسوقي**، شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، **حاشية الدسوقي على الشرح الكبير** للعلامة الدردير، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي، وشركاه، الدراسة ،القاهرة، مصر.

📖**الدمياطي**، أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد ١٣٠٢هـ)،**إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين** (هو حاشية

على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.

📖**الدولابي،** أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: ٣١٠هـ)، **الكنى والأسماء**،: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم - بيروت/ لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م .

📖**الرازي،** أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ)، **مفاتيح الغيب = التفسير الكبير**، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠هـ .

📖**الرازي**، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ) ، **المحصول في أصول الفقه**، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م.

📖**الرازي**، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)،**المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

📖مختار **الراعي**، أبو عبد الله شمس الدين الراعي الأندلسي (تـ٨٥٣هـ) **انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك**، **نشر**: دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة ١٩٨١م، و دار ابن حزم في طبعة جديدة منقحة ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

📖**الرحيباني**، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ) **مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى**، الناشر: المكتب الإسلامي

📖**الرشتي**، ميرزا حبيب الله الرشتي **رسالة في الغصب**، طبعة حجرية، طهران، (١٣٢٢هـ).

📖**الرضا، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام و المشتهر بـ** (فقه الرضا) ،المعروف بالفقه الرضوي، نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، **قم إيران،**

📖**الركبي،** محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال (المتوفى: ٦٣٣هـ)، **النَّظْمُ الْمُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِير غريبِ أَلْفَاظِ المهَذّبِ،** دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِم، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة، عام النشر: ١٩٨٨ م

📖**الرملي،** شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،** الناشر: دار الفكر، بيروت.

📖**الروحاني** ، السيد محمد صادق الروحاني **المسائل المستحدثة** ،دار الزهراء، بيروت،ط٢،(١٣٩٣هـ).

📖**الروحاني** ، السيد محمد صادق الروحاني **فقه الصادق في شرح التبصرة،** المطبعة العلميّة، قم.

📖**الريشهري**، محمد، محمدي نيك، **ميزان الحكمة**، تحقيق: دار الحديث، الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة: الاولى ١٤٢٢هـ.قم ، إيران.

📖**الزبيدي**، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ)، **الجوهرة النيرة**، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ.

📖**الزبيدي**، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ) **تاج العروس من جواهر القاموس**، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

📖**الزحيلي**، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، **الفقه الإسلامي وأدلته**، الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

📖**الزرقا**، مصطفى أحمد الزرقا، **المدخل الفقهي العام**، نشر: دار القلم ، سنة النشر: ١٤٢٥ – ٢٠٠٤.

📖**الزرقاني**، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١٢٢هـ)، **شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني**، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢م .

📖**الزركشي**، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) البحر **المحيط في أصول الفقه**، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

📖**الزركشي**، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)، **المنثور في القواعد الفقهية**، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

📖**الزيلعي**، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ)، **نصب الراية لأحاديث الهداية** مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها

محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

📖**الزيلعي**، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) **البحر الرائق شرح كنز الدقائق**، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.

📖**الزيلعي**، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) **تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّن**، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣هـ.

📖**سابق**، الشيخ السيد سابق (المتوفى: ١٤٢٠هـ) **فقه السنة**، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧م .

📖**السايس، الشيخ محمد علي**، والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، **مقارنة المذاهب في الفقه** ، طبع مطبعة جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة المحروسة .

📖**السبحاني**، الشيخ جعفر السبحاني، **الوضوء على ضوء الكتاب والسنّة**،: الناشر، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السَّلام).

📖**السبحاني**، والطباطبائي ، محمد كاظم اليزدي، **العروة الوثقى** ، مع شرح الشيخ جعفر السبحاني، نشر: مؤسسة آل البيت ، الطبعة الأولى، ١٤٣٩_٢٠١٩م

📖**السبزواري**، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، **مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام**، مطبعة الآداب، النجف،(١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م).

📖**السبزواري**، عبد الأعلى، المعروف بالمحقق السبزواري، **الكفاية**، طبع حجري.

📖**السبزواري**، عبد الاعلى، **مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام**،٦، قم، مؤسسة المنار، ١٤١٧ هـ.

📖**السبزواري**، محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواري، **ذخيرة المعاد في شرح الارشاد**، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، طبعة حجرية، إيران .

📖**السبزواري**، محمد باقر، **ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد**، الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم ، إيران.

📖**السبكي**، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، **الإبهاج في شرح المنهاج "منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي** المتوفي سنه ٧٨٥هـ"، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣.

📖**السرخسي** ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ، **أصول السرخسي**، الناشر: دار المعرفة – بيروت.

📖**السرخسي**، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) **المبسوط**، الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

سلار ،حمزة بن عبد العزيز الديلمي، الملقّب بسلار، **المراسم في الفقه الإمامي**، مع الجوامع الفقهية، طهران.، إيران.

السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ)، **تحفة الفقهاء**، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩ هـ)، **الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة**، المحقق: د. نايف بن نافع العمري، الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م .

السهارنفوري، الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (المتوفى: ١٣٤٦ هـ) **بذل المجهود في حل سنن أبي داود**، اعتني به وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

📖**السيد محمد صادق الروحاني، فقه الصادق** (ع)، الطبعة: الثالثة، سنة الطبع: ١٤١٤هـ

السيستاني، علي، الحسيني الروحاني، **المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات** ، مكتبة الايمان بيروت – لبنان، طبعة سنة ١٤١٧ه/ ١٩٩٦م

📖**السيستاني،** السيد على السيستاني، **الاستفتاءات** ، الاستنجاء : www.sistani.org

📖**السيستاني،** السيد علي الحسيني السيستاني ، **المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات،** طبعة منقحة ومصححة، ١٤٤١ه، بلا معلومات أخرى.

📖**السيستاني،** الشيخ على الحسيني السيستاني، الكتب الفتوائية ، **الوجيز في أحكام العبادات،** نشر: مؤسسة آل البيت ، قم ، طهران.

📖**السيستاني،** علي الحسيني السيستاني، **منهاج الصالحين،** دار المؤرخ العربي.

📖**السيستاني،** علي الحسيني، **التعليقة على العروة الوثقي لليزدي،** بلا معلومات أخرى.

📖**السيوطي** ، جلا الدين ، الشافعي، **الأشباه والنظائر**، ط. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

📖**السيوطي**، جلال الدين السيوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ)، **جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»**، المحقق: مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر، الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

📖**السيوطي**، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، **الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير**، المحقق: يوسف النبهاني، الناشر: دار الفكر - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

📖**الشاطري**، محمد بن أحمد الشاطري، شرح **الياقوت النفيس في مذهب ابن ادريس**، الناشر: دار الحاوي؛ سنة النشر: ١٤١٨ – ١٩٩٧م.

📖**الشافعي** الإمام ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ) **مسند الإمام الشافعي**، رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد

السندي، عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، عام النشر: ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١م .

📖**الشافعي الإمام**، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ) **اختلاف الحديث** (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)الناشر: دار المعرفة – بيروت سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م .

📖**الشربيني**، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)، **الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع**، المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر ،الناشر: دار الفكر – بيروت.

📖**الشريف المرتضى**، علي بن الحسين الموسوي العلوي،: **أمالي المرتضى**، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: عيسى البابي الحلبي، سنة النشر: ١٣٧٣ – ١٩٥٤م.

📖**الشريف المرتضي**، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي (٣٥٥ هـ - ٤٣٦ هـ/ ٩٦٦ - ١٠٤٤ م) **الناصريات**، تحقيق: مركز البحوث والدراسات العلمية، سنة الطبع: ١٤١٧ - ١٩٩٧م .

📖**شلتوت**، الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد علي السايس ، **مقارنة المذاهب في الفقه** ، طبع مطبعة جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة المحروسة .

📖**الشهيد الأوّل** ،أبو عبد الله، محمد بن مكّي العاملي، المعروف بالشهيد الأوّل **الدروس الشرعية**، ، طبع حجري،(١٢٤٩هـ).

📖**الشهيد الأوّل** أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي، المعروف بالشهيد الأوّل، **القواعد والفوائد في الفقه والأصول العربيّة**، ،(ت: ٧٨٦هـ)،تحقيق الدكتور عبد الهادي الحكيم، منشورات منتدى النشر، مطبعة الآداب، النجف،(١٩٧٩م).

📖**الشهيد الأول**، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، **ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة** ، نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: محرم ١٤١٩ـ ١٩٩٩م.

📖**الشهيد الأوّل**، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، المعروف بالشهيد الأوّل، **اللمعة الدمشقية**، مطبوعة مع شرحها الروضة البهية، بتحقيق السيد محمد كلانتر، مطبعة الآداب (١٣٩٨هـ).

📖**الشهيد الثاني** ، زين الدين الجبعي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، **الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية**، (٩١١ – ٩٦٥هـ)،ط٢بتحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر، منشورات جامعة النجف الدينيّة، مطبعة الآداب،(١٣٩٨هـ).

📖**الشهيد الثاني**، زين الدين الجبعي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، **مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام**، ،طبعة حجرية.

📖**الشوكاني**، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، **نيل الأوطار**، ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م

📖**الشوكاني**؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، **السيل الجرار، المتدفق على حدائق الأزهار**، الناشر: دار ابن حزم ، بيروت، لبنان.

📖**الشيباني**، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: ١١٣٥هـ)، **نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب** المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر - رحمه الله - الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.

📖**الشيخان**، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) **المهذب في** 📖**فقه الإمام الشافعي**، الناشر: دار الكتب العلمية، **بيروت، لبنان**.

📖**الصاحب بن عباد**، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: ٣٨٥هـ)، **المحيط في اللغة**، المحقق: محمد حسن آل ياسين، الناشر: عالم الكتب، سنة النشر: ١٤١٤ – ١٩٩٤.

الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، **بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك**. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، عام النشر: ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢ م

الصدر، محمد باقر، **الفتاوى الواضحة**، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ١٤٠٣هـ.

الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (حدود ٣٠٦ هـ - ٣٨١ هـ) / (٩٢٣ م - ٩٩١ م) ، **علل الشرائع**، نشر: دار المرتضي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م .

الصديقي الهندي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (المتوفى: ٩٨٦هـ)، **مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار**، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م.

الصرامي، عبد اللطيف بن سعود بن عبد الله. ٢٠٠٨. **قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك جله" تأصيلا و تطبيقا**. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : العلوم الشرعية و العربية،مج. ٢٠٠٨، ع. ٦.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ) **المصنف**، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي- الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) **المُعْجَمُ الكَبِير للطبراني قِطْعَةٌ مِنَ المُجَلَّدِ الحَادِي والعِشْرِينَ (يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ مُسْنَدِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ)**، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة: الأولى: ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦ م، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ(ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة – الطبعة: الثانية، بدون تاريخ).

📖**الطحاوي**، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ) **شرح معاني الآثار**، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار – محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي – الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى – ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م

📖**الطحطاوي**، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي ١٢٣١ هـ **حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح**، المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م

📖**الطوسي** ،الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، **النهاية في مجرد الفقه والفتاوى**، ط١ ،دار الكتاب العربي، بيروت، (١٣٩٠هـ – ١٩٧٠م).

📖**الطوسي** أبو جعفر، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، **مسائل الخلاف** ،مطبعة محمد علي العملي، طبعة حجرية، طهران،(١٣٧٠هـ).

📖**الطوسي**، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، **الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد**، نشر: مؤسسة الحسنين عليهما السلام لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام و علوم الإسلامية و الشيعية، بلا معلومات أخرى.

📖**الطوسي**، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المعروف بشيخ الطائفة ، **المبسوط في فقه الامامية**، عنيت بنشره المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية المطبعة الحيدرية، طهران ، الطبعة الثانية، سنة ١٣٨٧ه.

📖**الطوسي**، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (متوفى ٤٦٠ هـ/ ١٠٦٨ م) ، **الاستبصار فيما اختلف من الأخبار** ، تحقيق: تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر دار الكتب الإسلامية، تاريخ الإصدارعام ١٣٩٠ هـ.ق.

📖**الطوسي**، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (متوفى ٤٦٠ هـ/ ١٠٦٨ م) ، **تهذيب الأحكام**، الناشر مطبعة خورشيد، تاريخ الإصدا ، الطبعة الرابعة: ١٤٠٦هـ .

📖**الطوسي**، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (٣٨٥ ــ ٤٦٠ هـ) المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي، **الخلاف في الأحكام**، الناشر مؤسسة النشر الإسلامين شركة دار المعارف الإسلامية.

📖**الطيار**، وآخرون، د. عَبد الله بن محمد الطيّار، د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، **الفِقهُ الميَسَّر**، الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى ١٤٣٢/ ٢٠١١

📖**العاملي** ، السيد محمد جواد بن محمد بن محمد الحسيني العاملي، **مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة**، المطبعة الرضوية، مصر،(١٣٢٣هـ).

📖 **العاملي** ، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، و الحاج ميرزا حسين النوري، **وسائل الشيعة ومستدركها**، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين بقم ، إيران.

📖**العاملي**، السيد محمد ، بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي. **مدارك الأحكام** ، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث – مشهد المقدسة، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: محرم ١٤١٠،

المطبعة: مهر – قم، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث – قم المشرفة.

📖**العاملي**، السيد محمد جواد العاملي ، **مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة**، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ، إيران.

📖**العاملي**، زين‌الدين بن علي العاملي، **مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام**، تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٣، المطبعة: بهمن – قم، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية – قم – إيران .

📖**العاملي**، مُحَمّدْ بن الحسن الحُر العاملي، المتوفى سنَة ١١٠٤ ه، **وسائل الشيعة**، ـ المحقق ونشر: مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ، الطبعة: الأُولى ـ جمادى الثانية ١٤٠٩ هـ

📖**العاملي**، محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى سنة ١١٠٤هـ، **تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة**، تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث، قم ـ إيران

📖**عبد الجبار**، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩ هـ)، **الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة**، المحقق: د. نايف بن نافع العمري، الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م .

📖**عبد الغفار**، محمد حسن عبد الغفار ، **أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء**، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية .

📖**عبد الوهاب**، القاضي عبد الوهاب، : **المعونة على مذهب عالم المدينة** «الإمام مالك بن أنس»ـ المحقق: حميش عبد الحقّ ،الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة .

📖**العبدري**، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ) **التاج والإكليل لمختصر خليل**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م .

📖**عبيد،** كوكب عبيد ، **فقه العبادات على المذهب المالكي**، الطبعة الأولى، دمشق: مطبعة الإنشاء،(١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م)،

📖**العثيمين**، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، **الشرح الممتع على زاد المستقنع**، دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

📖**العدوي**، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: ١١٨٩هـ) **حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني**، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

📖**العطار**، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: ١٢٥٠هـ) **حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

📖**عطية، د. عبدالحسيب** سند عطية، **أنواع النجاسات**، بحث منشور على موقع الألوكة، ١٣/٨/٢٠١٢ ميلادي - ٢٥/٩/١٤٣٣ هجري. https://www.alukah.net

📖**العقيلي**، عبد الله بن منصور العقيلي، **نوازل الزكاة** «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»، الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض -

المملكة العربية السعودية، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

📖**عليش**، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ١٢٩٩هـ) **منح الجليل**، الناشر: دار الفكر - بيروت، تاريخ النشر: ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

📖**عمر، وآخرون**، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ) بمساعدة فريق عمل، **معجم اللغة العربية المعاصرة**، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م،

📖**العمراني**، يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي اليمني، **البيان في مذهب الشافعي**،المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج، سنة النشر: ١٤٢١ - ٢٠٠٠

📖**عميرة**، أحمد البرلسي عميرة، **حاشية البرلسي مع القليوبي على شرح المحلي للمنهاج** ، أحمد سلامة القليوبي ،المعروف ب "حاشيتا قليوبي وعميرة" ، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

📖**العوايشة**، حسين بن عودة العوايشة، **الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة** المطهرة، الناشر: المكتبة الإسلامية (عمان - الأردن)، دار ابن حزم (بيروت - لبنان)، الطبعة: الأولى، من ١٤٢٣ - ١٤٢٩هـ .

📖**العيني**، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) **البناية شرح الهداية**، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

📖**الغزالي** ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ) **المستصفى**، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .

📖**الغماري**، أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَارِي الحسني الأزهري (المتوفى: ١٣٨٠ هـ) **الهداية في تخريج أحاديث البداية** (بداية المجتهد لابن رشد)،٢/ ٢٠٦، حديث:١٨٩.، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.

📖**الغيتابى** ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) **البناية على الهداية** ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م .

📖**الفارابي**، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، (المتوفى: ٣٥٠هـ)، **معجم ديوان الأدب**،تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

📖الفاضل الآبي، **كشف الرموز**، تحقيق: الشيخ **علي پناه الإشتهاردي**، الحاج آغا حسين اليزدي، سنة الطبع: ذي الحجة ١٤٠٨تم استيراده بواسطة مؤسسة بلاغ المبين.

📖**فتح القدير**، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

📖**الفتوحي**، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين ابن النجار **معونة أولي النهى شرح المنتهى** ، المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الناشر: مكتبة الأسدي.

📖**الفراء**، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : ٤٥٨هـ)، **العدة في أصول الفقه**، الطبعة : الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

📖**فضل الله**، محمد حسين فضل الله ، زكاة النقدين، مسألة رقم (١٠٥٦) على موقعه الرسمي: .http://arabic.bayynat

📖**الفيروز أبادي**، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ)، **القاموس المحيط**،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م .

📖**الفيومي**، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ)، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**.، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.

📖**القاضي المغربي**، أبو حنيفة، النعمان بن محمّد بن منصور،التميمي، المغربي، **دعائم الإسلام، وذكر الحلال والحرام ،و القضايا والأحكام عن أهل بين رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام** ، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، نشر:دار الأضواء، للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ه/ ١٩٩١م.

📖**القحطاني**، وآخرون، أسامة بن سعيد القحطاني، د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، د. ظافر بن حسن العمري، د. فيصل بن محمد الوعلان، د. فهد بن صالح بن محمد اللحيدان، د. صالح بن عبيد الحربي، د. صالح بن ناعم العمري، د. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي، د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني، د. عبد الله بن سعد بن عبد العزيز المحارب، د. عادل بن محمد العبيسي، **موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي**،

الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م .

📖**القدوري** أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨ هـ)، **التجريد**، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.

📖**القرافي**، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)،**الذخيرة**، المحققون: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م .

📖**القرافي**، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ) **شرح تنقيح الفصول**، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣م .

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ) **نفائس الأصول في شرح المحصول**، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م .

القروي، محمد العربي القروي، **الخلاصة الفقهية** على مذهب السادة المالكية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت .

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: ٩٢٣هـ) **إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري**، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، ١٣٢٣ هـ .

القفال، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال **حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء**، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة - المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الطبعة: الأولى، ١٩٨٨م.

📖**قليوبي**، أحمد سلامة القليوبي، حاشية قليوبي ، على شرح المحلي للمنهاج، المعروف ب **"حاشيتا قليوبي وعميرة"** الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م

📖**القمي**، محمد بن علي بن الحسين، ابن بابوية، **فقه من لا يحضره الفقيه**، دار الكتب الإسلامية، بلا معلومات أخرى.

📖**الكاساني**، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)، **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

📖**كاشف الغطاء** ، الشيخ أحمد، **سفينة النجاة**،، وعليها حواشي وتعليقات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، المطبعة العلمية، النجف الأشرف،(١٣٦٦هـ).

📖**كاشف الغطاء** ، الشيخ جعفر بن خضر **الحقّ المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الإخباريين** مع القواعد الستّة عشرة، إمام المجتهدين، طبعة حجرية.

📖**كاشف الغطاء**، الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء، **النور الساطع في الفقه النافع** ، مطبعة الآداب، النجف (١٣٨١هـ – ١٩٦١م).

📖**كاشف الغطاء**، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء **تحرير المجلّة المكتبة الرضويّة**، مطبعة الحيدري، النجف الأشرف (١٣٦٩هـ).

📖**كاشف الغطاء**، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ أحمد كاشف الغطاء، **النظر الثاقب ونيل المطالب**، تعليقتان على المكاسب، طهران.

📖**الكرباسي**، صالح الكرباسي ، ما هي عقوبات تارك الصلاة؟ مركز الإشعاع الإسلامي: https://www.islam٤u.com

📖**الكركي**، علي بن حسين، **جامع المقاصد**، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ١٤٠٨ هـ .

📖**الكركي**، محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري العاملي **القواعد**، الشهيد الأوّل، عليها حواشي الكركي (ت: ١٣٠٨هـ)،طبعة حجرية.

📖**الكشناوي**، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفى: ١٣٩٧ هـ)،**أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»**، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية.

📖**الكفعمي**، الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العاملي الكفعمي، **مصباح الكفعمي**، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع.

📖**الكفوي**، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: ١٠٩٤هـ).

📖**الكليات**، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق: عدنان درويش – محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي **التهانوي** (المتوفى: بعد ١١٥٨هـ)، **موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم**،تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة: الأولى – ١٩٩٦م.

📖**الكليني** محمد بن يعقوب ، **الكافي** تحقيق: تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري، الطبعة: الرابعة .

📖**الكليني**، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ،**أصول الكافي**، منشورات الفجر، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨ه/ ٢٠٠٧م ، قوله " ولا تكونوا أعرابا" أي لا تكونوا كالأعراب جاهلين بالدين، غافلين عن أحكامه، معرضين عن تعلمها.

📖**الكليني**، محمد بن يعقوب الكليني، **فروع الكافي**، نشر: دار التعارف للمطبوعات – بيروت لبنان، الطبعة الأولى ، عام ١٩٩٢م

📖**الكوسج**، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: ٢٥١هـ)، **مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه**،،الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م .

📖**الگلپايگاني** ، السيد محمد رضا، **كتاب الطهارة**، الناشر: دار القرآن الكريم، مكان الطبعة: قم، سنة النشر: ١٤٠٧ ق

📖**لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية**، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ .

📖**المازري**، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: ٥٣٦هـ) **شرح التلقين**، المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، ١/ ٩٩٢،الطبعة: الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ م .

📖**المازندراني**، موسى الحسيني المازندراني، **العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير**، ط٢،مكتبة الصدوق،طهران،١٣٨٢هـ .

📖 **مالك** الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)، **موطأ الإمام مالك**،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، عام النشر: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م .

📖**مالك الإمام**، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ) **المدونة**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

📖**الماوردي**، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) **الإقناع في الفقه الشافعي**، الناشر: دار إحسان للنشر والتوزيع – إيران.

📖**الماوردي**، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) **الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر** 📖**المزني**،المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م .

📖**مجلة مجمع البحوث الإسلامية**، المجلد الأول [رجب شعبان رمضان] ١٣٩٥هـ.

📖**المجلسي** محمد باقر بن محمد تقي ، **بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار** ، تحقيق: محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، السيد إبراهيم الميانجي ، محمد الباقر البهبودي،، الناشر: دار الكتب الإسلامية الطبعة: الثانية المصححة، سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م.

📖**مجمع اللغة العربية بالقاهرة**، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، **المعجم الوسيط** نشر:دار الدعوة ، الإسكندرية مصر .

📖**المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي**، (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي) الناشر: دار الفكر.المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م .

📖**مختصر الكفاية**؛ للعبدري الشافعي، المتوفى سنة ٤٩٣هـ.**د. علي محمد بو سلمان** الجبيلي، الناشر: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع.

📖**مخلوف**، الشيخ محمد حسنين محلوف مفتي الديار المصرية، ، **التبيان في حكم زكاة الأثمان** ، طبع: جامعة الأزهر الشريف، ومجلة الأزهر.

📖**المدرسي**، الشيخ محمد تقي الحكيم المدرسي، **الأصول العامة للفقه المقارن**، مدخل إلى دارسة الفقه المقارن مؤسسة آل البيت (ع -) للطباعة والنشر الطبعة، الثانية آب (اغسطس ١٩٧٩) .

📖**المدني**، صدر الدين السيد علي خان المدني الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (منشورات المكتبة الحيدرية) إيران.

📖**المراكشي**، محمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك، **الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين** ، تحقيق الدكتور موسى إسماعيل، **دار الكفاية، الجزائر**.

📖**المرداوي**، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي (المتوفى: ٨٨٥ هـ) **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)**، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

📖**المرعشي**، شهاب الدين الحسيني المرعشي، **منهاج المؤمنين**، تنظيم: عادل العلوي. نشر: مكتبة آية الله العظمى، المرعشي، قم ، إيران، طبع مطبعة الخيام.

📖**المرغيناني**، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) **الهداية في شرح بداية المبتدي**، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان .

📖**المروزي**، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: ٢٥١هـ)، **مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه**، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م .

📖**المستظهري**، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: ٥٠٧هـ)، **حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء**،المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان، الطبعة: الأولى، ١٩٨٠م .

📖 **مسلم**، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، **المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، المعروف بصحيح مسلم**، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، **لبنان**.

📖**مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار**، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩)،وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١٠

إلى ١٧)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٨)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م).

📖**المشكيني**، علي المشكيني، اصطلاحات **الأصول ومعظم أبحاثها**، قم، نشر الهادي، د.ت.

📖**المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.

📖**مُصطفى الخِنْ**، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، **الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى**، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢م.

📖**المعلم**، محمّد علي صالح المعلم، **الخمس في فقه أهل البيت عليهم السلام**، مؤسسة الإمام الرضا عليه السلام للبحث و التحقيق العلمي، الطبعة: الأُولى، ١٤٣٧هـ = ٢٠١٦ م.

📖**المفيد**، الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب بـــ الشيخ المفيد، **المقنعة**، نشر: مؤسسة النشر الاسلامي جماعة المدرسين، قم، إيران.

📖**المناوي**، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)،**التوقيف على مهمات التعاريف**،الناشر: عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

📖**المنتظري**، الشيخ حسين علي المنتظري، **الأحكام الشرعية على مذهب آل البيت**، مؤسسة البلاغ المبين، بلا معلومات أخرى.

📖**المنوفي**، أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي (٨٥٧-٩٣٩هـ/ ١٤٥٣-١٥٣٢م)، **كفاية الطالب الرباني على رسالة** ابن أبي زيد القيرواني وبالهامش حاشية العدوي، رقم الطبعة : الأولى، ، بلد النشر، مصر، المحقق: أحمد حمدي إمام، السيد علي الهاشمي، كتاب، دار النشر، مطبعة المدني، تاريخ النشر، المدينة، القاهرة.

📖**الموسوعة الفقهية الكويتية**، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر

📖**الموسوي**، محمد بن علي الموسوي العاملي، **مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام** ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر.

📖**ميرداماد**، محمد باقر الحسيني الأستر آبادي، **الرواشح السماوية**، مؤسسة آل البيت للنشر والتوزيع.

📖**الميرزا القمي**، أبو القاسم بن محمد حسن، **غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام**،نشر: مكتب النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

📖**الميرزا النوري**، حسين بن محمد تقي بن علي محمد النوري الطبرسي، **مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل** ،نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم ، إيران، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ .

📖**النائيني** ميرزا محمد حسين الغروي النائيني، **المكاسب والبيع** ، ، إيران (١٣٧٢هـ).

📖**النبهاني**، يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت ١٣٥٠ هـ) **جواهر البحار**، في فضائل النبي المختار .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر سنة: ١٣٧٩هـ ١٩٦٠م .

📖**النجفي**، الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي، **مجمع البحرين** ، المحقق : السيد أحمد الحسيني، الناشر : مكتبة مرتضوي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، ١٤١٦هـ .

📖**النجفي**، محمد حسن النجفي، **جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام**، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين، قم ، إيران.

📖**النراقي** ، أحمد بن محمد بن أبي ذرّ النراقي ،**عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام** ،طبعة حجرية،(١٢٤٤هـ).

📖**النراقي** محمد ، النراقي ، **مشارق الأحكام**، طبعة حجرية،(١٢٩٤هـ).

📖**النّراقي**، المولى أحمد بن محمّد مهدي النّراقي، **مستد الشيعة، نشر**: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى، ١٤٢٩ه/ ٢٠٠٨م

📖**النسائي**، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ) **المجتبى من السنن "السنن الصغرى للنسائي"** تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .

📖**النفراوي**، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ)، **الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني**. الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

📖**النوري**، الحاج ميرزا حسين النوري والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، ، **وسائل الشيعة ومستدركها**، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي، التابعة لجماعة المدرسين بقم ، إيران.

📖**النووي** ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، **روضة الطالبين وعمدة المفتين**، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

📖**النووي**، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) **المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي**، الناشر: دار الفكر

📖**النووي**، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، **المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج** (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة)، الناشر: مؤسسة قرطبة، سنة النشر: ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.

📖**الهمداني**، أغا رضا محمد هادي، **مصباح الفقيه**، الناشر، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث، الطبعة، الاولى ١٤١٧هـ، التحقيق، محمد الباقري – نور علي النوري – محمد الميرزائي، اشراف، السيد نور الدين جعفريان.

📖**الهيتمي**، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: ٩٧٤هـ)،

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

📖**الهيثمي**، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ)، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م.

📖**الوادعي**، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي (المتوفى: ١٤٢٢ هـ)، **الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين**، الناشر: دار الآثار - صنعاء، اليمن، الطبعة: الرابعة، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

📖**اليتامى**، وآخرون، د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، **منية السَّاجِدِ بِشَرْحِ [بِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي (ت: ١١٩٢ هـ)]** الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧م .

📖**اليزدي**، محمد كاظم، **العروة الوثقى فيما تعم به البلوى**، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط ١، ١٤١٩ هـ .

الفهرس العام للكتاب

العنوان.....رقم الصفحة

افتتاحية الكتاب.....١

مقدمة الكتاب ٤

خطة الدراسة. ٨

الباب الأول: القضاء وأنواعه وأحكامه.....٩

الفصل الأول: **تعريف القضاء ودليل مشروعيته، وحكمة مشروعيته، وفضله، والترغيب فيه والترهيب منه، وأنواعه وحكمه**..... ١٠

المبحث الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا.....١١

المبحث الثاني: أدلة مشروعية القضاء.....١٧

المبحث الثالث: حكمة مشروعية القضاء.....٢٢

المبحث الرابع: القضاء بين الترغيب والترهيب.....٢٤

المبحث الخامس: أنواع القضاء ٣٧

المبحث السادس: حكم القضاء من حيث الحكم التكليفي ونماذج من مواقف القضاة فى التاريخ.....٤٥

المبحث السابع: الفرق بين الحكم القضائي وغيره.....٧٥

الفصل الثاني: **قضاء الحسبة**.....٩٣

المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاح ٩٦

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الحسبة.....٩٨

المبحث الثالث: أركان الحسبة.....١٠١

المبحث الرابع: التطور التاريخي للحسبة.....١٠٤

الفصل الثالث: القضـــاء العـــام.....١٠٩

المبحث الأول: أركان القضاء ١١٢

المبحث الثاني: شروط القضاء.....١١٥

المبحث الثالث: جهة تعيين القاضي ١٥١

المبحث الرابع: ولاية القاضي واختصاصاته ١٥٣

المبحث الخامس: آداب القاضي.....١٦٠

المبحث السادس: رَزْقُ القاضي.....١٨٩

المبحث السابع: قضاء القاضي بعلمه.....٢٠٩

المبحث الثامن: القضاء بالشاهد واليمين.....٢٣٢

المبحث التاسع: آداب القاضي.....٢٤٤

الفصل الرابع: قضاء المظالم.....٢٥٦

المبحث الأول: تعريف قضاء المظالم ٢٥٧

المبحث الثاني: شروط واختصاصات قاضى المظالم.....٢٦٢

المبحث الثالث: تعيين قاضى المظالم ومجلس حكمه.....٢٦٩

الباب الثاني: في الشهادة وأركانها وأنواعها وأحكامها.....٢٧٦

الفصل الأول: **تعريف الشهادة، وأدلة مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها، وحكم تحمل الشهادة وأدائها**.....٢٧٧

المبحث الأول: تعريف الشهادة.....٢٧٨

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الشهادة.....٢٨٤

المبحث الثالث: حكمة مشروعية الشهادة.....٢٨٧

المبحث الرابع: حكم تحمل الشهادة وأدائها.....٢٩١

الفصل الثاني: **أركان الشهادة**.....٢٩٦

المبحث الأول: الصيغة.....٢٩٩

المبحث الثاني: الشاهد.....٣٠٤

المبحث الثالث: شروط المشهود له.....٣١٣

المبحث الرابع: شروط المشهود عليه.....٣٢١

المبحث الخامس شروط المشهود به.....٣٢٣

الفصل الثالث: **نصاب الشهادة، وأخذ الأجرة عليها، والرجوع عنها**.....٣٣١

المبحث الأول: نصاب الشهادة.....٣٣٢

المبحث الثاني: حكم أخذ الأجر على الشهادة.....٣٧١

المبحث الثالث: الرجوع عن الشهادة.....٣٨٣

المبحث الرابع: تعريف شهادة الزور وحكمها وعقوبة شاهد الزور.....٣٨٧

الخاتمة.....٣٩١

فهرس المصادر والمراجع.....٣٩٣